
Auto 275/11

ACCION DE TUTELA-Mecanismos de cumplimiento de tipo sancionatorio y tipo material

TRAMITE DE CUMPLIMIENTO FALLO DE TUTELA E INCIDENTE DE DESACATO-
Facultad del accionante

CUMPLIMIENTO FALLO DE TUTELA-Competencia del juez de primera instancia

CORTE CONSTITUCIONAL-Competencia excepcional para conocer trámite de cumplimiento de fallo de tutela e incidente de desacato

JUEZ-Competente hasta que esté completamente restablecido el derecho o eliminadas las causas de la amenaza

ACCION DE TUTELA DE ASOCIACION DE RECICLADORES EN MATERIA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ASEO-Inclusión acciones afirmativas y proceso de selección en licitación pública 001/11

ACCION CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA-Resuelve controversias relacionadas con pliegos de condiciones/**ACCION DE TUTELA TRANSITORIA**-Procedencia excepcional para resolver controversias relacionadas con pliegos de condiciones

PROCESO DE TUTELA-Principios aplicables al cumplimiento del fallo

PRINCIPIO DEL EFECTO UTIL-Facultad del juez constitucional para determinar la forma de ejecución del fallo de tutela y la adopción de medidas para su cumplimiento

JURISDICCION CONSTITUCIONAL-Adopción de medidas adicionales para proteger derechos en ejercicio de la supremacía funcional y jerárquica/**JURISDICCION CONSTITUCIONAL**-Determina

oportunidad de intervenci? para hacer cumplir ?denes de tutela/**JURISDICCION CONSTITUCIONAL-**
Define medidas para dar cabal cumplimiento al fallo

DERECHO AL CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS

CONVENCION AMERICANA DE DERECHOS HUMANOS Y PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS CIVILES Y POLITICOS-Impone a los Estados el deber de garantizar el cumplimiento de toda decisi?

BLOQUE DE CONSTITUCIONALIDAD Y ACCESO A LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA-
No se agota con la decisi? de fondo sino se extiende hasta el cumplimiento y protecci? efectiva de derechos

JUEZ-Herramientas para la ejecuci? de su deber

DERECHOS CONSTITUCIONALES-Limitaci? al principio de mayor?

DERECHOS HUMANOS DE SUJETOS DE ESPECIAL PROTECCION

ACCION DE TUTELA DE ASOCIACION DE RECICLADORES EN MATERIA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ASEO-Intereses de proponentes de licitaci? p?lica 001/11 deben desplazarse en favor de los derechos de las minor?s

PRINCIPIO DE LA SOLEMNIDAD-Responsabilidad precontractual en el ?bito civil y mercantil no pueden traerse al ?bito de la contrataci? estatal/**RESPONSABILIDAD PRECONTRACTUAL O DA? IN CONTRAHENDO-**Da? antijur?ico consecuencia de acci? u omisi? en la etapa de celebraci? del contrato, adjudicaci? irregular de la licitaci?, o falta de perfeccionamiento del contrato

DERECHOS AL TRABAJO Y DIGNIDAD HUMANA-Privilegio de minor?s dedicadas al reciclaje por encima de expectativas comerciales de particulares oferentes

ESTADO SOCIAL DE DERECHO Y PRINCIPIO DE IGUALDAD FRENTE A SUJETOS DE ESPECIAL PROTECCION-Recicladores son hist?icamente titulares de un papel ambiental de suma trascendencia

ACCIONES AFIRMATIVAS-Redistribuci? de oportunidades sociales a favor de ciertos colectivos que por razones hist?icas se han visto privados de ellas

ACCIONES AFIRMATIVAS-Generan presi? sobre los derechos del resto de la colectividad por tratarse de cargas sociales en busca de la igualdad material

PRINCIPIO DE IGUALDAD-Deberes y poderes del juez constitucional

PRINCIPIO DE ESTADO SOCIAL DE DERECHO-Actuaciones de servidores p?licos est? sometidas al control pol?ico y judicial

PRINCIPIO DE DIVISION DE PODERES-Materializaci?

ACCION DE TUTELA-Protecci? de derechos fundamentales por acci? u omisi? de cualquier autoridad p?lica

POLITICAS PUBLICAS DE PROCESOS PRECONTRACTUALES ADELANTADOS A TRAVES DE LICITACIONES PUBLICAS-Autoridades competentes deben adelantar gestiones para concretar mandatos del principio de Estado Social de Derecho

DISPOSICION DE RESIDUOS EN RELLENO SANITARIO DO? JUANA-Realizaci? a trav? de recicladores vinculados

PLIEGO DE CONDICIONES-Niveles de protecci? planteados por la Unidad Administrativa Especial de Servicios P?licos en licitaci? p?lica 001/11

PLIEGO DE CONDICIONES-Participaci? o cesi? del patrimonio de proponentes adjudicatarios a favor de recicladores

PLIEGO DE CONDICIONES-Cesi? de participaci? accionaria de licitaci? p?lica 001/11 como acci? afirmativa en favor de recicladores

PLIEGO DE CONDICIONES-Recolecci? y transporte de material aprovechable separado por generadores a recicladores de oficio asistido por operadores del servicio de aseo

SERVICIO PUBLICO DE ASEO-Prestaci? requiere que se realice a trav? de un operador autorizado e inscrito en los t?minos de la Ley 142/94

PLIEGO DE CONDICIONES-Ofrecimiento de empleos en actividades de corte de c?ped y poda de ?boles a recicladores

ACCION DE TUTELA DE ASOCIACION DE RECICLADORES EN MATERIA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ASEO-Declarar incumplimiento de sentencia T-724/03 y auto A268/10

ACCION DE TUTELA DE ASOCIACION DE RECICLADORES EN MATERIA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ASEO-Dejar sin efecto licitaci? p?lica 001/11 y actos administrativos dictados en el proceso

ACCION DE TUTELA DE ASOCIACION DE RECICLADORES EN MATERIA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ASEO-Medidas de acci? afirmativa representan deberes, cargas u obligaciones para recicladores en raz? a que prestan un servicio p?lico

Referencia: solicitud de cumplimiento de la Sentencia T-724 de 2003 y del Auto 268 de 2010.

Peticionarios: Nohra Padilla Herrera.

Magistrado Ponente:

JUAN CARLOS HENAO PEREZ

Colabor? Javier Francisco Arenas Ferro

Bogot? D.C., diecinueve (19) de diciembre de dos mil once (2011).

La Sala Tercera de Revisi? de la Corte Constitucional, integrada por los Magistrados **GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO, JORGE IV? PALACIO PALACIO y JUAN CARLOS HENAO P?EZ**, quien la preside, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, profiere el siguiente

AUTO

I. ANTECEDENTES

1. Actuaciones generales

1.1 El veintiocho (28) de julio de dos mil once (2011), Nohra Padilla Herrera, representante de la Asociación Cooperativa de Recicladores de Bogotá (ARB), instauró ante esta Corporación solicitud de cumplimiento de la sentencia T-724 de 2003 y del Auto 268 de 2010, respecto de la Licitación Pública 001 de 2011, por la cual se concede ☐ (☐) *bajo la figura de ?eas de Servicio Exclusivo, la prestación del servicio público domiciliario de aseo en la ciudad de Bogotá D.C. ☐ Colombia, en sus componentes de recolección, barrido, limpieza de vías y ?eas públicas, corte de césped, poda de ?boles en ?eas públicas y transporte de los residuos al sitio de disposición final y todas las actividades de orden financiero, técnico, operativo, educativo y administrativo que ello conlleva* ☐ (Cuad. 1, folio 6).

1.2 La Sala Tercera de Revisión de la Corte Constitucional, mediante el Auto 180 del once (11) de agosto de dos mil once (2011), avocó el conocimiento de la solicitud de incumplimiento iniciado por Nohra Padilla Herrera contra la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP).

1.3 Posteriormente, mediante el Auto 183 del dieciocho (18) de agosto de la misma anualidad, con fundamento en el artículo 7º del Decreto 2591 de 1991, esta Corporación ordenó la suspensión de la mencionada Licitación Pública No. 001 de 2011, así como la práctica de pruebas.

1.4 Por Auto 189 de 2011, la Sala Tercera de Revisión de la Corte Constitucional dirigió un cuestionario a los diferentes actores del proceso de licitación pública 001 de 2011, en concreto a la UAESP, a los oferentes y a las diferentes organizaciones de recicladores con el fin de asegurar su participación en el presente trámite.

2. Solicitud de verificación de cumplimiento

La Asociación Cooperativa de Recicladores de Bogotá (ARB), representada por la señora Nohra Padilla Herrera, manifestó que la Licitación Pública 001 de 2011, no cumple con las obligaciones de incluir acciones afirmativas en favor de la población de recicladores de Bogotá [\[1\]](#_ftn1), de acuerdo con lo señalado en la sentencia T-724 de 2003 y sus autos posteriores, razón por la cual esta Corporación debe ☐ (☐) *resolver de fondo [el] dictado de protección de los derechos tutelados para los recicladores* (☐) ☐ (Cuad. 2, folio 1).

Como fundamento de su petición expresa lo siguiente:

2.1 Entre las ?denes establecidas por la Corte Constitucional, se advirtió sobre la adopción de criterios que tuviesen en cuenta la antigüedad de las asociaciones de recicladores, así como criterios que ☐ (☐) *aseguren la aplicación progresiva de la inclusión real y efectiva de los recicladores* (☐) ☐ (Cuad. 2, folio 2), aspecto que a su juicio no se materializó en el citado proceso de selección.

2.2 Manifestó la necesidad de disponer de medidas dirigidas a separar del proceso de concesión de los componentes de recolección, transporte, barrido y limpieza general de la ciudad, las actividades de reciclaje, tratamiento y aprovechamiento para que sean entregadas ☐ ☐ *en exclusividad a las organizaciones de recicladores de manera progresiva y remunerada de acuerdo a la capacidad de demostrar las toneladas recogidas, con los precios puestos por los costos de la regulación* ☐ ☐ (Cuad. 2, folio 3), pues ¿o así se materializarán acciones afirmativas que mejoren la situación en la que sobreviven como sujetos en desventaja.

2.3 Para la peticionaria la Licitación permite que ☐ ☐ *organizaciones de papel* ☐ ☐ (Cuad. 2, folio 5) participen en el proceso de selección y se beneficien de las medidas que deberán estar destinadas exclusivamente para la población de recicladores del Distrito. Alega que complementó indicando que existe un déficit de información de lo que sucederá con las 25.000 personas que de manera directa se verán impactadas por la Licitación No. 001 de 2011.

2.4 En sus términos, si bien se efectuaron diálogos entre la Administración y algunos gremios de recicladores -por espacio de diez (10) meses-, varias de las modificaciones de incidencia en el Pliego de Condiciones no fueron concertadas y se adoptaron a última hora. Un ejemplo de ello, se encuentra en la Adenda No. 8, por la cual se fijó que la participación accionaria de las asociaciones de segundo nivel será ☐ ☐ *en partes iguales para las organizaciones participantes, con lo que también se excluye la condición según la cual el 90% de la participación será direccionada a los recicladores de oficio directamente, a través de bonos redimibles, por lo cual se hace necesaria la disposición de tener como criterio el número de recicladores asociados* ☐ ☐ (Subrayas del original) (AZ 2, folio 23). Igualmente, si existía una política pública para tratar de superar la situación que padecen los recicladores de la capital, estimó que ☐ ☐ *no se hizo nada para mostrarla y tampoco cumplirla* ☐ ☐ (AZ 2, folio 22).

2.5 Adicionalmente, alega que la repartición de dividendos -que se les entregarán a las organizaciones de segundo nivel que comparten áreas de Servicio Exclusivo (ASE)-, se dará de manera independiente del número de afiliados con que cuente cada una. Por lo mismo, ☐ ☐ *da lo mismo ser una organización de 30 asociados que una de 300 o una de 1800* ☐ ☐ (Cuad. 2, folio 5). Asunto que, por lo demás, desincentiva el fortalecimiento de las organizaciones de segundo nivel.

2.6 Señaló que la UAESP, tras el sorteo realizado para asignarles a las doce (12) organizaciones de segundo nivel existentes -cuya constitución cuestiona en razón a que varias de ellas ☐ ☐ *nacieron entre el 3 y el 10 de junio de 2011* ☐ (AZ 2, folio 24), les impuso la aceptación de cualquier condición ofrecida por los proponentes. Así de no acogerse a tales condiciones el porcentaje de acciones otorgado será cedido a otra organización diferente.

2.7 Expuso que no es claro qué soportes o estudios utilizó la UAESP para seleccionar las organizaciones de recicladores favorecidas, las cuales si bien se benefician, no lo hacen ☐ ☐ *por participar en el negocio en todos sus componentes* ☐ ☐ (Cuad. 1, folio 14). En otras palabras, de la ☐ ☐ *participación accionaria para la distribución de utilidades para las organizaciones de segundo grado* ☐ *[no puede determinarse] a* ☐ *a título de qué [se otorga]* ☐ (Cuad. 1, folio 14); y enfatizó que ☐ ☐ *cuando la limosna es tan grande hasta el mismo santo la pone en duda* ☐ ☐ (AZ 2, folio 24).

2.8 Indica la peticionaria que el Decreto Distrital 456 de 2010, redujo las bodegas existentes en la ciudad de Bogotá. Así, *□(□) se genera una situación de incertidumbre para los miles de recicladores y bodegueros, pues una vez cumplido el término [de tal disposición] no tendrá en donde (sic) comercializar los materiales recolectados (□). [Dado que,] al no tener red de acopio, puede cambiar de escenario para la política de reciclaje, sacando a los actores de la cadena tradicional que incluye a los recicladores de oficio y entregando la actividad a muy pocos* (Cuad. 1, folios 9 y 10).

2.9 Como fundamento jurídico de sus alegaciones, prescribe que la jurisprudencia de la Corte Constitucional, entre ellas las sentencias T-724 de 2003 y T-291 de 2009, establecieron que la población en comento cuenta con el derecho de alcanzar soluciones económicas duraderas para la situación en que sobreviven, y *□(□) volverse[,] de manera progresiva[,] empresarios de la basura a través de las acciones afirmativas que les asign[e] la exclusividad en el oficio de reciclaje y el crecimiento en esta cadena articulada al servicio de aseo* (□) (Cuad. 2, folio 7).

2.10 Argumenta que el círculo que se está efectuando para remunerar a los concesionarios por la prestación del servicio público de aseo incluye todo tipo de residuos sólidos no peligrosos, y -por lo mismo- no distingue entre aquellos que son objeto de aprovechamiento y aquellos que sólo pueden ser sometidos a disposición final. En efecto, indica que *□(□) en la página 4 del documento soporte de justificación de razones para autorización de las ases (sic), puesto (□) a la Comisión de Regulación de Agua y CRA □(□), la UAESP estima (sic) la cantidad de residuos a ser utilizados en los círculos del modelo económico (□). Las metodologías de cálculo (sic) de tarifas se componen por los residuos de producción domiciliaria, de grandes generadores, barrido, material aprovechable, y residuos de de (sic) operativos especiales. Con lo anterior[,] queda demostrado que la UAESP, sí (sic) tiene en el modelo de la licitación incluida la porción del oficio que los recicladores hacen en el servicio de aseo, y que la entrega en ventaja a los operadores que resulten seleccionados* (subrayas del original) (AZ 2, folio 22). Esto implica entonces, tal y como está planteada la licitación, que se les excluya del acceso cierto y seguro a los residuos sólidos, mientras que los oferentes se apropian del material sobre el cual los recicladores trabajan. Separando así erróneamente, ambas actividades del objeto concreto sobre el que operan.

2.11 Sostuvo que las rutas de reciclaje, que antes se llamaban de recolección selectiva, *□(□) están en cabeza de los 4 operadores del servicio (LIME, CIUDAD LIMPIA, ASEO CAPITAL y ATESA), los cuales recorren 73 rutas en el mes, en todas las zonas. Para hacerlo usan 6 vehículos y 18 tripulantes, con los cuales recorren al mes 320 toneladas de residuos con potencial de reciclaje* (□) (AZ 2, folio 23). Así, el puntaje que se otorga al respecto en la actual licitación tiene que ver con el cubrimiento de usuarios en una zona determinada, independientemente de la producción de basuras o de la mano de obra utilizable.

2.12 Afirmó que la UAESP y otras entidades públicas han hecho algo en señalar que están dando cumplimiento a las órdenes conferidas por la Corte Constitucional y que las mismas *□(□) se quedaron cortas en las decisiones, [ya que] solo exige dar una participación accionaria, calificar un porcentaje de aprovechamiento y puestos de trabajo, cualquiera que estos sean* (□) (Cuad. 1, folio 18). Por ello, las acciones afirmativas se están reduciendo a *□(□) dar participación accionaria que[,] para este caso, se enmarca en tener una participación en las utilidades o ganancias del negocio y no en participar en costos y gastos de acuerdo a la carga de trabajo a desarrollar* (□) (AZ 2, folio 22).

Por lo mismo, alego que tienen el derecho de ser tenidos en cuenta no sólo en relación con su fuerza de trabajo, que incluye los conocimientos adquiridos a lo largo de los años laborados como recicladores, sino como socios estratégicos. Esto, con el fin de que cuenten con alternativas económicas duraderas que, impulsadas por acciones afirmativas reales, permitan que superen la situación que padecen y que se sustenta en su calidad de sujetos de especial protección constitucional. Asunto que, reitero, se desprende de las sentencias de la Corte Constitucional T-724 de 2003 y T-291 de 2009 que comprenden criterios vinculantes para todas las partes, incluidos los proponentes. Participando entonces de manera efectiva, como empresarios de las basuras, en la prestación del servicio. Sin embargo, y a pesar de los elementos de habilitación y de calificación, a su parecer, *“(□) los proponentes instrumentalizaron a los recicladores, al ponerlos como comodín, pero no como socios estratégicos, y todos los puntos diferenciadores atacan a estos pero no les aporta un solo beneficio”* (AZ 2, folio 25).

2.13 Concluyo que *“(□) en la licitación 001 de 2011 [se] cumple tangencialmente con el auto 268 de 2010; pero [se] incumple estructuralmente la sentencia T-724 de 2003”* (AZ 2, folio 26), pues no se les reconoce y valora por sus conocimientos y capacidades laborales, ni se les incluye como posibles empresarios de las basuras.

3. Las intervenciones.

Los diferentes actores: institucionales, órganos de control, proponentes en la licitación pública 001 de 2011 y organizaciones de recicladores de diferente nivel, radicaron sus intervenciones en el presente trámite, las cuales se exponen de manera ordenada y detallada en el Anexo No.1 de esta providencia.

A continuación, se presenta un resumen de las diferentes posiciones frente a la solicitud de incumplimiento:

3.1 Los intervinientes concuerdan en que las actividades que realizan los recicladores en la cadena productiva de las basuras son varias, ya que ejercen su oficio en la selección, la recolección, el transporte, la pre - transformación y la comercialización de residuos. Igualmente, no existen diferencias en torno a la importancia de la labor que los recicladores realizan y, los beneficios ambientales, económicos y sociales que su actividad representa.

Aunado a ello, también destacan la importancia de las bodegas o centros de acopio para la cadena del reciclaje, que consideran compleja, dado que múltiples personas interactúan durante su desarrollo en diferentes etapas. En este sentido, varios intervinientes están de acuerdo en que la salida del transporte de tránsito animal y la reducción de las bodegas en razón a la aplicación del Decreto Distrital 456 de 2010, generan impactos negativos en el desarrollo de su actividad. Lo anterior, por las distancias que tendrán que recorrer los recicladores para llevar los materiales potencialmente aprovechables hasta los centros de acopio que se mantuvieron, lo cual se agrava con la reducción de los lugares en los cuales podrán comercializarlos residuos, repercutiendo todo ello negativamente en los resultados económicos que derivan de su actividad.

3.2 Coinciden en que la Licitación 001 de 2011, concibe las rutas de reciclaje a cargo de los recicladores de

oficio, quienes laborar? bajo la ?ida de la libertad de mercado y que deber? actuar independientemente de la organizaci? de segundo nivel a la que se encuentren afiliados, recolectando los materiales potencialmente aprovechables. Corolario de esto, todos los proponentes adujeron estar dispuestos a efectuar acompa?amientos en beneficio de la poblaci? en comento, para que fortalezcan y formalicen su trabajo. Empero los oferentes, sin excepci?, adujeron que no han realizado negociaci? alguna con las diferentes organizaciones, dado que los beneficios para los recicladores se desprenden del pliego de condiciones, sin que haya lugar a concertar asuntos con ellos.

3.3 Los oferentes no tienen claridad sobre cu? es el aporte de industria a cargo de las organizaciones de segundo nivel. Igualmente, los proponentes, se abstuvieron de se?alar el porcentaje de las utilidades que tienen proyectadas o manifestaron que ?tas son inciertas.

3.4 En cuanto al pesaje, coinciden en se?alar que es posible efectuarlo en diferentes momentos: ya sea en los centros de acopio, en el sitio de disposici? final o incluso en ciertos veh?ulos con tecnolog? apropiada para ello^[2]. De hecho, alegaron que en las rutas informales de recolecci? -operadas por los recicladores de oficio- por lo general se pesan en las bodegas apenas son recibidos y antes de ser comercializados para su reincorporaci? al ciclo econ?mico o productivo. De la misma manera, apuntaron que el peso tiene una relaci? directa con la tarifa que se cobra por la prestaci? del servicio, que no incluye la labor adelantada por la poblaci? en comento.

3.5 Los intervinientes no entienden la raz? por la cual la UAESP opt?por descartar criterios de antig?dad para evitar que organizaciones reci? constituidas se vieran beneficiadas con las medidas adoptadas en el pliego de condiciones de la licitaci? p?blica 001 de 2011^[3].

3.6 Existen m?tiples argumentos, provenientes de todos los intervinientes, en torno al cumplimiento o no de las obligaciones contempladas en la sentencia T-724 de 2003 y el auto 268 de 2010, relativas a la inclusi? de acciones afirmativas en favor de la poblaci? de recicladores del distrito.

Con todo, es posible agrupar estas intervenciones de la siguiente forma:

3.6.1 Respecto de la existencia o no de las acciones afirmativas se encuentran posiciones divergentes. As? algunos proponentes y organizaciones de recicladores alegan que en el pliego de condiciones se contemplan medidas que sin lugar a dudas -am? de obedecer a los mandatos establecidos en la jurisprudencia de esta Corporaci?- constituyen pol?icas destinadas a favorecer a una poblaci? desventajada para que supere la situaci? que padece.

En este sentido, alegaron por ejemplo que el sorteo de las organizaciones de segundo nivel para asociarse con los operadores del servicio, permiti?la participaci? de todas las asociaciones por igual y que las acciones de industria que recibir?, los convierten en empresarios, fomentando las organizaciones de econom? solidaria, pues todo aqu? que se afilie se ver?beneficiado. Igualmente, expusieron que los criterios de habilitaci? y puntuaci? contemplados en el pliego de condiciones garantizan la vinculaci? de

la poblaci? en comento.

A m? de lo anterior, las utilidades se les entregar? antes de capitalizaciones y reservas. De igual forma sostienen que los recicladores se ver? beneficiados con la posibilidad de comercializar los materiales que recojan en las rutas selectivas, que estar? bajo su cargo. Sumado a esto, expusieron que darles la posibilidad de competir en dichas rutas es, por s?misma, una acci? afirmativa.

Frente al aumento a doce (12) organizaciones de segundo nivel, apuntaron que esto se debi?a las grandes expectativas de utilidades que ha generado la licitaci?. Por ello, con el pliego de condiciones, la entidad distrital ha fortalecido e incentivado la creaci? de asociaciones de los recicladores.

3.6.2 Por el contrario, otros proponentes y asociaciones de recicladores critican las medidas adoptadas por la UAESP, dado que -al abstenerse de utilizar criterios de antig?dad-se permiti? la participaci? en el proceso de organizaciones llamadas de □papel□, algunas creadas con posterioridad a la publicaci? del pliego de condiciones, desnaturalizando as?un elemento esencial en toda acci? afirmativa: su direccionamiento a un grupo espec?ico. En este caso, los recicladores del Distrito Capital.

Adem?, sostienen que las posibles utilidades ser? divididas en partes iguales entre las organizaciones que act?n en el ASE respectiva, asunto que carece de sentido al no tener en cuenta el n?ero de afiliados de cada una de ellas. Este elemento fue fijado en la Adenda 8, cuando ya se hab? realizado el sorteo y a pocos d?s del cierre de la licitaci?. Lo anterior es un desincentivo para aquellas organizaciones con mayor n?ero de miembros, pues tendr? que repartir los beneficios entre muchas m? personas. Asimismo, criticaron que las condiciones fueran impuestas, dado que si no aceptaban lo que el proponente tuviera a bien otorgarles, autom?icamente quedar?n por fuera del proceso.

Por lo dem?, en su entender, la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha establecido que su trabajo debe ser valorado por el conocimiento intr?seco que han acumulado por el ejercicio de su oficio durante varios a?s. Sin embargo, los oferentes proponen celebrar contratos laborales en cualquier ?ea del servicio, ocultando de paso que nada garantiza la estabilidad o duraci? de los mismos, as?como el hecho de que varios requieren ciertas competencias de las cuales carecen. As?las cosas, se instrumentaliza al gremio reciclador de Bogot? se le utiliza como un comod? para obtener puntuaci?.

De paso, se han separado err?eamente dos actividades -aprovechamiento y recolecci?- que se efect?n sobre los mismos residuos, fraccionando la cadena productiva del reciclaje, desconociendo su complejidad, y obviando la complementariedad y el valor del trabajo que como recicladores realizan.

Para estos intervinientes, el convertirlos en verdaderos empresarios de las basuras no se garantiza con las rutas de reciclaje formuladas, que est? dise?das sobre el n?ero de usuarios afiliados, mas no con respecto a los residuos recogidos. En este sentido, expusieron que no se efectuar?remuneraci? alguna por la labor que realizan y continuar? en las mismas condiciones existentes antes de la licitaci? p?lica referida, ya que el □otorgamiento□ de las rutas selectivas no es m? que la formalizaci? a trav? de normas jur?icas de las rutas informales que actualmente operan. A lo que se le suma las dificultades derivadas del cierre de

bodegas, las distancias para los pocos centros de acopio en funcionamiento y la prohibici? del uso de transportes halados por animales.

A m? de lo anterior, alegaron que la obligaci? para los proponentes, determinada por la UAESP -relativa al dise? de un plan para el aprovechamiento- conllevar? la apropiaci? de los socios capitalistas de la actividad que ellos han venido desarrollando. Mientras que la entidad argumenta, seg? ellos err?eamente, que se trata de una oportunidad ?ica para que los empresarios les brinden herramientas para fomentar, fortalecer y formalizar su oficio.

Entonces, en su entender, la licitaci? no los incluye en el sistema de aseo, ni elimina las desigualdades que actualmente padecen. La libre competencia entra en tensi? con la exclusividad que se pregona de las ASEs. De hecho, aseguran que la recolecci? para la disposici? final no colisionar? con el aprovechamiento, si se les otorgare a los recicladores esta actividad bajo la misma ?ida de las ?eas de servicio exclusivo.

En cuanto a las utilidades, am? de enfatizar que no se encuentran garantizadas, pues se sabe que en este tipo de contratos ?tas se generan despu? de varios a?s, apuntaron a que no existen reglas claras de distribuci? entre las organizaciones de segundo nivel y las de base. Asunto que es mucho m? problem?ico si se suma el argumento de la existencia de presuntas asociaciones ficticias que buscan provecho propio. Por lo dem?, como quiera que los recicladores de oficio tradicionales ser? los que act?n sobre el ASE a trav? de la ruta de reciclaje, si no est? afiliados, dejar? de percibir cualquier tipo de beneficio econ?ico por esa v?.

En este sentido, adem? de reiterar que existen organizaciones de dudosa procedencia y que es una obligaci? de la UAESP determinar que no se trate de asociaciones ficticias, apuntaron a que el censo realizado por la Universidad Javeriana muestra deficiencias, ya que la poblaci? de recicladores supera los 25.000 individuos, mientras que el documento elaborado por la instituci? universitaria plantea una poblaci? aproximada de 12.000 recicladores. Adicionalmente, se?laron que existen fen?enos de doble militancia que no han sido analizados.

3.6.3 Una cr?ica adicional al pliego de condiciones, esta vez de algunos **proponentes**, tiene que ver con el hecho de que se impone al proponente la obligaci? de garantizar por lo menos un 32% de cobertura de las rutas de reciclaje; rutas que en los t?minos del pliego no ser? operadas por los concesionarios sino por terceros (recicladores) que no adquieren ninguna obligaci? contractual.

Aunado a ello, se le exige a los proponentes ofertar puestos de trabajo a la poblaci? de recicladores, de forma que los operadores se ver? obligados a prescindir de operadores ya entrenados y calificados para los oficios propios de la licitaci?, aspecto que entre otros, genera desigualdades pues los oferentes con mayor experiencia han invertido mayores recursos econ?icos y t?nicos en la capacitaci? de personal que los nuevos operadores.

3.6.4. A m? de lo anterior, alegaron que -en raz? a la falta de planeaci?, que se evidencia en las adendas

proferidas a ?tima hora- no existen estudios serios sobre la viabilidad econ?mica de las futuras empresas. M?ime si se tiene en cuenta que varios de los proponentes ofrecieron acciones en monto superior al 40%. Con esto se pone en riesgo la prestaci? del servicio p?blico de aseo, pues en caso de no poder soportar los gastos econ?micos, dejar? de recoger los residuos s?idos de la ciudad y transportarlos al sitio de disposici? final. Sumado a esto, apuntaron que, al obligarlos a afiliarse con organizaciones de recicladores que no conocen, se les conculca la libertad de empresa y de asociaci?.

3.6.5. Otro punto de discordia radica en el aporte de las organizaciones de segundo nivel como socios de industria. As? para algunos de los proponentes no existen obligaciones en cabeza de dichas asociaciones. Basta con que participen en la constituci? de la empresa prestadora del servicio para resultar beneficiadas. Por lo mismo, incluyeron las acciones simplemente como un requisito habilitante y de puntuaci?, que les permitiera hacerse a la licitaci?.

Para otros proponentes la ruta de reciclaje estar?a cargo de los recicladores, por lo cual el oficio que han desempe?do se constituir? precisamente, en el aporte de industria en beneficio de la empresa por parte de las organizaciones aunque estas no lo presten directamente.

Sumado a lo anterior, para ciertos socios de capital, la actividad que aportar? las asociaciones de segundo nivel redundan en el seguimiento, control, vigilancia y capacitaci? de las organizaciones de base, as?como en el deber de afiliar a los recicladores de oficio que no se encuentren coaligados. Por lo tanto, el aporte de industria ser?la coordinaci? de asociaciones que s?desempe?r? el aprovechamiento.

Finalmente, para otros intervinientes, existe una contradicci? insalvable en el pliego de condiciones, que se presenta por el hecho de que la empresa que se constituir? no podr?ejercer el aprovechamiento porque ?te ser?ejercido por los recicladores de base mientras que las organizaciones de segundo nivel entrar? s?o a ser socias en las actividades de recolecci? y transporte de los operadores contratistas, sin cumplir funci? material alguna. Adicionalmente, el plan para incentivar el aprovechamiento ser? presentado por los proponentes y no por las mentadas asociaciones. As?las cosas, este punto tampoco se consolidar? como un aporte industrial.

Sobre lo anterior, incluso la Procuradur? General de la Naci? cuestion?que sean las asociaciones de segundo nivel las socias de industria, cuando son los recicladores de oficio quienes operar? las rutas de reciclaje. A m? de ello, apunt?que no existen garant?s en la prestaci? de esta actividad a favor de los usuarios del servicio y en beneficio de todos los habitantes de Bogot?

3.6.6. Otro punto de desavenencia que se observa se relaciona con la compresi? del acceso cierto y seguro a los residuos s?idos. Esto, a pesar de que la mayor? de los intervinientes apuntan que resulta un beneficio para la poblaci? de recicladores la obligaci? atinente a la entrega de dotaciones y equipos, que relativizan en raz? a que depende del n?ero de personas que se vinculen a las organizaciones de segundo nivel.

Sin embargo, algunos alegan que las rutas formales, al ser legalizadas a trav? de una declaraci? jur?ica y

operar bajo los parámetros de la libre competencia, conllevan un riesgo para la prestación del servicio, dado que los recicladores entrarían en contienda para hacerse a la materia prima de su trabajo, incluso en las aceras de la urbe capitalina^[4]. Aunado a esto, aducen que comprenden por acceso cierto la facilidad de obtener el material potencialmente aprovechable. Así las cosas, tal condición se maximizaría si la actividad que realizan se rige por las mismas reglas de exclusividad que operan para las ASEs.

A más de lo anterior, exponen que el acceso cierto conlleva la posibilidad de ejercer su oficio, sin las tensiones del libre mercado y sin que sean los proponentes quienes formulen los planes de aprovechamiento. Por ende, implica cobertura y autonomía en las rutas selectivas como empresarios de las basuras, pero en consideración de los residuos recolectados y no de los usuarios afiliados.

Otros, por el contrario, argumentan que es precisamente la libre competencia la que asegura el acceso a los materiales potencialmente aprovechables, a lo cual se suma la información que manejan y obtendrán por hacer parte del operador del ASE respectivo. Para ellos, existen garantías al trabajar puerta a puerta sin que exista inconveniente en que operadores y recicladores compitan por los mismos residuos, siempre que las rutas de reciclaje pasen primero que las rutas de los operadores.

3.6.7 Otro punto de diferencia radica en el Fondo de Reciclaje. Para ciertos intervinientes, como quiera que éste se financiara con la venta del material potencialmente reciclable - asunto que conforme a los elementos aportados al trámite, no resulta técnicamente cierto^[5]-, ello conlleva una carga para los recicladores de base, pues serán estos quienes verán menguados los recursos que recibirán al comercializar los residuos. Con todo, en estrecha similitud con este argumento, otros mencionan que se trata de una figura que se beneficia del trabajo de los recicladores □ dado que se calcula a partir del peso de los residuos que dejarán de llegar al relleno sanitario □ pero que sólo destina el 50% de sus ingresos a actividades de apoyo para el grupo poblacional. Mientras que la otra mitad, se devolverá a los usuarios por separar los residuos desde el punto de origen, desconociendo que en muchas ocasiones son los recicladores □ a través de las rutas informales □ los que terminan seleccionando tales materiales.

Otros, por el contrario, consideran que a pesar de que desconocen la naturaleza jurídica del Fondo, este se consolida como una herramienta para beneficiar a la ciudad, dado que incentiva tanto el aprovechamiento como la separación en la fuente. Adicionalmente, el Fondo asegura recursos que redundarán en beneficio de la población recicladora del distrito capital. En otras palabras, servirá como un estímulo tanto para los usuarios del servicio como para los recicladores, dado que les corresponderá sumas de dinero por la reducción de la magnitud de los materiales objeto de disposición que dejarán de llegar al relleno sanitario.

3.6.8. Finalmente, es necesario señalar que algunos de los intervinientes □ entre ellos la UAESP- solicitaron que se declarara el cumplimiento efectivo de las obligaciones contempladas en la sentencia T-724 de 2003 y en el Auto 268 de 2010. Por lo mismo, a su parecer, la Corte debe levantar la suspensión de la licitación pública en comento y permitir la continuación del proceso precontractual.

Otros solicitaron que se declarara el incumplimiento de las referidas providencias y que en su lugar se ordene: a. la adopción de criterios de antigüedad y la exclusión de organizaciones de dudosa procedencia; b. la separación efectiva del aprovechamiento y la recolección para la disposición final, en razón a que ambas

actividades operan sobre los mismos residuos potencialmente aprovechables; c. la entrega en exclusividad de la recolecci? para el aprovechamiento a los recicladores, garantizando el acceso cierto y seguro de manera permanente y constante (esto incluye la operaci? de las rutas de reciclaje); d. el reconocimiento econ?mico de su trabajo, en consideraci? al peso de materiales que recogen y transportan (esto incluye una diferenciaci? tarifaria, dado que, a su parecer, en este momento la tarifa reconoce el aprovechamiento como parte de la disposici? final de residuos s?idos); e. La permanencia del fondo de reciclaje, que los recursos sean destinados en su totalidad a la poblaci? de recicladores; f. El funcionamiento de centros de acopio y medios de trabajo adecuados para laborar (lo que incluye veh?ulos de transporte); g. contar con herramientas para crecer dentro de la cadena productiva de las basuras, con base en sus conocimientos; h. el incentivo a la econom? solidaria, otorgando el manejo de las rutas de reciclaje; y, finalmente, i. algunos solicitaron no ser socios de industria.

4. Elementos probatorios.

El material probatorio que fue allegado al presente tr?ite y, que sirve de fundamento para el estudio que se realiza a continuaci? se enlista en el Anexo No. 2 de esta providencia.

II. CONSIDERACIONES DE ESTA CORPORACI?.

Competencia para verificar el cumplimiento de un fallo de tutela y facultades del juez constitucional.

1. El Decreto ley 2591 de 1991, por medio del cual se reglamenta la acci? de tutela, consagra dos mecanismos que puede utilizar el actor en sede de tutela, simult?ea o sucesivamente, ante el incumplimiento de la orden emitida en un fallo de amparo proferido con ocasi? de la declaratoria de la vulneraci? o la amenaza de sus derechos fundamentales, no excluyentes entre s? uno de tipo sancionatorio y otro de tipo material, pues de lo que se trata es del goce efectivo de los derechos fundamentales, raz? de ser del Estado Social de Derecho.

En cuanto al primero, los mecanismos de cumplimiento de tipo sancionatorio (requerimiento al superior jer?quico, solicitud de apertura de proceso disciplinario, compulsi? de copias para que se adelanten investigaciones penales y tr?ite del incidente de desacato), suponen la valoraci? de la responsabilidad subjetiva de los demandados.

Por su parte, el mecanismo de naturaleza material, comprende cualquier otro tipo de actuaci? del juez que por v?s legales pueda conducir al cumplimiento de la orden impartida. Para ello se puede valer, por ejemplo: i. de la solicitud de pruebas^[6] con el fin de esclarecer los hechos del incumplimiento y adoptar la soluci? m? acertada, raz? por la cual su papel en materia probatoria se traduce en un deber espec?ico de emplear sus potestades legales en la comprobaci? del cumplimiento de los derechos tutelados, a fin de garantizar la cesaci? de la vulneraci? o amenaza de los mismos; ii. Dictar ?denes y requerimientos complementarios al fallo o decisi?^[7]; iii. Proferir sentencias de reemplazo en el caso de tutelas contra

providencias judiciales que no se cumplen^[8]; iv. Adicionar la decisi? inicial para vincular a quienes no quedaron expresamente incursos en las consecuencias que acarrea el incumplimiento^[9] o v. la celebraci? de audiencias para hacer p?licas las actuaciones de las autoridades encargadas del cumplimiento de ?denes judiciales^[10].

As? el Decreto 2591 de 1991 faculta al accionante ya sea para pedir el cumplimiento de la orden emitida en un fallo de tutela por medio del denominado *tr?ite de cumplimiento*, y/o para solicitar sea sancionada la autoridad incumplida a trav? del *incidente de desacato*.

2. Esta Corporaci? ha sostenido que en virtud de lo establecido en los art?ulos 23 y 52 del Decreto 2591 de 1991, la competencia para verificar y hacer cumplir las ?denes emitidas en un fallo de tutela, por regla general, es del juez de primera instancia, incluso si se trata de ?denes proferidas en segunda instancia o en sede de revisi?^[11]. Es ?te ☐ ☐ *el encargado de hacer cumplir la orden impartida, as? provenga de fallo de segunda instancia o de revisi?, ya que mantiene la competencia hasta tanto no se cumpla la orden a cabalidad* ☐ ^[12].

3. Sin embargo, en casos excepcionales esta Corporaci?, como m?imo ?gano de la jurisdicci? constitucional y garante del ordenamiento jur?ico colombiano, tiene competencia para conocer del tr?ite de cumplimiento y del incidente de desacato en sede de revisi?, para lo cual la misma Corte ha se?lado en sus providencias determinados requisitos que han de llenarse para que la excepci? proceda^[13]: ☐ (i) [que] se trate del incumplimiento de una sentencia emitida por la Corte Constitucional en virtud de la cual conceda el amparo solicitado (☐), (ii) [que] resulte imperioso salvaguardar la supremac? e integridad del ordenamiento constitucional y (iii) [que] la intervenci? de la Corte sea indispensable para la protecci? efectiva de los derechos fundamentales vulnerados o amenazados ☐ ^[14].

De igual forma tal competencia radicar?en la Corte Constitucional cuando las ?denes proferidas por ?ta no han sido acatadas, bien sea porque el juez competente no adopta las medidas conducentes para ello o bien porque pese a haberlas adoptado, la desobediencia persiste. En ese orden, el fundamento normativo que faculta a la Corte Constitucional para conocer, de manera excepcional, del incumplimiento de sus sentencias proviene del art?ulo 27 del Decreto 2591 de 1991, por el cual se dispone que el juez constitucional mantiene su competencia hasta que est? completamente restablecido el derecho fundamental conculcado o sean eliminadas las causas que lo amenazan^[15].

4. As?las cosas, y teniendo presente que: (i) en la sentencia T-724 de 2003 y en el Auto 268 de 2010, se dispuso que en futuras contrataciones de servicios p?licos de aseo, la Unidad Ejecutiva de Servicios P?licos del Distrito Capital o quien hiciera sus veces, deb? incluir acciones afirmativas a favor de los recicladores de Bogot? (ii) mediante la Resoluci? No. 364 de 2011 se abri?la licitaci? p?lica No. 001 de 2011 con el objeto de concesionar la prestaci? del servicio p?lico domiciliario de aseo en la ciudad de Bogot? en sus componentes de recolecci?, transporte y otros. (iii) la peticionaria manifest?ante el Juzgado 43 Penal Municipal -juez de primera instancia de la tutela T-723 de 2003-, el posible incumplimiento de las ?denes proferidas en la mencionada providencia, as?como en el Auto 268 de 2010 respecto de la citada licitaci?. (vi.) frente a tal solicitud **el juez de tutela de primera instancia se abstuvo de conocer el tr?itey lo remiti?a estaCorporaci?**. (vii.) puede existir un incumplimiento por

parte del Distrito a las ?denes impartidas por esta Corporaci? capaz de afectar derechos fundamentales de la poblaci? recicladora, resulta evidente que esta Sala de Revisi? es competente para verificar la eficacia de las precisas ?denes impartidas a trav? de la Sentencia T- 724 de 2003 y de los Autos 268 de 2010, 180 y 183 de 2011, en relaci? con la inclusi? de acciones afirmativas a favor de los recicladores en las condiciones que rigen la Licitaci? P?lica 001 de 2011.

5. Ahora bien, el incumplimiento que se demanda de las ?denes constitucionales contenidas en la sentencia T-724 de 2003 y en los Autos 268 de 2010, 180 y 183 de 2011, radica en el proceso de selecci? regido por la Licitaci? P?lica 001 de 2011.

Sobre este punto es preciso realizar la siguiente precisi?: la Corte Constitucional en sentencia SU-713 de 2006^[16] se?l? que no exist? raz? v?ida para que la acci? de tutela pudiera usarse como mecanismo definitivo y prevalente para impedir total o parcialmente la continuaci? del proceso licitatorio o la celebraci? del contrato estatal, en la medida que frente a los actos administrativos generales o particulares y, concretamente respecto del pliego de condiciones, era posible acudir ante la Jurisdicci? de lo Contencioso Administrativo por v? de anulaci? y suspensi? provisional, de forma que s?o era posible acceder a este amparo mediante la prueba de la existencia de un perjuicio irremediable y s?o de forma transitoria.

Sin embargo, el caso concreto que se aborda en esta providencia presenta circunstancias formal y materialmente diferentes a las que hace referencia el mencionado fallo. As? en el caso en estudio no se est? ante una acci? de tutela en la cual un proponente persiga la protecci? de sus derechos fundamentales a partir de la interrupci? de un procedimiento de selecci?, por causa de un posible vicio que amerite la revisi? de la legalidad de los actos administrativos que integran dicho proceso, caso en cual se justifica la operatividad del principio de subsidiariedad en sede de tutela. El problema que ocupa la atenci? de la Sala de Revisi? en esta oportunidad es el: **i) incumplimiento de un fallo de tutela en firme**, capaz de vulnerar el derecho constitucional de acceso a la administraci? de justicia protegido por el bloque de constitucionalidad, **ii) el fallo de tutela orden? la protecci? de un grupo discriminado y minoritario de la poblaci?** que debe ser protegido por el juez constitucional a trav? de cualquiera de los mecanismos legales a su alcance. **iii) el fallo de tutela incumplido impon? a las autoridades del distrito ?denes positivas concretas** que deb?n ser aplicadas en los procesos de selecci? para adjudicar cualquiera de los componentes del servicio p?blico de aseo. As? las acciones contenciosas: nulidad, nulidad y restablecimiento del derecho y con ellas la medida de suspensi? provisional, fuera de evitar la adjudicaci? de un contrato, carecen de toda fuerza vinculante para constre?r a la Administraci? Distrital para proponer un modelo realmente incluyente que dignifique el trabajo de la poblaci? de los recicladores.

Lo anterior, por cuanto las medidas que se adopten para asegurar el cumplimiento de las ?denes judiciales no tienen por finalidad que se revise la legalidad de los actos administrativos sino que el proceso de selecci? establezca medidas incluyentes reales para la poblaci? de recicladores. Estas complejidades y particularidades autorizan entonces al Juez Constitucional para adoptar medidas directas sobre el proceso de selecci? en curso.

6. Lo anterior plantea entonces el interrogante de ¿cu?es son las facultades del juez de tutela frente a la verificaci? de un incumplimiento a un fallo de tutela?

6.1 La jurisprudencia de la Corte ha sosteniendo que los principios de prevalencia del derecho sustancial, celeridad, eficacia, oficiosidad e informalidad, que caracterizan el proceso de tutela, son aplicables también al período de cumplimiento del fallo. Es claro que las facultades y obligaciones constitucionales que tiene el juez de tutela no se contraen a la etapa del juzgamiento, sino que se mantienen y se reafirman durante la etapa de la verificación del cumplimiento de los fallos^[17].

6.2 Bajo esas circunstancias, vale la pena recordar que la jurisprudencia constitucional, en la sentencia SU- 1158 de 2003, ha indicado que los jueces constitucionales *“(□) con el propósito de garantizar la efectividad de los derechos de los asociados y en desarrollo del principio del efecto útil de las sentencias, gozan de amplias facultades en la determinación de la forma de ejecución de los fallos de tutela y en la adopción de las medidas tendientes a su cumplimiento; deduciéndose, de tal aserto, el deber de velar por el cumplimiento efectivo de las garantías conferidas a los ciudadanos en sede de tutela, “[i]nterpretando las normas y las sentencias dictadas en el caso concreto”□□.* (subrayado fuera de texto)

En ese orden, también lo indicó la Corporación en la Sentencia C-802 de 2002 y lo reiteró luego en la Sentencia SU-1158 de 2003, ninguna autoridad perteneciente a la Jurisdicción Constitucional puede desconocer la competencia del órgano que la Constitución se la como garante de su eficacia en todos los órdenes, así como que en su carácter de órgano límite de esa jurisdicción constitucional y en ejercicio de la supremacía no solo funcional sino también jerárquica, puede adoptar medidas adicionales para proteger efectivamente los derechos por ella tutelados, dando aplicación precisamente a los artículos 3° y 27 del Decreto 2591 de 1991, para lo cual es autónoma para **(i)determinar la oportunidad en que interviene para hacer cumplir sus órdenes de tutela y (ii)para definir qué tipo de medidas son las adecuadas para dar cabal cumplimiento al fallo.**

6.3 El hacer cumplir el fallo de tutela se justifica en el carácter normativo que se predica de la Constitución (Artículo 4°)^[18]. Por lo mismo, el incumplimiento de las órdenes proferidas en las sentencias de tutela se traduce en una vulneración del artículo 86 de la Constitución y en una continuada transgresión de los derechos fundamentales protegidos mediante la decisión judicial. Asimismo, contraviene el principio de eficacia de los fallos judiciales^[19] y el principio de seguridad jurídica, pues los mismos se derrumban si las órdenes proferidas por una de las ramas del poder público, queda sometida a la contingencia de la voluntad de la parte demandada.

En este contexto, el artículo 229 Superior asegura a todo ciudadano la posibilidad de acceder a la Administración de Justicia, aspecto que comporta entre otros muchos derechos, el que las decisiones tomadas por las autoridades jurisdiccionales se cumplan, pues sólo de esa manera la protección que se deriva de ellas se realiza de manera real y efectiva. Es así como, a partir de la sentencia T-537/94, reiterada en providencias posteriores de esta Corporación^[20], la Corte ha sostenido que el cumplimiento de las sentencias, en términos generales, se constituye en un derecho subjetivo de imperativo acatamiento en un Estado Social de Derecho.

6.4 Por su parte, el artículo 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos y el artículo 2° del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, impone a los Estados el deber de *“(□) garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso”□*, pues de lo contrario la garantía de los derechos quedaría carente de protección efectiva y no sería más que una bella conjunción de frases destinadas a desaparecer en el tiempo. Es por ello que estos

instrumentos reconocen el derecho de todas las personas a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes que las ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales, aun cuando tal violación provenga de personas que actúan en ejercicio de funciones públicas. De esta manera, es una obligación para los Estados: **i)** garantizar que las autoridades competentes previstas por el sistema legal decidan sobre los derechos de toda persona que interponga tal recurso; **ii)** desarrollar las posibilidades de recurso judicial, y **iii)** garantizar **el cumplimiento** por las autoridades competentes de toda decisión en la que se haya estimado procedente el recurso.

Del bloque de constitucionalidad^[21] se infiere entonces que el derecho a la administración de justicia no se agota con la adopción de una decisión de fondo en la que se protejan los derechos de las partes, sino que su límite se extiende hasta el cumplimiento de las decisiones y, más allá, hasta la protección *efectiva* de los derechos involucrados, bien porque cese la amenaza o bien porque fenezca la vulneración de los mismos. Así, la vocación de la orden judicial es su cumplimiento y para garantizarla el mismo ordenamiento debe proveer: **i.** el procedimiento que permita reclamar la ejecución de los fallos judiciales, de forma que se trascienda de una simple sanción por su desacato, así como establecer **ii.** la obligación de los jueces de garantizar la prevalencia del derecho sustancial a partir de proferido el fallo con miras a la estricta realización del derecho y **iii.** las facultades para efectivizar el cumplimiento.

6.5 Es por ello que los artículos 27, 52 y siguientes del Decreto 2591 de 1991, señalan de manera enunciativa -que no taxativa-, algunas herramientas a disposición del juez para la ejecución de su deber: i) requerir al superior jerárquico del demandado ☐ cuando es autoridad pública ☐ para que cumpla las órdenes proferidas; ii) ordenar la apertura de proceso disciplinario contra el superior que no procedió conforme a lo antes señalado; iii) adoptar directamente todas las medidas necesarias para lograr el cabal cumplimiento del fallo; iv) compulsar copias para que se adelanten las investigaciones penales contra el obligado por los delitos de fraude a resolución judicial y prevaricato por omisión, entre otros; y v) sancionar al incumplido ☐ particular o autoridad pública ☐ por desacato con arresto de hasta seis meses y multas de hasta 20 salarios mínimos mensuales.

En este sentido, y en concordancia con el hecho de que es un fin del Estado el goce efectivo y no meramente simbólico de los derechos de las personas, el decreto en cita establece una fórmula amplia que faculta al juez para adoptar *cualquier* acción que garantice el cumplimiento de sus órdenes, una vez se haya constatado la renuencia de la autoridad pública responsable, al punto que el inciso segundo del artículo 23 del citado Decreto contempla que si la entidad continúa incumpliendo las órdenes proferidas por el juez, éste ☐ ☐ podrá disponer lo necesario para que el derecho sea libremente ejercido sin más requisitos ☐ ☐.

Asunto previo. Por qué en el presente trámite de verificación de cumplimiento se privilegia a la población de recicladores.

7. Tal como se indicó en la sentencia C-309 de 1997, los derechos constitucionales no pueden ser disueltos en un círculo utilitario sobre el bienestar colectivo, ni pueden estar únicamente sometidos al criterio de las mayorías, ya que esos derechos fundamentales e individuales son precisamente limitaciones al principio de mayoría. Sobre el punto ha referido esta Corte que ☐ ☐ condicionar la validez de un derecho constitucional a los criterios de las mayorías es quitarle toda su eficacia específica puesto que, en una gran medida, los derechos constitucionales fundamentales son las promesas que formulan las mayorías a las minorías -y a esas minorías radicales que son las personas- de que su dignidad e igualdad serán

siempre respetadas"^[22]. Por ello debe entenderse que el respeto de esos derechos es un componente primordial integrante del interés general.

Como bien lo señaló Luigi Ferrajoli, *“(□) el hecho de que los derechos humanos y con ellos todo progreso en la igualdad, se hayan ido afirmando cada vez más, primero como reivindicaciones y después como conquistas de los sujetos más débiles dirigidos a poner término a sus opresiones y discriminaciones, no se ha debido a la casualidad sino a la creciente evidencia de violaciones de la persona percibidas como intolerables”*^[23]. Por lo mismo, la guarda de tales derechos *“(□) más que en consideración de los sujetos de especial protección que sobreviven en situaciones que atentan contra la dignidad humana, más que de consolidarse como una necesidad en condiciones que exacerban la vulneración de los principios constitucionales actuales, se constituye en un ineludible deber a la luz de los parámetros del Estado Social de Derecho.*

8. Partiendo de ello, encuentra la Sala que los intereses de los proponentes involucrados en el trámite de la Licitación Pública 001 de 2011 *“(□) también particulares-*, deben desplazarse en este caso en favor de los derechos de las minorías que por esta vez se pretenden proteger, más allá de cuando no existe de por medio situaciones jurídicas consolidadas como las que devienen del acto de adjudicación de un contrato o la celebración del mismo, en la medida que en su condición de oferentes, sólo son titulares de una serie de expectativas referentes al posible contrato a adjudicar y de unos derechos frente a la Administración de que ésta haya obrado en el proceso de formación de los pliegos siguiendo los principios de transparencia, publicidad, igualdad, imparcialidad, responsabilidad y ante todo el deber de selección objetiva (arts. 23 y 29 ley 80 de 1993).

De ahí que las fuentes que enriquecen la responsabilidad precontractual en el ámbito civil y mercantil no puedan traerse al ámbito de la contratación estatal en toda su extensión, porque en este campo rige el principio de la solemnidad, de donde sólo se adquieren derechos a partir del acto de adjudicación y del perfeccionamiento del contrato en que el acuerdo de voluntades sobre el objeto y la contraprestación se eleve a escrito (art. 41 ley 80 de 1993). En ese orden, una eventual responsabilidad precontractual o por *“(□) da in contrahendo”*^[24] sólo se registra cuando un proponente sufre un daño antijurídico como consecuencia de una acción u omisión durante **la etapa de formación de la voluntad** (celebración del contrato), o la adjudicación irregular de la licitación, o la falta de perfeccionamiento del contrato, caso en el cual la Administración comprometer su responsabilidad, como también la comprometer el proponente que retira su oferta o que se niega a celebrar el contrato en las condiciones propuestas y aceptadas, todas ellas eventualidades que no se configuran en el presente asunto.

De allí que el hecho de privilegiar los derechos del trabajo y la dignidad humana de las minorías dedicadas al reciclaje por encima de las expectativas comerciales de los particulares que participan en condición de oferentes y que bien pueden hacerse presentes en futuros procesos de selección, no encuentra reparo alguno para esta Sala de Revisión en la medida que no se conculcan derechos fundamentales sino por el contrario se garantiza su realización en favor de la población menos favorecida.

9. Bajo la anterior consideración, se pregunta la Sala ¿qué impacto tiene el trámite de incumplimiento que se estudia frente al interés general, si se tiene en cuenta que la Licitación 001 de 2011 tiene por beneficiarios a los usuarios del servicio de aseo en el Distrito?

Pues bien, debe precisarse que los contratos de concesión de aseo para los componentes de recolección, transporte, limpieza, poda y corte de césped celebrados por la Administración Distrital en el año 2003, terminaron por expiración del plazo adicional el 15 de septiembre del año en curso y, con ellos la habilitación de áreas de servicio exclusivo en la ciudad, de lo cual se infiere que a partir de esa fecha rige el artículo 40 de la Ley 142 de 1994, que señala la regla general de libre competencia para la operación de estos servicios públicos domiciliarios.

Así las cosas y dada la suspensión del trámite del proceso de selección de nuevos concesionarios ordenado por la Corte Constitucional, el Distrito suscribió por el mecanismo de urgencia cuatro contratos que actualmente se encuentran en ejecución, por el término de seis meses, estos son : 157E, 158E, 159E, y 160E (AZ 4, folio 474 a 544). A través de ellos, los diferentes operadores se obligan con la Administración Distrital a prestar los componentes de recolección, transporte, limpieza, poda de árboles y corte de césped del servicio de aseo en las (i) **mismas áreas** en las cuales venían operando por virtud de la Resolución CRA 235 de 2002 y (ii) **con las mismas obligaciones**, lo cual significa que sin importar que exista libre competencia, estos operadores están obligados por virtud de los citados contratos a prestar una cobertura en el 100% de la ciudad y frente a todos los estratos, sin que sea posible afirmar en la actualidad que alguna zona de la ciudad esté desprovista del servicio de aseo o que los estratos 1 y 2 hayan dejado de ser atendidos por alguno de estos operadores.

En ese sentido el interés general está actualmente cubierto y puede seguir estando a través de las acciones que para el efecto establezca la Administración Distrital a partir de las herramientas previstas en la Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007 y 142 de 1994, sin que el presente trámite o las decisiones que en él se adopten puedan ser tomadas como excusa válida para entorpecer la debida prestación del servicio público de aseo y, sobre todo, para no garantizar este a la población más pobre.

Teniendo en cuenta lo anterior se puede afirmar que, si bien es cierto no está vigente verificación alguna de condiciones que autorice áreas de servicio exclusivo, de manera que en la actualidad opera un régimen de libre competencia, lo cierto es que con independencia de que operadores privados decidan competir por el servicio en determinadas zonas del Distrito, el efecto vinculante de los contratos citados garantiza que a través de la libre competencia, toda la ciudad en su conjunto no quede desprovista materialmente de la prestación de estos servicios. En otras palabras, sin ahondar más en este análisis, el eventual “descenso” del sector lo más probable que podrá generar es una eventual disminución de las tarifas en favor de los usuarios, lo cual no se compara con la desproporcionada afectación que podrán sufrir los recicladores de permitir que se incumplan las órdenes proferidas por esta Corporación en violación de los deberes constitucionales e internacionales.

Problema jurídico y esquema de resolución.

10. Con fundamento en la solicitud de verificación de incumplimiento, así como en los hechos narrados y probados dentro del presente trámite, corresponde a esta Sala de Revisión determinar si la UAESP dio o no efectivo cumplimiento a las órdenes impartidas por esta Corporación en la sentencia T-724 de 2003 y en el Auto 268 de 2010, referentes a la inclusión de acciones afirmativas a favor de la población de recicladores de Bogotá en el proceso de selección realizado con ocasión de la Licitación Pública No. 001 de 2011, por el cual se pretende concesionar el servicio público de aseo en los componentes de recolección, transporte,

limpieza, corte de césped y poda de árboles^[25].

11. Para solventar tal interrogante, la Sala abordar los siguientes puntos: **(i)** El Estado Social de Derecho y el principio de igualdad frente a sujetos de especial protección: **a.** Sujetos de Especial protección. **b.** El mandato de abstención y el mandato de acción; **c.** Los deberes y poderes del juez constitucional frente al principio de igualdad. **(ii) El caso concreto:** **a.** Las demandas de la Corte Constitucional presuntamente incumplidas por el Distrito. **b.** Los niveles de protección que fueron planteados por la UAESP a partir del pliego de condiciones y si estos pueden considerarse como acciones afirmativas en favor de la población recicladora: **(b.1)** participación accionaria de las asociaciones de segundo nivel en las sociedades concesionarias. **(b.2)** entrega de las rutas de reciclaje a la población recicladora. **(b.3)** La oferta de plazas de empleo de los concesionarios a los recicladores en actividades propias de su operación. **c.** Declaración de incumplimiento y demandas concretas.

El Estado Social de Derecho y el principio de igualdad frente a sujetos de especial protección constitucional.

12. Conforme al artículo 1º de la Carta Política, Colombia es un Estado Social de Derecho, que «entre otras características se configura como una entidad política que *se funda en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y en la solidaridad de las personas que la integran*»^[26]. Tal y como se reitera en la sentencia T-772 de 2003^[26], dicha declaración no reviste una simple fórmula retórica que brinda un elegante toque de filantropía a la idea tradicional del Estado o del Derecho. Por el contrario, «*se trata de un principio cardinal de nuestro ordenamiento constitucional, que le imprime un sentido, un carácter y unos objetivos específicos a la organización estatal en su conjunto, y que resulta en consecuencia vinculante para las autoridades*»^[26]. Entre esos fines que le son propios al Estado Social de derecho, siguiendo los postulados del prebulo de la Constitución, se halla la garantía de un orden político, económico y social justo, que sin duda se relaciona con la dignidad intrínseca de cada persona.

13. En este sentido, tal dignidad y las consecuentes obligaciones del Estado frente a ella, se relacionan intrínsecamente con el deber, contemplado en el artículo 13, de promover «*las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva [adoptando las] medidas a favor de grupos discriminados o marginados [y protegiendo] especialmente a aquellas personas que por su condición económica, física o mental, se encuentren en circunstancias de debilidad manifiesta; sancionando los abusos o maltratos que contra ellas se cometan*».

14. Ahora bien, tal como ha sido insistentemente reiterado por la jurisprudencia de esta Corporación, esto no significa que la igualdad ante la ley, baluarte de las revoluciones liberales del siglo XIX, haya dejado de ser relevante para esta fórmula del Estado, pero se le adiciona una nueva concepción de lo social. Se trata del reconocimiento de que para que exista un efectivo goce de los derechos y por ello de la materialización de los fines del Estado, que entre otros comprenden «*servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución*»^[27], se hace necesaria la adopción de medidas efectivas que contrarresten las situaciones de discriminación o marginación, que pueden ser físicas, mentales, económicas o de otra índole.

Es decir, dentro del Estado Social de Derecho resulta fundamental la igualdad ante la ley, también comprendida en el inciso primero del artículo 13 de la Constitución^[28], pero se le adiciona el deber de

contrarrestar las desigualdades materiales existentes dentro de esta sociedad; que □ por lo demás □ resultan no sólo evidentes, sino muchas veces groseras, superando con creces las enumeradas en el mentado artículo, y que, de acuerdo con lo indicado en el Auto 268 de 2010, □(□) han conllevado diferenciadas posibilidades de satisfacción de los derechos de las personas, [haciendo] evidente que la sociedad, al igual que el Estado, deben adoptar medidas para que estos grupos desventajados ^[29] puedan alcanzar las condiciones materiales que les permitan poder ejercer efectivamente - en iguales condiciones □ los derechos de los que son titulares□.

15. Puede afirmarse entonces que tratándose de la igualdad, conforme al principio del Estado Social de Derecho, la legitimidad del mismo depende de su intervención para precaver las situaciones que sustentan dichas desigualdades. Al respecto, reiterando la jurisprudencia de esta Corporación, en la sentencia T-772 de 2003 se afirmó que □(□) el grado de legitimidad del Estado y sus actuaciones se relaciona directamente con su compromiso efectivo hacia la construcción de un orden equitativo, a través de intervenciones razonables encaminadas a solucionar las disfuncionalidades propias del sistema social (□)□.

16. Así las cosas, con el objeto de garantizar la efectividad de los derechos, entre ellos la misma libertad y dignidad para todos, el Estado tiene que intervenir en la sociedad, incluso dentro de la esfera económica, tal y como lo establece el artículo 334 de la Carta, que consagra tal actuación □(□) para racionalizar la economía con el fin de conseguir el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes, la distribución equitativa de las oportunidades y los beneficios del desarrollo y la preservación de un ambiente sano□.

17. Tratándose del principio de igualdad, siguiendo los mandatos genéricos enunciados en el artículo 2º de la Constitución, así como en sus artículos 13, 334^[30] y 366^[31], la jurisprudencia de esta Corporación ha establecido que existen dos deberes diferenciados, aunque en ocasiones concomitantes del Estado: por una parte, se encuentran los deberes de abstención, que conllevan la prohibición de generar situaciones de discriminación o ahondar en aquellas existentes □ ya sea de manera directa o indirecta □ y, por la otra, los deberes de acción, que incluyen las denominadas acciones afirmativas.

Cabe precisar que esta Corporación expuso sobre lo anterior, en la sentencia T-291 de 2009^[32], que □(□) existe un deber de la administración de abstenerse de adelantar, promover o ejecutar políticas, programas o medidas que conduzcan a agravar o perpetuar la situación de exclusión, marginamiento o discriminación de grupos tradicionalmente desventajados en la sociedad (□)□. Adicionalmente, en esa providencia se destacó que □(□) la Constitución prohíbe, tanto las llamadas discriminaciones directas □ actos que apelan a criterios sospechosos o potencialmente prohibidos, para coartar o excluir a una persona o grupo de personas del ejercicio de un derecho o del acceso a un determinado beneficio, como las discriminaciones indirectas □ las que se derivan de la aplicación de normas aparentemente neutras, pero que en la práctica generan un impacto adverso y desproporcionado sobre un grupo tradicionalmente marginado o discriminado□.

18. Por otra parte, se hallan los deberes de acción, que implican la exigencia de adopción de medidas encaminadas a morigerar las situaciones de desigualdad o marginación existentes para garantizar el goce efectivo de los derechos para todos los habitantes de Colombia. Sobre este punto, en la sentencia T-724 de 2003^[33] se estableció que □(□) las diferentes autoridades del Estado están obligadas, cuando se encuentran en presencia de grupos en condiciones de marginalidad y discriminación, a adoptar todas

aquellas medidas necesarias para lograr una mayor igualdad sustantiva, incluyendo en sus decisiones tratamientos acordes con tales situaciones. Pasar por alto ese mandato, no contemplando medidas afirmativas a [favor] de grupos que pueden verse afectados por las decisiones adoptadas, (□) significa quebrantar el derecho a la igualdad, que impone, precisamente, su adopci? □.

19. Lo dicho puede sintetizarse a partir de lo expuesto en la sentencia T-772 de 2003, donde se estableci? que □(□) *se derivan dos clases de deberes diferenciables para el Estado: (i) por una parte, debe adoptar e implementar las pol?icas, programas o medidas positivas encaminadas a lograr una igualdad real de condiciones y oportunidades entre los asociados, dando as? cumplimiento a sus obligaciones internacionales y constitucionales de lucha contra la pobreza y progresiva satisfacci? de los derechos econ?icos, sociales y culturales b?icos de la poblaci? -en aplicaci? de lo que la jurisprudencia constitucional ha denominado □cl?sula de erradicaci? de las injusticias presentes□-; y (ii) por otra, se debe abstener de adelantar, promover o ejecutar pol?icas, programas o medidas ostensiblemente regresivos en materia de derechos econ?icos, sociales y culturales, que conduzcan clara y directamente a generar m? pobreza de la que actualmente agobia al pa?, y agraven la situaci? de exclusi? o marginaci? de determinados sectores de la sociedad, especialmente de aquellos que se encuentran en condiciones econ?icas precarias; mucho m? si, como consecuencia de tales pol?icas, programas o medidas, se acaba por empeorar la situaci? material de quienes ya est? en circunstancias extremas de subsistencia*^[34](□)□.

20. Ello no implica que el Estado, en obediencia del principio de igualdad y de las dos esferas descritas, no pueda adelantar actuaciones que generen impactos sobre grupos de especial protecci? constitucional. Esto concuerda con uno de los elementos contemplados en el art?ulo 1° de la Carta Pol?ica colombiana, que establece la prevalencia del inter? general sobre el particular. Sin embargo, s?conlleva que toda actuaci? estatal, que pueda generar tales efectos, est?sometida a estrictos par?etros de razonabilidad y proporcionalidad. De lo contrario, de no limitarse las pol?icas estatales que pudieran ejercer presi? sobre tales poblaciones, el cumplimiento de los fines esenciales del Estado, en especial la prosperidad general, la defensa de la convivencia pac?ica, la vigencia de un orden justo y la garant? de los derechos y libertades para todos y todas, no pasar? de ser una simple quimera enunciada en el texto de la Constituci?; un mandato de papel destinado a no materializarse nunca.

Esto fue reiterado en la sentencia T-291 de 2009, previamente citada en esta providencia, de la siguiente manera: □*Lo anterior no significa que toda medida que genere un impacto adverso en un grupo marginado o discriminado est?proscrita por la Constituci?. Pero s?significa que frente a dicho impacto, a la administraci? le corresponde demostrar que a pesar de la afectaci? desproporcionada para un grupo marginado, la medida, programa o pol?ica responde a condiciones de razonabilidad y proporcionalidad, y que la misma ha venido acompa?da por otras acciones dirigidas a contrarrestar el efecto adverso que ha podido generar en un grupo marginado o discriminado. En tanto est? en juego los derechos de grupos de especial protecci?, en estos casos opera prima facie una presunci? de discriminaci?, a la luz de la cual es a la administraci? a quien le corresponde desvirtuar esta presunci?,*^[35] *superando un escrutinio judicial estricto.*^[36] *Es decir, que debe demostrar que su actuaci?, a pesar de generar un efecto adverso en un grupo marginado o discriminado, obedece i) a una finalidad imperiosa, ii) es necesaria para lograr dicha finalidad y iii) es proporcionada, en el sentido de no sacrificar en exceso otros intereses constitucionalmente espec?icos en aras de promover la finalidad*^[37]□. Estos puntos, en especial el juicio de razonabilidad, proporcionalidad y la presunci? de discriminaci?, al igual que el deber de generar medidas que morigeren el impacto adverso, ser? abordados m? adelante.

Sujetos de especial protecci? constitucional.

21. Como ha sido reiterado por la jurisprudencia de esta Corporaci?, las personas beneficiarias de aquellos tratos destinados por el Estado para garantizar la igualdad material, al igual que el goce efectivo y real de los derechos, son los sujetos de especial protecci? constitucional. Asimismo, en las providencias que han abordado temas relacionados con los grupos poblacionales que ejercen la actividad del aprovechamiento, en especial el Auto 268 de 2010, la Corte explic? que se encuentran revestidos de tal calidad, no solo por las condiciones de pobreza y marginalidad en la que sobreviven, sino por los ingentes beneficios que en materia ambiental acarrear? para el resto de la sociedad.

En efecto, en el precitado Auto se afirm? que *“(□) la Corte no s?o debe referirse a la discriminaci? y marginaci? que padecen los recicladores en esta sociedad, sino a la importancia de su labor dentro de las relaciones ambientales que se han producido en algunas sociedades a partir del cambio energ?ico que se caus? con la revoluci? industrial, en especial a partir de la utilizaci? del petr?eo como principal fuente de energ?, as? como con el aumento del consumo por habitante a partir de mediados del siglo XX*^[38]. Y es que, no sobra precisar, el aprovechamiento repercute directamente en el impacto ambiental del ciclo productivo de la sociedad de consumo, pues, adem? de brindar materia prima para la producci? de diferentes bienes y servicios □ pi?sesse por ejemplo en la posibilidad de utilizar papel reciclado -, prolonga la vida ?il de los rellenos sanitarios, evitando que debamos ocupar territorios adyacentes a los centros urbanos para sepultar, en los sitios adecuados para la disposici? final, los millones de toneladas de residuos s?idos que se generan anualmente^[39].

22. Cabe precisar que seg? la jurisprudencia de esta Corte, como fue reiterado en el citado Auto, el ambiente es entendido como el *entorno vital* del ser humano, indispensable por tanto para las generaciones actuales como las futuras. Se trata as? de un concepto que comprende las relaciones sociales con los ecosistemas. Por lo mismo, en la sentencia C-189 de 2006, esta Corporaci? indic? que *“(□) el medio ambiente se encuentra al amparo de lo que la jurisprudencia ha distinguido con el nombre de □Constituci? Ecol?ica□, conformada por el □conjunto de disposiciones superiores que fijan los presupuestos a partir de los cuales deben regularse las relaciones de la comunidad con la naturaleza y que, en gran medida, propugnan por su conservaci? y protecci?□*^[40].

23. Es claro, entonces, que si tales relaciones deben propender por la conservaci?, todas aquellas actuaciones que repercutan ben?icamente en ellas, como sucede con el aprovechamiento, son de vital importancia, m?ime si son desarrolladas por sujetos que se encuentran en situaciones de marginaci? que los hace acreedores de la especial protecci? constitucional emanada de la cl?sula de erradicaci? de pobreza del Estado Social de Derecho.

Ahora bien, en t?minos del mencionado Auto 268 de 2010, que guarda estrecha relaci? con el asunto objeto de estudio en esta ocasi?, el Decreto 1713 de 2002, *□Por el cual se reglamenta la Ley 142 de 1994, la Ley 632 de 2000 y la Ley 689 de 2001, en relaci? con la prestaci? del servicio p?blico de aseo, y el Decreto Ley 2811 de 1974 y la Ley 99 de 1993 en relaci? con la Gesti? Integral de Residuos S?idos□*, se?la que el aprovechamiento reviste importancia ambiental, pues con ? se busca *“(□) racionalizar el uso y consumo de las materias primas provenientes de los recursos naturales (□), reducir la cantidad de residuos a disponer finalmente en forma adecuada (□) [y] disminuir los impactos ambientales, tanto por la demanda y uso de materias primas como por los procesos de disposici? final□*^[41].

24. Se resalta entonces que los recicladores -promotores del presente tr?ite-, adem? de ser sujetos de especial protecci? constitucional, son hist?icamente titulares de un papel ambiental de suma trascendencia, por lo cual son acreedores indiscutibles de un trato digno.

Mandatos de abstenci? y de acci?.

25. Ser sujeto de especial protecci? constitucional conlleva, por una parte, el derecho a no padecer discriminaciones -siguiendo los postulados de la esfera de abstenci? del principio de igualdad-. Lo cual implica tambi?, de otra parte, la prerrogativa de no padecer un empeoramiento de la situaci? en la que sobreviven, salvo que se satisfagan los criterios de proporcionalidad, razonabilidad y morigeraci? de los impactos adversos. Entonces, el Estado no puede generar situaciones que desemboquen en un acrecentamiento de situaciones como la pobreza, que se liga inexorablemente a la indebida satisfacci? del m?imo vital.

A este respecto, en la sentencia T-772 de 2003 se afirm?que la f?mula pol?ica del Estado Social de Derecho *“(□) opera como un l?ite elemental para el dise? y ejecuci? de pol?icas p?licas en cualquier sector de la vida nacional: se trata de la prohibici? de adoptar medidas inherentemente regresivas en materia de lucha contra la pobreza y mejoramiento de las condiciones generales de vida (□)□*. Adicionalmente, tal y como fue indicado con anterioridad, el mandato de abstenci? envuelve como consecuencia, trat?dose de sujetos de especial protecci?, que toda actuaci? adoptada que pueda incidir en un agravamiento de la situaci? de desigualdad que padecen, sea considerada *“(□) prima facie (□) discriminatoria y, por lo mismo, contraria a la Constituci?”*.

26. Con todo, tal calidad de sujeto de especial protecci? repercute en los deberes del Estado atinentes a solventar las desigualdades materiales, asunto que se concreta *“(□) entre otras (□) a trav? de las pol?icas p?licas, siguiendo los postulados de la esfera de acci? del principio de igualdad*. En efecto, es un deber del Estado alcanzar la igualdad de oportunidades para todos y todas, la prosperidad general y el mejoramiento de la calidad de vida. Esto se relaciona con la mentada cl?sula de erradicaci? de la pobreza, que por sobre todo conlleva la generaci? de posibilidades de trabajo *“(□) que incluyen tanto la esfera del empleo como la generaci? de empresa (□) para los habitantes del pa?”*. As?las cosas, los sujetos de especial protecci? constitucional son beneficiarios de las denominadas acciones afirmativas, que tienen por finalidad promover la igualdad real y efectiva, para que as?logren superar tales condiciones reprochables a la luz del ordenamiento jur?ico colombiano.

Ahora bien, es claro que en raz? a la complejidad pol?ica, econ?ica y ambiental que vive la sociedad colombiana resulta imposible satisfacer inmediatamente todas las necesidades existentes. Por ello, la jurisprudencia de esta Corte ha expuesto que tales actuaciones han de adelantarse de manera progresiva; lo cual significa, trat?dose de sujetos de especial protecci? constitucional, que su condici? *“(□) si bien puede mostrar una paulatina mejor? (□) no puede permanecer igual, sino que debe tender hacia un alivio paulatino*. Por lo mismo, no es aceptable que el Estado responda de la misma manera frente a situaciones de marginaci?, como lo haya hecho en el pasado. A este respecto, en la sentencia C- 617 de 2002 *“(□) reiterada en la sentencia T-772 de 2003 (□) se adujo que (□) la progresividad hace referencia al reconocimiento de prestaciones mayores y superiores en relaci? con cada uno de esos derechos sociales prestacionales, pero ese mandato de progresividad no excusa el incumplimiento del deber del Estado de*

asegurar, tan pronto como sea posible, coberturas universales de los contenidos mínimos de esos derechos, tal y como esta Corte ya lo hab? reconocido con anterioridad (□)□.

27. Tal y como fue se?lado con anterioridad el constitucionalismo vigente □a diferencia de aqu? decimon?ico-, asume la existencia de situaciones de desigualdad materiales que generan condiciones de exclusi? y, en ciertos casos, de explotaci?. Como consecuencia, impone el deber al Estado y a la sociedad de asumir ciertas cargas para paliar tales situaciones que se han materializado a lo largo de la historia.

Con estas obligaciones, se busca distribuir las oportunidades que han sido negadas a ciertos grupos humanos y que pueden ser entendidas, aunque no exclusivamente, como condiciones en las que se les ha privado del acceso al capital y se les ha marginado del consumo, lo que puede ser comprendido como un *apartheid* social^[42].

28. En este sentido, autores como Gim?ez Gl?k, se han pronunciado al respecto se?lando que las acciones positivas buscan la promoci? de la igualdad material de los colectivos. Por ello, parten de normas que diferencian entre grupos sociales beneficiados y desfavorecidos, teniendo por finalidad la lucha contra las situaciones de desigualdad material de los ?timos. As?las cosas, □(□) *Las tres caracter?ticas principales de este tipo de medidas son: a) la medida divide a la sociedad en colectivos cuya desigualdad material se manifiesta desde un punto de vista grupal, esto es, tiene como fundamento la igualdad material entre colectivos; b) la medida tiene como finalidad compensar la desigualdad material que los beneficiados por la norma sufren desde un punto de vista colectivo; y c) el rasgo que determina la diferenciaci? es la caracter?tica que los cohesiona como colectivo y por la que se identifica y discrimina socialmente a los miembros del mismo (ej.: el sexo, la raza, etc.) (□). [As? las cosas] acci? positiva ser? el trato formalmente desigual que beneficia a un colectivo que comparte un rasgo estigmatizado (□)□*^[43].

29. Como se observa, tres elementos pueden extraerse de esta cita: i. El fundamento de las medidas es la b?queda de la igualdad material, ii. Su finalidad es la compensaci? de una situaci? socialmente construida y iii. uno de sus rasgos es que se encontrar? circunscrita a determinado grupo determinable precisamente por las causas de la exclusi?.

En este sentido, en el Auto 268 de 2010, reiterando par?etros anal?icos esbozados en la sentencia T-291 de 2009, esta Corporaci? se?l?que los postulados de autores como Owen Fiss o Iris Marin Young pueden resumirse de la siguiente manera: □*El primero refiere que para hablar de un □grupo desventajado□ se deben tener en cuenta tres caracter?ticas: i) Se trata de □un grupo social□, que como tal □va m? all?de una serie de individuos, que por tomar un ejemplo extremo, se encuentran, por azar, en la misma esquina, en el mismo momento□. Es decir, que un grupo social es una entidad que tiene una identidad propia, de manera que es posible hablar del grupo, sin necesidad de entrar a hacer referencia particular a cada uno de los miembros que lo componen. As?mismo, la connotaci? de grupo social se distingue por □la condici? de interdependencia□, pues □la identidad y el bienestar de los miembros del grupo y la identidad y bienestar del grupo se encuentran interrelacionadas.□ Los miembros del grupo se autoidentifican □explican quienes son- refiri?dose a su condici? de miembros del grupo; y su estatus resulta determinado en parte por el estatus del grupo. ii) Se trata de un grupo que ha estado en una situaci? de subordinaci? prolongada y iii) el poder pol?ico del grupo se encuentra severamente limitado, bien sea por condiciones socioecon?icas, por haber sido relegados a una posici? de clase inferior, o por objeto de □perjuicio□ de los dem?.*

□ Por su parte, Iris Marin Young^[44] hace referencia a □ grupos oprimidos□, como grupos sociales frente a los cuales una o m? de las siguientes condiciones es aplicable a la totalidad o a una gran parte de sus miembros: □ i) Los beneficios derivados de su trabajo o energ? van a otras personas sin que ?tas les recompensen rec?rocamente por ello (explotaci?); ii) est? excluidos de la participaci? en las principales actividades sociales lo que en nuestra sociedad significa b?icamente un lugar de trabajo (marginaci?); iii) viven y trabajan bajo la autoridad de otras personas (falta de poder); iv) como grupo est? estereotipados y, a la vez, su experiencia y situaci? resultan invisibles en el conjunto de la sociedad, por lo que tienen poca oportunidad y poca audiencia para expresar su experiencia y perspectiva sobre los sucesos sociales (imperialismo cultural); v) los miembros del grupo sufren violencia y hostigamiento al azar merced al miedo o al odio hacia ?te.□

30. Lo anterior resulta de suma importancia, dado que saber qui?es son los sujetos de la acci? afirmativa se torna esencial para que la misma pueda existir, pues su objeto radica precisamente en mitigar las causas de la exclusi? de ese grupo espec?ico. Por lo mismo, las pol?icas destinadas por el Estado deben contar con un direccionamiento concreto: actuar sobre las causas que sustentan la desigualdad material de ese colectivo concreto.

31. Como bien se dijo, el fin de las acciones afirmativas redundaba en la redistribuci? de las oportunidades sociales a favor de ciertos colectivos que, por razones hist?icas, se han visto privados de ellas. As?las cosas, los deberes que emanan de la igualdad material son un complemento de aquella igualdad formal ante la ley, dado que en ?timas pretende el mismo goce de los derechos entre todas las personas. Ahora bien, existen varios tipos de medidas que puede llevar a cabo el Estado, con grados diferenciales, para lograr compensar esas situaciones desde?bles a la luz del constitucionalismo vigente.

32. En este orden de ideas, reiterando la jurisprudencia de esta Corporaci? y mencionando expresamente la sentencia T- 500 de 2002, en el Auto 268 de 2010 se indic?que existen los siguientes tipos de medidas que pueden ser adoptadas por el Estado: □(□) Acciones de concientizaci?. Son aquellas encaminadas a la formaci? y orientaci? en un determinado auditorio, as?como a la sensibilizaci? en torno a un problema. Campa?s publicitarias, de formaci? y capacitaci?, son algunas de estas medidas (□). Acciones de promoci?. Dirigidas, como su nombre lo indica, a impulsar la igualdad a trav? de incentivos como becas, exenciones tributarias, est?ulos, etc., que vinculan no s?o al sujeto, sino que generan una expectativa en favor de quien adelante la acci? deseada. La protecci? a la maternidad se encuentra en esta categor? (□) [y, finalmente] Acciones de discriminaci? inversa. Hacen parte de esta clasificaci? las medidas que establecen prerrogativas a favor de ciertos grupos hist?icamente discriminados y donde, por lo mismo, se utilizan criterios de diferenciaci? considerados como □sospechosos□ o □potencialmente discriminatorios□ (la raza, el sexo, la religi?, entre otros) o de aquellos prohibidos expresamente en los textos constitucionales. Se predica la discriminaci? inversa (tambi? llamada discriminaci? positiva), precisamente por la utilizaci? de estos criterios con car?ter definitorio en pro de quien tradicionalmente ha sido discriminado. Las medidas que favorecen el acceso a un empleo (leyes de cuotas), la promoci? en un cargo o el ingreso a centros educativos dependiendo del g?ero o de la raza, ejemplifican claramente esta modalidad de acciones afirmativas□ (subrayas fuera del original).

33. Como se trata de cargas sociales en busca de la igualdad material, las acciones afirmativas generan presiones sobre los derechos del resto de la colectividad. En este sentido, es necesario que exista una justificaci? para ese trato diferencial □ un objetivo leg?imo -, que se fundamente en la evidente exclusi? de que es v?tima el colectivo que se ver?beneficiado con tales medidas. De lo contrario, no se tratar? m? que de un privilegio sustentado en la arbitrariedad y, por lo mismo, proscrito por los principios del ordenamiento jur?ico colombiano. Este importante mandato constitucional refuerza la idea, ya tratada en

ac?ite anterior de la presente providencia, que indica porqu?se debe dar un trato especial a la situaci? de los recicladores frente al proceso licitatorio que es objeto de estudio por esta Corporaci?.

Igualmente, debe existir una relaci? entre los fines y los medios adoptados para paliar las causas de las desigualdades, pues □ por sobre todo □ las acciones afirmativas tienen que repercutir a favor del grupo social objeto de ellas y no s?o beneficiar a ciertos y privilegiados miembros de ese colectivo. Esto no significa que no puedan existir tratos diferenciales, dado que en muchas ocasiones la complejidad de la situaci? de discriminaci? as?lo requiere. Pi?sese, por ejemplo, en la posibilidad de que un mismo sujeto sea v?tima de dis?iles situaciones hist?icas de segregaci? que act?n simult?eamente afectando el goce efectivo de sus derechos fundamentales, como ser? el caso de una mujer, pobre, desplazada y recicladora. En este sentido, en el plurimencionado Auto 268 de 2010 se expuso que □(□) *Vale la pena, a modo enunciativo, mencionar que cuando quiera que se intenta determinar un grupo, siempre se acude a abstracciones y reducciones de las condiciones reales en las que sobreviven las personas, pues la sociedad siempre ser?m? compleja. As? por ejemplo, un mismo sujeto puede pertenecer a simult?eos grupos que han sido hist?icamente discriminados, como se dar? en el caso de una persona que fuera mujer, madre cabeza de familia y recicladora. Sin embargo, este hecho, que por lo dem? es ineludible en cualquier campo del conocimiento, no deslegitima la medida, ni niega su objeto o su admisibilidad, simplemente demuestra que deben ser repensadas seg? las condiciones materiales en las cuales sobreviven las personas, as? como que deben ser planeadas y ejecutadas □ en lo posible - a partir de criterios diferenciales. Esto implica, entonces, que las acciones afirmativas deben ser din?icas y concordar con la situaci? material sobre la que se quiere incidir*□.

34. Ahora bien, retomando el asunto de la afectaci? de los derechos de terceros y la diferencia de grado que pueden presentar las acciones afirmativas, es importante apuntar que en ese mismo orden ascendente □ acciones de promoci?, concientizaci? y discriminaci? inversa □ es que se considera la posible afectaci? a derechos de terceros como l?ite de las acciones afirmativas^[45]. Entonces, en el caso de las acciones de concientizaci? se tratar? de una incidencia leve, mientras que en las acciones de discriminaci? inversa versar?n sobre una afectaci? grave y por lo mismo el an?isis de su proporcionalidad y razonabilidad es m? riguroso o estricto.

35. Con todo, es claro que si el fin de estas acciones redundando en mitigar las desigualdades hist?icas, actuando sobre las causas que las generan, se suponen temporales hasta que materialicen tales objetivos. Esto conlleva dos elementos que sustentan, desde esta perspectiva, la presente providencia. Por una parte, las acciones afirmativas deben ser eficaces y - por la otra - temporales, pues una vez sea lograda la igualdad material y se haya compensado la situaci? de desigualdad, entonces habr? de desaparecer, ya que no se trata de la consolidaci? de privilegios para determinados grupos sociales. Lo contrario, redundar? en una trasgresi? a la igualdad formal, dado que si existe la posibilidad de gozar de la misma manera de los derechos, nada justifica un trato diferencial^[46].

36. En lo que respecta a su eficacia, para el asunto que convoca en esta ocasi? el pronunciamiento de la Corte Constitucional, es necesario enfatizar que las acciones positivas deben propender por promover las calidades de los miembros del grupo beneficiado de las mismas. En efecto, la Constituci?, en el art?ulo 1? enfatiza en que Colombia, como Estado Social de Derecho, se □(□) *funda en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y [en] la solidaridad* □(□). Igualmente, su art?ulo 25 contempla que □(□) *el trabajo es un derecho y una obligaci? social y [por ello] goza, en todas sus modalidades, de especial protecci? del Estado* □(□). Es as?como, en la sentencia T- 724 de 2003 se expres?que una de las actuaciones vulneradoras cometidas por la entidad demandada en ese momento redundaba precisamente

en no haber incluido ☐ () ninguna medida efectiva que permita la participaci? de la Asociaci? de Recicladores de Bogot? como grupo marginado de la sociedad, tendiente al mantenimiento y fortalecimiento de la actividad que han venido desarrollando a trav? del tiempo, como medio de subsistencia ☐ (subraya fuera del original).

37. Como se observa, la Constituci? no s?o protege el trabajo en su modalidad de subordinado, sino que ampara todas las formas leg?imas en que aqu? pueda desplegarse, lo que incluye la generaci? de empresa. Cabe recordar que a la luz del ordenamiento colombiano, existe una relaci? entre libertad individual y escogencia de profesi? u oficio. Es m?, el constituyente consagr? en el art?ulo 334 la intervenci? del Estado en la econom? precisamente para conseguir ☐ () la distribuci? de las oportunidades y los beneficios del desarrollo () ☐. Asunto que, para este caso, conforme a la providencia previamente mencionada, implica el mejoramiento de las condiciones en las que un grupo social excluido se ha desempe?ado, que ☐ por lo dem? ☐ acarrea ingentes beneficios ambientales para el resto del colectivo.

As?las cosas, las acciones afirmativas se oponen, en su esencia, a estrategias que podr?n ser catalogadas como asistencialistas. Por el contrario, buscan que se generen incentivos a las posibilidades de elecci? de las personas, distribuyendo las riquezas y los beneficios de la producci?. Son, entonces, fomentos a las potencialidades de los individuos. Es sobre lo anterior, precisamente, sobre lo que se sustenta su eficacia, que ☐ para el caso de los recicladores ☐ implica el acceso y la permanencia en el mercado, para que se promueva la competitividad social, y puedan labrar su destino conforme a la libre elecci? y a la dignidad humana. No sobra insistir que tales medidas buscan, principalmente, repercutir favorablemente en el grupo social, por lo que el incentivo ☐ am? de beneficiar al individuo ☐ debe mejorar su situaci? o ayudar a superar las causas de la exclusi?. Por ello, buenos ejemplos de estas medidas ser?n aquellas destinadas a incentivar la organizaci? del grupo social discriminado, as?como a superar situaciones de exclusi? y explotaci?.

38. Ahora bien, a pesar de que la finalidad de las acciones afirmativas es compensar una situaci? dada y *modificar el status quo* contrario a la Constituci?, esto no significa que tenga que hacerlo de manera inmediata. Como bien se dijo con anterioridad, estas medidas pueden ser progresivas, pero ☐ en todo caso ☐ eficaces. Esto implica que pueden conllevar transformaciones paulatinas.

Sin embargo, la progresividad tambi? tiene como consecuencia que las medidas adoptadas por el Estado *siempre* contemplen modificaciones de la situaci? que genera la exclusi?. Esto se observa en la orden dada por la Corte Constitucional en la sentencia T-724 de 2003, cuyo cumplimiento se analiza en esta providencia, donde se dijo a la autoridad administrativa del momento ☐ hoy remplazada en sus competencias por la UAESP - que incluyera acciones afirmativas a favor de los recicladores del distrito, ☐ () a fin de lograr condiciones reales de igualdad y de dar cumplimiento a los deberes sociales del Estado, y que por ning? motivo vuelva a reincidir en las omisiones en que incurri?/u> en la Licitaci? No. 01 de 2002, respecto de los recicladores de Bogot? () ☐ (subrayas fuera del original). Como se indic? anteriormente, tales omisiones redundaron en la ausencia de inclusi? de medidas *efectivas* que permitieran al grupo poblacional mencionado mantener y fortalecer la actividad econ?ica que leg?imamente realizaba como medio de subsistencia, pero tambi? se fund?en permitir que ☐ () el reciclaje de los materiales s?idos reutilizables quedar?en manos de los operadores del sistema () ☐.

-

39. A m? de esto, en el Auto 268 de 2010, una de las condiciones que se consideraron que atentaban contra el derecho a la igualdad del mentado colectivo, radicaba precisamente en ☐ () las condiciones laborales en las cuales realizan su trabajo, existen estudios que plantean que se trata de una poblaci? explotada. Esto, por cuanto, de los millones de d?ares que produce el negocio del reciclaje al a?, a ellos

s?o les corresponde un peque? monto. Seg? Mart? Medina, asesor del Banco Mundial en temas de residuos s?idos y de reciclaje, a los recicladores se les paga el 5% de lo que genera la industria. Esto, entre otras razones, por los monopolios de quienes compran los residuos s?idos recuperados o aprovechados bajo esta modalidad^[47]. Sumado a lo anterior, se ven expuestos a la llamada privatizaci? de la basura, dej?dolos a la suerte del mercado, ignorando el lugar tradicional que han ocupado en este proceso. En muchos de estos casos, se ha intentado removerlos de la labor que ven?n desempe?ndo, atentando contra la posibilidad de que generen ingresos por su cuenta y amenazando, por lo mismo, su subsistencia^[48] □.

-

40. Como se observa, desde hace a?s, esta Corporaci? ha llamado la atenci? al Distrito sobre la manera como ejercen su labor los recicladores de Bogot? que conlleva cr?icas a la ausencia de acceso cierto al material del cual derivan su sustento □ en raz? a la competencia con los operadores de la recolecci?- y a la falta de seguridad en la labor que acometen. Ambas situaciones conllevan entonces el mantenimiento de la explotaci? y la exclusi? de que son objeto.

-

Deberes y poderes del juez constitucional frente al principio de igualdad.

-

41. Conforme al principio de Estado Social de Derecho, todas las actuaciones que los servidores p?licos adelanten estar? sometidas a control, tanto pol?ico como judicial. Por lo mismo, el art?ulo 6? de la Carta Fundamental contempla que □ (□) *Los servidores p?licos [son responsables por infringir la Constituci? y las leyes] y por la omisi? o extralimitaci? en el ejercicio de sus funciones* □. A m? de lo anterior, resulta relevante resaltar el mandato comprendido en el art?ulo 29 de la Carta, que establece □ sin dubitaci? o excepci? alguna □ que □ *El debido proceso se aplicar?a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas* (□) □. Por ende, incluso en las actuaciones precontractuales, como lo son aquellas adelantadas en las licitaciones p?licas, los comportamientos de las autoridades p?licas se hallan sometidos a inspecci?. Esto es precisamente lo que diferencia la f?mula del Estado constitucional de una dictadura, donde el poder del pr?cipe ser? irrestricto, al carecer de regulaci? y de ?ganos que aseguran el cumplimiento de la misma.

-

No se trata entonces de una trasgresi? al principio de divisi? de poderes, sino de su propia materializaci?, dado que entre los ?ganos del Estado debe existir una colaboraci? arm?ica para alcanzar los fines del mismo. Por ello, una de las referencias que el poder constituyente efectu? en el pre?bulo de la Carta fue el aseguramiento de □ (□) *la convivencia, el trabajo, la justicia, la igualdad, el conocimiento, la libertad y la paz, dentro de un marco jur?ico, democr?ico y participativo que garantice un orden pol?ico, econ?ico y social justo* (□) □ (subrayas fuera del original). No existir? tal marco jur?ico, si las actuaciones de cualquier entidad p?lica quedaran revestidas de inmunidad al respecto. Es por eso que el art?ulo 86 de la Constituci? establece que la acci? de tutela proceder? para proteger los derechos fundamentales □ (□) *cuando quiera que ?tos resulten vulnerados o amenazados por la acci? o la omisi? de cualquier autoridad p?lica* □.

-

42. Ahora bien, trat?dose de pol?icas p?licas □ que en ocasiones se relacionan con procesos precontractuales como aquellos adelantados a trav? de las licitaciones p?licas -, quien debe adelantar todas las gestiones para que se concreten los mandatos del principio de Estado Social de Derecho son las autoridades competentes para ello, es decir □ para el caso bajo estudio □ el ejecutivo distrital.

-

En este sentido, cuando quiera que exista la obligación jurídica de incluir determinado aspecto, como lo son las acciones afirmativas, en el desarrollo de tal proceder, será la entidad mencionada la encargada de adoptar las medidas concernientes para darle efectivo cumplimiento. Sin embargo, en razón a que tal actuación se encuentra sometida a escrutinio judicial, en caso de que la autoridad administrativa competente incumpla con los mandatos constitucionales, el juez estará llamado a intervenir para precaver la vulneración o amenaza de los derechos fundamentales de las personas, más si se trata de la inobservancia de la obligación de erradicación de la pobreza, del deber de brindar posibilidades para mejorar la calidad de vida, de la obligación de no agravar las situaciones de desigualdad existentes, y de la obligación de crear prosperidad general, así como la igualdad de oportunidades para todos y todas.

-

Así las cosas, el juez constitucional debe velar porque los principios del Estado Social de Derecho se materialicen efectivamente en el quehacer de la Administración. Lo cual significa, para el asunto bajo estudio, que se obedezca el deber de incluir acciones que morigeren una situación de discriminación concreta, materializada en la exclusión y explotación de un grupo poblacional.

-

43. Ahora bien, hay que decir que, conforme con las consideraciones previamente mencionadas, los parámetros de intervención del juez en las acciones afirmativas se dan, en primer lugar, ante la ausencia de los elementos señalados con anterioridad. Es decir, la autoridad judicial deberá incidir en las medidas adoptadas por el Estado, si estas no cumplen un objetivo legítimo, no tienen como fundamento solventar una situación de discriminación de un grupo poblacional concreto, y no cumplen con la proporcionalidad y racionalidad que se predica de ellas. En otras palabras, si se trata de actuaciones estatales que, a pesar de parecer, no son realmente acciones afirmativas. Igualmente, el juez deberá analizar si son efectivas, pues se trata de una carga para el resto del conglomerado social que sólo se legitima si tiene la potencia de modificar el *status quo*.

-

44. Ahora bien, lo anterior son premisas generales a nivel constitucional. Sin embargo, para el caso que nos ocupa también existen parámetros definidos a nivel legal. En efecto, haciendo referencia a este punto, en el Auto 268 de 2010 se apuntó que ☐ (input) a pesar de que el debate en torno a la cualidad de determinada acción afirmativa puede y debe ser amplio, en el ordenamiento jurídico colombiano existen claros elementos que impelen al juez constitucional a utilizarlos, para analizar el cumplimiento de la referida orden impartida en lo concerniente a la población de recicladores de Bogotá?

☐ Así las cosas, la participación real de estos grupos es un elemento que indudablemente debe tenerse en cuenta, pues es resaltado por varias normas que regulan lo concerniente al aprovechamiento de residuos sólidos, que hace parte de la prestación del servicio público de aseo^[49]. En efecto, el artículo 9° del Decreto 1713 de 2002 ☐ modificado por el artículo 3° del Decreto 1505 de 2003 ☐ la contempla como uno de los elementos del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS), que deberá adoptar los Distritos y Municipios. Dichas disposiciones establecen que ☐ (input) en los estudios de prefactibilidad y factibilidad de alternativas para la Gestión Integral de los Residuos Sólidos, las autoridades Distritales y Municipales deberán garantizar la participación e incluso de los recicladores y del sector solidario en la formulación de dicho plan. Asimismo, el numeral 5° del artículo 67 de este Decreto ☐ modificado por el artículo 7° del Decreto 1505 de 2003 ☐ establece como un ☐ propósito fundamental ☐ de la recuperación y aprovechamiento de los materiales contenidos en los residuos sólidos, lo siguiente: ☐ (input) garantizar la participación de los recicladores y del sector solidario, en las actividades de recuperación y aprovechamiento, con el fin de consolidar productivamente estas actividades y mejorar sus condiciones de vida. Adem., el artículo 81 del mencionado Decreto ☐ también modificado por el artículo 8° del Decreto 1505 de 2003 ☐ estableció que ☐ (input) los Municipios y Distritos asegurar en la medida de lo posible la participación de los recicladores en las actividades de aprovechamiento de los residuos sólidos (input). Por

su parte, la Resolución 1045 de 2003, expedida por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, por la cual se adopta la metodología para la elaboración de los planes de gestión integral de residuos sólidos, PGIRS, y se toman otras determinaciones, establece, en el artículo 5º, que () En virtud de lo determinado en los artículos 90 y 67 del Decreto 1713 de 2002, las entidades territoriales deben asegurar la participación del sector solidario y los recicladores en los procesos de elaboración de los planes de gestión integral de residuos sólidos, PGIRS y en las actividades de recuperación y aprovechamiento definidas en estos. En concordancia con lo anterior, la Resolución 132 de 2004, por medio de la cual se adopta el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos de Bogotá D.C., expedida por el Gerente de la UAESP, se dentro de sus consideraciones generales que, conforme a las normas anteriormente reseñadas, se () deber garantizar la participación e incluso de los recicladores y del sector solidario en la formulación [del PGIRS] ().

-

45. Como se observa, de las normas mencionadas, que hacen parte del ámbito nacional y local, pueden deducirse los siguientes elementos: por una parte, resulta fundamental la participación de la población de recicladores para la formulación de los PGIRS y, por la otra, deben ser tenidos en cuenta para las actividades de recuperación y aprovechamiento, dado que estas han de ser fomentadas y su labor promovida, con el fin de consolidar su accionar económico y mejorar su calidad de vida. Adicionalmente, a nivel constitucional, las medidas que sean adoptadas, además de perseguir un objetivo legítimo, ser eficaces y temporales, deben incidir en la solución de las situaciones de discriminación que padecen determinados grupos concretos y cumplir con la proporcionalidad y racionalidad que de ellas se predica.

-

El caso concreto

-

46. Como se señaló con anterioridad, no existe en un Estado Social de Derecho ninguna actuación pública que escape al control judicial, más si se trata de comportamientos u omisiones que puedan trasgredir derechos fundamentales de grupos en condiciones marginales y de discriminación. Tal hecho es una consecuencia de la manifestación misma de la división de poderes y de la colaboración armónica entre ellos. Por esto, es un deber del juez constitucional analizar, como en este caso, si las actuaciones ordenadas en sus providencias han sido materializadas y, en el evento contrario, disponer lo necesario para su realización.

-

47. Como es obvio, la autoridad judicial debe ser cuidadosa al momento de ordenar determinados comportamientos para materializar los mandatos impartidos, en punto a no traslapar las competencias de otros órganos del poder público. En ese caso, se indicarán los parámetros desconocidos por la entidad primeramente obligada a partir de un análisis de los niveles de protección planteados por la UAESP en el pliego de condiciones de la Licitación Pública No. 001 de 2011, para que sea ella, dentro de sus poderes y deberes, quien consolide las medidas dirigidas a la preservación de los derechos fundamentales de estas personas.

-

48. Frente al caso concreto resulta oportuno hacer referencia a un estudio reciente^[50] a partir del cual se estructuran una posible tipología de incumplimiento de los fallos de la Corte Constitucional, clasificada de la siguiente manera a partir de la revisión de casos concretos: i. *El incumplimiento expreso de una orden judicial clara*; el ii. *El cumplimiento aparente o meramente formal de la orden constitucional: por el cual se promulgan o adoptan regulaciones internas por las entidades obligadas por los fallos las cuales nominalmente persiguen dar la apariencia de acatar las sentencias, pero que en realidad eluden lo ordenado*, iii. *Cohonestación del incumplimiento por parte de jueces encargados del cumplimiento de las*

sentencias de tutela y iv. los incumplimientos derivados de la indeterminaci? sem?tica de las providencias.

-

A partir de esta tipolog?, la Sala Tercera de Revisi? se propone establecer si se est?ante un cumplimiento □real□ o meramente □formal o aparente □ de las ?denes proferidas en la sentencia T-724 de 2003 y sus autos posteriores.

-

49. Para establecer dicho cumplimiento la Sala Tercera de Revisi? analizar? i. Las ?denes impartidas por la Corte Constitucional en sus diferentes providencias y c?o algunas de ellas s?o pod?n aplicarse al proceso de aprovechamiento en el componente de disposici? final. ii. Los niveles de protecci? que fueron planteados por la UAESP a partir del pliego de condiciones de la Licitaci? 001 de 2011 y si estos pueden considerarse como acciones afirmativas en favor de la poblaci? recicladora. Estos niveles son: (ii.i) participaci? accionaria de las asociaciones de segundo nivel en las sociedades concesionarias. (ii.ii) entrega de las rutas de reciclaje a la poblaci? recicladora.

-

Las ?denes impartidas por la Corte Constitucional en la sentencia T-724 de 2003 y en el Auto 268 de 2010.

50. Con el fin de establecer las ?denes cuyo cumplimiento se solicita verificar, es necesario puntualizar el marco f?tico que dio lugar tanto a la expedici? de la sentencia de tutela T-724 de 2003, como del Auto 268 de 2010.

-

51. La providencia T-724 de 2003, tuvo origen en el proceso de Licitaci? P?lica No. 001 de 2002, el cual tuvo por objeto □seleccionar para cada ?ea de servicio exclusivo -ASE- en que se ha dividido la ciudad, a la persona id?ea que en virtud del contrato de Concesi? se encargue de la prestaci? del servicio p?lico de aseo urbano, bajo el esquema de ?ea de servicio exclusivo, respecto de: a. Recolecci? y transporte (...) de los residuos generados por usuarios residenciales, peque?s productores, y de los residuos ordinarios producidos por los grandes generadores; b. Barrido y limpieza integral de v?s, ?eas y elementos que componen el amoblamiento urbano p?lico (...); y c. Corte de c?ped (...) en las ?eas verdes p?licas del Distrito Capital; as?como de las actividades adicionales de: (...) b. Realizar la recolecci? del material recuperable, mediante una ruta de recolecci? selectiva, y disponer del mismo en los Centros de Reciclaje y apoyar los programas de reciclaje que se?le el Distrito Capital a trav? de la UESP; y c. Poda de ?boles en los sitios y en la oportunidad que les indique la UESP□.

-

De manera que en ese entonces se solicit?a la Corte Constitucional, verificar si en el citado proceso de selecci?, semejante en su objeto al que ahora se aborda en esta providencia, se inclu?n acciones afirmativas en favor de la poblaci? de recicladores de la ciudad. As? la Corte concluy?que a pesar de haberse adjudicado la Licitaci? No. 001 de 2002 en la cual se verific?la no existencia de tales acciones, era necesario incluir en adelante en los procesos de selecci? para la prestaci? del servicio de aseo en sus diferentes componentes acciones positivas necesarias para eliminar o reducir las desigualdades de tipo social, cultural o econ?mico que afectaban a estos grupos, incluyendo en sus decisiones tratamientos acordes con tales situaciones, pues de no hacerse se quebrantar? el derecho a la igualdad, que impone, precisamente, la necesidad de adoptar tales medidas.

-

52. A su turno, el Auto 268 de 2010 fue proferido como consecuencia del incumplimiento de la tutela T-724 de 2003, pero esta vez: i. Dentro del marco de una licitaci? en curso, la 001 de 2010 y, ii. Respecto del servicio p?lico de aseo, pero para el componente de disposici? final de residuos s?idos, as?□(□) contratar la modalidad de concesi? Administraci?, Operaci? y Mantenimiento Integral del Relleno sanitario Do? Juana de la ciudad de Bogot? en sus componentes de disposici? final de residuos s?idos y tratamiento de lixiviados, con alternativas de tratamiento y aprovechamiento de los residuos que ingresen al RSDJ provenientes del servicio ordinario de aseo: todo lo anterior, de conformidad con los par?etros jur?icos, t?nicos y financieros contenidos en el pliego de condiciones y sus anexos□.

-

De all?que para afectos de garantizar el cumplimiento de inclusi? de acciones afirmativas en favor de los recicladores, en el proceso de selecci? del operador de disposici? final en el relleno sanitario, se orden?a a la UAESP establecer, mediante Adenda, criterios habilitantes, de calificaci? y de desempate que favorecieran a la poblaci? dedicada al reciclaje y aprovechamiento. Dentro de tales criterios, la providencia se?l? por ejemplo que: i. los proponentes se presentaran asociados con una organizaci? de segundo nivel, siguiendo en relaci? con estas los postulados se?lados por la UAESP sobre antig?dad y teniendo en cuenta los requisitos de existencia jur?ica. ii. incluir criterios de calificaci? a partir de la participaci? accionaria de la organizaci? de segundo nivel dentro del proponente as?como del porcentaje de residuos a aprovechar, haciendo especial ?fasis en la mano de obra que se requiriera dentro del proyecto de aprovechamiento.

-

53. En ese orden, debe la Corte puntualizar que unas son las acciones afirmativas gen?icas que sin excepci? deben estar presentes en todo proceso que involucre la prestaci? de los diferentes componentes del servicio p?lico de aseo y, otras las acciones afirmativas espec?icas, que depender? de las caracter? ticas intr?secas del componente de aseo sobre las cuales se materialicen.

-

54. Como se demostrar?en esta providencia, para la licitaci? p?lica No. 001 de 2011 la UAESP pretendi? estructurar un modelo id?tico al planteado por la Corte Constitucional para efectos de la administraci?, operaci? y mantenimiento integral del relleno sanitario Do? Juana, sin detenerse a evaluar que cada componente tiene una finalidad diferente, as?como una forma de operar espec?ica que impide calcar los criterios se?lados por el Auto 268 de 2010, para efectos de la recolecci? y transporte de residuos s?idos.

-

En ese orden, la disposici? de residuos en el relleno sanitario facilita en gran medida la labor de aprovechamiento, porque este componente se entrega al operador concesionario y es ?te quien asegura que el mismo se realice a trav? de recicladores vinculados a organizaciones de segundo nivel. Adem?, en el evento del relleno sanitario, la recolecci? no se encuentra dispersa por la ciudad, lo cual significa que no se compite por el material aprovechable, no existe la presi? del peso de los residuos, el ingreso al relleno sanitario es restringido a la organizaci? que se asocie al operador del servicio y la divisi? del trabajo es clara entre el operador del relleno y su socio dedicado a las labores de aprovechamiento.

-

No ocurre lo mismo en el caso del componente de recolecci? y transporte de residuos, en la medida en que no existen ?eas de servicio exclusivo para efectos del aprovechamiento, lo cual implica la abierta competencia entre recicladores formales y no formales, competencia o libertad de acci? que presenta dificultades a la hora de establecer un modelo asociativo con organizaciones de segundo nivel o a la hora de trasladar el componente de aprovechamiento a los recicladores de manera independiente a que

pertenezcan o no a estas organizaciones, como pasar? a explicarse.

-

55. Como se observa, no se trataba de copiar sistem?icamente las ?denes proferidas en el Auto 268 de 2010, pues toda acci? afirmativa debe corresponder a una situaci? espec?ica y concreta que requiere soluciones y propuestas particulares.

-

Por el contrario, los criterios a que se refiere la providencia T-724 de 2003, deben atender el contexto social, apuntar a alcanzar la igualdad material para todos y todas, as? como a formalizar la actividad del aprovechamiento como v? para alcanzar la condici? de empresarios en la cual se reconozca y promueva el conocimiento acumulado a lo largo de los a?s.

-

56. Esta consideraci? tiene especial importancia para comprender, como se ver?m? adelante, por qu?raz? el hecho de incluir acciones inspiradas de aquellas contempladas en el Auto 268 de 2010, en los pliegos de la Licitaci? P?blica No. 001 de 2011, no puede ser calificado por esta Sala de Revisi? como acciones afirmativas en favor de la poblaci? de recicladores, precisamente en raz? a que la UAESP, a m? de no lograr incidencia real en dicha poblaci?, no adecu? dichos criterios a las caracter?ticas y complejidades propias del componente de recolecci? y transporte de residuos ya no exclusivo de los operadores sino en el marco de la libre competencia.

-

57. As? a *grosso modo* y en el marco de la providencia T-724 de 2003, se enuncian a continuaci? los criterios gen?icos que la UAESP debi? haber tenido en cuenta para abordar la problem?ica de los recicladores en el distrito en relaci? con los componentes de recolecci? y transporte de residuos:

-

(i) Las medidas adoptadas deben ser progresivas, lo cual implica que deben incidir paulatinamente en el mejoramiento de la situaci? que padece el grupo marginado mencionado, de manera que deben conllevar cambios frente al *status quo*. As? las acciones afirmativas deben adecuarse a las circunstancias del caso, pues no se trata de f?mulas p?reas que no tengan la potencia de incidir en las condiciones que se pretenden cambiar.

-

(ii) Como quiera que toda acci? afirmativa resulta temporal, debe tener la potencia de generar avances para alcanzar la igualdad real y efectiva. Por lo mismo, el asistencialismo se opone a la esencia de este tipo de medidas que se desprenden del deber de alcanzar la igualdad material y el goce efectivo de los derechos para todos y todas. En ese orden, es posible que como resultado de una pol?ica p?blica se incluyan medidas asistencialistas dirigidas a esta poblaci?, aspecto que es bienvenido, pero tales medidas no pueden reemplazar acciones afirmativas destinadas a alcanzar la igualdad material. As? las cosas, la Corte no censura acciones asistencialistas dentro del Estado Social de Derecho, pero enfatiza que no son estas el objeto de las acciones afirmativas.

-

(iii) Resulta esencial determinar el grupo que se ver? beneficiado por las acciones afirmativas, en la medida que ello facilita el seguimiento de las medidas as? como su efectividad. De igual manera impide que tales beneficios sean percibidos por personas ajenas al grupo objeto de protecci?.

-

(iv) En este sentido, la acci? afirmativa debe propender por favorecer al colectivo espec?ico, raz? por la cual no debe estar destinada al beneficio de una peque? ?ite. Dicho colectivo espec?ico no necesariamente tiene que estar determinado en todos y cada uno de sus miembros, pues en ocasiones basta que lo sea en los elementos esenciales que lo definen para permitir dise?r con claridad la acci? afirmativa.

-

(v) Resulta fundamental la participaci? material de los recicladores en las actividades de recuperaci? y aprovechamiento de residuos, no s?o como trabajadores sino como empresarios de las basuras, en que puedan emplear los conocimientos que han adquirido a lo largo de los a?s y capitalizar los beneficios ambientales que para la ciudad representa su actividad.

-

(vi) Resulta esencial el acceso seguro y cierto a los residuos s?idos potencialmente aprovechables y, de ser posible, otorgar valor agregado a esta actividad de la cual derivan su sustento, con el fin de fomentar la labor y consolidar su accionar econ?ico, mejorando su calidad de vida.

-

(vii) Adem?, las acciones deben propender por beneficiar formas asociativas de los recicladores, no como fin en s?mismo, sino como medio para superar las condiciones de explotaci? y marginaci? que padecen tendiente a su regularizaci?, as?como para prestar de manera organizada servicios complementarios de aseo en calidad de □ otros prestadores□.

-

(viii) Igualmente, a nivel constitucional, las medidas que sean adoptadas, adem? de perseguir un objetivo leg?imo, deben ser eficaces y temporales, deben incidir en la soluci? de las situaciones de discriminaci? que sufren determinados grupos concretos y cumplir con la proporcionalidad y racionalidad que de ellas se predica, pues se trata de acciones que sin duda generan impactos en el resto de la sociedad.

-

58. Los elementos citados en el numeral anterior, se constituyen en el par?etro a tener en cuenta por la Corte al momento de resolver en concreto la cuesti? relativa a la inclusi? de acciones afirmativas en favor de los recicladores en la Licitaci? P?lica 001 de 2011. En ese orden, la Sala de Revisi? pasar?a continuaci? a realizar el estudio correspondiente a partir de lo previsto en el mencionado pliego y sus respectivas modificaciones.

-

Niveles de protecci? planteados por la UAESP en el pliego de condiciones de la licitaci? p?lica 001 de 2011.

-

59. Para iniciar este ac?ite de la providencia se debe precisar que el objeto de la licitaci? p?lica 002 de 2011, es:

-

□(□) *concesionar bajo la figura de ?ea de Servicio Exclusivo, la prestaci? del servicio p?lico*

domiciliario de aseo en la ciudad de Bogotá D.C. □ Colombia, en sus componentes de recolección, barrido, limpieza de vías y áreas públicas, corte de césped, poda de árboles en áreas públicas y transporte de los residuos al sitio de disposición final y todas las actividades de orden financiero, comercial, técnico, operativo, educativo y administrativo que ello conlleva

La presente licitación no contempla exclusividad para las actividades de recolección y transporte de material reciclable que sea presentado en forma separada por los generadores, ni tampoco contempla exclusividad alguna para las actividades de aprovechamiento.

En forma paralela a la búsqueda de operadores para las actividades del objeto de la presente licitación, la UAESP promoverá la conformación de esquemas empresariales constituidos por las organizaciones de recicladores, acorde con lo mandado por la Ley 142 de 1994, buscando la articulación del reciclaje y el aprovechamiento en general, con el servicio público de aseo y con la regulación vigente □ (AZI, Folio 8)

En este orden de ideas, el pliego plantea que: 1. La recolección y transporte de residuos no separados estarían circunscrita a las áreas de servicio exclusivo que sean adjudicadas y que este servicio sería prestado por los operadores que resulten concesionarios de tales áreas. 2. Las actividades de recolección y transporte de material aprovechable que se presente en forma separada por los generadores no estaría sujeta a exclusividad, por lo cual se desarrollaría bajo el esquema de libre competencia, quedando la operación de este servicio en cabeza de la población recicladora.

60. Es así como a partir de lo previsto en el pliego de condiciones correspondiente a la Licitación Pública No. 001 de 2011, es posible identificar dos medidas estructurales, copiadas del esquema previsto en el Auto 268 de 2010, que bajo el entendimiento de la UAESP se estiman acciones afirmativas en favor de la población recicladora.

60.1 La primera tiene que ver con la adopción de un modelo de participación accionaria de las organizaciones de segundo nivel, a partir de la constitución de sociedades con los oferentes que resulten adjudicatarios de la licitación pública, que se concretaría mediante un aporte de industria. Para este componente el pliego otorga un puntaje hasta de 100 puntos, de manera que a mayor participación accionaria, mayor puntaje. Este es por lo menos uno de los ejes centrales del pliego de condiciones en lo que tiene que ver con las medidas positivas que la licitación concibió para los recicladores.

60.2 La segunda contempla que la recolección y transporte de material potencialmente aprovechable que sea entregado en forma separada por los generadores, estaría a cargo de los recicladores de oficio ubicados en cada ASE, quienes continuarían ejerciendo su actividad en las zonas que habitualmente lo hacen, independientemente de la participación accionaria que corresponda a la asociación de recicladores de segundo nivel a la cual pertenezcan. De esta forma el material que recojan lo podrán comercializar en las bodegas que escojan y el valor de la transacción será de su propiedad.

Para el efecto, se ordena a los proponentes presentar un plan de trabajo destinado a las actividades de fortalecimiento y formalización de la recolección de material aprovechable por parte de los recicladores de

base, así como ofrecer dotación de uniformes y vehículos de tracción humana. Entre mayor cobertura de rutas ofrezcan los oferentes por parte de los recicladores, más puntaje obtienen de un total de 50 puntos.

-

61. Estas medidas permiten advertir a primera vista que podrá existir una variación del *status quo*, por lo menos nominal, respecto de la condición tradicional de los recicladores, en la medida en que impulsa la constitución de organizaciones de segundo nivel que representan sus intereses y porque se les reconoce como titulares de las actividades de recolección y transporte de residuos aprovechables presentados en forma separada por los generadores. Sin embargo, es en este momento en el cual adquieren relevancia todas las disquisiciones técnicas y jurisprudenciales que se han realizado en ocasiones anteriores de esta providencia, específicamente cuando se habla del Estado social de Derecho y el principio de igualdad frente a sujetos de especial protección constitucional, sobre los sujetos de especial protección, sobre los mandatos de acción y de abstención y sobre los deberes y poderes del juez constitucional frente al principio de igualdad, pues son los conceptos allí plasmados los que guían la interpretación del caso concreto para determinar si el proceso licitatorio analizado contempla o no medidas reales y eficientes de discriminación positiva frente a la población recicladora.

-

La pregunta que surge entonces es si estas acciones nominales tienen entidad material, es decir, si en la práctica resultan eficaces y cumplen con los parámetros técnicos que definen las acciones afirmativas. Para el efecto, pasa la Sala a revisar cada una de estas medidas a la luz del pliego de condiciones.

-

El pliego de condiciones y el primer nivel de protección planteado por la UAESP: Garantizar la participación o cesión del patrimonio de los proponentes que resulten adjudicatarios a favor de organizaciones de recicladores de segundo nivel.

-

62. Del contenido del pliego de condiciones de la licitación pública 001 de 2011, pueden extractarse los siguientes elementos:

-

(i) Podrá participar en la licitación ☐ () personas naturales o jurídicas interesadas en constituir una promesa de sociedad futura bajo la modalidad de empresa de servicios públicos de objeto único, conjuntamente con una organización de recicladores de segundo nivel, de las seleccionadas previamente por la UAESP ☐ ☐ () Igualmente[,] consorcios o uniones temporales de empresas de servicios públicos que prometan emitir o ceder una participación en su patrimonio por un porcentaje igual o mayor al 5% a favor de las organizaciones de recicladores que resulten favorecidas en la selección del ASE correspondiente, de acciones de industria ☐ ☐. También podrá hacerlo empresas de servicios públicos ya constituidas que prometan emitir o ceder una participación en su patrimonio por un porcentaje igual o mayor al 5% a favor de las [mismas] ☐ ☐ (AZ 1, folio 5, respaldo).

-

(ii.) Como requisito de admisibilidad de la propuesta, el Pliego de Condiciones estableció la obligación de los futuros concesionarios de participar con ☐ () al menos dos (2) integrantes de la sociedad por acciones (...) [que sean] una organización de recicladores de segundo nivel de la ciudad de Bogotá/ i> (AZ 1, folio 43).



(iii.) Frente a estas organizaciones, el adjudicatario adquiere la obligaci? de ceder una participaci? en su patrimonio en un porcentaje $\square(\square)$ que no podr?ser inferior al 5% de la sociedad, para las dos organizaciones asignadas en cada ASE ($\square$) $\square$ (AZ 1, folio 43, respaldo), representado en acciones de industria.

-

(iv.) La participaci? de las organizaciones de segundo nivel est?sujeta a las siguientes condiciones: $\square(\square)$) recibir utilidades por lo menos una vez por a?; A participar porcentualmente del mayor valor de la empresa al momento de su liquidaci?; El porcentaje de participaci? ofrecido a la organizaci? de recicladores no podr?ser modificado durante todo el periodo de duraci? de la concesi?; [y] La organizaci? de recicladores de segundo nivel no podr?vender ni ceder, a ning? t?ulo ni en ning? momento, durante la ejecuci? del contrato de concesi? su participaci? accionaria $\square$ (AZ 1, folio 43, respaldo).

-

(v.) En relaci? con dicha participaci? accionaria se otorga un puntaje de 100 puntos de un total de 1000 posibles a la cesi? de la participaci? accionaria de las organizaciones de segundo nivel (AZ 1, folio 54). Igualmente, el pliego agrega que $\square(\square)$ el mayor puntaje, es decir 100 puntos, se asignar? **a la propuesta cuya organizaci? de segundo nivel posea el mayor porcentaje de participaci? en la forma asociativa** propuesta por el oferente. A las dem? se les aplicar?una regla de tres simple directa $\square$ (AZ 1, folio 55) (Resaltado fuera de texto).

-

(vi) El pliego toma como uno de los criterios de desempate, tras la selecci? de aquella propuesta que haya obtenido mayor puntaje en la oferta econ?ica, el criterio de participaci? accionaria de las organizaciones de segundo nivel, de la siguiente manera: se $\square(\square)$ preferir?[a qui?] haya obtenido el mayor puntaje en el componente de participaci? accionaria para la organizaci? de recicladores de segundo nivel $\square$ (AZ 1, folio 57, respaldo).

-

(vii) Por su parte, el anexo 21 de los pliegos establece las condiciones de participaci? de las organizaciones de segundo nivel a partir de un modelo en el cual se permite a las asociaciones de mayor antig?dad escoger el ?ea de su preferencia (AZ 1, folio 60). De esta forma, en caso de ser m? de 6, las siguientes organizaciones deben someterse al alea de un sorteo hasta que todas aquellas que est? habilitadas sean asignadas (AZ 1, folio 61).

-

(viii) En el referido Anexo, se estableci?que $\square$ En caso de que por cualquier motivo, la organizaci? de recicladores de segundo nivel o una agrupaci? de estas (sic)($\square$) decida(n) no aceptar la cesi? de la participaci? accionaria por parte del concesionario correspondiente a dicha ASE o tuviese cualquier impedimento legal para ello, ?te (sic) concesionario deber?construir la sociedad en los t?minos de su propuesta y ceder dicha participaci? a otra de las organizaciones de segundo nivel habilitadas en el proceso $\square$ (AZ 1, folio 60).

Y

(ix) En el evento en que dos (2) o m? organizaciones fueran asignadas a la misma ASE, $\square(\square)$ el porcentaje de participaci? accionaria ofrecido por el proponente que resulte adjudicatario ($\square$) ser? dividido en partes iguales $\square$ (AZ 1, folio 60, respaldo; y AZ 2, Folio 34).

-

(x) Finalmente, se indica en este anexo que **la recolección de material** potencialmente aprovechable ☐ (☐) estar a cargo de los recicladores de oficio ubicados en cada ASE, quienes continuar ejerciendo su actividad en los territorios que actualmente lo hacen, independientemente de la participación accionaria que corresponda a la asociación de recicladores de segundo nivel a la que pertenezcan (☐) (AZ 1, folio 60, respaldo). Esto evidencia que la recolección de material no está físicamente en cabeza de las organizaciones de segundo nivel, sino a cargo de los recicladores de oficio.

63. Identificados estos elementos se analizar la naturaleza de la cesión de participación accionaria propuesta, para lo cual se revisará: a. La naturaleza jurídica de las organizaciones de segundo nivel y su característica de carecer de ánimo de lucro así como el mecanismo de reinversión de sus ganancias o utilidades. b. La definición del aporte de industria y c. Sobre a partir de tales conceptos, la participación accionaria ordenada en los pliegos de condiciones de la licitación pública 001 de 2011, existe o no una acción positiva en favor de los recicladores de base.

Naturaleza jurídica de las asociaciones de segundo nivel y el mecanismo de reinversión de sus ganancias.

64. Las organizaciones de segundo nivel son aquellas que coaligan a asociaciones de base, conformadas por recicladores de oficio. Estas organizaciones bien pueden responder al esquema de organizaciones de economía solidaria previstas en la Ley 454 de 1998, entre las cuales se encuentran los organismos de segundo y tercer grado que agrupen formas asociativas y solidarias, sin ánimo de lucro^[51], en las cuales sus afiliados son simultáneamente aportantes y gestores o corresponder a simples formas asociativas civiles también sin ánimo de lucro.

65. En su calidad de corporaciones o asociaciones de naturaleza civil sin ánimo de lucro, persiguen una utilidad común dirigida a un grupo específico de la comunidad, en este caso los recicladores del Distrito. A la luz de la jurisprudencia constitucional, los incentivos o apoyos que estas asociaciones reciban -y esto aplica tanto para las de base como para las de segundo nivel- deben servir para mejorar las condiciones del grupo poblacional objeto de la acción afirmativa.

66. Dada la ausencia de animus lucrandi, no se contempla la posibilidad jurídica de reparto de utilidades en favor de personas naturales o sociedades que la integran, de forma que los rendimientos alcanzados por el ejercicio de su objeto social se denominan excedentes o beneficios, los cuales deben permanecer dentro de la entidad para el desarrollo del objeto social o beneficio común^[52].

Lo anterior no significa que las organizaciones de segundo nivel no puedan realizar actividades per se lucrativas, como las puramente mercantiles, en aras de la conservación e incremento de su patrimonio, pero dichas actuaciones deben estar afectas a la finalidad para la cual fue constituida según sus estatutos. Esto implica, conforme a los artículos 633 a 637 del Código Civil, que estas asociaciones pueden perseguir ganancias para reinvertirlas, pero no para distribuir las entre sus asociados, sin perjuicio de que se traduzcan en beneficios para los afiliados a partir de los cuales se faciliten y mejoren las actividades de los recicladores de base.

El aporte de industria.

-

67. Ahora bien, la estructura del pliego de condiciones supone de parte de las organizaciones de segundo nivel un aporte de industria a la sociedad prestadora de servicios p^ulicos que se conforme con ocasi^on de la adjudicaci^on de ASE^os, aporte que les otorgar^e el derecho a recibir una participaci^on accionaria. Ello guarda relaci^on con el art^oculo 98 del C^odigo de Comercio, seg^un el cual el contrato de sociedad requiere un aporte que puede ser en dinero, en trabajo o en otros bienes apreciables en dinero. Asⁱ en t^{er}minos del art^oculo 137 del mismo estatuto, puede ser objeto de aportaci^on la industria o trabajo personal del asociado, sin que tal aporte forme parte necesariamente del capital social. En otras palabras, no puede conformarse una sociedad sin que se materialice aporte por parte de sus integrantes.

-

68. Los aportes del socio industrial representan prestaciones consistentes en una actividad personal, conocimientos tecnol^ogicos, asistencia t^ecnica y, en general cualquier obligaci^on cierta de hacer, por concepto de la cual el aportante adquiere una contraprestaci^on que se materializa en la participaci^on de las utilidades sociales estipuladas en el contrato de sociedad.

-

69. De lo anterior se concluye que el aporte de industria, que bien puede ser realizado por una persona natural como por una persona jur^{id}ica, debe concurrir efectiva e invariablemente para efectos de asegurar la constituci^on de una sociedad. Este aporte asegura la participaci^on accionaria que se recibe en el contrato de sociedad en calidad de contraprestaci^on, pues de lo contrario, de no existir una obligaci^on de hacer que pueda calificarse como aporte de industria, se estar^e frente a una defraudaci^on al patrimonio social y a un enriquecimiento sin causa por parte del socio de industria que participa de las utilidades sociales, en la medida que este aporte debe amortizarse con cargo a la cuenta de p^{er}didas y ganancias de cada ejercicio social, en la parte proporcional que al socio de industria corresponda, en t^{er}minos del art^oculo 139 del C^odigo de Comercio.

-

A pesar de que algunos intervinientes consideraron que el hecho de asociarse con asociaciones de segundo nivel de recicladores como socios de industria supone que ^las aportan una concreta obligaci^on de hacer consistente en su conocimiento del negocio, lo cierto es que el esquema planteado no puede llevar a tal conclusi^on. Lo anterior porque, de una parte, la m^odima forma en la que podr^en participar en la toma de decisiones al interior de la sociedad las mentadas asociaciones, impide que su trabajo sea elemento esencial al aporte de industria. De la otra, porque, como se ver^e la variante del aprovechamiento del material reciclable, al estar en esquema de libre competencia por recicladores de oficio que no necesariamente pertenecen a la asociaci^on de segundo nivel, impide que los socios de industria puedan verter su conocimiento en el proceso de selecci^on de basuras, puesto que no tienen ni los recicladores a quienes transmitirlo ni, en caso de que lo anterior llegare a ocurrir, los mecanismos jur^{id}icos que permitan que su conocimiento sea de utilidad. Es decir, aunque dichas asociaciones pueden contar con un know how, el esquema en que est^e planteada su participaci^on le impide su aplicaci^on.

-

An^olisis de la cesi^on de participaci^on accionaria ordenada en los pliegos de condiciones de la licitaci^on p^ublica 001 de 2011 como acci^on afirmativa en favor de los recicladores de base.

-

70. A prop^osito de lo se^ulado en los numerales anteriores y descendiendo al caso concreto, esta Sala de Revisi^on evidencia la omisi^on en los pliegos de condiciones de elementos sustanciales que aseguren la

eficacia de esta medida frente a la población? materia de protección?, sin los cuales no es posible aseverar que se está ante una acción afirmativa material en favor de la población? recicladora. Así lo que podrá entenderse como una acción afirmativa formal no lo es en la práctica, por las siguientes razones: __

71. El primer elemento que se extrae en los pliegos es que no se define en qué consiste el aporte de industria que deben realizar las organizaciones de recicladores de segundo nivel. Aporte que, en todo caso, no es el aprovechamiento en la medida que la recolección y el transporte de material aprovechable que se presente separado por los generadores, ser realizado directamente por los recicladores de oficio de manera independiente a su afiliación a las organizaciones de segundo nivel.

71.1. Este aspecto se confirma no sólo por lo expresado en el pliego, sino que se infiere con claridad de las diferentes respuestas de los proponentes a la pregunta expresa de ¿cuál es el aporte de industria?, como se puede observar en el siguiente cuadro:

OFERENTE	EN TÉRMINOS DEL PLIEGO DE CONDICIONES CUÁL ES EL APOORTE DE INDUSTRIA DE LAS ORGANIZACIONES DE SEGUNDO NIVEL.
UNION TEMPORAL CAVO VIGIA.	Explica que el aporte de industria de los recicladores contemplado en el pliego de condiciones de la licitación en comento, a su juicio consiste en que ☐ los recicladores desarrollar parte del trabajo correspondiente a la prestación del servicio, específicamente aquel que tenga referencia con la recolección y aprovechamiento de los residuos susceptibles de aprovechamiento ☐ (AZ 5, folio 316).
ATESA	☐ la UAESP fue clara y reiterativa en señalar que el aporte de industria al que las condiciones del pliego hacen (sic) referencia, NO son cuantificables y que corresponden por tanto a las que trata el artículo 137 en concordancia con el artículo 380 del Código de Comercio ☐ (mayúsculas y negrillas tomadas del texto original) (AZ 5, folio 296). Aclaró que ☐ las actividades que componen el aprovechamiento, conforme a las condiciones de la licitación, serán realizadas y usufructuadas en su totalidad por los recicladores de oficio por conducto de las asociaciones a la cual (sic) pertenezcan y por tal concepto los operadores no recibiremos utilidades, no tenemos proyecciones de las mismas ☐ (AZ 5, folio 298).
Promesa de Sociedad Futura ASEO Bogotá (AZ 2, folio 236 a 237)	☐ las asociaciones de recicladores no harán aporte alguno como socios o accionistas industriales, hasta el punto que ni siquiera cancelar los costos de la emisión de sus acciones de industria que, en nuestro caso, será el cien por ciento (100%) de las que se emitan exclusivamente para dichas asociaciones ☐ (AZ 5, folio 305).
Promesa de Sociedad Futura IPSUM (AZ 2, folio 254 a 265)	Adujo que el aporte de industria es fruto de las obligaciones contempladas en el Auto 268 de 2010 y que corresponde ☐ a una estimación anticipada ☐ de su aporte en trabajo ☐ (AZ 5, folio 178). Luego, expresó que el aporte ☐ consistirá en la prestación de su fuerza de trabajo, así como de sus conocimientos técnicos para el desarrollo del objeto de la sociedad que se constituya, en particular respecto de su conocimiento y experiencia relacionados con el reciclaje ☐ (AZ 5, folio 179).

Consortio CONAMBIENTALES y Unifon Temporal ASEO Triple A (AZ 2, folio 266 a 268)	Recordando que existen dos tipos de socios: de capital y de industria. Aclarando que las acciones de industria est? ☐ (☐) previstas en los art?culos 137 y 138 del C?digo de Comercio, es decir ☐ (☐) sin estimaci? de su valor, por lo cual no redimen o liberan cuotas de capital social, aunque conceden derecho a participar en las utilidades sociales ☐ (AZ 5, folio 188). No responde en qu? consiste el aporte de industria de la poblaci? recicladora.
Proponente Plural conformado por Ciudad Limpia Bogot? y otros (AZ 2, folio 269 a 299)	Enfatizando que tiene dudas en torno al aporte industrial de los recicladores, dado que se generaron cuestiones nebulosas en el pliego de condiciones de la licitaci?. En efecto, conforme establece el Anexo 21, la recolecci? para el aprovechamiento seguir? a cargo de los recicladores que tradicionalmente est? trabajando en el ASE respectivo. Por lo tanto, tal actividad ☐ (☐) no estar? a cargo de su socio industrial (asociaci? de segundo nivel), sino de los recicladores de oficio ubicados en dicha ASE. Esto genera una confusi? de caracter l?gico y jur?dico con respecto a la identidad y el real aporte de nuestros posibles socios industriales, de los cuales se debe esperar una contraprestaci? en su calidad de socios, como lo establece el art?culo 380 del C?digo de Comercio (☐) ☐ (AZ 5, folio 207).
Promesa de Sociedad Futura Bogot? Ambiental S.A. E.S.P (AZ 2, folio 306 a 315)	Adujo que ni en el pliego de condiciones ni en las dem? etapas de la licitaci? se aclar? en qu? consiste el aporte de trabajo que efectuar? los recicladores en su condici? de socios de industria.
Consortio Lime (AZ 4, folio 5 a 18)	El aporte de industria ☐ (...) consiste en una prestaci? de hacer, referida a la labor que en materia de reciclaje realizar? dichas organizaciones por conducto de sus miembros ☐ (AZ 5, folio 272).
Promesa de Sociedad Futura ☐ Promoambiental Distrito S.A.S. ESP (AZ 4, folio 39 a 43)	El aporte industrial de los recicladores consiste en ☐ (☐) colocar su experiencia y conocimiento al servicio del componente de aprovechamiento, que es parte integral de la prestaci? del servicio p?blico de aseo (☐) ☐ (AZ 5, folio 160).
Promesa de Sociedad Futura RBL Bogot?DC (AZ 4, folio 106 a 146)	Afirmando que ☐ (☐) el aporte que como socios de industria efectuar? las organizaciones de recicladores de segundo nivel en la empresa de servicios p?blicos (☐) est? representado por el servicio de recolecci? del material potencialmente aprovechable (actividad de reciclaje) y por el trabajo que ejecuten como personal a cargo de las labores de recolecci?, barrido mec?nico, barrido manual, limpieza, lavado, corte de c?ped y poda de ?boles, para las cuales ser? vinculados (sic) como mano de obra ☐ (AZ 5, folio 284).
Aseo Capital, Unifon Temporal (AZ 4, folio 147 ☐ 155)	Con respecto al aporte de industria, trajo a colaci? una respuesta de la UAESP que absolvi? dudas en lo tocante a este tema. As? seg? el proponente, la entidad se?al? que ☐ las acciones industriales representan el trabajo de la organizaci? de segundo nivel que se encargar? de hacer seguimiento, control, vigilancia, coordinaci?, educaci? e interlocuci? con los recicladores que de manera individual y aut?noma se dedique (sic) a las labores de reciclaje dentro de la ASE correspondiente ☐ (AZ 5, folio 247). Por lo tanto, estas asociaciones no tendr? por actividad el reciclaje, a pesar de relacionarse con personas que lo ejerzan.
Promesa de Sociedad Futura Desarrollo Limpio S.A. ESP (AZ 5,	Expresando frente al aporte de industria de los recicladores que ☐ (☐) no tendr? que llevar a cabo ninguna actividad adicional a la suscripci? de las acciones

folio 223 a 235)	para hacerse propietarios de las mismas (AZ 5, folio 231).
------------------	--

71.2 Así las cosas, se observan al menos cuatro posiciones dispares y contradictorias en torno a lo que se concibe por aporte de industria: i. Algunos oferentes indican que las organizaciones de segundo nivel están a cargo del aprovechamiento que se realice en el ASE respectiva, a pesar de que los pliegos asignan esta labor de manera directa a los recicladores de oficio. ii. Otros afirman de manera directa que tales asociaciones no llevarán a cabo ningún tipo de trabajo, con lo cual se contravienen abiertamente las disposiciones relativas a la conformación de sociedades comerciales, así como los criterios de la jurisprudencia constitucional que señalan claramente que debe incentivarse el trabajo material de los recicladores. iii. Una tercera opinión afirma que no comprende en qué consiste el aporte de industria y, iv. Finalmente, un grupo afirma que el aporte de industria es la obligación de ejercer cualquier actividad que haga parte del objeto de la concesión, como la coordinación de las actividades de los recicladores de oficio que el pliego radica expresamente en cabeza del concesionario o el desarrollo de actividades tales como el corte de césped o la poda de árboles.

71.3 En suma, las consideraciones expuestas no pueden conducir sino a la conclusión de que las organizaciones de segundo nivel reciben participación accionaria y posibles utilidades sin que exista de por medio un verdadero aporte, esto es una definida obligación de hacer, aspecto que insinúa un enriquecimiento sin causa o por lo menos injustificado de las organizaciones de segundo nivel, lo cual resulta irrazonable y desproporcionado, además de que contraviene el sentido de las acciones afirmativas, que redundan en que los beneficios para estas organizaciones sirvan como un medio para alcanzar la igualdad real y efectiva y la dignificación de su trabajo.

72. El segundo elemento que reafirma la conclusión de que no se está frente a una acción afirmativa material, tiene que ver con la indefinición en los pliegos respecto de cuál debe ser el destino que se da a las utilidades que puedan llegar a ser percibidas por las organizaciones de segundo nivel, en caso de producirse.

72.1 Como se señaló en párrafos anteriores, al no ser repartidos los beneficios, estos deben ser reinvertidos en el desarrollo del objeto social de estas organizaciones. En ese orden, son sus directivas quienes deciden en qué se invierten los recursos y en qué porcentajes, de acuerdo con los límites señalados por la finalidad social, lo cual deja al arbitrio de dichas directivas la destinación final de tales ingresos.

72.2 Así por ejemplo, de acuerdo con los estatutos de la Confederación Ambiental Hagamos de Colombia un país grande (Confederación Ambiental FUNCOLGRAN), esta organización es () una entidad sin ánimo de lucro () cuya función principal es la de agrupar a las organizaciones, cooperativas y asociaciones de Recicladores () sus bienes serán repartidos entre cada una de las organizaciones teniendo en cuenta que el 60% de estos () pasarán a Organizaciones ambientales que manejen niños y ancianos () y [el] 40% [a] Organizaciones sociales ambientales legalmente constituidas y con reconocimiento de la autoridad ambiental () (AZ 2, folio 426), de manera que en los términos de sus estatutos las posibles ganancias no estarán dirigidas a promover el proceso de formalización de los recicladores de base o a realizar actividades directamente desarrolladas con la labor de aprovechamiento, sino que podrán utilizarse en actividades que no guardan relación directa con la labor que ejecuta la población de recicladores.

72.3 Otro caso práctico que ilustra la complejidad de omitir la destinación de posibles beneficios derivados de la participación accionaria, es el que tiene que ver con los estatutos de la Federación Sindical Ambiental del Reciclador Colombiano, FEDERSIN. Como objeto de la organización -definida como de segundo nivel- figura ☐ (☐) la integración de los Sindicatos cuyos trabajadores en su ejercicio laboral, defienden el medio ambiente, los recursos naturales y con su actuar, se disminuye la contaminación, (sic) en las fuentes hídricas, la polución del aire y trabajan en la cadena del reciclaje descontaminando los residuos sólidos para que no vayan a los rellenos sanitarios, recuperando típicamente productos industriales ☐ (AZ 2, folio 384). Esta amplitud permite a sus directivas reinvertir en actividades propias del aprovechamiento o en cualquier otra actividad que tenga que ver con la protección del medio ambiente y que no guarde relación alguna con la selección, tratamiento y aprovechamiento de los residuos.

-

72.4 Estos dos casos enunciados son apenas ejemplos de cómo no se asegura que los posibles beneficios cumplan con el objetivo de regularizar a la población recicladora en la prestación de servicios complementarios al servicio público de aseo. En conclusión, esta Corporación no puede aceptar que la entrega de dinero -revestida de una aparente potencialidad de acción afirmativa y en todo caso eventual- sea conferida sin contraprestación de las organizaciones de recicladores de segundo nivel y no responda a una lógica destinada a la producción de beneficios directos a los recicladores de base.

-

73. Un tercer elemento que reafirma el hecho de que la participación accionaria tal como está concebida en el pliego no representa una acción afirmativa, es que este esquema vulnera abiertamente el derecho a la igualdad entre los proponentes y las asociaciones de segundo nivel, en la medida que las utilidades a percibir no serán iguales para todos los operadores e incluso pueden llegar a ser inexistentes o por lo menos no se percibirán en los mismos tiempos y en idénticos porcentajes. Al respecto, vale la pena citar la respuesta dada por la Contraloría General de la República al Auto 240 de 2011, en relación con los mencionados porcentajes de participación accionaria:

-

☐ (☐) Una vez analizados los parámetros de evaluación financiera contenidos en el proceso de la licitación pública número 001 de 2011, y en particular la manera como se establece el equilibrio financiero de las distintas propuestas que contemplan participación del 50% de las ganancias, la Contraloría General considera que podrán cumplir con los requerimientos establecidos por los términos de referencia de la licitación, en lo que concierne a la rentabilidad real del 13% y un componente de inflación del 3.8% para los ocho (8) de ejecución del proyecto ☐ ☐.

-

Con todo, conviene precisar que la rentabilidad mencionada está determinada por el monto de la inversión inicial, en tanto que la utilidad, a la que se refiere la participación de los recicladores, corresponde al balance anual de ingresos, costos y gastos de operación. **Por consiguiente, es posible que hayan bajas utilidades anuales, e incluso pérdidas, compatibles con rentabilidades normales del proyecto.**

-

Por estas razones, será posible considerar la asignación de una participación en las utilidades igual o mayor al 50% de las ganancias a las asociaciones de recicladores de segundo nivel, reduciendo la base del resultado anual (ingresos y gastos) a distribuir en los siguientes escenarios:

-

(i) Subfacturación de los ingresos efectivamente percibidos por los negocios que conforman la cadena del servicio contratado en forma individual o conjunta[,] de manera ☐ que lo que se lleve por utilidades por distribuir sea previamente disminuido.

-

No obstante, este escenario tendrá una viabilidad restringida, en la medida en que para el caso que nos ocupa, existe un buen nivel de control para evitar esta subfacturación, dada la existencia de la

metodolog? tarifar?, un mecanismo financiero (fiducia) que administra los recursos, una interventor? financiera y la existencia de un Sistema Integrado de Informaci? del Servicio de Aseo (SIISA).

(ii) Sobredimensionamiento de los costos de producci?, para el caso de proponentes nuevos, a trav? de autoabastecimiento en las distintas fases de la cadena contratada, las cuales podr?n ser convenidas con empresas del grupo concesionario, reduciendo la utilidad a distribuir: En este caso es necesario contemplar como aspectos cr?icos las fases de recolecci?, barrido, transporte y disposici? final y, en cuanto a los gastos de funcionamiento, la posibilidad de tercerizaci?, as? como la inversi? en sistematizaci? (software y (hardware), actividades realizadas a trav? de empresas del mismo grupo, m? all? del normal marco general de las econom?s a escala.

(iii) Caso de proponentes que ya son concesionarios y por consiguiente tienen ☐ base de operaci? instalada ☐ y Know how. En este evento, y teniendo en cuenta que los proponentes ya ven?n prestando el servicio, puede concluirse que sus condiciones financieras son favorables, desde el primer momento, puesto que tienen rentabilidades plenas, **toda vez que ya han amortizado la inversi? inicial, ventaja que ser? adicional a la situaci? descrita en el escenario (ii)** (resaltado fuera del original).

(iv) Cuando las asociaciones de recicladores participan patrimonialmente con acciones industriales, como lo prev? el pliego, se tendr? la situaci? en que se remunera el inter? minoritario como remuneraci? a su aporte de capital.

(v) Una combinaci? de algunos de los anteriores escenarios.

En los anteriores t?minos se advierte que el proceso de selecci? que nos ocupa, **contiene elementos financieros objetivos que ocasionan la posibilidad de que los distintos proponentes no entren en igualdad de condiciones al proceso de evaluaci?, con lo cual la participaci? de los recicladores en las ganancias, si bien resulta ser un veh?ulo o instrumento para la adjudicaci? de la licitaci?, no ser? determinante para establecer la participaci? efectiva en la rentabilidad del negocio de las organizaciones recicladores de segundo nivel.** (☐ ☐

De la misma manera, frente al an?lisis que realiza el ente de control a prop?ito de los diferentes escenarios de rentabilidad, indic?

☐ En conclusi?, aunque formalmente se podr?n presentar escenarios viables, en los que se otorgue participaci? a las asociaciones de recicladores de segundo nivel iguales o mayores al 50%, es importante resaltar que en estos casos se podr? utilizar esta variable para obtener un mayor puntaje en la calificaci? de la oferta y resultar as? adjudicatario de la licitaci?, **sin que ello se traduzca, en la pr?ctica, que los recicladores obtengan utilidades significativas, en la medida que estas pueden ser previamente disminuidas, inclusive pudiendo llegar a ser nulas, conforme a los escenarios descritos, traduci?dose esto en una ficci? de beneficios.** (☐ (Resaltado y subrayado fuera de texto)

74. Si a todo lo anterior se suma que el porcentaje de participaci? accionaria que se ofrezca a las organizaciones de segundo nivel, resulta fundamental para obtener puntaje, el esquema de la licitaci? instrumentaliza la participaci? accionaria ?icamente a efectos de obtener un puntaje representativo dentro del esquema de calificaci?.

En efecto, seg? los documentos allegados al presente tr?ite y como ya ha quedado dicho, de un total de 1000 puntos posibles, la d?ima parte est?atada al reconocimiento de participaci? accionaria. As? 100 puntos se otorgan a la propuesta que ofrezca mayor participaci? en las utilidades sociales, de forma que a los dem? se les aplica una regla de tres simple directa (AZ 1, folios 54 y 55). Ello sin contar con que

este criterio tambi? se estableci?para efectos de un posible desempate. (AZ 1, folio 57, respaldo).

Esto implic? en la pr?tica, que varios oferentes propusieran m? del 50% de utilidades en favor de las organizaciones de segundo nivel, no con el prop?ito de remunerar un aporte de industria -cuya omisi? en cuanto a su definici? qued?demostrada- sino con el ?ico objetivo de hacerse acreedores a 100 puntos, argumento adicional para que esta medida no pueda ser catalogada como una acci? afirmativa, pues realmente no repercute en la situaci? de los recicladores de oficio quienes dif?ilmente recibir? beneficio alguno. Es decir, la supuesta medida de discriminaci? positiva concebida por el pliego de condiciones realmente lo que genera es la instrumentalizaci? de las asociaciones de recicladores de segundo nivel, en la medida en que genera que entre m? utilidades se les d?-que se reitera son totalmente inciertas e indefinidas- m? puntaje se le da al concesionario. De all?por qu?el citado documento de la Contralor? General de la Rep?lica cuestione tal proceder en el pliego de condiciones.

Cabe precisar que en el Auto 268 de 2010 se orden? como requisito habilitante, que los oferentes se presentaran asociados con organizaciones de segundo nivel de recicladores, pero en ese caso ambas partes deb?n negociar las condiciones en las cuales podr?n trabajar en el Relleno Sanitario Do? Juana, lejos de los frentes de trabajo donde se sepultan los residuos s?idos que se producen en Bogot? Por lo mismo, se trata de una medida cualitativamente distinta a aquella establecida en el presente asunto.

75. Por otra parte, vale la pena recoger las impresiones tanto de los oferentes como de las asociaciones de recicladores, respecto del mecanismo de participaci? accionaria que prev?el pliego de condiciones.

Participaci? Accionaria	
Oferentes	
Uni? Temporal Cavo Vig? (AZ 2, folio 227 a 231)	Ofert?dependiendo de la ASE, entre el 5% y el 45% de acciones , que implica □(□) una utilidad muy importante a favor de las acciones de recicladores (□), lo que sin lugar a duda representa (□) la posibilidad de mejorar sus condiciones de vida□ (AZ 2, folio 230). De manera puntual, se?l? que en su oferta se entregar?a la organizaci? de segundo nivel que corresponda □el equivalente al cuarenta y cinco por ciento (45%) de las utilidades si se le asignan las ASE 1, 2, 3 o 6 y el cinco por ciento (5%) en el evento que se le adjudiquen las ASE 4 y5□ (AZ 5, folio 316).
ATESA Siglo XXI S.A.S. E.S.P. (AZ 2, folio 232 a 235)	Aclar?que □[e]l margen de utilidades proyectadas por las ASE y para cada a? de la concesi? despu? de amortizar las inversiones se estim? aproximadamente entre el 5% y el 6%, donde los primeros cuatro a?s son de amortizaci? □ (AZ 5, folio 298). De todas maneras, advirti?que el comportamiento del negocio es din?ico y puede sufrir variaciones.
Promesa de Sociedad Futura ASEO Bogot? (AZ 2, folio 236 a 237).	Sintetiz?que □(□) las utilidades que se deriven no de la Licitaci? sino del Contrato de concesi?, se repartir? de acuerdo con los estatutos sociales prometidos, las exigencias del pliego de condiciones y el C?igo de Comercio, es decir, por lo menos una vez al a? en caso de presentarse en el ejercicio□ (AZ 5, folio 303).

Uni? Temporal Gestió Ambiental (AZ 2, folio 238 a 253)	Sobre este punto, no hay elementos a destacar.
Promesa de Sociedad Futura IPSUM (AZ 2, folio 254 a 265).	Manifest?que seg? la sentencia T-291 de 2009, las acciones afirmativas conllevan el derecho de los recicladores de volverse progresivamente empresarios de las basuras; asunto que se alcanza con la condici? habilitante de conferir un porcentaje no menor al 5% de las acciones. Esto, a su vez, les confiere derechos como recibir utilidades -pagadas antes de las reservas o capitalizaci?- y participar porcentualmente del mayor valor de la empresa al momento de su liquidaci?. El hecho de que la participaci? accionaria sea un criterio de calificaci?, ha tenido como consecuencia ☐ (☐) <i>que algunos de los proponentes [hayan ofrecido] que entregar?n una participaci? accionaria a las organizaciones de recicladores de segundo nivel [de] 49% al 71%</i> ☐ (AZ 2, folio 258).
Consorcio CONAMBIENTALES y Uni? Temporal ASEO Triple A (AZ 2, folio 266 a 268)	Al respecto, no hay elementos a destacar.
Proponente Plural conformado por Ciudad Limpia Bogot?y otros (AZ 2, folio 269 a 299)	En cuanto a las posibles utilidades que ser?n repartidas a los recicladores, se?l?que ☐ (☐) <i>el modelo econ?mico y financiero estimado y presentado por la UAESP contempla p?didas netas para todas las ASE por lo menos para el primer a? de operaci? (☐). [Igualmente] el modelo contempla significativos aportes de capital de parte de los inversionistas durante los dos primeros a?s de la concesi? en todas las ASE, y estima que los inversionistas podr? recuperar tales aportes a capital durante los a?s siguientes a la operaci? (☐). [Por] tal raz? solo se generar?n dividendos a partir del cuarto a? de la concesi?, con excepci? del ASE 1 en la que para el tercer a? se generar?n dividendos por un valor que no supera los setecientos veinticinco millones de pesos</i> ☐ (AZ 2, folio 286). Ello implica que las utilidades para las organizaciones de segundo nivel sean eventuales. A esto se le suma que el porcentaje otorgado a los recicladores no puede ser variable, salvo que la empresa genere p?didas. Sin embargo, a continuaci? elabor? unas tablas que mostrar?n dos posibles e hipot?ticos resultados seg? un modelo efectuado por el proponente, en raz? al cual, dependiendo del porcentaje de acciones de industria otorgadas (emple?dos escenarios; uno de 5% y otro de 60%), la utilidad per-c?ita anual redundar?n, para el a? 2018 entre los ☐ (☐) \$105.648 [pesos] (☐) y \$2.052.571 [pesos] ☐ (AZ 2, folios 288 a 293). En este sentido, concluy?que al no existir certeza sobre el beneficio a recibir, ☐ (☐) el mecanismo de repartici? de dividendos a los socios de industria respecto de las utilidades de las sociedades que resulten concesionarias (☐) no es un mecanismo eficaz para lograr los objetivos que se buscan con la acci? afirmativa ☐ (AZ 2, folio 295).
Promesa de Sociedad Futura Bogot? Ambiental S.A. E.S.P (AZ 2, folio 306 a 315).	Argument?que tras la Adenda 8 se elimin?el tope de 10% accionario a entregar a las referidas organizaciones. Por eso, se generaron situaciones discriminatorias al permitir que los empresarios ofertaran porcentajes abismales seg? la rentabilidad de cada ASEs. Concatenado a esto, apunt?que a su juicio ☐ (☐) <i>s?constituir? una acci? afirmativa (☐) establecer la obligatoriedad para los proponentes de ceder un porcentaje X, igual para todas las ASE, a las organizaciones de recicladores, que por m?, deben incluir a toda la poblaci? que se busca proteger. As?mismo, <u>consideramos de</u></i>

	<u>suma importancia restablecer criterios razonables para el ofrecimiento de porcentajes a los recicladores de segundo nivel en la participaci? de la sociedad concesionaria, a fin de evitar que se realicen ofrecimientos de porcentajes que pongan en peligro la prestaci? del servicio p?lico de aseo</u> (□) (AZ 2, folio 310). Asegur?que al permitir el ofrecimiento de porcentajes accionarios irrazonables, se hicieron inviables econ?icamente las sociedades concesionarias. Esto, a su vez cuestiona la viabilidad futura de las pretendidas acciones afirmativas, pues □(□) <u>contraviene el principio de la continuidad en la prestaci? del servicio p?lico y por tanto, afecta los derechos ofrecidos a los recicladores</u> (AZ 2, folio 310). <u>Sobre lo anterior, enfatiz?que tal Adenda fue introducida a escasos cuatro (4) d?s h?iles del cierre de la licitaci?, lo cual □(□) muestra que la UAESP no analiz?los efectos materiales negativos que, frente a la acci? afirmativa de dar porcentajes a los recicladores de segundo nivel en la participaci? de la sociedad concesionaria, podr? tener el hecho de no poner un l?ite razonable a tales ofrecimientos</u> (AZ 2, folio 311). En este sentido, expuso que no resulta l?ico que quienes deben responsabilizarse por el 100% de la operaci?, se desprendan de sumas como el 71%, el 49%, el 46% o el 45% de las acciones (AZ 2, folio 311). De contera, la inviabilidad financiera de la concesi?, afectar? principios de la Ley 142 de 1994, como la continua e interrumpida prestaci? del servicio. De otro lado, se!?que de poderse cumplir las prometidas utilidades, ser? necesario cuestionar la f?mula tarifaria existente. Esto, en raz? a que seg? lo previsto por la Ley 142 de 1994, la tarifa permite amortizar los costos de inversi?, los gastos de operaci?, as?como la obtenci? de utilidades. Sin embargo, deben ser razonables y no desproporcionadas. Asunto que cuestion?con el otorgamiento de porcentajes de utilidades que rondan entre el 45% y el 71%. As?las cosas, □(□) <u>el ofrecimiento de tales porcentajes de las utilidades a las asociaciones de recicladores pone en "jaque" la estabilidad del sistema tarifario de las basuras en Bogot?/u>, pues pondr? en evidencia que la tarifa actual est? incorrectamente calculada, [ya que] con su recaudo no solo le permite a los socios inversionistas recuperar su inversi? y hacer una utilidad razonable, sino que adem? da para que un tercero, no inversionista, no operador, no expuesto al riesgo contractual, se lleve porcentajes significativos del beneficio econ?ico de la concesi?</u> (AZ 2, folio 314). Adicionalmente, si las tarifas son injustas, se estar?n vulnerando derechos colectivos y cabr?n las acciones populares correspondientes. A su parecer, ser?n acciones afirmativas aquellas que delimitaran el porcentaje accionario para las organizaciones de segundo nivel, tal y como estaba previsto antes de la Adenda 8. (p. 49) <u>Igualmente, afirm?que a las organizaciones de recicladores de segundo nivel se les ofrecer?un porcentaje de participaci? en las utilidades equivalente al 9% trat?dose de las ASE 1, 2, 4, 5 y 6. En la ASE 3, se les ofrece a las organizaciones de recicladores un 5% en la participaci? de las utilidades. En ambos casos, la distribuci? de utilidades se har?anualmente, acorde con lo establecido en el pliego de condiciones, salvo que la junta directiva opte por distribuir utilidades semestralmente.</u>
FEMSO de Colombia (AZ 2, folio 316 a 328).	Aleg?que no existen elementos pr?ticos para verificar que los porcentajes accionarios otorgados por los oferentes sean materialmente alcanzables. M?ime si se tiene en cuenta que tales organizaciones no asumen ning? riesgo, responsabilidad frente a la UAESP, inversiones o deudas.
Consorcio Lime (AZ 4, folio 5 a 18).	El Consorcio LIME se!?que, en materia de distribuci? de utilidades, las empresas de servicios p?licos se rigen por las normas del C?igo de Comercio referentes a las sociedades an?imas. Con todo, □(□) <u>en relaci? con los</u>

	accionistas de industria, las utilidades generadas durante el periodo de concesi? (8 a?s), se dividir? o repartir? de acuerdo con lo previsto en el Pliego de Condiciones (□), a cuyo tenor, de las utilidades generadas cada a? se repartir? inicialmente □ antes de reservas□, la parte que corresponda a los accionistas de industria, en el porcentaje asignado en cada ?ea de Servicio Exclusivo, ASE a las organizaciones de recicladores de segundo nivel, y, posteriormente, el remanente susceptible de distribuci? se repartir?a los accionistas capitalistas□ (AZ 5, folio 272).
Promesa de Sociedad Futura □ Promoambiental Distrito S.A.S. ESP (AZ 4, folio 39 a 43).	Record? los ofrecimientos elaborados por Proambiental, que redundan en participaci? accionaria entre el 18.36% y el 20% como socios de industria. Esto implica el derecho de los recicladores de participar en utilidades, as? como el beneficio de recibir esos porcentajes cuando la sociedad sea liquidada. Por lo dem?, asistir? con derecho a voz a las reuniones de la asamblea de accionistas. Por otra parte, adujo que durante los ocho (8) a?s de prestaci? del servicio de aseo las utilidades se repartir? conforme a la proporci? de participaci? de todos los accionistas. Como quiera que ellos ofrecieron entre el 18.36% y el 20% de acciones, ese ser? el monto que corresponda a las organizaciones de segundo nivel, sin afectarlos con reservas y sin lugar a capitalizaci?. (AZ 5, folio 160).
Promesa de Sociedad Futura RBL Bogot? DC (AZ 4, folio 106 a 146)	Al momento de analizar las acciones afirmativas, debe constatare □(□) <i>si con las mismas se garantiza la forma de subsistencia de la poblaci? vulnerable dedicada a esta actividad</i> (□) □ (AZ 4, folio 108). Pues bien, a su parecer el m?imo de 5% de participaci? accionaria les permite ingresar en esquemas empresariales reales. Igualmente, se?l? que □(□) <i>bajo los requerimientos de la concesi?, as? como de los estatutos y la ley, adoptar? las determinaciones atinentes al reparto y distribuci? de utilidades, tanto en funci? de la participaci? en su capital de los socios o accionistas, as? como de los titulares de aportes de industria</i> □ (AZ 5, folio 284).
Aseo Capital, Uni? Temporal (AZ 4, folio 147 □ 155).	En cuanto a las utilidades, hizo menci? a que depender? de la aprobaci? de los estados financieros que efect? la Asamblea de Accionistas y que, conforme con la licitaci?, deber? seguirse determinadas reglas para el pago de las mismas. Adicionalmente, expuso que el valor intr?seco de las acciones no se capitalizar? no har? parte del capital social y □(□) <i>la referencia al 5% del capital sirve para saber el valor de la empresa en el momento de la constituci? y el momento de su liquidaci?</i> □ (AZ 5, folio 249). Por lo dem?, si llegasen a haber p?didas, conforme con el art?ulo 380 del C?igo de Comercio, las organizaciones no participar? en las mismas, dado que su aporte es de industria. (AZ 5, folio 250).
Promesa de Sociedad Futura Desarrollo Limpio S.A. ESP (AZ 5, folio 223 a 235).	No hay elementos a destacar.

El cuadro y las consideraciones anteriores permiten arribar a las siguientes conclusiones: 1. No existe actividad o trabajo material que se constituya en aporte de industria a remunerar mediante la participaci? ofrecida. 2. Las organizaciones de segundo nivel no estar?n en condiciones de igualdad frente a la cesi? de participaciones en la medida que unos concesionarios podr?n empezar a redimir utilidades m? pronto que otros (unos en el corto plazo, otros en el mediano plazo e incluso, las utilidades, podr?n llegar a ser ?fimas o inexistentes). 3. El margen de ganancias, de causarse, no implica

que se aplique a verdaderas acciones dirigidas a la regularizaci? de los recicladores informales o a contribuir para formalizar la cadena de aprovechamiento. 4. La participaci? accionaria, en este caso, s? o es un mecanismo destinado a otorgar puntaje dentro del proceso de calificaci? de las ofertas y no una acci? afirmativa en favor de los recicladores de base.

76. De acuerdo con lo expuesto, el hecho de que las organizaciones de segundo nivel cuenten con participaci? accionaria en una sociedad comercial no permite afirmar que se est? frente a empresarios de los servicios p?licos complementarios de aseo, como lo afirman err?eamente varios oferentes.

La empresa es una unidad econ?ica-social en la cual el capital, el trabajo y la direcci? se coordinan para realizar una producci? socialmente ?il, de suerte que el empresario es aquella persona que de forma individual o colectiva fija los objetivos y toma decisiones sobre las estrategias, los medios y la forma de ejecutar su actividad social o materia de trabajo. En este caso, es claro que las organizaciones de segundo nivel ni tienen control sobre las actividades concesionadas -porque el mismo pliego limita la capacidad de voto-, ni aportan trabajo material al desarrollo del objeto social porque el aprovechamiento no est? en cabeza de ellas sino en los recicladores de base, ni asume responsabilidad alguna derivada de la administraci? del negocio. Lo anterior significa que son accionistas mas no empresarios, que es lo que se persigue con la acci? afirmativa.

77. Finalmente, se extra? en el pliego la ausencia de negociaciones y acuerdos entre los socios de capital y los de industria, la cual tampoco se dio por consecuencia en la realidad. Cabe recordar que todos los oferentes sin excepci? (ver anexo 2) afirmaron que no existi? di?ogo con las asociaciones de segundo nivel, pues los beneficios para los recicladores deven?n exclusivamente delo ordenado en el pliego de condiciones.

Tal omisi?, am? de representar un desconocimiento tajante del derecho a la libertad de empresa de los recicladores, repercuti? en el incumplimiento de uno de los componentes centrales de las acciones afirmativas: la participaci?. Si este derecho se desconoce, se pregunta la Sala, ?c?o puede otorgarse a estas organizaciones el car?ter de asociaciones empresariales?

Sobre el punto cabe mencionar que en el Auto 268 de 2010, si bien se orden? que los proponentes se asociaran con organizaciones de segundo nivel como un criterio habilitante, en ning? momento se les impuso agrupaci? alguna. Por el contrario, se les facult? para negociar con las cuatro organizaciones existentes en ese momento las condiciones de asociaci?. En efecto, en tal providencia se expuso: □(□) Como quiera que los proponentes han vinculado a asociaciones de base y les han otorgado una participaci? accionaria, pueden cumplir lo anterior con las organizaciones de segundo nivel en las cuales aquellas se encuentren coaligadas. En este sentido, los proponentes actuales podr? modificar sus ofertas, dentro de los siete (7) d?s h?iles siguientes a la expedici? de la adenda, conforme a lo ordenado en el presente Auto (□). La Corte estima que este t?mino es suficiente para que se pongan en contacto con las diferentes organizaciones de segundo nivel existentes en Bogot? y lleguen a un acuerdo con ellas para cumplir con los nuevos criterios habilitantes, as? como con los de calificaci? □ (subrayas fuera del original).

Por lo dem?, incluso las pretendidas utilidades ofertadas por los proponentes, que no en pocos casos

superan el 20% de las ganancias llegando hasta el 71%, obligan a la Sala a elevar serios cuestionamientos. Pues bien, muchos de los intervinientes alegaron la ausencia de reglas claras en torno a la repartición de tales utilidades, que tendr? como consecuencia □ en la pr?ctica □ que s?o algunos vean los frutos econ?micos de tales medidas.

Para la Sala es claro, adem?, que al menos un elemento resulta evidente: la repartición en partes iguales de las ganancias entre las organizaciones de segundo nivel que hayan sido favorecidas con la asignación del ASE respectivo, sin que importe el n?mero de miembros que ellas tengan. Tal condición se estableció mediante la Adenda 8. Con respecto a ella, es importante enfatizar que esta modificación al pliego de condiciones se efectuó con posterioridad al sorteo de las asociaciones, pues este ?timo se adelantó el veinte (20) de junio de dos mil once (2011) (AZ 2, folio 183, respaldo), mientras que la referida adenda fue expedida - según la Veeduría Distrital (AZ 2, Folio 161) - el veintidós (22) de julio de dos mil once (2011). Precisamente, el cambio efectuado radicó en la repartición de las posibles acciones, dado que - en un principio - se contemplaba que serían adjudicadas proporcionalmente al n?mero de asociados de las organizaciones de base^[1], mientras que con la mentada Adenda □ como ya se indicó □ tal división se haría por partes iguales.

Así las cosas, sin importar el n?mero de afiliados, las organizaciones recibirían los mismos beneficios. Por ello, esta medida no puede contemplarse como un incentivo al fortalecimiento de las asociaciones existentes sino como una disposición que, am? de ser cuestionable por el momento posterior al sorteo en el que fue adoptada, incidiría en el n?mero de asociados de las m? grandes organizaciones. Lo anterior, dado que, en caso de que las utilidades de las asociaciones de segundo nivel fueran repartidos entre los miembros de las organizaciones de base, aquellas que coaligaran a un menor n?mero tendrían m? que prorratear. Por lo mismo, se debilita a ciertas organizaciones de recicladores □ las m? antiguas y con mayor cantidad de afiliados □ en beneficio de las m? recientes, muchas de las cuales □ tal y como se se? l? □ no tienen ni un a? de constituidas.

Análisis del segundo nivel de protección propuesto por la UAESP: Entregar la actividad de recolección y transporte de material aprovechable que se presente separado por los generadores a los recicladores de oficio, asistido por los operadores del servicio de aseo.

78. Entra la Sala de Revisión a analizar el segundo nivel estructural anunciado acerca de las medidas de discriminación positiva concebidas por la UAESP en el pliego de licitaciones bajo estudio, esto es, si el hecho de que la actividad de aprovechamiento que se prev? sea adelantada directamente por parte de la población de recicladores de base responde a los criterios originalmente se?lados por la Corte en sus diferentes providencias. A continuación, se precisará lo se?lado por el pliego de condiciones y sus anexos:

79. De conformidad con el pliego de condiciones elaborado por la UAESP para la Licitación Pública 001 de 2011, las condiciones de participación de los recicladores de base, se sintetiza de la siguiente manera:

79.1 El objeto de la Licitación Pública 001 de 2011, prev? que □ La presente licitación no contempla exclusividad para las actividades de recolección y transporte de material reciclable que sea presentado en forma separada por los generadores, ni tampoco contempla exclusividad alguna para las actividades de aprovechamiento □ (AZ 1, folio 8)

-

79.2 Es así como respecto al aprovechamiento, el pliego estableció lo siguiente:

-

□ el puntaje asignado a este ítem es de 50 puntos.

-

Actualmente, Bogotá tiene una cobertura aproximada de 32% de usuarios del servicio de aseo cubiertos por las rutas de reciclaje, en el marco de las acciones adelantadas con el fin de incentivar las actividades de reciclaje por parte de los usuarios del servicio.

-

Para este componente el puntaje se asignará a la propuesta que ofrezca el mayor porcentaje de cobertura de usuarios de la Ruta de Reciclaje dentro de la respectiva ASE, partiendo como mínimo de la cobertura actual de 32% la cual debe garantizarse obligatoriamente.

-

Los cincuenta puntos correspondientes a este ítem, se distribuirán y asignarán calificando aquellos proponentes que ofrezcan la mayor cobertura de usuarios en el menor tiempo, de la siguiente manera:

-

Se asignarán 30 puntos a la propuesta que ofrezca mayor porcentaje acumulado de cobertura de usuarios de la Ruta de Reciclaje dentro de su respectiva ASE, durante el primer año, contado a partir del día siguiente a la fecha de terminación del período de transición. A los demás se les aplicará una regla de tres simple directa.

-

Se asignarán 10 puntos más a la propuesta que ofrezca el mayor porcentaje acumulado de cobertura de usuarios de la Ruta de Reciclaje dentro de su respectiva ASE durante el segundo año. A los demás se les aplicará una regla de tres simple directa.

-

Se asignarán 5 puntos más a la propuesta que ofrezca el mayor porcentaje acumulado de cobertura de usuarios de la Ruta de Reciclaje dentro de su respectiva ASE durante el tercer año. A los demás se les aplicará una regla de tres simple directa.

-

Se asignarán 5 puntos más a la propuesta que ofrezca el mayor porcentaje acumulado de cobertura de usuarios de la Ruta de Reciclaje dentro de su respectiva ASE durante el cuarto año. A los demás se les aplicará una regla de tres simple directa.

-

El proponente deberá presentar en su oferta, además del porcentaje de cobertura de usuarios de la Ruta de Reciclaje, para cada uno de los cuatro primeros años, contados a partir del día siguiente a la fecha de terminación del período de transición, partiendo como mínimo de la cobertura actual existente de 32%, la cual debe garantizarse obligatoriamente, el plan de trabajo para adelantar a efectos de la implementación de las actividades de fortalecimiento y formalización de la recolección de material potencialmente aprovechable, en los términos establecidos en el ANEXO 21. INCLUSIÓN DE LA POBLACIÓN RECICLADORA. □ (AZ 1, folios 55 a 56).

-

80. Por su parte, el Anexo 21 del pliego de condiciones correspondiente a la Licitación 001 de 2011, indica (AZ 1, folio 60 a 62)

-

□ La recolección de material potencialmente aprovechable estará a cargo de los recicladores de oficio ubicados en cada ASE, quienes continuarán ejerciendo su actividad en los territorios que actualmente lo hacen, independientemente de la participación accionaria que corresponda a la asociación de recicladores de segundo nivel a la que pertenezcan.

-

La recolección de material potencialmente aprovechable se realizará a partir de la acera, mediante el

sistema puerta a puerta, con las herramientas y dotaciones que ser? provistas por los concesionarios del servicio de aseo a los recicladores de oficio ubicados en su (s) ASE (s) , de acuerdo con los requerimientos espec?icos de cada ASE, y en los t?minos previstos m? adelante.

El material que recojan los recicladores de oficio en los territorios que actualmente ocupan, ser? comercializado por ellos en las bodegas que escojan, y el valor de dicha transacci? ser? de su propiedad (subrayado y resaltado fuera de texto)

81. En relaci? con el Plan de Trabajo que deben entregar los operadores, el anexo 21, establece que:

Los proponentes entregar? con la propuesta el plan de trabajo a adelantar a efectos de la implementaci? de las actividades de fortalecimiento y formalizaci? de la recolecci? de material potencialmente aprovechable, que ser? realizada por los recicladores de oficio ubicado en la ASE respectiva, independiente de la asociaci? de segundo nivel a la que pertenezcan.

Dicho plan debe incluir la utilizaci? de las bodegas del sector y, contener como m?imo:

- a) Diagn?tico de la actividad de recolecci? de material potencialmente aprovechable en el ASE.
- b) Ubicaci? de los recicladores de oficio.
- c) Estrategia para promoci? de la afiliaci? de los recicladores de oficio en condiciones de vulnerabilidad, censados, que a? no est? afiliados a la asociaci? de segundo nivel.
- d) Estrategia para el mejoramiento de las condiciones en las cuales se realiza la actividad de recolecci? de material potencialmente aprovechable en las ASE.
- e) Estrategia para el incremento de recolecci? de material potencialmente aprovechable en el ASE.
- f) N?ero de usuarios a ser beneficiado con la recolecci? de material potencialmente aprovechable.
- g) Utilizaci? de bodegas del sector.
- h) Cantidad, especificaciones y momento de entrega de los equipos, dotaciones y dem? apoyos que ser? entregados a los recicladores de oficio para garantizar el cumplimiento de la cobertura de aprovechamiento de la propuesta

82. Por su parte, el Anexo 5 del Pliego de condiciones relativo al Reglamento T?nico Operativo estableci? lo siguiente (AZ. 6 Folios 28 a 29):

La recolecci? selectiva consiste en recoger separadamente diferentes fracciones de los residuos s?idos con el fin de reciclarlos. La recolecci? selectiva y el reciclaje permiten ahorrar recursos escasos y parte de la energ? necesaria para la fabricaci? de los productos a partir de materias primas v?genes.

La recolecci? selectiva estar?a cargo de los recicladores de oficio en cada ASE, quienes continuaran ejerciendo su actividad en las zonas de la ciudad que actualmente lo hacen, de acuerdo con la informaci? del censo de recicladores del distrito, independientemente de la asociaci? de recicladores de segundo nivel a la que pertenezcan.

La recolecci? selectiva de residuos se realizar?a partir de la acera, mediante el sistema puerta a puerta, garantizando la cobertura m?ima propuesta por cada concesionario en su oferta a partir de los equipos y dotaciones que ser? provistos por el concesionario del servicio a los recicladores. Son objeto de este componente todos los residuos s?idos potencialmente aprovechables, inorg?nicos, secos, no peligrosos, separados por los usuarios y presentados de manera separada.

Por su parte los concesionarios est? obligados de acuerdo con los pliegos de condiciones y correspondiente propuesta presentada, de proporcionar a los recicladores en su ASE, de la dotaci?,

uniformes, equipos y veh?culos necesarios para que esta actividad se realice en mejores condiciones de reconocimiento, formalizaci?, participaci?, inclusi? social del gremio de los recicladores.

En cualquier caso, la dotaci? y herramientas que el operador proporcione a los recicladores de oficio, deber? cumplir con las especificaciones t?nicas m?imas de producto establecidas en este documento, y deber? ser seleccionados en funci? de los siguientes principios rectores:

- Dise? ergon?ico
- Bajo peso
- F?cil operaci?
- Capacidad de carga adecuada a las capacidades humanas y a las necesidades de la ciudad
- Garantizar las mejores condiciones de seguridad posibles
- Promoci? de tecnolog?s verdes
- Acoger las disposiciones en cuanto a imagen e identidad visual de la establecida por la Unidad, de manera que todos los elementos contemplados o contenidos cumplan con los lineamientos del Distrito Capital. □

An?lisis del contenido de los pliegos.

83. De acuerdo con lo transcrito puede concluirse lo siguiente:

83.1. Las labores de reciclaje y aprovechamiento est? sometidas al esquema de libre competencia y no se encuentran sujetas a las restricciones que impone el sistema de ?eas de servicio exclusivo.

83.2. Las labores de recolecci? selectiva y transporte de material aprovechable que se presenten en forma separada por los generadores pasa a estar en cabeza de los recicladores de oficio.

83.3. Los operadores deben en todo caso asegurar una cobertura m?ima obligatoria de las rutas de reciclaje del 32%, aunque no sean ?tos los directos obligados a operarlas.

83.4. El pliego otorga hasta 50 puntos a los operadores que oferten mayor porcentaje de cobertura, por encima del 32%, a cargo de los recicladores y mayor duraci? de cobertura a partir de la terminaci? de la fase de transici? que, se define en el numeral 2.12 como un per?do de seis (6) meses de ejecuci? de los contratos de concesi? durante los cuales se realizar? los ajustes operativos y t?nicos para la prestaci? de los diferentes componentes de su servicio, (AZI Folios 70 a 73).

83.5. Se estructura en cabeza de los operadores la obligaci? de establecer planes de trabajo con los recicladores de su ASE, dirigidos a asegurar los porcentajes de cobertura, as? como dotar de uniformes, botas y carros de tracci? humana a esta poblaci?.

84. Como se puede evidenciar, los pliegos diferencian el servicio de recolecci? y transporte de residuos no separados que realizan los operadores tradicionales en zonas de servicio exclusivo, de la recolecci? y transporte de residuos aprovechables que se presenten en forma separada por los generadores en un esquema de libre competencia.

-

Desde ese punto de vista, se podr? pensar que se incluye un avance de naturaleza conceptual, en la medida en que como la afirma la UAESP y se deduce de los pliegos, esta ?tima actividad se radicar?, ya no de manera informal sino formal, en cabeza de los recicladores, al punto que ya no habr? una distinci? entre la rutas formales de reciclaje que en la actualidad operan los concesionarios y las rutas informales que cubren los recicladores, pues toda la actividad estar? de manera □formal□ en cabeza de este grupo marginal.

-

85. Si se tiene en cuenta que el fin de las acciones afirmativas que se demandan, no es otro que el que la operaci? del servicio p?lico complementario de aprovechamiento est?en cabeza de sus destinatarios naturales -los recicladores-, este podr? ser tenido en principio como una formal acci? afirmativa. Sin embargo, la eficacia de la medida radica en que este grupo se encuentre materialmente preparado para asumir la operaci? del servicio. De lo contrario, este cambio de paradigma no tendr? ninguna repercusi? desde el punto de vista pr?tico, pues sin la adecuada organizaci? y log?tica este grupo marginal seguir?realizando su labor sin que se aprecien cambios significativos m? all?de que no tendr? la presi? de la competencia que implican las rutas formales de reciclaje operadas por los concesionarios □aunque s?la del paso de los camiones recolectores en su labor en la acera= y, que contar? con uniformes, botas y carros de tracci? humana que faciliten su trabajo.

Se debe tambi? agregar que, como se ver?a continuaci?, a? en la hip?esis en la cual se pudiera considerar que all?se contempl?una acci? afirmativa, el esquema desarrollado por la licitaci? entra en franca contradicci? con la posibilidad de que se incremente el reciclaje puesto que si los concesionarios tuvieran inter? en incrementarlo □lo cual es en suma dudoso porque sus ganancias provienen del peso recogido y porque se estar?en competencia con los recicladores de oficio-, quienes en realidad lo realizar? □los recicladores de oficio- no tienen v?culo jur?ico alguno con el concesionario.

-

El modelo de licitaci? propuesto por la UAESP plantea, en el Anexo 21, se recuerda, que la recolecci? de material potencialmente aprovechable □(□) estar?a cargo de los recicladores de oficio ubicados en cada ASE, quienes continuar? ejerciendo su actividad en los territorios que actualmente lo hacen, independientemente de la participaci? accionaria que corresponda a la asociaci? de recicladores de segundo nivel a la que pertenezcan (□)□ (AZ 1, folio 60, respaldo). Por lo mismo, no existe una relaci? de coordinaci? necesaria entre las organizaciones de segundo nivel que habr? sido asignadas a las ?eas de servicio exclusivo mediante el sorteo y aquellas organizaciones de base □ o recicladores no coaligados □ que efectivamente trabajan en las ASEs.

-

86. As?las cosas, la Sala observa que no existen mecanismos que aseguren que los recicladores de oficio efectivamente recojan el material potencialmente aprovechable que los usuarios presenten en las aceras. Esto, por cuanto el contrato que llegare a celebrarse con los proponentes seleccionados □ asociados con las organizaciones de segundo nivel □ no obligar?a los recicladores de oficio a prestar el componente de la recolecci? de los materiales potencialmente aprovechables del servicio p?lico de aseo.

-

87. En ese orden, percibe la Sala de Revisi? que esta medida no viene acompa?da de herramientas que

aseguren su eficacia. De allí que la Sala de Revisión la encuentre ineficaz, por las siguientes razones:

-

87.1. No se asegura que los usuarios del servicio público de aseo presenten de manera separada sus residuos. Gran parte del ítem de la medida contemplada en el pliego de condiciones requiere de una política seria en materia de separación en la fuente. Sin ella los recicladores seguirán avocados a meter sus manos en los contenedores de basura mezclada y sin separación y, en consecuencia, seguirán compitiendo con los grandes operadores por los mismos residuos.

-

87.2. No existe regulación o modelo que asegure que los usuarios del servicio público de aseo presenten de manera separada sus residuos, ni siquiera medidas escalonadas dirigidas a este fin, dado que gran parte del ítem de la medida contemplada en el pliego de condiciones, requiere de acciones concretas de separación en la fuente. Tampoco el Plan de Trabajo que debe elaborar el operador garantiza que la separación efectivamente se materialice, pues no existe ningún tipo de control por parte de la UAESP sobre el mismo y, en éstimas, éste carece de poder vinculante frente a los usuarios y a los recicladores. En efecto, si bien en caso tal la administración podrá utilizar poderes contractuales para concretar el cumplimiento contenido obligatorio que deriva del plan de trabajo, lo cual de por sí faltará de elementos que permitan su eficacia como corresponde a una medida de discriminación afirmativa, el hecho es que frente a los recicladores de oficio no existe la posibilidad jurídica de que sean obligados.

-

Sin medidas de separación en la fuente concretas o escalonadas, se reitera, los recicladores seguirán avocados a meter sus manos en los contenedores de basura mezclada y sin separación para obtener el material aprovechable y, en consecuencia, seguirán compitiendo con los grandes operadores por los mismos residuos.

-

Con ello se omite el cumplimiento de un criterio propio de las acciones afirmativas, según el cual los recicladores deben acceder de manera cierta y segura a los residuos sólidos potencialmente aprovechables y, de ser posible, incluir valor agregado a la actividad de la cual derivan su sustento.

-

87.3. No se establece en el pliego un proceso progresivo dirigido a la normalización de la población recicladora de oficio, de tal forma que pueda prestar de manera organizada y coordinada el servicio público complementario de aseo en el componente de aprovechamiento -que incluye la recolección, transporte, tratamiento y uso de residuos-.

-

Es preciso recordar que la prestación del servicio público de aseo en cualquiera de sus componentes, requiere en los términos de la Ley 142 de 1994, que se realice a través de un operador autorizado e inscrito. De esta manera, la entrega oficial de la operación del servicio de recolección y transporte de material aprovechable en la ciudad a los recicladores, exige como medida mínima que se establezcan metas claras y paulatinas para alcanzar este propósito en el corto plazo. De lo contrario, no será posible ejercer control sobre la prestación efectiva de este servicio público que, entre otras cosas, opera bajo la modalidad de libre competencia.

-

Así nada garantiza el cubrimiento efectivo de las rutas de reciclaje por parte de esta población como

tampoco la calidad y frecuencia del servicio, pues se recuerda que por v? contractual el ?ico obligado a garantizar cobertura es el operador, aspecto que cuestiona la racionalidad de la medida como criterio afirmativo.

87.4. Se observa la ausencia de remuneraci? formal del servicio p?lico de recolecci? y transporte de residuos aprovechables que se radica en cabeza de los recicladores, v? tarifa o a trav? de un sistema de precios. Ello por cuanto si bien la metodolog? tarifaria prevista en la Resoluci? CRA 351 de 2005, consider?el aprovechamiento como un incentivo para los usuarios dentro del componente de disposici? final, dirigido a que disminuya la tarifa a partir del c?culo de un porcentaje de reducci? de residuos por efecto del aprovechamiento cuyo costo □ser? igual al valor que genera indiferencia en el costo de disposici? final al suscriptor, ajustado por las diferencias generadas por concepto de tramo excedente□, lo cierto es que el servicio de recolecci? y transporte como componente tarifario es inexistente. Al trasladar la prestaci? de este servicio al reciclador no se consagra ninguna remuneraci? v? tarifa, como tampoco la obtendr?para efectos de formalizar su actividad de la comercializaci? de los residuos, en la medida que no existe un sistema de precios unificado en los centros de acopio.

87.5. No existen razonablemente centros de acopio y recepci? del material reciclable, cercanos a los sitios de recolecci?, y los veh?ulos de tracci? humana no son id?eos ni eficaces para el transporte de residuos en trayectos largos, si se tiene en cuenta que muchas ?eas no cuentan con centros de reciclaje y los existentes se ubican en zonas que demandan largos desplazamientos.

Las carencias anteriores no son nuevas pues, en efecto, de acuerdo con el Informe de la Contralor? de Bogot? elaborado para la vigencia de dos mil cinco (2005), titulado: □An?isis y Evaluaci? al manejo, estabilidad y vida ?il del Relleno Sanitario Do? Juana, proyecto de Biogas y Parques de Reciclaje□, se dej?constancia del repetido incumplimiento del Distrito desde el a? 2001, respecto de la creaci? de seis (6) parques de reciclaje, de los cuales a 2011, s?o uno (1) se encuentra en funcionamiento. (AZ 3, folios 289 a 298).

Por otro lado, el efecto del Decreto 456 de 2010 fue la disminuci? de los centros de acopio de la ciudad que se redujeron a 66, esto es 1 por cada 112.000 habitantes aproximadamente^[53]. Esta cifra demuestra la desproporci? que existe entre la obligaci? de alcanzar una cobertura del 100% de recolecci? y transporte de material aprovechable en una ciudad con \$7.300,000 habitantes, si se tiene en cuenta que s?o funciona un parque de reciclaje y 66 centros de acopio.

As?las cosas, resulta imposible que los recicladores, ante la ausencia de centros de acopio cercanos y debidamente adecuados puedan prestar el servicio de manera inmediata. Es m?, en la pr?tica y por lo mismo, la afiliaci? de los usuarios a las rutas selectivas no conllevar?un beneficio ambiental del aprovechamiento por imposibilidad material de su ejecuci?.

88. Lo anterior demuestra que la pol?ica p?lica por parte del Distrito debe orientarse precisamente a que esta formalizaci? encuentre bases s?idas; sin embargo, el pliego parece disolver esta responsabilidad en los operadores del servicio p?lico de aseo a quienes traslada la carga de realizar un Plan de Trabajo con los recicladores de oficio para que estos asuman la prestaci? del servicio, planes que pueden resultar ?timos, pero tambi? de mediana a baja calidad en la medida que no se exigen est?

dares m?imos ni se establecen aspectos por lo menos medibles y verificables por parte de la UAESP.---

-

89. Aunque el pliego anuncia para efectos de otorgar el puntaje, un per?do de transici?, aparentemente entre la operaci? de rutas formales por los concesionarios y la operaci? de las mismas por parte de la poblaci? recicladora, no se define ni cualitativa ni cuantitativamente dicho per?do. Sin embargo, el mismo resulta necesario para que los usuarios beneficiarios de las actuales rutas formales de aprovechamiento no vean lesionados sus intereses, por los cuales pagan una contraprestaci?, de forma que no se desarticule el sistema de multiusuarios.

-

90. De otra parte, la licitaci? establece una obligaci? directa al concesionario de asegurar una cobertura de rutas de reciclaje por lo menos igual al 32% en cada ASE. No obstante, en ? no recae la obligaci? de prestar el servicio de recolecci? y transporte de material aprovechable que se presente separado por el generador ya que ?te se traslada al reciclador de oficio.

-

En ese orden ¿c?o pueden garantizar los concesionarios que unos terceros (recicladores) no vinculados por el contrato de concesi?, aseguren una cobertura m?ima de 32% en su ASE en cuanto a rutas de reciclaje? Lo anterior se muestra al menos problem?ico si se tiene en cuenta que este porcentaje de 32% para toda la ciudad lo garantizaban actualmente cuatro operadores -Ciudad Limpia, Aseo Capital, Lime y ATESA-, a trav? de siete (7) frecuencias semanales, en setenta y tres (73) micro rutas, para las seis (6) ASEs, mediante la utilizaci? de seis (6) carros de tracci? mec?ica destinados especialmente para tal fin (AZ 5, folio 332).

-

Adicional a ello, el que se ampl? la cobertura de rutas en la ciudad no es sin?imo de mayor recolecci? de residuos aprovechables. De hecho, seg? el estudio realizado por la Universidad Javeriana, los recicladores recogen al menos 1200 toneladas al d? de material reciclable□es decir que [sus] rutas informales de reciclaje operan por fuera de todo contrato de recolecci? y transporte para eliminaci? por aprovechamiento industrial del 27% de las basuras que produce la ciudad, mientras que las rutas formales [de reciclaje] de los concesionarios operando bajo contrato solo recogen el 3%.□ (AZ 5, folio 330).

-

De all?que el aumento de cobertura de rutas no asegura para nada que los recicladores incrementen su acceso actual al material aprovechable, pues el verdadero acceso se garantiza con medidas que aseguren la separaci? en la fuente. De lo contrario tendremos dos operadores persiguiendo un mismo material, ello por cuanto una cosa es aumentar la cobertura y, otra muy distinta, aumentar la recolecci? de material aprovechable.

-

91. En este sentido, los pliegos de condiciones le imponen a los recicladores de oficio unas obligaciones sin ser sujetos vinculados contractualmente por virtud de la concesi?, con la dificultad de que ni siquiera se encuentran censados o identificados en cada ASE. El siguiente cuadro revela los problemas existentes frente a las rutas de reciclaje y la apreciaci? que operadores y recicladores tienen de ellas:

Oferentes	
Uni? Temporal Cavo Vig? (AZ	En lo que se refiere al funcionamiento de la ruta de reciclaje,

2, folio 227 a 231)	explic?que se trata de una ruta establecida por la UAESP, realizada por el operador del Servicio de Aseo y ☐ (☐) <i>definida como la forma en la cual el operador recoge el material reciclable separado previamente en los hogares</i> ☐ (AZ 5, folio 314). En cuanto a la frecuencia, se?l?que la ruta de recolecci? selectiva es un servicio que se brinda una vez por semana en menos de la mitad de la ciudad.
ATESA Siglo XXI S.A.S. E.S.P. (AZ 2, folio 232 a 235)	La ruta de reciclaje es en s? misma una acci? afirmativa, dado que contempla un plan operativo con un itinerario preciso y definido. Sobre el tema de la ruta de reciclaje y su relaci? con los usuarios y con los recicladores, sostuvo que los primeros ser? los encargados de presentar el material debidamente separado y que los recicladores lo recolectar? ☐ (☐) <i>con los apoyos, dotaciones y equipos que los operadores hemos ofrecido dentro de las ofertas presentadas</i> ☐ (AZ 5, folio 294).
Promesa de Sociedad Futura ASEO Bogot?(AZ 2, folio 236 a 237).	Aseo Bogot?relat?la manera c?o funciona hoy en d? la recolecci? del material potencialmente reciclable ☐ <i>Una vez que el concesionario realiza la recolecci? del material recuperable, debe disponerlo en el centro de reciclaje o centro de acopio asignado, cumpliendo la ruta de recolecci? selectiva</i> ☐ (AZ 5, folio 303).
Uni? Temporal Gest? Ambiental (AZ 2, folio 238 a 253)	No aport?elementos relevantes.
Promesa de Sociedad Futura IPSUM (AZ 2, folio 254 a 265).	Manifest?que en raz? a que se dar? 50 puntos por tal concepto, se gener?un incentivo ☐ (☐) <i>para que los proponentes aumenten considerablemente el porcentaje de aprovechamiento</i> (☐) <i>[Esto se consolida como una]</i> acci? afirmativa de la UAESP plasmada en el Pliego de Condiciones (☐) <i>para aumentar de forma significativa la cobertura de usuarios de la Ruta de Reciclaje dentro de la respectiva ASE</i> (☐) ☐ (AZ 2, folio 260). Por ello, 10 de los 13 proponentes ofertaron aumentar tal cobertura a un 100% de usuarios. Frente a la ruta de reciclaje, mencion?que est?destinada a la recolecci? de material potencialmente reciclable, que ha sido separado previamente en la fuente. Siendo la cobertura actual equivalente al 32% de usuarios y esperando que sea ampliada al 100%.
Consortio CONAMBIENTALES y Uni? Temporal ASEO Triple A (AZ 2, folio 266 a 268)	Con respecto a la ruta de reciclaje, se limit?a mencionar aspectos contemplados en el anexo 5 del pliego de condiciones. Con respecto a la ruta de reciclaje, se limit?a repetir lo contemplado en el Anexo 21 del pliego de condiciones y expres?que la relaci? con el usuario se da cuando ?te presenta los materiales potencialmente aprovechables. Por su parte, la vinculaci? con los recicladores se da cuando estos recogen dichos residuos.
Proponente Plural conformado por Ciudad Limpia Bogot?y otros (AZ 2, folio 269 a 299)	Manifest?que ☐ <i>la ruta de reciclaje planteada en el pliego de condiciones, hace referencia a la que realizar?el reciclador asociado, el cual tendr?una dotaci? suministrada por el operador de aseo, el (sic) realizar?un recorrido libre, es decir, no</i>

	<i>necesariamente en el ASE asignada a su asociaci? () (AZ 5, folio 204).</i>
Promesa de Sociedad Futura Bogot?Ambiental S.A. E.S.P (AZ 2, folio 306 a 315).	<i>La ruta de reciclaje es un recorrido que hace un veh?ulo lentamente () mientras los recicladores realizan la evacuaci? de los residuos puerta a puerta hasta completar la capacidad del veh?ulo o finalizar el recorrido (AZ 5, folio 258). Se agreg?que () la ruta de reciclaje ser?atendida exclusivamente por los recicladores de cada una de las ASE mediante el uso de veh?ulos de tracci? humana y los veh?ulos que oferte el operador (AZ 5, folio 258).</i>
FEMSO de Colombia (AZ 2, folio 316 a 328).	No manifest?elementos relevantes.
Consortio Lime (AZ 4, folio 5 a 18).	<i>Expuso que en un principio se hab? contemplado que la sostenibilidad financiera de la ruta de reciclaje estar? a cargo de las organizaciones de segundo nivel de cada una de las ASEs, mientras que ser? responsabilidad de los proponentes entregar los suministros de equipos y veh?ulos necesarios para la operaci? inicial de la misma. No obstante, la versi? final del pliego contempl?como una obligaci? del proponente () mantener el porcentaje de cobertura ofertado una vez se entregue el manejo de la RDR [Ruta de Recolecci?](AZ 4, folios 9 a 10). Ahora bien, lo anterior genera problemas, pues esa ruta estar?a cargo de los recicladores, frente a los cuales no existen garant?s del cumplimiento total de esta actividad. Por lo mismo, los porcentajes ofertados por los diferentes proponentes, que incluso llegaron al 100% en el primer a?, son ilusorios y muy probablemente imposibles de materializar. Sumado a esto, enfatiz?que () esta situaci? traer?como consecuencia la posible imposici? de multas contractuales al concesionario, frente al incumplimiento de actividades que no podr?cumplir o sanear, por depender de [los recicladores] (AZ 4, folio 10). En cuanto a la definici? y funcionamiento de las rutas de reciclaje, el Consorcio realiz?una transcripci? de un fragmento del Anexo 1 del Reglamento T?nico Operativo que determina lo que se entiende por ruta de reciclaje para despu? concluir, a partir de all? que () corresponde a los recicladores y recuperadores recoger el material potencialmente aprovechable; a los generadores de los residuos o usuarios del servicio seleccionar previamente dicho material potencialmente aprovechable y a los concesionarios del servicio de aseo suministrar a los primeros los veh?ulos (de tracci? manual o automotor), equipos, dotaciones y uniformes durante el primer a? de operaci? (AZ 5, folio 271).</i>
Promesa de Sociedad Futura Promoambiental Distrito S.A.S. ESP (AZ 4, folio 39 a 43).	<i>Sobre la Ruta de Reciclaje, mencion?que se trata de recorridos que efect?n los recicladores, recogiendo el material potencialmente aprovechable. Para ello, contar? con equipos e implementos suministrados por los concesionarios. Existe, igualmente, una relaci? directa entre los usuarios y esta ruta, dado que el ?ito de las mismas depende de la separaci? en la fuente. Concluy?enfatisando que () la ruta de recolecci? selectiva es una actividad directa a cargo de la poblaci? recicladora de oficio (AZ 5, folio 159).</i>
Promesa de Sociedad Futura RBL Bogot?DC (AZ 4, folio 106	<i>Existen localidades donde actualmente no hay rutas de selecci?, por lo que de ser adjudicataria del contrato se compromete a ampliar la</i>

a 146)	cobertura. La ruta de reciclaje se refiere, seg? RBL Bogot? a ☐ (☐ <i>aquel sector a atender con unidades especializadas tipo furg? y con horarios y frecuencias preestablecidas en los cuales se llevar?a cabo la recolecci? de los materiales potencialmente aprovechables</i> ☐ (AZ 5, 283). Agreg?RBL Bogot?que las rutas de reciclaje ser? reforzadas por los recicladores que ☐ <i>ser? dotados con carros de tracci? manual para recorrer la zona</i> ☐ (AZ 5, folio 283).
Aseo Capital, Uni? Temporal (AZ 4, folio 147 ☐ 155).	Frente a la ruta de reciclaje, al igual que otros proponentes, trajo a colaci? que se encuentra definida en el numeral 6.17 del Reglamento T?nico y Operativo de la Licitaci? 001 de 2011.. Para esta actividad, los concesionarios deber? entregar dotaciones, equipos y veh?ulos. ☐ (☐ <i>En cualquier caso, la dotaci? y herramientas que el operador proporcione a los recicladores de oficio, deber? cumplir con las especificaciones t?nicas m?imas de producto establecidas en [el reglamento t?nico operativo]</i> ☐ (AZ 5, folio 245).
Promesa de Sociedad Futura Desarrollo Limpio S.A. ESP (AZ 5, folio 223 a 235).	En relaci? con las rutas de reciclaje, mencion? ☐ al igual que los otros proponentes ☐ que implica la recolecci? de residuos previamente seleccionados y que en la actualidad esta actividad en Bogot?la desarrollan los operadores del servicio, pero gracias a la licitaci? p?lica 001 de 2011 estar?a cargo de los recicladores. Sobre este punto, es importante resaltar que mencion?la obligaci? de los usuarios de separar en la fuente y el hecho de que si los recicladores recogen los materiales por su propia cuenta no se contabilizar? dentro de la tarifa de aseo.
Recicladores	
Asociaci? de Organizaciones de Reciclaje y Recuperaci? Ambiental (ARAMBIENTAL) (AZ 2, folio 329 a 336).	La ruta de reciclaje ☐ <i>se inici?en el a? 2006 en el mes de septiembre por iniciativa de la UAESP con llegada al CENTRO PILOTO DE RECICLAJE LA ALQUER?</i> ☐ (AZ 5, folio 416). A dicho centro, donde ☐ <i>se desarrollan principalmente actividades de selecci?, clasificaci?, beneficio, alistamiento y comercializaci?</i> ☐ (AZ 5, folio 416), solo llegan veh?ulos procedentes de la ruta de reciclaje que recolectan y transportan los residuos reciclables. Los residuos de org?nicos y sanitarios - residuos de rechazo - son evacuados en m?imo 24 horas. Frente a la relaci? de los recicladores con la ruta de reciclaje, manifest?que el centro ☐ La Alquiler? ☐ es operado por la ARB, ARAMBIENTAL y la ARUB, organizaciones que constituyeron una Uni? Temporal liderada por la Se?ra Nohra Padilla quien tambi? lidera la ARB. Esta organizaci?, seg? ARAMBIENTAL, ha sido la m? beneficiada a trav? de sus l?eres, la Se?ra Padilla y el Se?r Silvio Ruiz Grisales. Adicionalmente y siempre frente a la ruta de reciclaje, anot?que ☐ (☐ <i>la ruta recicladora en las ASES debe ser de los recicladores organizados y beneficiar a todas las personas vinculadas y no vinculadas, ya que los l?eres de las organizaciones han aprendido que con el fortalecimiento empresarial y organizativo adquirido en estos procesos se encuentran preparados para dignificar el trabajo del reciclador</i> ☐ (AZ 5, folio 417). (p. 68)
Federaci? sindical de Recicladores de Bogot?	En cuanto al funcionamiento de la ruta de reciclaje y a la participaci? de los recicladores en ella, ☐ <i>Si hablamos de la que</i>

FEDARSIN (AZ 2, folio 370 a 383).	<i>existe actualmente, sabemos que ?ta es manejada por los consorcios de basuras, donde recogen 3 veces por semana en las mismas rutas que tienen para las basuras, y su disposici? final es el parque de La Alquer? y sabemos que no hay participaci? del reciclador en esta ruta</i> (AZ 5, folio 510). Anot?adem? que la administraci? de este centro de acopio est?a cargo de una de las organizaciones participantes en la licitaci? 001 de 2011 que no habr? permitido la inclusi? de otras organizaciones de recicladores que igualmente participan en la licitaci?. Aunado a lo anterior, FEDARSIN agreg? <i>Ahora, si mencionamos la ruta de reciclaje que est?dentro de la licitaci? 001 de 2011, es de nuestro conocimiento por lo que hemos le?o que s?se da participaci? a los recicladores pero no es algo que est?claro debido a las ?timas modificaciones de esta licitaci? y a que no hay exclusividad para los recicladores ni las organizaciones que est? participando</i> (AZ 5, folio 510).
Confederaci? Ambiental Hagamos de Colombia un Pa? Grande ☐ Confederaci? Ambiental FUNCOLGRAN (AZ 2, folio 398 a 425)	En lo relativo al funcionamiento de la ruta de reciclaje y la participaci? de los recicladores en ella, esta organizaci? coment?que existe un centro de reciclaje localizado en el barrio La Alquer?, en donde los recicladores de oficio realizan la separaci? y clasificaci? del material aprovechable. Dicho centro es administrado por la Uni? Temporal conformada por tres organizaciones de recicladores de segundo nivel -ARB, ARAMBIENTAL y ARUB. Adicionalmente, inform?que trat?dase de la Licitaci? 001 de 2011 la ruta de reciclaje debe ser dise?da por las organizaciones de segundo nivel en acuerdo con los consorcios.
Federaci? de Recicladores Independientes de Colombia (FEDERINCOL) (AZ 3, folio 146 a 154)	La ruta de reciclaje es uno de los cuatro componentes del Programa Distrital de Reciclaje (PDR), programa que es coordinado por la UAESP y que consta de ☐ (☐ dos componentes t?nicos (ruta y parque de reciclaje) y dos sociales (separaci? en la fuente e inclusi? de la poblaci? recicladora) (AZ 5, folio 431). A?di? que ☐ La ruta de reciclaje se implement?desde el a? 2008 como un sistema a trav? del cual los operadores recogen el material reciclable previa separaci? en la fuente realizada por los ciudadanos en sus hogares (AZ 5, folio 431). Por lo dem?, el dise? y operaci? de la ruta corre a cargo de los concesionarios, quienes establecen las frecuencias y horarios. En directa relaci? con lo anterior, esta organizaci? se?l?que ☐ Al igual que la ruta normal de recolecci? de residuos s?idos que pasa tres veces por semana recogiendo la ☐ basura ordinaria, la ruta de recolecci? selectiva es un servicio adicional que se presta por los operadores del servicio una vez por semana, ?icamente para los residuos reciclables (AZ 5, folio 432). Volviendo a la ruta de reciclaje, FEDERINCOL agreg? que ?ta no ha sido implementada por la UAESP en todas las localidades sino que abarca solo el treinta y tres por ciento (33%) de la ciudad; adem? no genera costos adicionales para el usuario puesto que ?te servicio est? incluido en la tarifa que paga por la prestaci? del Servicio P?blico de Aseo. Tambi? explic? que ☐ Los residuos recolectados en la ruta de reciclaje son llevados al centro de reciclaje ☐ La Alquer? en donde se almacenan y se clasificande acuerdo a su tipo (pl?tico, cart?, metal y vidrio principalmente) para posteriormente ser comercializados (AZ 5, folio 432).

FUNREDAMBIENTE (AZ 3, folio 255 a 261)	Frente a la pregunta que versa sobre el funcionamiento de la ruta de reciclaje ☐ elevada en el Auto 189 de 2011 -explic?que ☐ (☐ est? siendo manejada por los consorcios que prestan el servicio de aseo hoy por hoy, la realizan mediante campa?s informativas a la comunidad y luego con un ruteo de veh?ulos motorizados que recogen el material reciclado y seleccionado por los usuarios de servicio p?blico de aseo en sus casas, dicho material es entregado en el parque de reciclaje ☐ LA ALQUERIA ☐ , all?la Uni? Temporal conformada por ARB, ARAMBIENTAL y ARUB lo clasifica y comercializa ☐ (AZ 5, folio 568). En cuanto a la relaci? que tienen los recicladores con la ruta de reciclaje, se?l?que ☐ El material seleccionado por los usuarios en sus casas, recolectado por los consorcios y entregado a ☐ LA ALQUERIA ☐ lo recibe la Uni? Temporal (ARB, ARAMBIENTAL y ARUB), es en estos momentos cuando algunos asociados de las tres organizaciones mencionadas realizan la clasificaci? del material, recibiendo por su trabajo un jornal establecido por la uni? temporal y que fluct? dependiendo de las pol?icas internas que ellos manejan ☐ (AZ 5, folio 568). (p. 79)
Asociaci? Colombina de Recicladores Independientes (ACOREIN) (AZ 3, folio 269 a 271)	No hay elementos relevantes a destacar.
Asociaci? de Recicladores Unidos por Bogot?(ARUB) (AZ 3, folio 309 a 311 y 388 a 391).	En cuanto al funcionamiento de la ruta de reciclaje, se?l?que ☐ Funciona de dos maneras. La primera es la ruta que la UAESP llama informal que es realizada por los recicladores de oficio. Y la segunda la ruta selectiva realizada por los consorcios de aseo en diferentes puntos de la ciudad ☐ (AZ 5, folio 470). En la primera ruta los recicladores recuperan los residuos por las calles usando costales, triciclos y carretas de tracci? animal entre otros. En cuanto a la ruta selectiva realizada por los consorcios de aseo, ?tos ☐ (☐) tienen programado un d? espec?ico para cada zona de la ciudad donde una parte de estos residuos llegan al CENTRO DE RECICLAJE LA ALQUERIA y en donde los recicladores le dan el aprovechamiento de selecci? ☐ (AZ 5, folio 470)de manera que el 70% es aprovechable y el 30% restante es material de rechazo.
ANIR (AZ 3, folio 320 a 337).	No hay elementos relevantes a destacar.
Red de Organizaciones de Recicladores Ambientales ☐ Dame tu Mano - (AZ 3, folio 338 a 341).	No mencion?elementos relevantes a destacar.
Federaci? Sindical de Recicladores y Carreteros de Bogot?(FESIRBO)	Alega que desconoce el funcionamiento de la ruta de reciclaje puesto que nunca han sido incluidos en ese proyecto.
Federaci? Sindical de Organizaciones Protectoras del Medio Ambiente (FESNOPMA)	Manifest?desconocer el funcionamiento de la ruta de reciclaje. As? mismo, aleg?que sus afiliados no tienen ninguna relaci? con ella y que nunca han tenido la oportunidad de participar, raz? por la cual ☐ (☐) deambulan por la v? p?lica abriendo las bolsas de basura que frente a las viviendas dejan los residentes, mas no se [constituyen en] comerciantes [o] empresa[rios], ya que este

	reciclaje lo selecciona, transporta y comercia[liza] un peque? grupo de l?eres que se auto titulan los ?icos abanderados y representantes de los recicladores (AZ 5, folio 517). Adem?, se?l? que los carros de la Ruta Selectiva del Reciclaje llegan al Centro de Reciclaje La Alquer?, enviados por los consorcios de aseo que operan actualmente en la ciudad y () han sido la ARB, la ARUB y ARAMBIENTAL las organizaciones que han obtenido los beneficios (AZ 5, folio 518-519).
Federaci? Sindical Cultura de los Recicladores (FESINCURE)	No hay elementos adicionales a destacar.
Federaci? Sindical de Recicladores y Carreteros de Colombia (FESINRECOL)	La ruta est?a cargo de consorcios. Estos consorcios disponen de veh?ulos que recorren los barrios recogiendo los desechos para trasladarlos al centro de acopio La Alquer? () donde la uni? temporal conformada por ARB, ARAMBIENTAL y ARUD los procesan en la clasificaci? y comercializaci? (AZ 5, folio 558). En cuanto a la participaci? de los recicladores en la ruta de reciclaje, sostuvo que, en su opini?, los ?icos recicladores que participan en ella son aquellos que pertenecen a las tres organizaciones de la Uni? Temporal, puesto que son ellos quienes realizan la labor de clasificaci? de los residuos. Anot? adem?, que () Las dem? organizaciones de segundo nivel no tienen ninguna relaci? con la ruta de reciclaje porque ellos reciclan en las calles o en las fuentes por su propio esfuerzo (AZ 5, folio 559).
M?kbys (AZ 3, folio 375 a 376); Cooperativa de Trabajo Asociado de Recicladores el Triunfo (AZ 3, folio 377 a 378); Asociaci? de recicladores Puerta de Oro de Bogot?(AZ 3, folio 379 a 380); Asociaci? de Recicladores Rafael Uribe Uribe (AZ 3, folio 381 a 382); Asociaci? de Recicladores el Triunfo (ASORETRIUNFO (AZ 3, folio 383 a 384); Asociaci? de Recicladores (Luz Verde) de Usaqu? (AZ 3, folio 386 a 387).	Buscan que las rutas de reciclaje sean operadas por ellos, conforme a las organizaciones de econom? solidaria que han conformado. Asunto que, adem?, mejorar? los sistemas de aprovechamiento en beneficio de la ciudad. Sin embargo, aclararon que al acabarse con las bodegas de reciclaje, se afecta la cadena econ?mica y ambiental en que participan de manera grave. Por lo dem?, enfatizaron que no est? interesadas en participar como socias industriales de los operadores de servicio de aseo.

92. Lo anterior permite concluir que: **i.** Rutas de reciclaje sin parques de reciclaje o centros de acopio no tienen posibilidad de operar de manera eficaz. **ii.** Rutas de reciclaje que ofrezcan coberturas entre el 32 % y el 100% de la ciudad a cargo de los recicladores no pueden garantizarse a partir de la dotaci? de uniformes, botas y carros de tracci? humana, si se tiene en cuenta que operadores con mayor capacidad tecnol?ica, t?cnica y financiera apenas cubren el 32% por ciento de la ciudad. **iii.** El incremento de cobertura no significa el incremento de material aprovechable para beneficio de los recicladores y para beneficio ecol?ico de la ciudad. **iv.** Mientras no exista separaci? en la fuente los recicladores y operadores seguir? compitiendo en condiciones desiguales por los mismos residuos. **v.** No existe desarrollo de pol?ica p?blica que acompa? la materializaci? de esta medida, la cual en otras circunstancias ser? ideal como acci? afirmativa en favor de los recicladores. **vi.** No se establece un sistema de transici? entre la operaci? de rutas formales por parte de los operadores y las rutas operadas por los recicladores, aspecto que afecta directamente a los usuarios del servicio de recolecci? y

transporte de residuos presentados de forma separada. **vii.** No existe posibilidad de que la UAESP o los concesionarios tengan la facultad de obligar a los recicladores de oficio que desarrollar? la labor de recoger los residuos que han sido previamente separados. **viii.** Se seguir? en la situaci? actual, esto es, sin que la ciudad se beneficie de pol?icas necesarias de separaci? en la fuente. **ix.** En el esquema actual tampoco existen incentivos para que el material aprovechable sea comercializado adecuadamente.

93. En este orden de ideas, queda claro que las condiciones de los recicladores no variar? sustancialmente en el proceso de selecci? bajo estudio, ya que en el desarrollo de su labor han venido compitiendo entre ellos y con los operadores para hacerse a los materiales potencialmente aprovechables, lo cual seguir? en similares circunstancias. Se destaca en todo caso, que como medida asistencial, la entrega de elementos de dotaci? como uniformes, botas y carritos de tracci? humana, representa una mejora en las condiciones f?icas en que actualmente los recicladores vienen realizando sus actividades, aunque su entrega no repercute en la superaci? de las condiciones marginales y de pobreza.

El ofrecimiento de empleos en actividades de corte de c?ped y la poda de ?boles.

94. En cuanto a la creaci? de puestos de trabajo, se insiste en que tal ofrecimiento per se resulta positivo para los integrantes de esta poblaci? que decidan no dedicarse a las actividades de reciclaje, pero lo cierto es que este ofrecimiento no representa por s? mismo un avance destinado a la formalizaci? de este grupo marginal, ni implica un reconocimiento a la experiencia acumulada a lo largo de los a?s en raz? a la labor econ?ica que realizan.

95. En este aspecto no existe una relaci? directa entre la oferta laboral que se realiza en actividades de corte de c?ped y poda de ?boles con la labor de reciclaje y aprovechamiento propiamente dicho, que es la actividad con la que pueden acreditar experiencia y conocimiento. Es decir, brilla por su ausencia la relaci? entre la mano de obra que se requerir? para efectos de las labores aqu? estudiadas respecto de la existente y tambi? requerida en materia de aprovechamiento de residuos, lo cual muestra que esta oferta de contrataci? para efectos de corte de c?ped y poda de ?boles no solo no podr? cobijar al conjunto de la poblaci? que se pretende proteger, sino que la actividad de reciclaje quedar? disminuida en las personas que a ella se dedican.

96. Cabe mencionar que uno de los aspectos materia de cr?ica en la sentencia T-724 de 2003, fue precisamente que el modelo de licitaci? estudiado en ese momento, desconoc? el aprendizaje experiencia acumulada de los recicladores, as? como el beneficio ambiental para la colectividad -aspectos que precisamente los define como sujetos de especial protecci? constitucional-. En efecto, en dicha providencia se indic? ☐ (☐) Si bien, de acuerdo con el Pliego de Condiciones, los proponentes y concesionarios que resulten seleccionados deben tener en cuenta que el 15% de los operarios que se requieran para la realizaci? de la actividad de corte de c?ped, deber? ser seleccionado con personas en situaci? de desplazamiento y recicladores, esta medida no reporta ninguna protecci? eficaz de la actividad de reciclaje que vienen desempe?ando los recicladores. En primer lugar, porque la actividad a desarrollar es diferente a la de reciclaje, esto es, el corte de c?ped; en segundo lugar, porque se acent? las condiciones de marginamiento de casi la totalidad de esa poblaci?, teniendo en cuenta que el 15% de los operarios que se piensa vincular para el corte de c?ped, est? compartido por otra poblaci? en condiciones de debilidad manifiesta, como son los desplazados ☐ (subrayas fuera del original).

-

97. En suma, para el caso bajo estudio, esta medida no puede ser considerada como una acción afirmativa, pues desconoce la participación de este colectivo en la actividad del aprovechamiento, no sólo como trabajadores, sino como empresarios, de manera que esta medida de corte asistencialista si bien resulta aceptable, no reivindica el trabajo de la población marginal. Así en la hipótesis en que pudieren ser contratados en tareas diferentes a la poda de árboles y corte de césped, por ejemplo, recogiendo la basura en los camiones, lo cierto es que esta situación tampoco los convertiría en empresarios de las basuras ni significaría una acción afirmativa en tanto recicladores.

-

La acción afirmativa que se consagre en el pliego de condiciones debe estructurarse de manera que pueda subsistir por sí sola

-

98. Debe ahora la Sala Tercera de Revisión establecer un punto técnico esencial que atraviesa lo que se ha desarrollado en los artículos inmediatamente precedentes y que apunta a afirmar que las acciones afirmativas, si en gracia de discusión se aceptare que existieron, de todas formas están supeditadas a que las mismas sean complementadas por actuaciones inciertas de las autoridades o de los concesionarios, lo cual genera que también por este aspecto no se pueden calificar como tal.

-

99. La acción afirmativa, como medida que genera una diferenciación que le otorga prevalencia a determinada comunidad sobre el resto de la sociedad, rompe de manera tajante con el principio de igualdad que rige en los Estados constitucionales actuales, y específicamente en el Estado Social de Derecho en Colombia, por expreso mandato del artículo 13 de la Carta. Así la acción afirmativa fractura la igualdad formal que debe existir entre todos los ciudadanos y ciudadanas y le otorga a determinado grupo beneficios específicos que le permitan trascender la situación de discriminación a la cual ha sido históricamente sometido. Esta excepción que la acción afirmativa hace ante el principio de igualdad, se deriva de un análisis material de la realidad social afectada, trascendiendo las consagraciones formales de equidad que puedan existir en el ordenamiento. Sólo por medio de un diagnóstico de las condiciones prácticas de igualdad en determinada sociedad, es que se convierte en una realidad la aplicación de acciones afirmativas, que entienden el limitado rol que juega la consagración formal de derechos cuando se trata de modificar situaciones históricas de discriminación. La acción afirmativa depende de aquello que ocurre en la vida real, su construcción y aplicación debe ser un reflejo de este estudio y por tanto se aleja estructuralmente de las consagraciones formales que puedan hacerse en pro de la igualdad de los grupos discriminados. -----

-

Beauchamp describe los esfuerzos por trascender el plano formal argumentando que existe considerable evidencia que indica que la discriminación es intratable y no puede eliminarse por medio de la aplicación de normas genéricas de igualdad. Las cuotas u objetivos numéricos se justifican si son necesarias para superar los efectos discriminatorios reales que no podrán ser eliminados por la aplicación cotidiana y formal de la ley. ^[54] Es así como se puede evidenciar que la construcción de este tipo de medidas debe desprenderse del plano formal y conformarse de manera tal que se establezcan las condiciones que permitan su materialización. Una vez se conoce el estado real de la situación que se pretende afectar con la medida de discriminación positiva, se podrá establecer las condiciones suficientes para que ésta sea efectiva y alcance los objetivos planteados.

-

100. La necesidad de que la acción afirmativa se construya teniendo en cuenta las condiciones materiales

del problema que pretende solucionar, permite que la medida subsista por sí sola en el ordenamiento. Así, la importancia de la aproximación sociológica en la medida de discriminación positiva se justifica, pues de ella se deriva la efectividad real que la política sentada pueda tener. Una vez se han estudiado las características y aristas reales del problema de marginación atacado, se pueden consagrar todos los elementos que necesite la acción para generar cambios en la realidad del grupo desprotegido. Sólo así la medida podrá subsistir por sí sola, sin depender de factores externos y formales que aseguren el fracaso de la disposición.

Por estos motivos es que la acción afirmativa se debe regir por un principio básico de independencia, que permita que la eficiencia de la medida dependa únicamente del estudio detallado que se hizo de la realidad en el momento de conformación de la política y no de la relación con el ordenamiento y el sistema formal de derecho. Por supuesto, no se puede desconocer que las políticas que pretenden eliminar la discriminación en una sociedad deben formar parte de un plan integral que se traduzca en una política de Estado, que afecte transversalmente a todas las ramas del poder público, en sus diversas expresiones, pero sin perjuicio de la autonomía que determina la eficacia de este tipo de medidas. La independencia de la acción afirmativa resulta esencial para su existencia pues es el elemento que le permite subsistir, sin la necesidad de recurrir al ordenamiento formal que muchas veces desconoce las situaciones reales de discriminación que se quieren eliminar.

En la misma dirección se ha pronunciado la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos al revisar casos que involucran la aplicación de medidas afirmativas. Para este alto tribunal, la eficacia de la medida afirmativa depende de que este ☐ estrechamente confeccionada ☐ y por tanto goce de la suficiente independencia como para que su realización no penda de la intervención de otras autoridades o de la aplicación de otras disposiciones del ordenamiento.^[55] El alcance que se le ha dado al término de ☐ estrechamente confeccionado ☐ se traduce en que la política debe comprender de manera integral todos los elementos que se necesiten para su aplicación efectiva en el contexto que se pretende alterar. Así, cuando la acción afirmativa esté consagrada de manera completa, no necesita de futuras intervenciones, regulaciones u actuaciones, que en otras tantas se conviertan en los factores de los cuales pende el éxito de la medida.

101. En el caso bajo estudio se evidencia claramente que las supuestas acciones afirmativas que se incluyeron en el pliego de condiciones, no gozan del principio de independencia que rige la existencia de estas medidas y que asegura su efectividad. En el pliego se establecieron inicios de acción afirmativa, cuya efectividad, en otras tantas, depende de la intervención futura de la administración por medio de otras regulaciones o la imposición de ordenes policivas. Así, por ejemplo, medidas que estimulen en concreto la separación en la fuente, que fomenten la creación de centros de acopio y parques de reciclaje, la formalización de los recicladores informales y el acceso cierto y seguro al material aprovechable. En síntesis, la entrega de las rutas de reciclaje no constituye un caso de acción afirmativa, pues no subsiste por sí sola y su aplicación depende de las actuaciones que el oferente decida o no poner en práctica.

Por tanto, los inicios de acción afirmativa que se plantean en este pliego vulneran la independencia de la cual se deriva su eficacia, al exigir que para su satisfacción real deba existir interacción con las autoridades, el ordenamiento formal o el criterio de los proponentes. Si la medida estuviese correctamente contemplada, podrá llevarse a cabo sin necesidad de recurrir a los elementos ya mencionados y los componentes necesarios para su implementación se encontrarían contemplados en el pliego. Por supuesto, esta reflexión no puede conducir a que sólo las medidas de discriminación positiva que estén exhaustivamente desarrolladas puedan ser efectivas, pero sí se requiere que en la conformación de la política se incluyan los elementos básicos que aseguren la materialización real de la misma, situación

que no se verifica en el presente caso. Como se demostró previamente, en el pliego de condiciones analizado, el contexto de la aplicación de las acciones afirmativas para incluir a los recicladores está sujeto a factores que el contrato en formación -a través del proceso licitatorio- no regula ni contempla. Cuando la medida está incompleta, por carecer de los mecanismos necesarios para su ejecución, es como si no existiera, pues no tiene un elemento esencial de esta figura jurídica: los medios para lograr una afectación real en la situación de discriminación.

Es así como se puede concluir que en el pliego de condiciones estudiado no existen acciones afirmativas reales pues las que se encuentran ahí consagradas no gozan de la independencia que asegure su eficacia y por tanto no trascienden el plano de lo formal, requisito indispensable para la existencia de la medida de discriminación positiva. Una acción afirmativa real, estará estructurada de manera tal que en el pliego existieran los elementos básicos que permitieran su aplicación, sin estar sujeta a actividades posteriores de la administración o del contratista. La acción afirmativa existe en la medida en que sus disposiciones aseguren su eficacia, pues la consagración formal de estas medidas es precisamente lo que las mismas pretenden superar.

Declaratoria de incumplimiento.

102. Por las razones expuestas a lo largo de esta providencia, la Sala Tercera de Revisión, en ejercicio de sus competencias legales y constitucionales, estima que existen elementos suficientes para declarar el incumplimiento por parte de la UAESP de aquellas ordenes impartidas desde el año dos mil tres (2003), atinentes a la inclusión de acciones afirmativas materialmente efectivas en favor de la población de recicladores de Bogotá cuando se trate de la contratación del servicio público de aseo, destinadas a reparar la afectación continuada a los derechos fundamentales de sujetos de especial protección constitucional.

103. Ahora bien, podrá pensarse que las falencias anotadas del pliego de condiciones serían susceptibles de ser corregidas o modificadas sin necesidad de afectar el desarrollo normal de la licitación pública No. 001 de 2011. Sin embargo, son varias las razones que impiden la corrección de los pliegos y la modificación de las ofertas sin dejar sin efecto el proceso de licitación: i. La participación accionaria de las organizaciones de segundo nivel está anclada de manera representativa a la asignación de un puntaje que puede llegar hasta cien (100) puntos de mil (1000), lo cual conlleva que cualquier cambio en los pliegos en relación con la participación accionaria necesariamente tendrá un impacto en el sistema de calificación, así como en la oferta económica a la cual se le ha asignado en el pliego setecientos (700) puntos posibles. En efecto, si se ha considerado que las eventuales utilidades ofrecidas a las asociaciones de segundo nivel no son en realidad acciones afirmativas, el hecho de reformar el tratamiento a las mismas supondrá indefectiblemente el resquebrajamiento del esquema financiero planteado por cada proponente, porque ambos componentes están indisolublemente ligados. Lo anterior hace necesario entonces una reforma total y estructural del pliego, no sólo en relación con la inclusión de verdaderas acciones afirmativas, sino también con el esquema de calificación y su impacto en la oferta económica. ii. Adicionalmente el esquema de la licitación otorgaba cincuenta (50) puntos al compromiso de cobertura de entre el treinta y dos (32) y el cien (100) por ciento de las rutas de reciclaje, de suerte que al verificarse que no existe un vínculo jurídico de los recicladores de oficio frente a los oferentes, dirigido a hacer coercitivo el cumplimiento de ese porcentaje, nada justificará que el mismo fuese otorgado, punto de más que afectará el esquema general de la licitación, al no poder ser tenido en cuenta. iii. Además, el esquema de asociación planteado no asegura que todas las asociaciones de recicladores de segundo nivel tengan acceso a utilidades ciertas y periódicas ni que se respete el principio de igualdad, aspecto que no depende del pliego sino del nivel de inversión que cada operador está llamado a amortizar durante el

plazo de los respectivos contratos, lo cual podr? llevar a replantear la idea de otorgar utilidades al menos bajo la concepci? actual, as?como el puntaje m?imo pero libremente ascendente por ese ?em. iv. Finalmente, como quiera que no existe la posibilidad de que los recicladores asuman las rutas selectivas de manera eficiente, la medida adoptada relacionada con ellas no supera el test de razonabilidad y proporcionalidad, por cuanto no se garantiza la prestaci? continua del servicio p?blico de aseo en el componente de aprovechamiento a favor de todos los usuarios de la ciudad.

-

104. La Sala Tercera de Revisi? puede entonces concluir respecto del incumplimiento de la sentencia T-724 de 2003 y del Auto 268 de 2010, con base en los argumentos de s?tesis que se precisan a continuaci?.

-

104.1. En primer t?mino, se debe recordar que la Corte Constitucional es competente para desatar el presente tr?ite de cumplimiento puesto que as?lo facultan los art?ulos 23 y 27 del Decreto 2591 de 1991, puesto que el juez de primera instancia envi?a esta Corporaci? el mencionado tr?ite, puesto que se trata de recicladores considerados como sujetos de protecci? especial, puesto que est? en juego derechos constitucionales fundamentales, puesto que de no obrar las sentencias judiciales quedar?n en letra muerta, puesto que el juez constitucional goza de amplias facultades para determinar la forma de ejecuci? de los fallos de tutela y puesto que as?lo mandan la Convenci? Americana de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Pol?icos, que forman parte del bloque de constitucionalidad.

-

104.2. Sentada su competencia, es claro, en segundo t?mino, que los mandatos constitucionales del Estado Social de Derecho, del principio de igualdad (art. 13 CP) y de la necesidad de tomar medidas reales de discriminaci? positiva que la concreten, de racionalizaci? de la econom? con el fin de conseguir el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes, la distribuci? equitativa de las oportunidades y los beneficios del desarrollo y la preservaci? de un ambiente sano (art. 334 CP), de la necesidad de hacer respetar en la sociedad a las minor?s que reciben a su favor el pacto de las mayor?s de hacer valer el acuerdo m?imo que son los derechos constitucionales fundamentales, de la ponderaci? entre los derechos de los recicladores y los del inter? general as?como el de los proponentes, de la necesidad de contrarrestar las desigualdades existentes dentro de nuestra sociedad, del cumplimiento de los postulados de nuestra Carta Ecol?ica, son el par?etro y el sustento constitucional para que la Corte estudie a fondo si los pliegos de condiciones elaborados para contratar el servicio p?blico de aseo en la ciudad de Bogot? respeta los est?dares m?imos de promoci? de la igualdad real. Este sustento constitucional es precisamente, se reitera, el que permite desatar el presente tr?ite de cumplimiento.

-

104.3. Es as?como, basado en los criterios constitucionales anteriores, se debe tener en cuenta, en tercer t?mino, que en el proceso licitatorio bajo estudio la UAESP plante?dos medidas estructurales que entendi?como medidas de discriminaci? positiva: la participaci? accionaria de las asociaciones de segundo nivel de recicladores como socios de industria, para lo cual otorg?100 puntos sobre 1000 de la calificaci? □sin l?ite a partir del 5% en el porcentaje otorgado-, y, asignar bajo el esquema de libre competencia rutas de reciclaje con la provisi? de ciertos equipos a los recicladores de oficio, as?como promover su contrataci? en labores diferente al reciclaje, para los cuales se otorgaron otros 100 puntos de la calificaci?. Como se observ?en los considerandos de la presente providencia, ninguno de los dos niveles se puede considerar medidas reales de acciones afirmativas. Lo anterior, como punto te?ico de partida, porque no toda acci? dirigida a una poblaci? discriminada se puede calificar de positiva. Para ello se requiere que sea eficaz, transitoria y altere positiva y progresivamente el status quo, de suerte que se pueda afirmar que hubo un cambio sustancial antes y despu? de la misma, lo cual oblig?a la Sala a estudiar si en el caso concreto hubo cumplimiento de manera aparente o de manera real, llev?dola a la

conclusi? que ocurri?lo primero.

-

104.4. En efecto, las medidas exigidas desde hace m? de ocho a?s -lo cual es relevante para el an?isis de la progresividad de las medidas de discriminaci? positiva-, se concibieron en dos niveles sin que ninguno de ellos hubiere logrado sobrepasar el test estricto que en estos casos se aplica, habida consideraci? de la situaci? de sujetos de especial protecci? constitucional que conforman los recicladores frente a la carga que implica dicha acci? frente a terceros. Por dem?, la acci? afirmativa que se consagra en el pliego de condiciones debe estructurarse de manera que pueda subsistir por s?sola, respetando el principio de independencia que rige estas medidas de discriminaci? positiva, sin depender de futuras intervenciones regulatorias o policivas de la administraci? o del criterio potestativo de los oferentes.

-

104.5. As? la primera medida de discriminaci? positiva concebida por la UAESP, esto es, la participaci? accionaria de las asociaciones de segundo nivel de recicladores como socios de industria, no result?ser tal. Por el contrario se convirti?en un instrumento que, permitiendo desmesuradas, inciertas e ilusorias ganancias a dichas asociaciones, se convirti?simplemente en la ocasi? para que los proponentes pudieren hacerse a la licitaci? gracias a la obtenci? del puntaje por ello ofrecido.

-

104.6. El esquema planteado de las acciones de industria a favor de las asociaciones de segundo nivel de los recicladores, no redundar?en beneficio de aquellos de primer nivel, esto es, de quienes en efecto realizan el oficio, que es la primera poblaci? llamada a proteger. En efecto, como ha quedado visto, no existe claridad sobre las utilidades que se podr? presentar, pero a? d?dolas por ciertas, no existe obligaci? jur?ica alguna que permita que los miembros de las asociaciones de primer nivel puedan ver alg? beneficiode dichas utilidades.

-

104.7. Tambi? el esquema planteado lleva ?sito, como lo expuso en este tr?ite la Contralor? General de la Rep?lica, el incremento de la desigualdad de la poblaci? recicladora. Al estar adscritas las asociaciones de segundo nivel a ASEs espec?icas con proponentes diferentes, y al estar cada propuesta basada en ofertas tambi? diferentes sustentadas en esquemas financieros dis?iles, existir? obligatoriamente asociaciones que, en caso de que haya utilidades, las recibir? en grados y en plazos sustancialmente distintos a las de otras que se asociaron con otro proponente. Asimismo, el esquema planteado para la repartici? de utilidades no tuvo en cuenta el n?ero de los afiliados a cada una de ellas, raz? por la cual se repartir?n los mismos ingresos con independencia del n?ero de afiliados, violando el principio de igualdad y de contera el esp?itu asociativo de las mentadas asociaciones.

-

104.8. El aporte de industria de las asociaciones de segundo nivel no contiene una expresa y clara obligaci? de hacer de ?tas frente a la sociedad comercial que se constituya, puesto que no solo carecen de la posibilidad de incidir frente a ?ta sino, m? importante a?, convierte a las asociaciones de segundo nivel en parte de una sociedad comercial que tiene un objeto social al cual se le excluy?el aprovechamiento porque ?te se dej?en cabeza directa de los recicladores. Las asociaciones de segundo nivel se convierten en socias de una empresa cuyo objeto social no es el aprovechamiento. Se recuerda que en las propias intervenciones de los proponentes, la gran mayor? de ellos estimaron que dicho aporte no ten? causa, no aportaba nada, no era cuantificable, se generaba una □nebulosa□ causando una □confusi? de car?ter l?ico y jur?ico con respecto a la identidad y al real aporte de nuestros posibles socios industriales□, etc.

-

No sobra recordar en estas conclusiones que no existi?participaci? de las asociaciones de segundo nivel en la escogencia de la forma de utilidades ofertadas en el pliego, pues no se concibi?un di?ogo previo con sus socios de capital.

-

105. En lo que tiene que ver con el segundo nivel mencionado, esto es, el de la entrega de las rutas de reciclaje a los recicladores de oficio, tampoco encontr?la Sala que se cumplieran con los elementos que permiten declarar la existencia de reales acciones afirmativas.

-

El esquema de los pliegos de la licitaci? que plantea que el porcentaje de cubrimiento de las rutas de reciclaje, debe ser m?imo del 32% de cobertura, entra en una contradicci? insalvable que lo hace inoperante, con el hecho de que las personas que deben recolectar dicho material no son objeto de relaciones contractuales puesto que se trata de los recicladores de oficio que, bajo el esquema concebido de libre mercado y libre circulaci? por toda la ciudad, no tienen relaci? jur?ica alguna con los concesionarios que adquieren la obligaci?. Esto implica entonces, que el porcentaje m?imo de cobertura de rutas que se tienela esperanza de cubrir para promover la recolecci? de material aprovechable, no podr?ser objeto de cumplimiento y en caso tal generar? m? bien incumplimientos del contratista. Lo anterior significa que tan importante labor ecol?ica para la ciudad quedar?en letra muerta, al no haber mecanismos jur?icos que la haga realidad. Se reitera adem? que una cosa es el cubrimiento de las rutas de reciclaje y otra bien distinta es la separaci? del usuario en la fuente, aspectos que bien pueden encontrarse sustancialmente diferenciados, tal como ocurre en la actualidad.

-

106. La labor de los recicladores de oficio no cambiar?ni eficiente, ni sustancialmente. Si bien se plantea que las antiguas rutas selectivas que operaban los concesionarios ser?n liberadas a favor de los recicladores para recoger los residuos potencialmente aprovechables, lo cierto es que por el hecho de tener que competir por los mismos residuos con el cami? recolector □todo depender?de qui? pase primero por la acera donde se encuentra la basura, lo cual por dem? no est? reglamentado-, por el hecho de que no existe separaci? segura en la fuente, por el hecho de que no existen centros de acopio garantizados en los lugares cercanos a cada ASE, por el hecho de que no existe mercado garantizado para los productos aprovechables, por el hecho de que no existe un sistema de precios o tarifario que remunere el servicio, no se trata de una medida eficiente, coherente, proporcional y racional.

-

107. Las supuestas acciones positivas concebidas por la UAESP no logran identificar el grupo destinatario de las mismas. Si bien se habla de recicladores, el hecho es que el alejamiento radical entre las asociaciones de segundo y primer nivel no permite ni permitir? en el esquema bajo estudio, que aquellos que son objeto de protecci? constitucional especial, encuentren beneficios con la adjudicaci? del contrato.

-

108. Los motivos anteriores suponen modificaciones estructurales al pliego de condiciones porque tocan con elementos de habilitaci? □acciones de industria- y de calificaci? □las mismas acciones y el aprovechamiento-, lo cual impide que pueda ser modificado parcialmente, dado que, se reitera, el modelo de licitaci? planteado por la UAESP no supera el test estricto efectuado para casos como el presente, al desconocer las necesidades y caracter?ticas propias de los componentes del servicio p?lico de aseo que se pretend?n licitar y su relaci? con la labor que acometen los recicladores. Estos elementos son transversales al proceso de selecci? porque tocan el componente financiero y alterarlos supondr? desarticular el pliego de condiciones, ya que cualquier cambio que se haga en las utilidades que recibir? n las asociaciones de segundo nivel como socias de industria, alterar? indefectible y sustancialmente el

esquema presentado por los proponentes.

Finalmente, la Sala de Revisi? tiene en cuenta que la ciudad no se encuentra ni se encontrar? desprovista del servicio p?lico de aseo, en raz? a que existen, como se ha dicho, unos contratos en operaci? por los cuales los contratistas se obligan ante el Distrito a prestar de manera eficiente el servicio y en la medida en que ?te cuenta, a su turno, con herramientas jur?icas suficientes que le permiten hacer frente a la situaci? sin que ning? sector de la poblaci? se vea vulnerado por la presente decisi?.

?denes concretas.

109. Comprobado y fundamentado el incumplimiento de las ?denes impartidas en la sentencia T-724 de 2003 y en el Auto 268 de 2010, que se materializa dentro del proceso de selecci? abierto por el Distrito para □(□) concesionar[,] bajo la figura de ?eas de Servicio Exclusivo, la prestaci? del servicio p?lico domiciliario de aseo en la ciudad de Bogot?D.C. □ Colombia, en sus componentes de recolecci?, barrido, limpieza de v?s y ?eas p?licas, corte de c?ped, poda de ?boles en ?eas p?licas y transporte de los residuos al sitio de disposici? final y todas las actividades de orden financiero, comercial, t?nico, operativo, educativo y administrativo que ello conlleva□ (Cuad. 1, folio 6), la Sala de Revisi? **ordenar? dejar sin efecto la Licitaci? P?lica No. 001 de 2011,**as?comotodos los actos administrativos proferidos con ocasi? de dicho proceso, en orden a que el Distrito defina y redise? un esquema que dignifique la actividad del reciclaje y que tienda a su normalizaci? a trav? de la fijaci? de metas a cumplir en el corto plazo que sean concretas, cualificadas, medibles y verificables. Tal esquema ser?entregado a esta Corte, as?como a la Procuradur? General de la Naci?, para su seguimiento, a m? tardar el 31 de marzo del a? 2012. Dicho Plan deber?contener acciones afirmativas en favor de la poblaci? que se dedica de manera permanente a la actividad de reciclaje -lo que supone un enfoque diferencial-, de manera que se logre su regularizaci? respecto de la prestaci? de los servicios complementarios de aseo en los componentes de reciclaje, transporte, transformaci? y aprovechamiento de residuos. El seguimiento a tales metas ser?realizado por la Procuradur? General de la Naci? a trav? de la dependencia que estime competente para el efecto.

El esquema que contenga las mencionadas acciones positivas en favor de los recicladores se podr? incluir a nivel de regulaci? distrital, en el plan de gesti? integral de residuos s?idos -PGIRS-, siempre que su ejecuci? se materialice en el corto plazo, en los procesos de concepci? y/o contrataci? de servicios de aseo, as?como en la prestaci? misma de los mencionados servicios p?licos, de acuerdo con las pautas generales y criterios ya se?lados por esta Corporaci? en sus diferentes providencias (en especial la sentencia T-724 de 2003 y el auto 268 de 2010), la normatividad vigente y la especificidad del componente de aseo.

110. Por otro lado, la Administraci? Distrital deber?normalizar en el menor tiempo posible -dadas las actuales circunstancias de contrataci? de urgencia-, la prestaci? del servicio p?lico de aseo en sus componentes de recolecci?, transporte al sitio de disposici? final, barrido, limpieza de v?s, corte de c?ped y poda de ?boles, a trav? del esquema que estime pertinente y atendiendo para el efecto las metas que sean fijadas por el Distrito para entrar a operar en el corto plazo.

111. Para efectos de lograr la regularizaci? del servicio de aseo en los componentes de reciclaje,

tratamiento y aprovechamiento, el Distrito podr?hacer uso,entre otras, de la figura legal de "organizaciones autorizadas" para la prestaci? de servicios p?licos domiciliarios, consagradas por el Legislador en el art?ulo 15, numeral 4 de la Ley 142 de 1994, las cuales en t?minos de la sentencia C-741 de 2003, no s?o pueden prestar servicios a municipios menores, en zonas rurales y en zonas urbanas espec?icas, sino competir en cuanto a la prestaci? de servicios p?licos domiciliarios en cualquier lugar del territorio nacional, aspecto al cual fue condicionada la exequibilidad de la citada norma.

Vale decir que estas organizaciones son diferentes a las asociaciones de primer y segundo nivel que operan para la representaci? de los recicladores, en la medida en que se les reconoce como prestadores autorizados por la Superintendencia de Servicios P?licos, para los cuales el Distrito en coordinaci? con la Comisi? de Regulaci? de Agua Potable y Saneamiento B?ico deber?establecer par?etros para la prestaci? de los servicios de reciclaje, tratamiento, aprovechamiento e intermediaci? en el modelo de comercializaci? de los residuos, aspecto que se reflejar?en el esquema de metas verificables en el corto plazo.

112. En consecuencia, se ordenar?al Distrito definir con la colaboraci? t?cnica de la CRA -a quien se exhortar?para tal efecto-, par?etros especiales que definan c?o ser? ofrecidos en la pr?tica los servicios de reciclaje, tratamiento y aprovechamiento de residuos y, la forma en que la prestaci? de los mismos deber? ser remunerada, bien a trav? de la tarifa o bien mediante la fijaci? de un esquema de precios, de forma que estos componentes sean manejados ?tegramente por las organizaciones de recicladores que entren en proceso de regularizaci?.

En ese orden, se deber?se?lar la manera en que el esquema de libre competencia u otro legalmente posible para los componentes de reciclaje, tratamiento y aprovechamiento se coordinar?con otros modelos de operaci? como la concesi? de ?eas de servicio exclusivo autorizadas para los componentes de recolecci? y transporte de residuos no separados o cualquier otro modelo, garantizando alternativas a trav? de las cuales sectores de la poblaci? tradicionalmente marginados, participen de manera real y material en la prestaci? del servicio p?lico de aseo en sus componentes complementarios de reciclaje, transformaci? y aprovechamiento. Este aspecto deber?reflejarse en el esquema de metas a corto plazo se?lado en el numeral 105 de esta providencia.

113. En esos t?minos, la Sala rechazar?de plano cualquier medida o f?mula, como la planteada en el esquema de selecci? que se deja sin efecto, en la cual se establezca la entrega de utilidades o remuneraciones a asociaciones de recicladores que en la pr?tica no prestan ninguno de los servicios complementarios de aseo o en la que se reciban beneficios inconsultos que no remuneran el trabajo de los recicladores, con los cuales se pretenda beneficiar a unos pocos afiliados y no a la universalidad de la poblaci? recicladora. Por la misma raz?, la Sala de Revisi? ordenar?dar traslado a la Contralor? General de la Rep?lica, a la Contralor? Distrital, a la Procuradur? General de la Naci? y a la Fiscal? General de la Naci? del proceso que por esta v? se deja sin efectos con el fin de que se investiguen las posibles irregularidades cometidas en el proceso de constituci? de asociaciones de recicladores por parte de afiliados no dedicados a la actividad econ?ica del reciclaje, s?o con la finalidad de beneficiarse de los esquemas de reparto de utilidades planteado en la Licitaci? p?lica No. 001 de 2011^[56].

114. Lo expuesto, requiere habilitar un modelo que opere en dos v?s, esto es: un trabajo coordinado en materia de regulaci? en el nivel distrital y en el nivel nacional. En caso de que el Distrito decida abrir un

proceso de licitaci? para la concesi? de cualquiera de los componentes del servicio p?lico de aseo o para la celebraci? de contratos de prestaci? de servicios o establezca la operaci? bajo cualquier otro esquema, se deber? incluir acciones afirmativas en favor de la poblaci? de recicladores del Distrito que respondan a los par?etros de esta providencia y al esquema de metas propuesto para ser cumplido en el corto plazo.

-

115. Por tal motivo se exhortar? a la Comisi? de Regulaci? de Agua Potable y Saneamiento B?ico en su calidad de ?gano aut?omo nacional de car?ter t?nico para: (i) En desarrollo de sus competencias constitucionales y legales revisar y definir par?etros generales para la prestaci? de los servicios de reciclaje, tratamiento y aprovechamiento de residuos s?idos, aspecto que deber? estar listo y reglamentado en el primer trimestre del a? 2012. Para el efecto, la Comisi? trabajar? aspectos tales como la separaci? en la fuente por parte de los usuarios, formalizaci? de rutas y modelos para la recolecci?, transporte y disposici? de material aprovechable por parte de la poblaci? recicladora; posibilidades de est?ulos para la creaci? y funcionamiento de organizaciones autorizadas (recicladores) prestadoras de los servicios de reciclaje, tratamiento y aprovechamiento de residuos; reglas de creaci? y funcionamiento de centros de acopio como intermediarios dentro de los procesos de reciclaje, tratamiento y aprovechamiento, as? como para parques de aprovechamiento. (ii) Asegurarse que dichos par?etros se vean reflejados en la metodolog? tarifaria actualmente en construcci? por la Comisi? de Regulaci?. (iii) Acompa?r desde el punto de vista t?nico y, en desarrollo de la funci? de colaboraci? arm?ica de las instituciones p?licas, al Distrito en la definici? de par?etros normativos del orden distrital que favorezcan las actividades de reciclaje, tratamiento y aprovechamiento de los residuos.

-

116. Ordenar al Distrito que con el acompa?miento de la Comisi? de Regulaci? de Agua Potable y Saneamiento B?ico, genere la regulaci? normativa necesaria para: (i) establecer, en lo posible, la separaci? en la fuente de todos los usuarios en la Capital de la Rep?lica; (ii) el establecimiento de rutas y modelos para el transporte y la recolecci? de residuos aprovechables que funcionen de manera coordinada con los componentes de recolecci? y transporte de residuos s?idos en ?reas de servicio exclusivo de forma que no se genera una competencia por los mismos desechos en condiciones de desigualdad; (iii) la definici? de est?ulos para procesos de creaci? de prestadores organizados para el reciclaje, la comercializaci? de residuos, transformaci? y aprovechamiento de los mismos; (iv) el dise? de pol?icas y sistemas de financiaci? blandos que favorezcan la creaci? de microempresas para el aprovechamiento y transformaci? de las basuras; la posibilidad de incentivos para la creaci? de centros de acopio en las diferentes ?reas de servicio exclusivo y su regularizaci?, de forma que se definan sus par?etros de funcionamiento dentro de esquemas que estimulen el libre mercado, fijaci? de precios y costos de intermediaci?; (v) la creaci? y funcionamiento de los parques de reciclaje que no hayan sido creados en abierto incumplimiento del Plan de Gest? de Residuos S?idos desde el a? 2001. Ofrecer garant?s de acceso a la creaci? de estas organizaciones por parte de recicladores informales, as? como de aquellos afiliados a las asociaciones de recicladores de primer y segundo nivel, entre otras. Toda esta regulaci? deber? estar comprendida en el esquema de metas a corto plazo y deber? ser concreta, cualificable, cuantificable, medible y verificable.

-

117. Adicionalmente se ordena al Distrito actualizar el censo de recicladores adelantado por la Universidad Javeriana, con prop?ito de identificar y carnetizar a los recicladores formales e informales dela ciudad; establecer horarios y rutas de reciclaje -con participaci? de las organizaciones de recicladores- que funcionen de manera coordinada con los horarios y rutas de recolecci? de basuras por parte de los operadores concesionados y su difusi?, de forma que los recicladores puedan optimizar la actividad de recolecci? de material aprovechable, en orden a evitar que compitan con el operador regular. La definici? y operaci? de centros de acopio debidamente distribuidos por toda la ciudad a los cuales pueden dirigirse los recicladores y las medidas de precios que regir? la compra e intermediaci? de los residuos aprovechables; as? como cualquier otra obligaci? que sea definida por el Distrito como

acci? positiva en favor de esta poblaci?.

118. Para la Sala es necesario precisar que las medidas de acci? afirmativa llamadas a ser dispuestas, pueden representar deberes, cargas u obligaciones para los recicladores en raz? a que prestan un servicio p?lico con ingentes beneficios ambientales para el colectivo, tal y como ha sido se?lado a lo largo de esta providencia. En ese sentido, el esquema de medidas a cumplir en el corto plazo, de conformidad con la normatividad existente y con las ?denes contenidas en esta providencia, deber? establecer compromisos, cargas y obligaciones en cabeza de los recicladores para su adecuada normalizaci?. Lo anterior, por cuanto la protecci? especial que merecen como sujetos en condiciones de vulnerabilidad no es obst?ulo para disponer acciones de doble v?, dada la naturaleza del servicio p?lico domiciliario y esencial del cual participan.

DECISI?.

En m?ito de lo expuesto, la Sala Tercera de Revisi? de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constituci?

RESUELVE

PRIMERO.- DECLARAR EL INCUMPLIMIENTO por parte de la UAESP de las ?denes conferidas en la sentencia T-724 de 2003 y de los criterios generales fijados en el Auto 268 de 2010.

SEGUNDO.- DEJAR SIN EFECTO la Licitaci? P?lica No. 001 de 2011, as?como todos los actos administrativos dictados con ocasi? de dicho proceso.

TERCERO.- ORDENAR a la Alcald? Mayor de Bogot? a trav? de la Unidad Administrativa Especial de Servicios P?licos (UAESP) -o la entidad que haga sus veces-, que **defina** un esquema de metas a cumplir en el corto plazo con destino a la formalizaci? y regularizaci? de la poblaci? de recicladores, que contenga acciones concretas, cualificadas, medibles y verificables, el cual debe ser entregado a la Corte Constitucional, as?como a la Procuradur? General de la Naci? a m? tardar el 31 de marzo del a? 2012. Dicho Plan deber?definirse a partir de las ?denes previstas en los numerales 109 a 118 de esta providencia.

CUARTO. ORDENAR a la Procuradur? General de la Naci? que efect? la labor de seguimiento al esquema de metas de corto plazo elaborado en favor de la poblaci? de recicladores por parte del Distrito e informe de su evoluci? y cumplimiento a la Corte Constitucional de manera trimestral.

QUINTO.- EXHORTAR a la Comisi? de Regulaci? de Agua Potable y Saneamiento B?ico (CRA) para

que revise y defina parámetros generales para la prestación de los servicios de separación, reciclaje, tratamiento y aprovechamiento de residuos sólidos en los términos establecidos en el numeral 115 de esta providencia. La CRA remitir un informe de los parámetros que hayan sido o vayan a ser fijados a la Corte Constitucional a más tardar dentro del primer trimestre del año dos mil doce (2012). La CRA deberá asegurarse de que tales parámetros se reflejen en la estructura tarifaria que por virtud de la ley debe ser fijada en el año dos mil doce (2012).

-

SEXTO.- EXHORTAR a la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA), para que acompañe y preste su colaboración al Distrito -a través de la UAESP o de la entidad que haga sus veces-, en la definición de la regulación especial a nivel distrital dirigida a la regularización de la población de recicladores en los componentes de separación, reciclaje, transformación y aprovechamiento de residuos, en los términos del numeral 116 de esta providencia.

-

SETIMO.- ORDENAR, a la Alcaldía Mayor de Bogotá a través de la UAESP o de la entidad que haga sus veces, que normalice en el menor tiempo posible la prestación del servicio público de aseo en sus componentes de recolección, transporte al sitio de disposición final, barrido, limpieza de veredas, corte de césped y poda de árboles, a través del esquema que estime pertinente, atendiendo para el efecto las metas que sean fijadas por el Distrito para entrar a operar en el corto plazo en favor de la población de recicladores de la ciudad.

-

OCTAVO.- ORDENAR a la Secretaría General de esta Corporación que dimita, en los términos del numeral 113 de las ordenes concretas de esta providencia, a la Contraloría General de la República, Contraloría Distrital, Procuraduría General de la Nación y a la Fiscalía General de la Nación.

-

NOVENO.- ORDENAR a la Alcaldía Mayor de Bogotá a través de la UAESP o de la entidad que haga sus veces, por el mecanismo que estime pertinente, que actualice el censo de recicladores elaborado por la Universidad Javeriana.

-

Notifíquese, comuníquese y céplase,

-

-

-

JUAN CARLOS HENAO PEREZ

Magistrado

-

-

-

GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO

Magistrado

-

-

-

JORGE IVAN PALACIO PALACIO

Magistrado

-

-

-

MARTHA VICTORIA SACHICA DE MONCALEANO

Secretaria General

ANEXO 1

1. Intervenci? de la peticionaria: Nohra Padilla Herrera

1.1 Por medio del Auto 189 de 2011, el Magistrado Ponente formul?los siguientes interrogantes a la peticionaria, la se?ra Nohra Padilla Herrera:

▪ ¿C?o funciona la ruta de reciclaje?

▪ ¿Qu?relaci? tienen los recicladores con ella?

▪ ¿C?o funciona el Servicio P?blico de Aseo?

▪ ¿Cu?do intervienen los recicladores en ??

▪ ¿Qu?par?etros fueron negociados con cada uno de los proponentes para la respectiva ASE que les fue asignada tras el sorteo efectuado por la UAESP? En este sentido

▪ ¿Qu?derechos tendr? como organizaci? de recicladores en raz? a tales negociaciones? Y ¿C?o se relacionan estas prerrogativas con el pliego de condiciones?

▪ ¿Qu?entienden por acceso cierto y seguro a los residuos s?idos?

▪ Consideran que con los par?etros de la actual licitaci? ¿se est?garantizando tal acceso?

Dichas cuestiones fueron absueltas por la peticionaria de la siguiente manera:

1.2 Frente al primer interrogante relativo a c?o han experimentado las organizaciones de recicladores - desde la econom? informal - la recolecci? y el transporte de residuos potencialmente aprovechables en la urbe capitalina, manifest?que los recicladores, por su mismo oficio, efect?n rutas que pueden ser catalogadas como selectivas. Aunado a esto y para explicar la complejidad del asunto, apunt?que las bodegas existentes en Bogot? □ antes de la regulaci? efectuada por el Distrito mediante el Decreto 456 de 2010 □ se constitu?n en un eslab? fundamental de estas rutas que han existido por □ (□) m? de 80 a? s (□) □ (AZ 5, folio 329), pues en ellas se acopia el material recolectado por los recicladores en las 19 localidades urbanas de Bogot?.

A continuaci?, expuso que un elemento determinante de la viabilidad de la labor de este grupo poblacional, as?sea en la informalidad, son los veh?ulos que se utilizan para transportar los residuos. Pero en todo caso, ya sea mediante carros de tracci? humana o animal (zorras), la actuaci? de los recicladores siempre sigue las rutas y frecuencias de los operadores del servicio de aseo. Sin embargo, existen dis?iles circuitos de recolecci? que, a su vez, cuentan con distintas formas de operaci? □ afectada en todo caso por la reducci? de las bodegas-.

Se trata entonces de una cadena donde intervienen diferentes actores. Afirma que, ☐ () el material reciclado tiene tan bajo costo que garantiza gran rentabilidad y acumulaci? de capital para la industria, [pero] no para el recuperador o el comercializador [de las bodegas] ☐ (AZ 5, folio 331). Por otra parte, expuso que el mercado define la din?ica del valor de estos materiales, pero ☐ () de ninguna manera cubre el valor real del trabajo de los recicladores de oficio, y del comercializador o bodeguero ☐ (AZ 5, folio 331).

-

En esta actuaci?, seg? el censo de la Universidad Javeriana, se recogen al menos 1200 toneladas al d? de material reciclable. ☐ Es decir que [sus] rutas informales de reciclaje operan por fuera de todo contrato de recolecci? y transporte para eliminaci? por aprovechamiento industrial del 27% de las basuras que produce la ciudad, mientras que las rutas formales [de reciclaje] de los concesionarios operando bajo contrato solo recogen el 3%. [Hay que aclarar que] la ruta de los recicladores de oficio en pobreza junto a la ruta de los operadores contratados, aunque en distinta proporci? y con distintos esfuerzos, son el sistema de reciclaje que sustenta a la ciudad ☐ (AZ 5, folio 330). Por lo mismo y a pesar de no ser reconocidos formalmente, las rutas informales que operan desde hace a?s son esenciales para el manejo de residuos en Bogot? beneficiando al colectivo, generando mercanc?s y prolongando la vida ?il del relleno sanitario, a m? de otros beneficios ambientales.

-

1.3 En relaci? con la segunda pregunta, hizo referencia a la ruta de reciclaje formal existente en la urbe capitalina, coordinada por la UAESP, entregada a los operadores del servicio de aseo desde la licitaci? de dos mil tres (2003) y que incluye el centro de acopio La Alquer?; operado por una Uni? Temporal conformada por tres (3) organizaciones de segundo nivel desde agosto de dos mil ocho (2008), gracias a las ?denes de la sentencia T-724 de 2003.

-

En esta ruta formal, se acord? que los cuatro operadores ☐ Ciudad Limpia, Aseo Capital, Lime y Atesa ☐ tendr?n siete (7) frecuencias semanales, en setenta y tres (73) micro rutas, para las seis (6) ASEs existentes. El material que recogen equivale ☐ aproximadamente - a doce (12) toneladas y, para su funcionamiento, utilizan seis (6) carros, dieciocho (18) operarios y un promotor social. En el centro de acopio, que ☐ () cont?con la financiaci? que inici?con el 100% de la UAESP, hasta llegar al 10% del cubrimiento de los costos del Centro, [dado que] progresivamente la operaci? cubr? los costos () ☐ (AZ 5, folio 332), trabajan cincuenta (50) recicladores de manera permanente y cien (100) de manera temporal. Por ello, cree que el manejo del mismo demuestra la capacidad de estas organizaciones para constituirse en empresarios de las basuras.

-

En este sentido, manifest?que estas medidas tambi? se debieron al desarrollo de las disposiciones contempladas en el Plan de Manejo de Residuos S?idos para Bogot? ☐ PMIRS ☐ y permitieron que los recicladores se capacitaran, certificaran sus actividades y devengaran ☐ al menos dos mil (2000) de ellos ☐ ingresos en condiciones de dignidad. Con todo, el centro ☐ La Alquer? ☐ es piloto, pues la idea original era crear parques de reciclaje. Lastimosamente, ?tos no se consolidaron. Cabe se?lar que la interviniente enfatiz?que esas rutas actuales compiten con la recolecci? efectuada por los recicladores de base de manera informal.

-

1.4 En la tercera parte, se pronunci?sobre las rutas de reciclaje que se proponen para el lapso comprendido entre dos mil once (2011) y dos mil diecinueve (2019), seg? ☐ () [ha] logrado entender de los pliegos y conversaciones con la UAESP () ☐ (AZ 5, folio 333). En este orden de ideas, apunt?que en su sentir no pueden constituirse o funcionar, por cuanto la libre competencia lo impedir? ya que ☐ () en

vez de formalizar[los, conlleva] el desorden del reciclaje, [la] rapi? [y los] mete (□) con uniformes y obligaciones, pero sin remuneraci? y como socios (□)□ (AZ 5, folio 333). Por ello, tendr? que competir con sus compa?ros m? vulnerables, afectando la paz social y los ingresos de aquellos recicladores de base no organizados.

-

1.5 Se refiri? a la manera como intervienen los recicladores en el servicio de aseo. Para ello, mencion? las Leyes 142 de 1994, 632 de 2000, as? como los Decretos 1713 de 2002 y 1505 de 2003, y expuso que dentro de este marco normativo figura el aprovechamiento, la recolecci?, el transporte, el tratamiento y la disposici? final, entre otras actividades como parte del mentado servicio. Con todo, enfatiz? que el componente de recolecci? incluye todos los residuos s?idos que se llevan al sitio de disposici? final o al de aprovechamiento.

-

En este sentido, los recicladores intervienen en la separaci? de los residuos desde el punto de origen, en la recolecci? y transporte hasta puntos de acopio (bodegas), en la selecci? y acondicionamiento de los materiales recuperados, y en la pretransformaci? de los mismos. As? las cosas, esta poblaci? act? de manera similar a los operadores, pero -al desplegar su oficio- adicionan actividades como la recuperaci? y el aprovechamiento. Igualmente, el destino de su labor no es el relleno sanitario, sino los centros de acopio. Si ellos no operaran, as? sea informalmente, □(□) el servicio de aseo enterrar? en el Pa? m? de 8 mil toneladas al d? en los rellenos sanitarios y por ende tendr? que introducir m? carros, m? personal (□), m? actividades y sus utilidades disminuir?n sustancialmente□ (AZ 5, folio 335).

-

1.6 Expuso tambi? que no ha negociado con ninguno de los proponentes, dado que las condiciones del pliego han acarreado que no haya lugar a ello. De hecho, enfatiz? el modelo planteado por la UAESP□(□) est? entregando la exclusividad sobre el reciclaje a los empresarios del aseo de manera disimulada (□)□ (AZ 5, folio 336). Con todo, no ahond? en razones que justificaran tal aseveraci?.

-

Por otra parte, apunt? que los altos porcentajes de acciones otorgadas, hacen dudar que los operadores reporten realmente las utilidades generadas. En este sentido, aleg? que les han recomendado contratar auditorias; lo que resulta contradictorio, dado que las acciones afirmativas se sustentan en las condiciones de marginaci? en las que sobreviven, por lo cual evidentemente no cuentan con los medios para sufragarlas. A m? de lo anterior, record? la existencia de organizaciones de cuestionable procedencia que sin importar el n?ero de afiliados -gracias a Adendas de ?tima hora, como la n?ero 8- recibir? por partes iguales los posibles beneficios econ?micos. Por lo mismo, esta medida no se consolida como un incentivo de organizaci? y formalizaci?, sino todo lo contrario: un impulso para desarticular las asociaciones existentes.

-

Adicionalmente, mencion? que si bien podr? ser favorable para la poblaci? en comento la contrataci? por parte de los operadores, lo cierto es que no existe garant? de duraci? o estabilidad de estos v?culos laborales. De hecho, si estos dejan la ruta informal que realizan tradicionalmente ante la posibilidad de un nuevo trabajo, la misma ser? ocupada por otro reciclador y, al volver, tendr?n que buscar una nueva.

-

1.7 Indic? que por acceso cierto y seguro a los residuos s?idos entiende la posibilidad de ejercer su oficio sobre □(□) la basura que producen los hogares, las oficinas y la industria [,] para poderla recuperar y transportar[,] y luego separarla en pl?stico[,] metal, cart? y vidrio (□)□ (AZ 5, folio 338).

Ahora bien, enfatiz?que el acceso que han tenido hasta este momento se debe a la ausencia de rutas formales de reciclaje y al olvido del Estado sobre esta materia. Empero, cuando empezaron a implementarse medidas al respecto, se decidi?entregar el funcionamiento de las mismas a los operadores privados, excluyendo as?a los recicladores. Fue por esto la implementaci? de un modelo de recolecci? y transporte de la totalidad de residuos s?idos en cabeza de grandes empresarios □ que se vieron en la necesidad de instaurar la acci? de tutela que dio origen a la T-724 de 2003.

En este orden de ideas, aleg?que □(□) con la nueva licitaci? no [tienen] acceso cierto y seguro porque si antes [estaban] reciclando informalmente al lado de los operadores, ahora [entran] a competir formalmente en pleno libre mercado por el acceso a la basura. Tener uniformes y posibles utilidades por acciones no equivale a tener acceso cierto constante y permanente a las canecas de basuras. [As?las cosas, resulta incomprensible] que ahora que le quitaron la ruta selectiva del contrato a los operadores deciden no darla a quienes informal pero tradicionalmente la han operado (□)□ (AZ 5, folio 339). De hecho, al contemplar la licitaci? que los operadores deben formular planes de acci? para optimizar el reciclaje, en realidad les est?entregando la exclusividad sobre esta actividad. □Decir que el reciclaje lo har? los Recicladores a los que antes les han cortado el circuito de acopio, los han dejado sin veh?ulos y los pone (sic) a despesa de organizaciones de papel y empresarios con autorizaci? para formular los planes de acci? de reciclaje [,] es una manera formal de trasladar el oficio de manos (□)□ (AZ 5, folio 339).

Sobre el punto hizo ?fasis en que debe analizarse la licitaci? en concordancia con medidas como el cierre de bodegas □ asunto que dificulta el trabajo informal de los recicladores que deber? caminar por horas para poder comercializar los materiales -, y la carencia de veh?ulos de transporte para poder movilizarse en recorridos de larga distancia. S?o as?es posible comprender c?o las medidas adoptadas no ayudan a este grupo poblacional. A su parecer, en desarrollo de las obligaciones de incluir acciones afirmativas, se □(□) debi?[dar] al gremio no solo trato igual que a los operadores, sino preferencial para contratar en exclusividad las rutas de reciclaje, luego con esto acent? las condiciones de vulnerabilidad del gremio y (□) lo despoja sutil pero progresivamente de su oficio y por lo tanto[,] reitera y profundiza la violaci? al trabajo de los recicladores y la leg?ima confianza que le otorg?al gremio (□)□ (AZ 5, folio 341). De esta manera, podr?n consolidarse como empresarios de las basuras, calidad que no se les reconoce en la licitaci? en comento.

1.8 Por otra parte, aleg?que escogi?el ASE 2 por cuanto, a pesar de contar con organizaciones de base en toda Bogot? en ella operan importantes aliados de la cadena del reciclaje. Adicionalmente, mencion? que la adenda 2 les impon? la selecci? de una ASE, bajo la amenaza de quedarse por fuera del proceso.

2. Intervenciones institucionales.

2.1 Veedur? Distrital (AZ 2, folio 160 a 165)

La Veedora Distrital -Mar? Consuelo del R? Mantilla- radic?escrito ante esta Corporaci? el diecisiete (17) de agosto de dos mil once (2011), en el cual explica que desde marzo de ese a? la Veedur? Distrital ha realizado una labor de acompa?miento al proceso licitatorio No. 001 de 2011. Tal labor la ha efectuado con el fin de detectar □(□) los posibles riesgos que puedan afectar el proceso contractual y

[promover] actuaciones ?icas entre los interesados en el concurso del mismo□ (AZ 2, folio 160).

2.1.1 Afirm?que desde que inici? su acompa?miento se han efectuado diez (10) modificaciones al Pliego de Condiciones, □(□) de las cuales las adendas Nos. 2 de junio 14 de 2011, 6 de junio 24 de 2011, 7 de 13 de julio de 2011, 8 de 22 de julio, 9 y 10 de julio 25 de 2011 (□)□ (AZ 2, folio 161) atendieron asuntos relacionadas con la poblaci? recicladora. Es importante resaltar entonces, que al menos cinco de las 10 variaciones que se efectuaron en el pliego fueron llevadas a cabo a partir de junio de este a?.

2.1.2 Entre los puntos resaltados por la Veedora, se encuentran los siguientes: (1) La realizaci? de 10 modificaciones al pliego de condiciones definitivo, varias de ellas en respuesta a inquietudes planteadas por la poblaci? recicladora. (2) La inclusi? del componente de gesti? social en el Anexo 5 del pliego de condiciones. (3) La obligaci? impuesta a los concesionarios de proporcionar a los recicladores de su ASE una dotaci? correspondiente a uniformes, equipos y veh?ulos necesarios para la realizaci? de su actividad. En este sentido, expuso que □(□) la recolecci? selectiva estar?a cargo de los recicladores de oficio en cada ASE, quienes continuar? ejerciendo su actividad en las zonas de la ciudad que actualmente lo hacen (□) independientemente de la asociaci? de recicladores de segundo nivel a la que pertenezcan (□)□ (AZ 2, folio 161); (4) La destinaci? del 50% del monto anual del aprovechamiento en el marco de la gesti? integral de los residuos s?idos a un □Fondo Reciclaje□ en beneficio de la poblaci? recicladora o de su actividad. Sin embargo, no especific?qu?es dicho fondo; (5) El establecimiento de condiciones m?imas para habilitar la participaci? de las organizaciones de segundo nivel y el sorteo para la escogencia de cada ?ea de Servicio Exclusivo □ ASE de acuerdo con su antig?dad. A su vez, resalt?la existencia de un □(□) plan de trabajo a adelantar a efectos de la implementaci? de las actividades de fortalecimiento y formalizaci? de la recolecci? de material potencialmente aprovechable, que ser?realizada por los recicladores de oficio ubicados en el ASE respectiva (□)□ (AZ 2, folio 162); (6) La realizaci? de una convocatoria p?blica de amplia difusi? con el ?imo de que todas las organizaciones de recicladores de segundo nivel que operan en la ciudad pudieran inscribirse, quedando doce (12) elegidas y asignadas de a dos (2) por cada ASE; y (7) La cesi? de la participaci? accionaria como acciones de industria en un porcentaje no menor al 5% a favor de las organizaciones de segundo nivel que le hayan sido asignadas en el ASE correspondiente. Sobre este punto, expuso □ adem? □ que □(□) el d? del cierre de la licitaci?, julio 29 de 2011, verific?que en ning? caso dicho porcentaje fue inferior al 5%□ (AZ 2, folio 163).

2.1.3 Igualmente, las organizaciones de segundo nivel tendr? derecho a: (1) recibir utilidades al menos una vez al a?; (2) participar porcentualmente del mayor valor de la empresa al momento de su liquidaci?; (3) la no modificaci? del porcentaje de participaci? en ning? momento de la concesi?. Como garant?, se?l?que las organizaciones de segundo nivel no podr? vender ni ceder a ning? t?ulo su participaci? accionaria.

2.1.4 Por lo dem? y en relaci? con el cumplimiento de las ?denes contenidas en la Sentencia T-724 de 2003 y en el Auto 268 de 2010, la Veedur? Distrital aleg?que: (i) el pliego de condiciones incluy?como requisito habilitante de participaci? que los proponentes deb?n presentarse conformados con m?imo dos (2) organizaciones de recicladores de segundo nivel de Bogot? (ii) se establecieron como criterios de calificaci? los denominados □cesi? de la participaci? accionaria a la organizaci? de recicladores de segundo nivel del Distrito Capital□, □Porcentaje de aprovechamiento□ y □Porcentaje de mano de obra de poblaci? recicladora contratada para adelantar las labores de corte de c?ped y poda de ?boles. Reciclaje□ (AZ 2, folio 165). A estos criterios se asignaron 100, 50 y 50 puntos respectivamente.

2.1.5 En suma, para la Veeduría Distrital, la UAESP () dio cumplimiento a las dos providencias antes anotadas [Sentencia T-724 de 2003 y Auto 268 de 2010] en relación con la implementación de acciones afirmativas en desarrollo de la Licitación Pública No. 001 de 2011 (AZ 2, folio 165). Sin embargo, cabe precisar que esta entidad no indica por qué estas medidas se constituyen en acciones afirmativas materiales, que están destinadas -temporalmente- a favorecer a un grupo desventajado para superar la situación de exclusión en la que se encuentran. De hecho, en su escrito básicamente se relatan elementos contenidos en el Pliego de Condiciones.

2.2. Red de Veedurías de Colombia y Veedores sin Fronteras (AZ 2, folio 166 a 175).

2.2.1 El coordinador internacional de VEEDORES SIN FRONTERAS y co-fundador y actual presidente de la RED VER, RED DE VEEDURÍAS CIUDADANAS DE COLOMBIA -Pablo Bustos Sánchez- en su escrito de intervención, radicado ante esta Corporación el día diecisiete (17) de agosto de dos mil once (2011), eleva ante esta Corporación la petición consistente en solicitar que el proceso licitatorio originado por la Licitación Pública 001 de 2011 () continúe sin interrupción alguna dado que el mismo cuenta con el riguroso y juicioso acompañamiento de los órganos de control, y de veeduría ciudadana (AZ 2, folio 167).

A su juicio la suspensión de la Licitación Pública 001 de 2011, solo beneficia a los actuales operadores del servicio de aseo quienes habrían tratado de entorpecer el proceso licitatorio en curso para seguir asegurándose los gigantescos dividendos derivados de la continuidad de sus operaciones-. En este sentido, se le pide que prorrogar la concesión actual solo perjudica a las personas que habitan la urbe capitalina, dado que deberán pagar aproximadamente cinco mil millones de pesos (\$5.000.000.000) por cada mes adicional, dinero que va directamente a las arcas de los actuales operadores del servicio de aseo sin retribución alguna en términos de mejoramiento de la calidad del servicio. En este sentido, expuso que existe () un sobreprecio del 20% en la tarifa actual con relación a la que se cobraría con los nuevos contratos () (AZ 2, folio 169).

2.2.2 Indica que resultó una garantía al proceso la suspensión de la directora de la UAESP. Myriam Martínez, asunto que -por lo demás- () fue nuestro persistente requerimiento () a efecto de asegurar su transparencia y selección objetiva () (AZ 2, folio 167).

2.2.3 Recordando que la Comisión de Regulación de Agua Potable y saneamiento Básico expidió la Resolución CRA 512, por la cual amplió por un año el marco vigente de Régimen de Servicio Exclusivo en Bogotá. Empero, dado que esta condición de exclusividad solo se mantendrá hasta el diez (10) de septiembre del presente año, la suspensión del proceso licitatorio podrá acarrear la pérdida del servicio de aseo en el Distrito () trayendo como consecuencia una libre competencia que afectará notoriamente a los estratos bajos y pondrá en desventaja a la ciudad en cumplimiento del decreto 1713 de 2002, donde se establece que el servicio de aseo debe ejecutarse con continuidad, frecuencia y eficiencia a toda la población (AZ 2, folio 171), además podrá abrir la puerta a todo tipo de abusos generados por la posición dominante de los actuales operadores quienes finalmente podrán quedarse con el mercado de un día para otro (AZ 2, folio 173).

2.2.4 Finalmente, Veedores sin Fronteras enfatiza que el proceso licitatorio 001 de 2011, contempla que

a todas y cada una de las asociaciones de recicladores de segundo nivel existentes en el Distrito se les vincule. Asimismo, dado que fueron asignadas a las ASE por sorteo, se garantiza su participaci? en condiciones de igualdad. Por ello, como quiera que □(□) durante el desarrollo de la futura concesi?, ser?obligaci? de dichas asociaciones de recicladores de segundo nivel promover y facilitar activamente la afiliaci? de todos los recicladores de oficio (□), se asegura el desarrollo de mecanismos que permitan garantizar que 11.109 personas tengan acceso a la recolecci? de materiales potencialmente aprovechables. [Adicionalmente, figura] la inclusi? [de los recicladores de oficio] como mano de obra para la ejecuci? de los contratos de concesi? en los pr?imos 8 a?s□ (AZ, folio 174).

-

2.3 Procuradur? General de la Naci? (AZ 2, folio 176 a 182).

-

2.3.1 Mediante escrito radicado en esta Corporaci? el diecis?s (16) de agosto de dos mil once (2011), la Procuradur? General de la Naci? intervino dentro del presente incidente, esclareciendo que su actuaci? la adelantaba con base en □(□) la informaci? obtenida de la actuaci? preventiva desarrollada por la Procuradur? Delegada para la Vigilancia Preventiva de la funci? P?lica (□)□ (AZ 2, folio 176).

-

En este orden de ideas, relat? someramente qu??denes fueron impartidas en la sentencia T-724 de 2003, as? como las obligaciones que fueron contempladas en el Auto 268 de 2010, en relaci? con la licitaci? p?lica concerniente al Relleno Sanitario Do? Juana. A continuaci?, expuso que estos par?etros deber?n servir para analizar la conducta de la UAESP.

-

2.3.2 Se?l?que seg? el pliego de condiciones un requisito de habilitaci? es la presentaci? conjunta del proponente con una organizaci? de recicladores de segundo nivel. En este sentido, trajo a colaci? los criterios de calificaci?, que conllevan el otorgamiento de 100 puntos por la participaci? de organizaciones de recicladores y de otros 50 puntos por el empleo de mano de obra de poblaci? recicladora en cualquier actividad, es decir 150 puntos de los 1000 posibles. Respecto a este porcentaje, acot?que iguala la sumatoria de aqu? otorgado al incentivo a la industria nacional (100 puntos) y de aprovechamiento (50 puntos) y solo es superado por los 700 puntos que le corresponden al componente econ?mico.

-

As?las cosas, □(□) en el plano de los hechos no se puede negar que la UAESP ha realizado varias conductas tendientes a cumplir con lo dispuesto en las providencias atr? citadas. Si se aprecia el tenor literal de los textos citados, los cambios introducidos en las condiciones apuntan a favorecer a los recicladores (□)□ (AZ 2, folio 181). Sumado a ello, □(□) en el plano del derecho, en vista de los datos que arroja el plano de los hechos, no puede calificarse prima facie que la UAESP haya incumplido con sus obligaciones□ (AZ 2, folio 181).

-

Sin embargo, el acompa?amiento que ha realizado no significa aval alguno, co-administraci? o intromisi? en las gestiones de la entidad referida. Es m?, expuso que □(□) comparte con la Corte la preocupaci? que se pone de presente en el punto 21 del Auto 180 de 2011, pues tambi? reconoce la carencia de material probatorio para constatar el cumplimiento de las ?denes impartidas en las mencionadas providencias'□ (AZ 2, folios 181 a 182). Por ello, a pesar de que podr? considerarse que existen medidas que cumplen con el esp?itu de las acciones afirmativas y que prima facie permiten descartar que son meros paliativos, el Ministerio P?lico comparti?la necesidad de adelantar a fondo

mayores pesquisas probatorias.

2.3.3 La Procuraduría General de la Nación envió un segundo escrito a esta Corporación, con fecha dos (2) de septiembre de dos mil once (2011)^[57], en el cual repitió los elementos desarrollados anteriormente e indicó que mediante oficio No. 8813 del catorce (14) de junio de dos mil once (2011), advirtió a la UAESP () que no estaba claro que, si los proponentes debían asociarse con una organización de segundo nivel, por qué razón se estableció que las personas que van a recoger el material son los recicladores de oficio que están actualmente en cada zona, con independencia de si pertenecen o no a la organización de segundo nivel anotada (AZ 5, folio 60). Igualmente, expresó que se debían fijar condiciones y exigencias que garantizaran la prestación de las actividades por parte de los recicladores en beneficio de los usuarios.

2.4 Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP)

2.4.1 Incluso antes de que esta Corporación avocara el conocimiento del presente incidente, la entonces directora de la UAESP Miriam Margoth Martínez, envió un primer escrito destinado a justificar las razones por las cuales consideraba que la Licitación Pública 001 de 2011, daba cumplimiento a las ordenes contempladas en la sentencia T-724 de 2003 y en el Auto 268 de 2010 (AZ 2, folio 183 y ss), en los siguientes términos.

2.4.1.1 En lo planteado que los contratos adjudicados en el dos mil tres (2003) para la prestación del servicio público de aseo en Bogotá vencían el quince (15) de septiembre de dos mil once (2011). Con los nuevos contratos, para los que se inició la licitación pública No. 001 de 2011, se espera una reducción de las tarifas de aproximadamente el 19%.

2.4.1.2 De otro lado, indicó que a su juicio, en la citada licitación, se () ha cumplido a cabalidad con las decisiones proferidas por la Honorable Corte Constitucional en el sentido de adelantar acciones afirmativas a favor de los recicladores de oficio () (AZ 2, folio 183). Así entre ellas enumeró las siguientes: las organizaciones de segundo nivel fueron asignadas mediante sorteo a las ASEs existentes en el Distrito; serán socias con un porcentaje no menor al 5%; se establecieron criterios de calificación, así () se le darán 100 puntos (el mayor puntaje), a la propuesta cuya organización de segundo nivel posea el mayor porcentaje de participación en la forma asociativa propuesta por el oferente y 50 puntos al (sic) la propuesta que ofrezca el mayor número de puestos de trabajo para ser ocupados () en cualquier actividad de la prestación del servicio (AZ 2, folio 183, respaldo); los recicladores de base continuarán ejerciendo su actividad en los territorios que actualmente lo hacen () (AZ 2, folio 183, respaldo); el material potencialmente aprovechable les pertenecerá podrá comercializarlo y recibir dotaciones para ello; y, concluyó señalando que se conformará el Fondo de reciclaje, que se constituye por () el valor de las toneladas de Material Potencialmente reciclable que recojan las Rutas de Reciclaje y que dejaron de llegar al Relleno Sanitario Doña Juana (). El 50 por ciento de esos recursos será destinado para beneficiar a la población de recicladores y el 50 por ciento restante será devuelto a los usuarios del Distrito, vía factura () (AZ 2, folio 184), lo cual conlleva, además, un incentivo para la separación en la fuente.

2.4.1.3 Finalmente, afirmó que () en la metodología actual los operadores del servicio que desarrollen actividades de aprovechamiento en forma directa, o a través de terceros, reciben un incentivo que les

representa la obtenci? de ingresos adicionales a aquellos que se generan como consecuencia de esta actividad (□)□ (AZ 2, folio 184, respaldo).

-

2.4.2 El diecis?s (16) de agosto de dos mil once (2011), Bertha Cruz Forero □ actuando como Directora General encargada de la UAESP □, envi?un nuevo escrito a esta Corporaci? (AZ 2, folio 213 y ss), mediante la cual se da respuesta a algunos interrogantes que le fueron planteados en el Auto 180 de 2011:

-

2.4.2.1 Sobre el cuestionario manifest?que se est?beneficiando a doce (12) organizaciones de segundo nivel dos por cada ASE- dado que se constituyen, en calidad de socios obligatorios, en beneficiarios directos. En este sentido, expuso que podr? □(□) participar en el mayor valor de la empresa en el momento de la liquidaci? y [tendr? derecho] a participar en un porcentaje de las utilidades antes de capitalizaci? y reservas (□)□ (AZ 2, folio 213, respaldo). Esto tiene relevancia, dado que a mayor participaci? accionaria que ofrezcan los proponentes, mayor puntaje les ser?otorgado.

-

En este orden de ideas, enfatiz? que al reconocerles a los recicladores la calidad de socios, □(□) pueden participar en las juntas directivas, asistir a las asambleas, revisar los libros y papeles de la sociedad, participar en las utilidades, participar en la mayor valorizaci? de la empresa. [Igualmente] tienen como obligaci? societaria coordinar las actividades de los recicladores de su ASE buscando el mayor aprovechamiento de los materiales en su propio beneficio□ (AZ 2, folio 214, respaldo).

-

2.4.2.2 Por lo dem?, afirm?que se escogieron 12 organizaciones por cuanto □(□) acreditaron tener la condici? predicha (□). No se excluy?[a] ninguna (□) porque se trataba de incluir el mayor n?ero de recicladores (□). Sin embargo[,] a la hora de hacer la selecci? de las ASES a las seis (6) organizaciones m? antiguas se les dio la oportunidad de escoger la ASE a la que quer?n estar vinculadas y a las seis (6) restantes se les sorte?(□)□ (AZ 2, folio 214). A pesar de ello, esta Corporaci? hab? solicitado se le informara las razones por las cuales no se hab?n utilizado criterios de antig?dad para precaver que agrupaciones ficticias se beneficiaran de las acciones afirmativas a favor de un grupo poblacional espec?ico. Este interrogante no fue satisfecho en ese momento.

2.4.2.3 Expuso que las rutas de reciclaje en cabeza de los actuales operadores desaparecieron y que a los recicladores se les entreg?la posibilidad de □(□) reciclar la totalidad del materia aprovechable a su discreci?, utilizando las microrutas que operan actualmente de manera artesanal, y d?doles la posibilidad que las optimicen canalizando esta actividad a trav? de la organizaci? de recicladores de segundo nivel socia del concesionario de la ASE correspondiente (□)□ (AZ 2, folio 213, respaldo). Conviene precisar que la Corte solicit?definir qu?era la ruta de reciclaje y c?o funcionaba, pero este interrogante no fue absuelto.

-

2.4.2.4 De otro lado, sin especificar en qu?normatividad sustentaba su respuesta, indic?que no era posible fijar una □(□) tarifa a pagar a los recicladores por la recolecci? y aprovechamiento de los residuos porque tal posibilidad no est?contemplada en la actual estructura tarifaria vigente, siendo de la incumbencia de la Ley y la CRA, y no de la Unidad variarlo□ (AZ 2, folio 214).

-

2.4.2.5 Finalmente, concluy?que □(□) el proceso de licitaci? separa la recolecci?, barrido y limpieza

general de la ciudad del aprovechamiento de residuos en cabeza de los recicladores. No entrega esta (sic) ?tima actividad en exclusividad porque la ley no lo permite y porque para hacerlo se requiere obtener por parte del gremio una organizaci? seria y responsable que la unidad est?procurando construir () (AZ 2, folio 215). Sin embargo, no se?l? a qu?disposiciones se refer? al indicar que tal actuaci? estaba proscrita ni ahond?en las razones por las cuales consideraba que no exist? un nivel organizacional suficiente para permitir que los recicladores gestionaran el aprovechamiento de manera exclusiva.

-

2.4.3 De manera posterior y obrando a trav? de apoderado especial, la UAESP, remiti?un nuevo escrito a esta Corporaci?, destinado a adicionar las explicaciones requeridas mediante el Auto 180 de 2011^[58]:

-

2.4.3.1 De los elementos a destacar, es importante mencionar la referencia a un plan de trabajo que deber? presentar los concesionarios conforme al anexo 21 para fortalecer y formalizar la recolecci? del material potencialmente aprovechable. Actividad que deber?realizarse en el ASE que gane la licitaci? y que busca () generar estrategias para el incremento de material potencialmente aprovechable, mostr?dole al reciclador de manera real las diferentes oportunidades y estrategias que pueden adoptar para beneficiar y mejorar las condiciones t?nicas y operativas de la actividad (AZ 5, folio 29).

-

Adicionalmente, se expresa que las medidas adoptadas en el pliego de condiciones constituyen incentivos empresariales, dado que le otorga a esta poblaci? participaci? accionaria en las sociedades que se conformar?. Lo que a su vez fomenta la asociaci? de los recicladores de base con las estructuras de econom? solidaria existentes, ya que quien haga parte de las organizaciones y se vincule al proceso resultar? beneficiado.

-

2.4.3.2 Por otra parte, en relaci? con la ruta de reciclaje, establece que ?ta se define en t?minos delos pliegos como un () recorrido que realizar? los recicladores, recogiendo el material potencialmente aprovechable, apoyados con los equipos, dotaciones y dem? elementos que los proponentes ofrecer? en el plan de trabajo con el cual sustentar? la propuesta de aprovechamiento o reciclaje, que se incentivar?en cada ASE (AZ 5, folio 30). As?las cosas, la ruta deber?operar bajo par?etros de cobertura que redunde en el n?ero de usuarios, actuaci? que se circunscribe a la manera como se desarrollar?, y estrategias de ampliaci? de la misma, que deber? ser acordadas entre el concesionario y las organizaciones de recicladores.

-

Cabe destacar que el grupo poblacional en comento, que tradicionalmente ha ejercido su oficio en cada ASE, seguir?participando en la ruta y realizando la actividad, sin importar si est? o no coaligados a una organizaci? de segundo nivel. El material que recojan podr?ser comercializado por ellos en las bodegas que escojan y el resultado de la transacci? ser?de su propiedad, () sin otorgar parte alguna a la organizaci? de segundo nivel o al concesionario (AZ 5, folio 31). Sumado a lo cual, el plan dise?do para dar ampliaci? a la cobertura deber?incluir la utilizaci? de bodegas del sector.

-

Con todo, la entidad pretende que la ruta de reciclaje tambi? se optimice, por lo cual en una segunda fase consecutiva a aquella piloto que comprende el centro La Alquer? - se buscar? la utilizaci? de lugares de acopio de mayor rendimiento. Aunado a lo cual, en una tercera fase, se implementar? parques

de reciclaje. Por lo mismo, se espera que en el mediano plazo [cinco (5) años], se implemente un esquema de aprovechamiento como servicio complementario al de aseo; que esté a cargo de los recicladores de oficio.

-

2.4.3.3 Por otra parte, [] se implementará el fondo de Reciclaje, con los recursos de la participación accionaria del gremio por las utilidades del concesionario, más una parte de la tarifa de aseo que es equivalente al valor establecido en la Resolución CRA 351 de 1991 para la tarifa de disposición final que (sic), de alguna manera, compense los costos de recolección y transporte por aprovechamiento y que solo sea factible bajo las consideraciones de una actuación conjunta [] (subrayas por fuera del original) (AZ 5, folio 32). Por lo demás, se establecerán centros de acopio distritales [] definidos como puntos verdes[,] manejados por los recicladores y en donde los pequeños comercializadores puedan actuar como socios de los mismos [] desplazados de su oficio por la regulación de bodegas [] (AZ 5, folio 32 y 33).

-

2.4.3.4 En el largo plazo [] más de cinco (5) años se espera que el esquema de recolección esté a cargo de los recicladores de oficio, previendo una corresponsabilidad entre operadores de aseo y organizaciones de recicladores. También se construirán parques de reciclaje siendo la Alquería uno de ellos. Por ello, se pretende un [] esquema de administración [] público [] privado con participación del Distrito con normas claras y obligaciones en relación con la articulación requerida con el sistema de aseo de la ciudad [] (AZ 5, folio 33).

-

2.4.3.5 En cuanto a la ausencia de una tarifa para la actividad que desarrollan los recicladores, esto obedecerá a normativas vigentes que deben seguirse para el ciclo tarifario del servicio público de aseo. En efecto, la Resolución CRA 351 del veinte (20) de diciembre de dos mil cinco (2005) establece, en el artículo 17, que [] como incentivo a las actividades de aprovechamiento, estas se considerarán para efectos de tarifa como una actividad de disposición final, cuyo costo máximo será igual al valor que genera indiferencia en el costo de disposición final al suscriptor, ajustado por las diferencias generadas por concepto de tramo excedente []. En virtud de lo anterior, la UAESP propuso como artículo al aprovechamiento en la actividad de reciclaje un pago equivalente al valor establecido en la Resolución CRA 351 de 2001 para la tarifa de disposición final, el cual será consignado anualmente a un **Fondo del Reciclaje** destinado a beneficiar a la población recicladora o a la actividad de reciclaje. Para ello, se encargará de impulsar el mejoramiento y optimización de los procesos de reciclaje, especialmente en educación ciudadana para separación en la fuente de residuos sólidos, y la inclusión social de recicladores para mejorar las condiciones de vida a través del desarrollo de procesos de asociatividad, fortalecimiento organizativo y empresarial, erradicación de trabajo infantil, entre otros [] (fase del original) (AZ 5, folio 34).

-

2.4.3.6 Como incentivo a la separación en la fuente, la UAESP devolverá anualmente el valor de las toneladas de material potencialmente aprovechable que se recojan en las rutas de reciclaje y [] destinará el 50% al fondo de reciclaje y el 50% restante será devuelto a los usuarios del distrito, vía factura, como incentivo del reciclaje total de los Bogotanos [] (AZ 5, folio 35). En el primer año, ese valor corresponde a 1.200 toneladas; suma que se desprende del censo de recicladores efectuado por la Universidad Javeriana durante el año dos mil diez (2010). [] Para el segundo año se tomará como referencia la toneladas del primer año, actualizadas por la tasa de disminución de las toneladas que se dejaron de disponer en el Relleno Sanitario Doña Juana [] (AZ 5, folio 35).

-

2.4.3.7 Frente a los criterios que se utilizaron para escoger doce (12) asociaciones, la entidad expuso

que solicitó cierta documentación para que pudieran participar; atinente a la constitución y objeto social, identificación del representante legal y certificados de sus antecedentes disciplinarios, así como inventarios de las asociaciones de primer nivel conformantes. A partir de allí, elaboró una lista de aquellas organizaciones que podrían entrar al proceso, que tenía por objeto vincular el conjunto total de personas dedicadas a esta actividad. Para esto, se usó como una estrategia la realización de un censo el cual tenía como propósito identificar la población recicladora de oficio en la ciudad de Bogotá y su núcleo familiar, con el fin de formular las políticas de inclusión social y acciones afirmativas a favor de la misma, y garantizar su participación en los procesos de gestión integral de residuos sólidos del Distrito Capital, especialmente el de la licitación de Recolección, barrido y limpieza (AZ 5, folio 36). Como resultado del mismo, se obtuvo un total de 11.109 recicladores, donde el 31% son mujeres y el 69% hombres. De ellos, solo el 18% está afiliado a una organización de recicladores.

-

2.4.3.8 A raíz de lo anterior, y tras analizar la información que remitieron las organizaciones de segundo nivel, se determinó que 8180 recicladores de oficio no estaban censados, [por lo que] es evidente que una de las tareas más importantes de inclusión social es la de buscar el fortalecimiento de las organizaciones para que los 19.289 recicladores de oficio hagan parte de una de las organizaciones legalmente constituidas (AZ 5, folio 38).

-

3. Intervención de los oferentes y demás interesados.

-

Las intervenciones de los oferentes e interesados se dividen en dos apartes. Una primera sección en la que cada oferente intervino en el presente incidente, ofreciendo sus diversas perspectivas sobre el proceso licitatorio adelantado. La segunda parte se compone de las repuestas que cada oferente e interesado dio a los cuestionamientos formulados en el Auto 189 del 30 de agosto de 2011. Dichos cuestionamientos son los siguientes:

-

▪ ¿Qué actividades componen el Aprovechamiento en el marco del Servicio Público de Aseo?

▪ ¿Cuál de estas actividades es realizada por los recicladores?

▪ ¿En qué etapas está dividido y cómo funciona el proceso de Aprovechamiento en el marco de la Gestión Integral de Residuos Sólidos?

▪ ¿En cuáles de estas etapas intervienen los recicladores y los operadores?

▪ Dentro del proceso de Aprovechamiento en el marco de la Gestión Integral de Residuos Sólidos ¿Cómo se pesan los residuos y en qué etapa? ¿Los residuos son separados según su fuente (residuos de producción domiciliaria, residuos de grandes generadores, barrido, material aprovechable y residuos de operativos especiales) para ser pesados? ¿Qué incidencia tiene el peso de los residuos en la metodología de cálculo de la tarifa?

▪ ¿Qué es y cómo funciona la ruta de reciclaje? ¿Qué relación tiene con los usuarios? ¿Qué relación tiene con los recicladores?

▪ Durante los ocho años de la concesión ¿Cómo se dividen y reparten las utilidades derivadas de la Licitación Pública No. 001 de 2011 entre los miembros de las empresas prestadoras del servicio público de aseo?

▪▪ ¿En qué consiste el aporte como socios de industria de los recicladores contemplado en el pliego de condiciones de la Licitación Pública No. 001 de 2011?

▪▪ ¿Qué es el Fondo de Reciclaje y de dónde obtendrá sus recursos?

▪▪ ¿Cómo explica que se hayan incrementado a 12 grupos las Organizaciones de Segundo Nivel - existiendo incluso algunas que se conformaron a partir de marzo del presente año -?

▪▪ ¿Qué parámetros fueron negociados con cada una de las organizaciones de segundo nivel para la respectiva ASE que les fue asignada tras el sorteo efectuado por la UAESP? En este sentido ¿Qué derechos tendrán como organización de recicladores en razón a tales negociaciones? ¿Cómo se relacionan estas prerrogativas con el pliego de condiciones? Y ¿Serán modificables tales condiciones a lo largo de la ejecución del contrato de concesión?

▪▪ ¿Cuáles son las utilidades que tienen proyectadas para cada una de las ASE en Bogotá? Y en relación con lo anterior ¿Existe alguna utilidad proyectada por el aprovechamiento de residuos sólidos?

▪▪ ¿Qué entienden por acceso cierto y seguro a los residuos sólidos? Consideran que con los parámetros de la actual licitación ¿se está garantizando tal acceso?

3.1. Unión Temporal Cavo Vig (AZ 2, folio 227 a 231)

3.1.1 El ciudadano colombiano Marcio Natel, obrando como representante legal de la Unión Temporal Cavo Vig, intervino dentro del presente incidente para indicar que en la Licitación Pública 001 de 2011, se incluyeron medidas a favor de la población de recicladores de Bogotá. Lo anterior, en razón a que el numeral 2.7 del pliego de condiciones establece que las organizaciones de segundo nivel serán parte de la sociedad que opere la ASE correspondiente y que recibirán, por lo mismo, acciones de industria.

Adicionalmente, mencionó los criterios de calificación existentes entre ellos los 100 puntos que corresponden al porcentaje accionario otorgado a las referidas organizaciones y el hecho de que en la recolección el material potencialmente aprovechable estará a cargo de los recicladores de oficio, que continuarán ejerciendo su labor de manera independiente.

La Unión temporal a la cual representa ofertó dependiendo de la ASE, entre el 5% y el 45% de acciones, que implica una utilidad muy importante a favor de las acciones de recicladores, lo que sin lugar a duda representa la posibilidad de mejorar sus condiciones de vida (AZ 2, folio 230). En este sentido, enfatizó que con tal porcentaje se convertirá automáticamente en empresarios.

Sin embargo, expuso que estas acciones no representan compromiso alguno por parte de los recicladores, por el contrario, solamente les otorga beneficios y participación en las utilidades de la compañía (AZ 2, folio 230). Concatenado a esto, mencionó que no han adelantado ninguna negociación con los recicladores ni llegado a acuerdo alguno con relación a la licitación en comento (AZ 2, folio 231).

3.1.2 Con posterioridad al Auto 189 de 2011, la Uni? Temporal CAVO VIGIA, remiti?un nuevo escrito a esta Corporaci? ^[59], en el cual manifest?lo siguiente:

3.1.2.1 Respecto al aprovechamiento que □ El Plan maestro para el Manejo Integral de Residuos S?idos tiene como objetivo general articular todas las acciones p?licas, privadas, de los usuarios del servicio p?lico de aseo y de las comunidades organizadas vinculadas al manejo de residuos s?idos con el fin de aumentar su impacto en la minimizaci? de generaci? de residuos, en el reciclaje y aprovechamiento y tambi? en la reducci? de los costos de prestaci? del servicio p?lico de aseo y en la protecci? del patrimonio ambiental□ (AZ 5, folio 309). A continuaci?, cit?el art?ulo 1? del Decreto 1505 de 2003 para concluir que tambi? hacen parte del aprovechamiento actividades como el fortalecimiento de una cultura ciudadana orientada a una menor generaci? de residuos y a la separaci? de los mismos en la fuente, el apoyo a las cadenas de reciclaje, el fortalecimiento de las organizaciones de recicladores y su vinculaci? a procesos productivos, comerciales y de servicios, el reconocimiento y reducci? de las condiciones de vulnerabilidad de la poblaci? recicladora y □(□) la creaci? de centros de reciclaje y aprovechamiento gestionados por las organizaciones de recicladores de oficio□ (AZ 5, folio 310).

3.1.2.2 Frente a la participaci? que tienen los recicladores en las actividades que componen el aprovechamiento en el marco del Servicio P?lico de Aseo, se?l?que en su propuesta las organizaciones de recicladores de segundo nivel □(□) participar? como empleados de la Uni? Temporal CAVO VIGIA en el proceso de recolecci? de basuras y a trav? de la ruta especial de reciclaje y la instalaci? de la bodega de acopio y comercializaci?, participar? en la etapa de aprovechamiento, cuyos ingresos recibir? de manera ?tegra□ (AZ 5, folios 311 a 312).

3.1.2.3 En cuanto a las etapas en que est?dividido el proceso de aprovechamiento en el marco de la Gesti? Integral de Residuos S?idos, inform?que □ El aprovechamiento de los residuos s?idos se divide en las siguientes etapas: 1. Separaci? en la fuente 2. Recolecci? 3. Transporte 4. Almacenamiento [y] 5. Comercializaci?□ (AZ 5, folio 312). A continuaci?, expuso que □ Este proceso se inicia con la separaci? de los residuos en la fuente como consecuencia de la concientizaci? de la comunidad sobre la importancia de esta labor o mediante la separaci? manual que realizan los recicladores. Los residuos separados podr? ser recolectados por la ruta especial de reciclaje o por los recicladores, en ambos casos ser? transportados a las bodegas de acopio y comercializaci? zonales, en donde ser? preparadas para su final comercializaci?□ (AZ 5, folio 312). Frente a las operaciones adelantadas por los recicladores en dicho proceso, anot?que □(□) los recicladores intervienen en la separaci? de los residuos cuando ?ta no se hace en la fuente, en el transporte de los residuos que ellos mismos clasificuen, en la gesti? del almacenamiento y su posterior comercializaci?□ (AZ 5, folio 312).

3.1.2.4 Con relaci? al peso de los residuos, indic?que ?tos son separados seg? su fuente para ser pesados, labor que se realiza en la b?cula □(□) en el momento de su ingreso al centro de acopio de cada zona□ (AZ 5, folio 313). Adem?, frente a la pregunta tendiente a establecer qu?incidencia tiene el peso de los residuos en el c?culo de la tarifa, respondi?que la mencionada tarifa se calcula □(□) con base en el tonelaje que llega al relleno sanitario para cada ASE de acuerdo al peso arrojado por la b?cula□ (AZ 5, folio 313). Y agreg?que □ El peso de los residuos tiene relaci? directa con el costo variable medio de referencia (CVMR), con el costo del transporte por tramo excedente y con el costo de la disposici? final (Resoluci? 351 y 352 de 2005). Si existe una diferencia de peso, entre el proceso de recolecci? y la disposici? final, caso de reciclaje, esta diferencia se convierte autom?ticamente en un beneficio para el usuario□ (AZ 5, folio 314).

3.1.2.5 En lo que se refiere al funcionamiento de la ruta de reciclaje, explic? que se trata de una ruta establecida por la UAESP, realizada por el operador del Servicio de Aseo y □(□) definida como la forma en la cual el operador recoge el material reciclable separado previamente en los hogares □ (AZ 5, folio 314). En cuanto a la frecuencia, se?l? que la ruta de recolecci? selectiva es un servicio que se brinda una vez por semana en menos de la mitad de la ciudad. Sobre la relaci? de dicha ruta con los usuarios, manifest? que □(□) La Ley 1466 de 2011 autoriz? la creaci? del Fondo Social de los Recicladores para que los recursos generados por los comparendos ambientales alimenten el fondo que ser? destinado al bienestar de los recicladores colombianos □ (AZ 5, folio 315).

3.1.2.6 En torno al incremento de las organizaciones de recicladores de segundo nivel, que pasaron de ser cuatro (4) a doce (12) desde la licitaci? del Relleno Sanitario Do? Juana, apunt? que desconoce el proceso de formaci? de este tipo de organizaciones. As? mismo, asegur? no haber adelantado negociaci? alguna con ellas, pues solamente hasta la adjudicaci? de las ASEs podr? saberse con certeza con cu? de ellas se desarrollar? el contrato. Agreg? que los derechos que tendr? estas organizaciones, son aquellos establecidos en la oferta como participaci? de utilidades de la empresa, adem? □(□) todo el material que no sea seleccionado en la fuente por los ciudadanos se clasificar? por los recicladores, como hasta ahora se ha hecho, confluyendo ?te y el de la ruta selectiva en el mismo centro de acopio □ (AZ 5, folio 316).

3.1.2.7 Sobre la divisi? presente y futura de las utilidades derivadas de la Licitaci? P?lica 001 de 2011, CAVO VIGIA comunic? que □ Las utilidades se dividir? entre los accionistas de la UNION TEMPORAL CALVO VIGIA en nuestro caso y los socios industriales que son la organizaci? de segundo nivel que haya ganado el sorteo de la ASE que nos sea asignada (□) □ (AZ 5, folio 316). De manera puntual, se?l? que en su oferta se entregar? a la organizaci? de segundo nivel que corresponda □ el equivalente al cuarenta y cinco por ciento (45% de las utilidades si se le asignan las ASE 1, 2, 3 o 6 y el cinco por ciento (5%) en el evento que se le adjudiquen las ASE 4 y 5 □ (AZ 5, folio 316). Explic? adem? que el aporte de industria de los recicladores contemplado en el pliego de condiciones de la licitaci? en comento consiste en que □(□) los recicladores desarrollar? parte del trabajo correspondiente a la prestaci? del servicio, espec?icamente aquel que tenga referencia con la recolecci? y aprovechamiento de los residuos susceptibles de aprovechamiento (□) □ (AZ 5, folio 316).

3.1.2.8 En cuanto a las prerrogativas ofrecidas a los recicladores, CAVO VIGIA inform? que □(□) est? perfectamente definidas en el Pliego de Condiciones y en la oferta presentada □ (AZ 5, folio 317); y se trata de □(□) a. contrataci? por parte de la empresa de algunos de sus afiliados gozando de todas las garant?s laborales establecidas por la ley colombiana c. comercializaci? de los residuos de la ruta de reciclaje d. Capacitaci? y participaci? en el programa de educaci? formal contemplado dentro del Plan de Gest? Social de la empresa □ (AZ 5, folio 317). Adicionalmente, se?l? que tales condiciones no son susceptibles de modificaci? alguna a lo largo de la ejecuci? del contrato por hacer parte de los pliegos de condiciones, de las adendas y de la propuesta.

3.1.2.9 Cuestionada sobre las utilidades proyectadas para cada una de las ASE, esta uni? temporal respondi? que dicha informaci? no puede ser suministrada por ser confidencial y depender del an?lisis financiero que fue incluido en la oferta econ?mica que todav? no se ha dado a conocer. A? as? reiter? que □(□) los recicladores recibir? el porcentaje de los dividendos establecidos en nuestra oferta en su calidad de socios de industria para cada una de las ASE que nos sea adjudicada, de acuerdo a la oferta ya presentada (□) □ (AZ 5, folio 318). En directa relaci? con lo anterior, aleg? que no se ha proyectado ninguna utilidad por el aprovechamiento de residuos s?idos □(□) toda vez que los Pliegos de la Licitaci? determinan que el producto de la venta de los materiales recuperados es exclusivamente de los

recicladores (□) (AZ 5, folio 318). A?di? que est?plenamente de acuerdo con esta estipulaci?, pues es parte de su compromiso ambiental.

3.1.2.10 Finalmente, en lo relativo al acceso cierto y seguro a los residuos s?idos, anot?que lo comprende c?o □(□) la real cobertura del servicio de recolecci? selectiva de material reciclable en la ciudad [,] que le otorgue a los recicladores autonom? en esta actividad □ (AZ 5, folio 318). En cuanto al acceso seguro, se?l?que lo entiende como la garant? de □(□) las condiciones de seguridad industrial que aseguren la protecci? de los recicladores, mediante el uso de la dotaci? adecuada definida por las normas de seguridad y calidad vigentes □ (AZ 5, folio 318). Y a?di?que □ En desarrollo de la licitaci? los proponentes nos obligamos no solo a permitir el ejercicio de los recicladores en su ASE, sino que debemos presentar a la UAESP, en los seis primeros meses un Plan de Trabajo que garantice el mejor aprovechamiento de la Ruta de Reciclaje y entregar la dotaci? y las herramientas requeridas para adelantar esta labor □ (AZ 5, folios 318 - 319).

3.1.2.11 En directa relaci? y frente a si la licitaci? en comento garantiza a los recicladores el acceso cierto y seguro a los residuos s?idos, esta Uni? Temporal consider?que □(□) nunca hab?n tenido los recicladores tantos beneficios como los que recibir? como consecuencia del cumplimiento por parte del concesionario de las cl?sulas del contrato referentes a la inclusi? de la poblaci? de recicladores en condiciones de vulnerabilidad □ (AZ 5, folio 310). Adem?, el incumplimiento de tales cl?sulas acarrear? para el proponente numerosas sanciones que incluyen la cancelaci? del contrato.

3.2 ATESA Siglo XXI S.A.S. E.S.P. (AZ 2, folio 232 a 235)

El representante legal de este proponente, Carlos Germ? Arroyave, tras la solicitud efectuada por esta Corporaci? en el Auto 180 de 2011, intervino dentro del incidente para se?lar que □(□) los puntos de vista que el Consejo de Estado ha previsto en esta materia (□) □^[60] (AZ 2, folio 233), resultaban relevantes para esclarecer el cumplimiento o no de acciones afirmativas a favor de la poblaci? de recicladores de Bogot?

3.2.1 Comenz?por se?lar que en la sentencia T-724 de 2003, no se defini?con claridad qu?deb? entenderse por tales acciones. Sin embargo y sin especificar a qu?providencia se refer?, expuso que □(□) en el auto del Consejo de Estado (□) □ (AZ 2, folio 234) s?se determinaron algunos par?etros.

En este sentido, apunt?que la participaci? accionaria se constituye en una acci? afirmativa, □(□) por cuanto es un incentivo real para ser empresarios del servicio en la medida en que ser? parte efectiva de la sociedad prestadora, de sus utilidades y de los dem? derechos que les concede la condici? de accionistas □ (AZ 2, folio 234). Aunado a ello y sin exponer razones, manifest?que la ruta de reciclaje es en s?misma una acci? afirmativa, dado que contempla un plan operativo con un itinerario preciso y definido. Igualmente, apunt?a que la obligaci? de vincular laboralmente a los recicladores ayuda a la formalizaci? de ese grupo poblacional.

Por lo dem?, el precio del reciclaje □(□) quedar?a la din?ica propia del mercado, del valor de los

productos, de su calidad, etc., en la medida en que es una actividad vinculada a procesos netamente de comercializaci? de productos con el sector real de la econom?, que no pueden fijarse de antemano por contrato o por resoluci? □ (AZ 2, folio 234).

Finalmente, adujo que en raz? a las condiciones previstas en la Licitaci?, □(□) no [han]adelantado acercamiento, tratativa, negociaci? y menos a? acuerdo alguno con ninguna de las Asociaciones de recicladores de Segundo Nivel asignadas a cada ?ea de servicio exclusivo □ ASE □ (□) □ (AZ 2, folio 235).

3.2.2 Con posterioridad al Auto 189 de 2011, este proponente remiti?un nuevo escrito dirigido a dar respuesta al cuestionario formulado^[61].

3.2.2.1 Inicialmente, cit?los Decretos 1713 de 2002 y 1505 de 2003, en los cuales se le da alcance al t?mino aprovechamiento. Seguidamente, ATESA asegur?que □(□) tanto las actividades dirigidas a efectuar la recolecci?, el transporte, como la separaci? de los residuos aprovechables, son realizadas por los recicladores de oficio □ (AZ 5, folio 291). En cuanto al aprovechamiento, hizo referencia textual a los mismos decretos para definir reutilizaci? como □(□) la prolongaci? y adecuaci? de la vida ?il de los residuos s?idos recuperados y que mediante procesos, operaciones o t?nicas devuelven a los materiales su posibilidad de utilizaci? en su funci? original o en alguna relacionada, sin que para ellos requieran procesos adicionales de transformaci? □ (AZ 5, folio, 292). Adem?, defini?reciclaje como □(□) el proceso mediante el cual se aprovechan y transforman los residuos s?idos recuperados y se devuelve a los materiales su potencialidad de reincorporaci? como materia prima para la fabricaci? de nuevos productos □ (AZ 5, folio 292).

3.2.2.2 A la par, ATESA trajo a consideraci? el Anexo 21 del pliego de condiciones de la Licitaci? 001 de 2011, que prev?que los recicladores estar? a cargo de la ruta de reciclaje, de la actividad de aprovechamiento y que □[e]l material que recojan (□) en los territorios que actualmente ocupan, ser? comercializado por ellos en las bodegas que escojan, y el valor de dicha transacci? ser?de su propiedad □ (AZ 5, folio 292). As?las cosas, □[l]os operadores del servicio p?lico de aseo, conforme al pliego de condiciones, no intervienen en ninguna de estas etapas, en tanto est? llamadas ?icamente a prestar apoyo a los recicladores de su ASE, en los t?minos del anexo 21 (□) y a compartir las utilidades generadas por la prestaci? del servicio de aseo con los mismos □ (AZ 5, folio 293).

3.2.2.3 En lo que tiene que ver con el pesaje, ATESA sostuvo que ?te lo realizan los recicladores al momento de comercializar los residuos. □Eventualmente, el pesaje se produce al momento de la recolecci? de los residuos por parte de los recicladores de oficio cuando dicha recolecci? implica una venta del material por parte del generador al reciclador □ (AZ 5, folio 293). De todos modos, □(□) la CRA precisa que el pesaje de los residuos para los suscriptores que no sean aforados □es decir, a quienes no se les realiza el pesaje al momento de la recolecci? de los residuos- se realiza en los sitios de disposici? final (rellenos sanitarios o sitios de aprovechamiento). Por estas razones regulatorias, es obligatorio que estos sitios tengan b?cula de pesaje □ (AZ 5, folio 293). Con todo, anot?que los residuos aprovechables se separan en funci? de sus caracter?ticas y composici?, es decir, en org?icos, inorg?icos, papel, cart?, vidrio, etc., y no en funci? del tipo de generador. Tambi? recalc? que esta separaci? nunca se hace en el relleno sanitario. Ligado a lo precedente, manifest?que el peso incide en la tarifa a cobrar, puesto que est? incluido en la metodolog? tarifaria.

-

3.2.2.4 Sobre el tema de la ruta de reciclaje y su relaci? con los usuarios y con los recicladores, sostuvo que los primeros ser? los encargados de presentar el material debidamente separado y que los recicladores lo recolectar? □(□) con los apoyos, dotaciones y equipos que los operadores hemos ofrecido dentro de las ofertas presentadas□ (AZ 5, folio 294). Adicionalmente, respondi?a la Corte que en el reparto de utilidades se atender?a lo ordenado en el pliego de condiciones, esto es, que los socios industriales tendr? derecho a recibir utilidades por lo menos una vez al a?.

-

Atado a lo anterior, ATESA plante?que □(□) la UAESP fue clara y reiterativa en se?lar que el aporte de industria al que las condiciones del pliego hacen (sic) referencia, **NO son cuantificables** y que corresponden por tanto a las que trata el art?ulo 137 en concordancia con el art?ulo 380 del C?igo de Comercio□ (may?culas y negrillas tomadas del texto original) (AZ 5, folio 296).

-

3.2.2.5 En cuanto al Fondo de Reciclaje, asever?que □(□) corresponde a un fondo-cuenta destinado a beneficiar a la poblaci? de recicladores o a la actividad del reciclaje, y se alimenta del 50% del valor anual de las toneladas de material potencialmente reciclable que recojan los recicladores de oficio en las rutas de reciclaje que la entidad devolver?a los mismos□ (AZ 5, folio 296). Sumado a lo cual, frente al incremento en las organizaciones de reciclaje de segundo nivel a 12 grupos, no expres?opini? por tratarse de un tema que fue del resorte exclusivo de la UAESP.

-

3.2.2.6 Con ocasi? de las negociaciones adelantadas con las organizaciones de recicladores, ATESA respondi?que □(□) no hemos adelantado acercamiento, tratativa, negociaci? y mucho menos acuerdo alguno o negociaci? de par?etro alguno con ninguna de las asociaciones de recicladores (□) que de manera aut?oma e independiente fueron definidas y seleccionadas por la UAESP□ (AZ 5, folio 297). M? aun, hizo ?fasis en que todos los derechos de los recicladores provienen del pliego de condiciones y que □[n]o existe ning? derecho a favor de los recicladores que provenga de negociaci? alguna con nosotros□ (AZ 5, folio 298). Asimismo, insisti?en que la UAESP precis?que las asociaciones de recicladores no ser?n accionistas de capital.

-

Al final de su escrito, aclar? que □[e]l margen de utilidades proyectadas por las ASE y para cada a? de la concesi? despu? de amortizar las inversiones se estim?aproximadamente entre el 5% y el 6%, donde los primeros cuatro a?s son de amortizaci?□ (AZ 5, folio 298). De todas maneras, advirti?que el comportamiento del negocio es din?ico y puede sufrir variaciones. Luego, precis?que □(□) las actividades que componen el aprovechamiento, conforme a las condiciones de la licitaci?, ser? realizadas y usufructuadas en su totalidad por los recicladores de oficio por conducto de las asociaciones a la cual (sic) pertenezcan y por tal concepto los operadores no recibiremos utilidades, no tenemos proyecciones de las mismas□ (AZ 5, folio 298).

-

Para terminar, ATESA expuso que el acceso cierto y seguro a los residuos s?idos debe comprenderse como □(□) la efectividad del acceso que dicha poblaci? (la recicladora) tiene respecto de los residuos aprovechables□ (AZ 5, folio 299). En tal orden de ideas, entiende que □(□) conforme a las condiciones de la actual licitaci? la poblaci? recicladora tiene total acceso a los residuos aprovechables desde la fuente de generaci?, en la medida en que se proh?e a los operadores del servicio de aseo desarrollar la actividad de aprovechamiento, dejando dicha actividad en cabeza ?icamente de la poblaci? recicladora. Por ello, consideramos que la actual licitaci? garantiza tal acceso a los residuos a favor de la poblaci?

recicladora exclusivamente (AZ 5, folio 299).

3.3 Promesa de Sociedad Futura ASEO Bogot? (AZ 2, folio 236 a 237).

El se?r Eduardo G?ez V?quez, obrando como representante legal del proponente mencionado, manifest? que se cumplen a cabalidad las obligaciones de incluir acciones afirmativas para la contrataci? del servicio p?blico de aseo, contempladas en la sentencia T-724 de 2003 y el Auto 268 de 2010. Esto, en raz? a que () se incluyeron factores de evaluaci? y por lo mismo de asignaci? de puntaje que propenden por el mejoramiento de la calidad de vida y el desarrollo de la actividad de la poblaci? de Bogot? dedicada a la actividad del reciclaje de desechos () (AZ 2, folio 236).

3.3.1 En efecto, se exige la participaci? de las organizaciones de segundo nivel como accionistas, calificando el monto accionario otorgado a cada una de ellas. Esto, () no s?o les otorgar? el estatus de empresarios, sino que permitir? la obtenci? de importantes utilidades en desarrollo de la concesi? () (AZ 2, folio 236). As? mismo, se impuso la obligaci? de entregarles dotaciones y elementos que permitan el desarrollo de la actividad () con mayor decoro, condiciones de higiene y en general de facilitaci? para su labor (AZ 2, folio 237).

Finalmente, al igual que los proponentes anteriormente mencionados, se?l? que () a la fecha, no ha adelantado negociaci? alguna con las Asociaciones de Recicladores de Segundo Nivel, toda vez que cualquier negociaci? eventual est? necesariamente ligada a la adjudicaci? de una o dos ASEs () (AZ 2, folio 237).

3.3.2 Promesa de Sociedad Futura Aseo Bogot? S.A. E.S.P., alleg? escrito a la Corte Constitucional en cumplimiento del Auto 189 de 2011.

3.3.2.1 En primer t?mino, acudi? al art?ulo 1? del Decreto 1713 de 2002 para determinar el concepto de aprovechamiento como () el conjunto de actividades dirigidas a efectuar la recolecci?, transporte, y separaci? () de residuos s?idos que ser? sometidos a procesos de reutilizaci?, reciclaje o incineraci? con fines de generaci? de energ?, compostaje, lombricultura o cualquier otra modalidad que conlleve beneficios sanitarios, ambientales, sociales y/o econ?icos en el marco de la Gesti? Integral de los Residuos S?idos (AZ 5, folio 300). Sumado a lo cual, expuso las cuatro etapas principales de aprovechamiento, a saber: producci?, recolecci?, recuperaci? y disposici?.

La producci? es, seg? el escrito de Aseo Bogot? la generaci? de residuos s?idos. La recolecci?, por su lado, consiste en recoger los residuos. La recuperaci? [c]onsta de la separaci? de los residuos que por su composici? y naturaleza, pueden ser sometidas (sic) a distintos tratamientos para su transformaci?, reuso y comercializaci? (AZ 5, folio 301). La etapa final del proceso () consiste en depositar los residuos, que no han sido recuperados y no es posible reinsertarlos a un nuevo ciclo productivo mediante ning? mecanismo, por lo que deben ser dispuestos en lugares con ?te (sic) fin como son los rellenos sanitarios al t?mino de su vida ?il (AZ 5, folio 301).

-

En opini? de Aseo Bogot? en el proceso de aprovechamiento los operadores y los recicladores participan de manera paralela. De modo que □[l]os operadores del Servicio de Aseo realizan la actividad de aprovechamiento por medio de la adopci? de ruta de reciclaje que realizan los recicladores. De esta manera se garantiza que los prestadores paguen el costo de oportunidad por la actividad de recolecci? que hacen los recicladores□ (AZ 5, folio 301).

-

3.3.2.2 Sobre el procedimiento de pesaje de los residuos, Aseo Bogot?precis?que □[l]a metodolog? actual indica que los residuos potencialmente aprovechables se pesan en el momento en que los camiones ingresan a los centros de Reciclaje o aprovechamiento□ (AZ 5, folio 302). Por consiguiente, apunt?que el costo de disposici? final para los usuarios corresponde al □(□) costo promedio ponderado de la suma de las toneladas aprovechables y no aprovechables. En este escenario los ingresos agregados de la empresa por realizar cada actividad por separado deben ser iguales a los que obtendr? sin hacer el aprovechamiento□ (AZ 5, folio 302).

-

3.3.2.3 Ahora bien, en lo que a la ruta de reciclaje se refiere, Aseo Bogot?relat?la manera c?o funciona hoy en d? para despu? establecer que el usuario realiza la separaci? en la fuente y presenta los residuos reciclables en los d?s y horas previstos por la empresa de aseo. □Una vez que el concesionario realiza la recolecci? del material recuperable, debe disponerlo en el centro de reciclaje o centro de acopio asignado, cumpliendo la ruta de recolecci? selectiva□ (AZ 5, folio 303).

-

3.3.2.4 Aseo Bogot?sintetiz?que □(□) las utilidades que se deriven no de la Licitaci? sino del Contrato de concesi?, se repartir? de acuerdo con los estatutos sociales prometidos, las exigencias del pliego de condiciones y el C?igo de Comercio, es decir, por lo menos una vez al a? en caso de presentarse en el ejercicio□ (AZ 5, folio 303). A?di?que en la aprobaci? de los estados financieros interviene el revisor fiscal y todos los accionistas, incluidos los de industria, en los t?minos previstos en los estatutos sociales y en el C?igo de Comercio.

-

3.3.2.5 De igual modo, entreg? una explicaci? con respecto a los aportes de industria con base en las normas pertinentes del C?igo de Comercio y enunci?los derechos que tendr? las organizaciones recicladoras como accionistas de industria: derecho a recibir utilidades por lo menos una vez al a?, derecho a participar porcentualmente del mayor valor de la empresa al momento de su liquidaci? y derecho a que la participaci? ofrecida a la organizaci? no sea modificada durante el per?do de duraci? de la concesi?. Paralelamente, las organizaciones de recicladores no podr? vender o ceder, a ning? t?ulo, su participaci? durante la ejecuci? del contrato. Concluy?este apartado indicando que □(□) las asociaciones de recicladores no har? aporte alguno como socios o accionistas industriales, hasta el punto que ni siquiera cancelar? los costos de la emisi? de sus acciones de industria que, en nuestro caso, ser? el cien por ciento (100%) de las que se emitan exclusivamente para dichas asociaciones□ (AZ 5, folio 305).

-

3.3.2.6 Aseo Bogot?explic?que el Fondo de Reciclaje □(□) es un instrumento para la avanzada en la implementaci? de los programas en beneficio de los recicladores□ (AZ 5, folio 305), cuyas fuentes de financiaci? son □(□) los recursos de promoci? al reciclaje y aprovechamiento que se asignen en la prestaci? del servicio p?blico de aseo□ (AZ 5, folio 305), □(□) el aporte que los administradores de los centros o parques de reciclaje definan destinar a este fondo□ (AZ 5, folio 305), □(□) los recursos

gestionados para tal fin de la cooperaci? nacional e internacional□ (AZ 5, folio 305) y □(□) donaciones de diversa fuente□ (AZ 5, folio 305).

3.3.2.7 Por otra parte, constat? que desconoce las causas por las cuales se increment?el n?ero de organizaciones de segundo nivel. Aunado a ello, aleg?no tener □(□) la obligaci? de entrar en contacto con las asociaciones de recicladores, efectuando negociaci? alguna toda vez que su asignaci? fue producto de los procedimientos elaborados por la UAESP□ (AZ 5, folio 306).

A m? de lo anterior, declar?que □(□) la utilidad estar? dada de manera independiente para cada una de las ASE entre un 15 y un 20%□ (AZ 5, folio 306). □No obstante, la utilidad para el aprovechamiento si bien no est?referenciada en el marco regulatorio actual de servicio, si (sic) ser?un valor real para quienes recojan los materiales potencialmente aprovechables, en este caso los recicladores y en los valores que hemos establecido en nuestra oferta□ (AZ 5, folio 306).

3.3.2.8 En su entender, el acceso cierto y seguro a los residuos s?idos alude a una garant? que tienen los recicladores de acceder a los residuos potencialmente aprovechables presentes en el ASE donde desarrollen su labor. De suerte tal que Aseo Bogot?estim?que dicho acceso cierto y seguro se garantiza en la actual licitaci? □(□) a trav? de la exclusividad que brinda a los recicladores de oficio de ejercer su actividad en un ?ea de servicio exclusivo, minimizando la competitividad actual que se presenta en este componente□ (AZ 5, folio 306).

3.3.2.9 Por ?timo, agreg?que □[e]l aprovechamiento en la futura concesi? (□) debe medirse como el resultado de aumentar la recolecci? de materiales potencialmente aprovechables, donde los Concesionarios aportar? el valor o la utilidad que a la fecha es sacrificada por los recicladores debido a los costos no reconocidos por la recolecci? de estos materiales. Por lo tanto[,] se mejorar?su actividad econ?ica sin ninguna inversi? adicional. Tambi? se les otorgar? utilidades por la recolecci?, transporte y barrido de los residuos s?idos, es decir por actividades del servicio Aseo que no ejecutan□ (AZ 5, folio 307).

3.4 Uni? Temporal Gest? Ambiental (AZ 2, folio 238 a 253)

Menzel Am? Avenda?, representante legal de la Uni? Temporal Gest? Ambiental, intervino dentro del incidente para manifestar que □(□) en ning? momento se ha hecho part?ipe dentro de la Licitaci? P? lica No. 001 de 2011 abierta por la UAESP□ (AZ 2, folio 238). Sin embargo, record?que s?lo hizo para la licitaci? correspondiente al Relleno Sanitario Do? Juana.

Como quiera que las consideraciones efectuadas por la uni? temporal para efectos de la disposici? final de residuos no se encuentran relevantes para este asunto y, fueron resumidas en el Auto 268 de 2010, la Sala se abstiene de efectuar un recuento de las mismas.

3.5 Promesa de Sociedad Futura IPSUM (AZ 2, folio 254 a 265).

-

3.5.1 El ciudadano previamente mencionado, Menzel Rafael Am? Avenda?, intervino como representante legal de este proponente^[62] y sobre el punto materia de estudio indic? que los recicladores han sido escuchados en varias instancias dis?iles durante todo el proceso licitatorio. Para esto, se celebraron diferentes audiencias, lo cual garantiz? que sus intereses fueron escuchados por la UAESP y por los proponentes.

-

Se refiri? □ al igual que los anteriores proponentes □ a la participaci? accionaria otorgada a la organizaci? de segundo nivel, a la vinculaci? □ (□) de mano de obra para adelantar las labores de corte de c?ped y poda de ?boles (□) □ (AZ 2, folio 256) y al porcentaje de aprovechamiento dentro de las rutas de reciclaje. Estos elementos constituyen tres (3) de los cinco (5) componentes de evaluaci? previstos, sumando en total 200 puntos de los 1000 posibles.

-

En este sentido, manifest? que seg? la sentencia T-291 de 2009, las acciones afirmativas conllevan el derecho de los recicladores de volverse progresivamente empresarios de las basuras; asunto que se alcanza con la condici? habilitante de conferir un porcentaje no menor al 5% de las acciones. Esto, a su vez, les confiere derechos como recibir utilidades □ pagadas antes de las reservas o capitalizaci? - y participar porcentualmente del mayor valor de la empresa al momento de su liquidaci?.

-

El hecho de que la participaci? accionaria sea un criterio de calificaci?, ha tenido como consecuencia □ (□) que algunos de los proponentes [hayan ofrecido] que entregar?n una participaci? accionaria a las organizaciones de recicladores de segundo nivel [de] 49% al 71% □ (AZ 2, folio 258). En este sentido, adujo que existen criterios de desempate concernientes a tal participaci?.

-

Igualmente, la puntuaci? atinente a los puestos de trabajo, se ha constituido en un incentivo para vincular y formalizar a los recicladores de Bogot? Lo que ha implicado que algunos oferentes hayan propuesto crear 1100 puestos de trabajo. □ (□) De este modo[,] habr? una discriminaci? positiva a trav? de una acci? afirmativa de la UAESP, que permite dar preferencia a la contrataci? de mano de obra de poblaci? recicladora (□) □ (AZ 2, folio 259). Igualmente, tal vinculaci? se constituye en un criterio de desempate.

-

En cuanto a las rutas de reciclaje, manifest? que en raz? a que se dar? 50 puntos por tal concepto, se gener? un incentivo □ (□) para que los proponentes aumenten considerablemente el porcentaje de aprovechamiento (□) [Esto se consolida como una] acci? afirmativa de la UAESP plasmada en el Pliego de Condiciones (□) para aumentar de forma significativa la cobertura de usuarios de la Ruta de Reciclaje dentro de la respectiva ASE (□) □ (AZ 2, folio 260). Por ello, 10 de los 13 proponentes ofertaron aumentar tal cobertura a un 100% de usuarios.

-

Finalmente, al igual que todos los proponentes anteriores, expuso que □ (□) no han entrado en procesos de negociaci? con las organizaciones de recicladores de segundo nivel (□). [De hecho] teniendo en cuenta los incentivos establecidos en el Pliego de Condiciones (□) las organizaciones de recicladores de

segundo nivel no requieren de aumentar su poder de negociaci? para conseguir condiciones m? favorables (□)□ (AZ 2, folios 260 y 261).

-

3.5.2 Posteriormente, para dar respuesta al Auto 189 de 2011, envi?un nuevo escrito en el cual se?l?lo siguiente.^[63]

-

3.5.2.1 El aprovechamiento debe ser entendido en el marco fijado por el Decreto 1713 de 2002, la Ley 632 de 2000, la Ley 689 de 2001, el Decreto Ley 2811 de 1974 y la Ley 99 de 1993. Por ello, tal actividad comprende la recolecci?, transporte y separaci? de residuos s?idos que ser? sometidos a procesos de reutilizaci?, reciclaje o incineraci? con fines de generaci? de energ?, compostaje o cualquier actividad que conlleve beneficios sanitarios, ambientales, sociales y econ?icos.

-

3.5.2.2 A continuaci?, repiti? par?etros contenidos en el anexo 21, atinentes a que los recicladores tradicionales ser? los encargados de recoger los residuos a partir de la acera. Igualmente, expuso que el concesionario entregar?implementos y acompa?r?a las organizaciones de segundo nivel para incrementar la recolecci? de material potencialmente aprovechable.

-

3.9.2.3 Para referirse a la etapa concreta en que intervienen los recicladores, reiter?que tanto el Decreto 1713 de 2002 como el Decreto 1503 de 2003 contemplan el proceso de la siguiente manera: generaci?, separaci? en la fuente, presentaci?, recolecci?, transporte, acopio y clasificaci?, tratamiento, transformaci? y embalaje, comercializaci?, y reincorporaci? al ciclo econ?ico y productivo. La participaci? de los recicladores se dar?principalmente en la recolecci? selectiva y las subsiguientes etapas, dado que □conforme al pliego□, ser? propietarios de lo que recojan y podr? comercializarlo.

-

3.5.2.4 En cuanto al pesaje, mencion?que aquel material informalmente recolectado es pesado al momento de la venta final al cliente. En cambio, aquel que no sea seleccionado, llega al Relleno y ah?es pesado. □(□) En todo caso, en el futuro y de acuerdo con la normatividad vigente, teniendo en cuenta que el Aprovechamiento en el marco de la GIRS [Gesti? Integral de Residuos S?idos] se considera como una actividad de disposici? final, el MPR [Material Potencialmente Reciclable] ser? pesado en los sitios de acopio u transformaci? (□)□ (AZ 5, folio 170). A su vez, indic?que el peso de los residuos es vital para determinar la tarifa, dado que uno de los componentes es el costo de tratamiento y disposici? final, que dependen exclusivamente del n?ero de toneladas dispuestas en el sitio de disposici? final.

-

Frente a la ruta de reciclaje, mencion?que est?destinada a la recolecci? de material potencialmente reciclable, que ha sido separado previamente en la fuente. Siendo la cobertura actual equivalente al 32% de usuarios y esperando que sea ampliada al 100%.

-

3.5.2.5 Con respecto a las utilidades para las organizaciones de recicladores del ASE respectivo, apunt? que recibir? una vez al a? un porcentaje que se pagar?antes de las reservas y capitalizaciones. Por otra parte, adujo que aquellas devienen del aporte de industria de los recicladores, que es fruto de las obligaciones contempladas en el Auto 268 de 2010 y que corresponder? □(□) a una estimaci? anticipada (□) de su aporte en trabajo□ (AZ 5, folio 178). Luego, expres?que el aporte □(□) consistir?

en la prestaci? de su fuerza de trabajo, as?como de sus conocimientos t?nicos para el desarrollo del objeto de la sociedad que se constituya, en particular respecto de su conocimiento y experiencia relacionados con el reciclaje (AZ 5, folio 179). Esto, a pesar de que el objeto de la licitaci? expresamente excluye el aprovechamiento.

-

3.5.2.6 En cuanto al Fondo de Reciclaje, aleg?que el anexo 6 lo menciona, pero se abstuvo de efectuar mayores comentarios al respecto. Por lo dem?, tambi? enfatiz?que carece de conocimiento para explicar el por qu?del aumento de organizaciones de segundo nivel. Sin embargo, se?l?que debido a la ausencia de requisitos atinentes a la antig?dad, es posible que personas que hubiesen ejercido la actividad decidieran coaligarse para participar de la licitaci?. Aunado a esto, expuso que no ha efectuado negociaci? alguna con esas asociaciones, dado que el pliego de condiciones no lo exig? ni permit?.

-

3.5.2.7 Por lo dem?, relat?que para cada ASE existe una proyecci? diferente de utilidades. Sin embargo, dado que se trata de informaci? confidencial y a pesar de haberla consignado, solicit?a esta Corporaci? no revelarla. Ahora bien, con respecto al material potencialmente aprovechable, expuso que entiende que su comercializaci? estar? a cargo de las organizaciones de segundo nivel. Por ello, dentro de las utilidades, no se incluy?ning? rubro correspondiente al aprovechamiento de los residuos s?idos.

-

3.5.2.8 Finalmente, en cuanto al acceso cierto y seguro a estos materiales, apunt?que lo comprende como () la posibilidad que tendr? tanto los concesionarios como los recicladores de llevar a cabo todas las actividades propias del servicio de recolecci?, transporte, barrido y limpieza de residuos s?idos en el caso de los concesionarios, y de aprovechamiento de residuos en el caso de los recicladores (). Frente al acceso seguro, () se entregar?a los recicladores de oficio la dotaci?, equipo y herramientas que [les] permitan () llevar a cabo su oficio protegiendo su integridad f?ica (AZ 5, folio 183).

-

3.6 Consorcio CONAMBIENTALES y Uni? Temporal ASEO Triple A (AZ 2, folio 266 a 268)

-

3.6.1 CONAMBIENTALES se?l?que a su parecer todo lo concerniente a las acciones afirmativas ya fue tratado y agotado en la audiencias p?licas adelantadas durante el proceso de la referida licitaci?. Igualmente, adujo que la asignaci? de cada una de las organizaciones de segundo nivel se debi?a un sorteo elaborado por la UAESP y que no () ha adelantado conversaci? alguna y mucho menos () contacto con alguna de estas asociaciones (AZ 2, folio 267).

-

3.6.2 Posteriormente, en respuesta al Auto 189 de 2011, expuso lo siguiente^[64]:

-

3.6.2.1 Se asocian al aprovechamiento m?tiples actividades; entre ellas la generaci?, la recuperaci?, el transporte, el almacenamiento, la pretransformaci? y la reutilizaci?. Los recicladores, participan principalmente en la recuperaci?, el transporte y la pretransformaci?.

-

Concatenado esto, se?l?que el Decreto 312 de 2006 adopt?el Plan Maestro para el Manejo Integral de

Residuos Sólidos. Empero, no presenta una descripción del proceso de aprovechamiento, ni las etapas en las que intervienen los recicladores. A pesar de ello, apunta que en el referido Decreto se contemplan estrategias para aumentar la competitividad de la cadena del reciclaje, que deberá ser apoyadas por el Distrito, vinculando a la población recicladora.

-

3.6.2.2 En cuanto al pesaje de material potencialmente aprovechable, alega que en el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos de la Ciudad (PGIRS) el Decreto 620 de 2007 no se menciona, en el artículo 24, la importancia de que las bodegas de reciclaje cuenten con un área donde se pueda determinar el tonelaje recuperado. Sin embargo, a continuación expuso que el PIGIRS no presenta ningún señalamiento ni procedimiento al respecto, se hace referencia únicamente al sistema de pesaje en el sitio de disposición final (AZ 5, folio 186). Sumado a esto, alega que el pesaje resulta fundamental para determinar la tarifa, dado que la medición resulta relevante para fijar el cobro del servicio. Para el caso de la recolección y disposición final, se utiliza el número total de toneladas que ingresan al relleno sanitario de cada área de prestación entre el número de suscriptores de dicha área (AZ 5, folio 186). Con respecto a la ruta de reciclaje, se limitó a mencionar aspectos contemplados en el anexo 5 del pliego de condiciones.

-

3.6.2.3 A modo de lo anterior, frente a la división de las utilidades derivadas de la concesión, recorda que existen dos tipos de socios: de capital y de industria. Los primeros recibirán utilidades luego de que la Asamblea General de accionistas apruebe los estados financieros. En cambio, los segundos se beneficiarán de las utilidades conforme a lo establecido en el pliego de condiciones. Con todo, aclara que estas acciones de industria están previstas en los artículos 137 y 138 del Código de Comercio, es decir sin estimación de su valor, por lo cual no redimen o liberan cuotas de capital social, aunque conceden derecho a participar en las utilidades sociales (AZ 5, folio 188).

-

Vale la pena señalar que este proponente no respondió concretamente en qué consiste el aporte de industria de la población recicladora. Igualmente, omitió ahondar en el funcionamiento o existencia del Fondo de Reciclaje. Por lo demás, también enfatizó que no le corresponde explicar el por qué del incremento a doce (12) organizaciones de segundo nivel. Empero, alega que en razón al sorteo para adjudicar las ASEs, donde como proponente no tuvo ninguna ingerencia, no ha adelantado conversaciones alguna o negociaciones con tales asociaciones.

-

3.6.2.4 Con respecto a las posibles utilidades, expuso que no tiene control total sobre las variables que incidirán en las ganancias de la empresa. Por ello, se abstuvo de responder la pregunta de fondo. Sumado a lo cual, mencionó que su relación con el aprovechamiento no redundará en acompañamientos a los recicladores, por lo que no espera beneficios económicos de esta actividad.

-

3.6.2.5 Finalmente, alega que por acceso cierto a los residuos sólidos comprende la facilidad que tendrán los recicladores de obtener el material para desarrollar su labor (AZ 5, folio 192). Así las cosas, no observa que exista tensión entre la labor de los recicladores y la recolección de la empresa, pues tal actividad se desarrollará con anterioridad a la recolección de los residuos ordinarios dispuestos en la vía para disposición final.

-

3.6.3 Por su parte, la Unión Temporal Aseo Triple A, apunta que tampoco ha adelantado procesos de

negociaci? con las diferentes organizaciones de recicladores de segundo nivel.

-

3.6.4 Al igual que el anterior proponente, esta Uni? Temporal envi?un nuevo escrito tras el Auto 189 de 2011 para absolver los interrogantes all?planteados^[65]. En este sentido, tambi? hizo referencia a las normas que regulan el aprovechamiento, entre ellas el Decreto 1505 de 2003, y expuso que las actividades que realizar? los recicladores ser? la recolecci?, separaci? y comercializaci? de los materiales potencialmente aprovechables.

-

3.6.4.1 Frente al pesaje, aleg? que no tiene conocimientos respecto a c?o se efect?, pues esta actividad no le corresponde al operador. Por lo mismo, □(□) tampoco [sabe] c?o opera la separaci? en la fuente dentro del proceso de aprovechamiento desarrollado en virtud de la licitaci? □ (AZ 5, folio 237). Sin embargo, mencion?que la medici? de los residuos provenientes del aprovechamiento provocar?una reducci? en las tarifas a pagar por los usuarios.

-

3.6.4.2 Con respecto a la ruta de reciclaje, se limit?a repetir lo contemplado en el Anexo 21 del pliego de condiciones y expres?que la relaci? con el usuario se da cuando ?te presenta los materiales potencialmente aprovechables. Por su parte, la vinculaci? con los recicladores se da cuando estos recogen dichos residuos. Aunado a esto, relat?que dependiendo de las ASEs se proyectan dis?iles utilidades. Empero, enfatiz?que □(□) examinados los pliegos y sus anexos, (□) NO encontr? aparte alguno en el que se indicara en qu?consiste este aporte de industria [de las organizaciones de segundo nivel]; no obstante lo [incluyeron] en [su] propuesta por cuanto ?te era una exigencia del pliego □ (AZ 5, folio 238). A pesar de ello, record?que la UAESP, en respuestas dadas a observaciones elevadas frente a la licitaci?, indic?que las acciones de industria representan el trabajo de dichas asociaciones, que se encargar? de hacer seguimiento, control, vigilancia, coordinaci?, educaci? e interlocuci? con aquellos recicladores de base que trabajen en el ASE respectivo.

-

3.6.4.3 Omiti?referirse al Fondo de Reciclaje y al aumento de las organizaciones de segundo nivel, dado que ambos son asuntos ajenos al proponente. A m? de ello, reiter?que no ha efectuado negociaciones con dichas asociaciones. Asunto que, a su parecer, no incidir?en los beneficios que, seg? el pliego, les corresponden. En cuanto a las utilidades proyectadas, al igual que otros proponentes, se ampar?en el art?ulo 15 de la Constituci? para omitir la respuesta. Sin embargo, manifest? que no existen utilidades proyectadas por concepto de aprovechamiento.

-

3.6.4.4 Finalmente, manifest?que entiende por acceso cierto y seguro a los residuos s?idos las actividades que se derivan de la asignaci? de ASEs, en raz? a la exclusividad concedida al operador que prestar?en ellas el servicio. Con todo, □(□) la garant? de este acceso no est?concedida al prestador del servicio, sino que entendemos se le concede a las organizaciones de reciclaje asignadas a cada ASE □ (AZ 5, folio 240).

-

3.7 --- Proponente Plural conformado por Ciudad Limpia Bogot?y otros (AZ 2, folio 269 a 299)

-

3.7.1 Felipe Holgu? Pe?, representante legal del proponente plural, intervino dentro de este incidente

para señalar que a su parecer □(□) la Acci? Afirmativa que dise? la UAESP en esta licitaci? y alrededor del componente de aprovechamiento en el servicio p?lico y de formalizaci? o inclusi? de los recicladores no se cumple realmente (□). [De hecho, afirm?categ?icamente que] no es una acci? afirmativa real, capaz de incluir a los recicladores de oficio en el sistema de aseo (□)□ (AZ 2, folio 270).

-

3.7.1.1 Para desarrollar lo anterior, expuso que opera en Bogot?desde 1989 y que fue una de las empresas adjudicatarias en el dos mil tres (2003) de una de las ASEs licitadas en ese momento. As? mismo, manifest?que ha prestado el servicio p?lico domiciliario de aseo en ciudades como Neiva, Yumbo, Cartagena, Tunja, Santiago de Chile, en Chennai y Ambattur (India), en Valencia (Venezuela) y en Col? (Panam?.

-

Tras relatar brevemente c?o opera para la prestaci? del servicio, enfatiz?que paralelo a su actividad, desde la informalidad, □(□) est? □ y desde antes que nosotros [han estado] □ los recicladores de oficio con sus carretillas, balineras, costales y veh?ulos de tracci? manual o animal□ (AZ 2, folio 272). Concientes de este hecho, adujo, han desarrollado una pol?ica para con este grupo poblacional que incluye su capacitaci?. As? mismo, una medida adoptada es dirigir y operar sus actividades sin competir con ellos. En este sentido, enfatiz?que □(□) Ciudad Limpia se encuentra dise?ndo un plan para apoyar a los recicladores en la nueva condici? de 'empresarios de la basura' que les reconoci?la Corte desde el caso de Cali (□)□ (AZ 2, folio 274). Sin embargo, no especific?en qu?consiste el mismo, mas se?l?que el negocio del proponente que representa no es el reciclaje; que □por lo dem?□ contempla como una actividad que no rivaliza, necesariamente, con la recolecci? para la disposici? final en el relleno sanitario.

-

Del mismo modo, relat?que en el 2003, se les hab? exigido a los proponentes montar un parque de reciclaje en el cual se dar? trabajo a los recicladores. No obstante, tal asunto no se materializ?y se termin?incluyendo en los contratos una ruta selectiva que deb? llevar ciertos residuos a un centro piloto de aprovechamiento: La Alquer?. Para ello, circula □(□) un carro compactador (□) [cuya labor] consiste en recoger el material dentro de un 29% del ASE 6 y entreg?selo al distrito en el centro de acopio ubicado en el barrio La Alquer? en Bogot? dicho material no representa m? del 01% del total de material reciclable disponible dentro del [ASE]□ (subrayas del original) (AZ 2, folio 275). Una de las razones para ello, radic?en □(□) que los recicladores de oficio recog?n con antelaci?□ (AZ 2, folio 275). Por ello, considera □como se dijo anteriormente□ que el aprovechamiento y la recolecci? para disposici? final no compiten.

-

3.7.1.2 A continuaci? y tras mencionar el caso de los recicladores en Cali que dio origen a la sentencia T-291 de 2009, record?cinco puntos □desarrollados en ese asunto-, que no fueron tenidos en cuenta dentro de la licitaci? p?lica 001 de 2011. As? expuso que para esta ?tima se impuso la asociaci? con las organizaciones de segundo nivel como criterio habilitante y de puntuaci?, mientras que en aqu? caso solo se le tom?como criterio de desempate. En otras palabras, se permit? a los prestadores asociarse libremente. Por ello, tal requisito □ enfatiz?□ se □(□) constituye [en] una violaci? a la libertad de asociaci?, tanto de los empresarios cooperativistas como [de] los empresarios de capital (□)□ (AZ 2, folio 277).

-

3.7.1.3 De igual modo, en Cali se consider?que la licitaci? era solo una herramienta de formalizaci? dentro de una pol?ica p?lica mucho m? compleja □ que inclu? elementos dentro del Plan de Gesti? Integral de Residuos S?idos (PGIRS). En cambio, para Bogot? □(□) la licitaci? (□) busca convertirse

en la herramienta ?ica de formalizaci? de los recicladores de oficio, sin mayores consideraciones del PMIRS [Plan de Manejo Integral de Residuos S?idos] □ (AZ 2, folio 277).

3.7.1.4 De otro lado, adujo que en el caso cale? se impuso la necesidad de incluir a los recicladores como empresarios aut?omos de la basura, situaci? que se echa de menos en el presente asunto. Esto ?timo, tambi? sucede ante la ausencia de mecanismos que aseguren acompa?miento permanente en aspectos t?nicos, financieros y organizativos.

3.7.1.5 A continuaci?, desarroll? las razones de hecho y de derecho por las cuales considera que en la actual licitaci? no se cumplen las obligaciones relativas a la inclusi? de acciones afirmativas, pues las medidas adoptadas no sirven para la efectiva inclusi? de la poblaci? en comento o para eliminar o reducir las diversas desigualdades que padecen. En este sentido, adujo que tales razonamientos fueron puestos en conocimiento de la UAESP durante diferentes etapas del proceso licitatorio, pero que la entidad hizo caso omiso a tales elementos.

3.7.1.6 As? las cosas, relat? qu? razones t?nico-operativas sustentan su parecer. En primer lugar, apunt? que □(□) no es conducente que se mezclen (□) las actividades de recolecci?, barrido y limpieza [□ bajo la modalidad de ASEs □] con (□) la actividad de reciclaje y aprovechamiento, particularmente cuando esta actividad se deja sin exclusividad y en libre concurrencia del mercado (□) □ (AZ 2, folio 280). Lo anterior, por cuanto en la ?tima actividad, s?o se es un actor m?, que compite con recicladores que no conoce, pero con la obligaci? de desarrollar el aprovechamiento. En efecto, □(□) los proponentes est? obligados a ofertar un porcentaje de cubrimiento de reciclaje en cada una de las 6 ASE, el cual no puede ser inferior al 32%, aun cuando la actividad de reciclaje no le corresponde prestarla a los futuros concesionarios por virtud de los pliegos. En este sentido[,] se le asigna una responsabilidad a los futuros concesionarios que no depende de ellos, sino de quienes realicen en cada ?ea la actividad de reciclaje □ (AZ 2, folio 281). A su parecer, nada garantiza que efectivamente se cumpla con la obligaci? de aprovechamiento, a pesar de ser un criterio de calificaci? dentro de la licitaci?, dado que los proponentes no ostentar? ning? control sobre la actividad de los recicladores que □ se reitera □ se desarrollar? bajo la ?ida de la libertad del mercado.

3.7.1.7 En cuanto a la obligaci? de vinculaci? laboral, apunt? que resulta una contradicci? esperar que los proponentes efect?n las contrataciones, mientras se impone a las organizaciones de segundo nivel el deber de incentivar la afiliaci? de los recicladores para desarrollar la actividad de reciclaje. Esto conlleva, a su juicio, una competencia entre ambas partes por mano de obra que, adem?, tendr? como consecuencia que □(□) los recicladores de oficio que sean contratados por los futuros concesionarios como mano de obra para actividades diferentes del reciclaje, no podr? afiliarse a una organizaci? de recicladores, precisamente porque dejar? de dedicarse a esa actividad de reciclaje para pasar a realizar una actividad distinta, ya como asalariados □ (AZ 2, folio 282). Esto conlleva, de hecho, un incentivo para la salida de los recicladores de la actividad, lo cual no puede entonces considerarse como una acci? afirmativa.

3.7.1.8 A m? de lo anterior, expuso que para los proponentes que ya han prestado el servicio, tal condici? se constituye en un conflicto frente a los actuales operarios □ que a lo largo de los a?s se han capacitado □ pues los obligar? a competir con la mano de obra a contratar en raz? a los puntajes que se otorgar? por esa causa. Asunto que, adem?, resulta una fuente de desigualdades entre los proponentes que concursan por primera vez, pues no tendr? que asumir el costo econ?mico y moral de perder personal

formado y con experiencia.

-

3.7.1.9 De otro lado, indic? que las condiciones fijadas por la UAESP permitieron que organizaciones formadas dos (2) o tres (3) meses antes del cierre de la licitaci? participaran, por lo que existen dudas sobre su calidad como asociaciones de recicladores. Al permitir que personas que no pertenecieran al gremio fueran beneficiadas de supuestas acciones afirmativas, se desnaturalizaron a las mismas.

-

3.7.1.10 Apunt? adem?, que no existe certidumbre sobre la remuneraci?. Esto, por cuanto no tienen asegurado acceso exclusivo al material reciclable dadas las condiciones de libre mercado que se plantean. Adicionalmente ☐ (☐) no se establece la forma como se calcular? la tarifa o el valor que cada reciclador deber? cobrar por la actividad que realice (☐) ☐ (AZ 2, folio 284). Por ello, no hay elementos que garanticen el derecho de desenvolverse como empresarios aut?omos de las basuras, reconocido en la jurisprudencia de la Corte Constitucional.

-

3.7.1.11 En cuanto a las posibles utilidades que ser?n repartidas a los recicladores, se?l? que ☐ (☐) el modelo econ?mico y financiero estimado y presentado por la UAESP contempla p?didas netas para todas las ASE por lo menos para el primer a? de operaci? (☐). [Igualmente] el modelo contempla significativos aportes de capital de parte de los inversionistas durante los dos primeros a?s de la concesi? en todas las ASE, y estima que los inversionistas podr? recuperar tales aportes a capital durante los a?s siguientes a la operaci? (☐). [Por] tal raz? solo se generar?n dividendos a partir del cuarto a? de la concesi?, con excepci? del ASE 1 en la que para el tercer a? se generar?n dividendos por un valor que no supera los setecientos veinticinco millones de pesos ☐ (AZ 2, folio 286). Ello implica que las utilidades para las organizaciones de segundo nivel sean eventuales. A esto se le suma que el porcentaje otorgado a los recicladores no puede ser variable, salvo que la empresa genere p?didas.

-

Sin embargo, a continuaci? elabor?unas tablas que mostrar?n dos posibles e hipot?icos resultados seg? un modelo efectuado por el proponente, en raz? al cual, dependiendo del porcentaje de acciones de industria otorgadas (emple?dos escenarios; uno de 5% y otro de 60%), la utilidad per-c?ita anual redundar?n, para el a? 2018 entre los ☐ (☐) \$105.648 [pesos] (☐) y \$2.052.571 [pesos] ☐ (AZ 2, folios 288 a 293). En este sentido, concluy? que al no existir certeza sobre el beneficio a recibir, ☐ (☐) el mecanismo de repartici? de dividendos a los socios de industria respecto de las utilidades de las sociedades que resulten concesionarias (☐) no es un mecanismo eficaz para lograr los objetivos que se buscan con la acci? afirmativa ☐ (AZ 2, folio 295).

-

3.7.1.12 Adicionalmente, se?l? que las medidas adoptadas por la UAESP, am? de no constituirse en acciones afirmativas por no lograr su finalidad, ☐ (☐) amenazan otros valores constitucionales (☐) ☐ (AZ 2, folio 296).

-

En primer lugar, al no estar realmente dirigida a una poblaci? desventajada espec?ica, viola el principio de igualdad. Esto, se debi?a la no utilizaci? de criterios de antig?edad para probar que se trataba de organizaciones tradicionales y representativas de esta poblaci?.

-

En segundo lugar, al ser la proyección de utilidades definitiva, no garantiza el mínimo vital. A esto se le suma que el () no es claro cómo los recicladores afiliados a las organizaciones de segundo grado van a distribuir [las utilidades] () con los nuevos afiliados y () con aquellos recicladores de oficio no vinculados a ninguna organización que sigan trabajando y contribuyendo a realizar el aprovechamiento del área respectiva, pero sin beneficio alguno a cambio en este esquema. Así puede haber recicladores que no trabajan y automáticamente tienen ingresos y otros () los que no están organizados () que si trabajan, contribuyen a la meta de aprovechamiento aun sin querer, pero no reciben nada a cambio (AZ 2, folio 297).

-

En tercer lugar, y en relación con lo anterior, indicar que habrá tres tipos de relaciones posibles que dificultan los vínculos con los recicladores: socios industriales con utilidades no vinculados laboralmente; recicladores trabajadores con salario cierto, pero no accionistas; y recicladores tradicionales de oficio no garantizado que contribuyen al aprovechamiento sin recibir nada a cambio. En este punto, se trata de que existe un problema adicional, atinente a los menores de edad y personas de la tercera edad, pues no sabrá () de ser adjudicatario () cómo vincularlos.

-

En cuarto lugar, manifestar que obligar a los recicladores a asociarse conlleva límites a su autonomía de empresarios y capacidad de crecimiento a sus empresas de economía solidaria. Con ello, de contera, se desconoce la Ley 1450 de 2011, que el () en su artículo 251 establece la necesidad de considerar a los recicladores en socios estratégicos del negocio del aseo y no solo como un actor más de libre mercado o dependiente enteramente de las empresas de capital () (AZ 2, folio 297). En este mismo sentido, se trata de que se desconoce la ley 1466 de 2011 que promueve la recolección de residuos sólidos inorgánicos para aprovechamiento en cabeza de las organizaciones autónomas de los recicladores.

-

En quinto lugar, reiterar que a su parecer () con las condiciones de la licitación () se vulnera el derecho de libertad de asociación. Esto, dado que () además de obligar a los proponentes y organizaciones a asociarse () no les permite ceder sus acciones de industria durante los ocho años de la concesión.

-

En sexto lugar, apuntar que se amenaza el saneamiento ambiental al permitir la libre competencia, ya que se deja el () a los residuos inorgánicos sin prestador, ruta, exclusividad, () destino de aprovechamiento definido. [Esto pondrá en peligro los intereses de otros grupos poblacionales ()] (AZ 2, folio 298 y 299).

-

3.7.1.13 Finalmente, se trata de que el () no hemos adelantado proceso de negociación alguna con los recicladores () [porque] toda libertad para negociar, conversar, elegir socio, escoger operador de aprovechamiento para la sociedad futura desapareció completamente y desde el inicio por voluntad de la UAESP () [quien impuso la obligación de] ceder un porcentaje de acciones o utilidades sin saber quiénes son ni que (sic) capacidad de trabajo tienen, qué experiencia han acumulado o cuánto trabajo de aprovechamiento pueden proponer. Las acciones que cedemos no representan, no pueden representar trabajo[.] Para nosotros[.] como seguramente para todos los licitantes[.] es sencillamente un requisito habilitante para licitar que si no se cumple equivale a cerrar la empresa y salir del mercado de la capital (AZ 2, folio 278 y 279).

-

3.7.2 Con posterioridad al Auto 189 de 2011, este proponente remitió un nuevo escrito a esta Corporación,

con el fin de absolver los interrogantes planteados en esa providencia^[66].

3.7.2.1 El aprovechamiento se considera como una de las actividades complementarias del servicio p^ublico de aseo. Aunado a ello, describi^óc^óo operan los recicladores en las ciudades colombianas y c^óo se ha transformado su quehacer desde la prohibici^ó de laborar en los frentes de trabajo de los rellenos sanitarios. Igualmente, apunt^óque la poblaci^ó recicladora acarrea los residuos recuperados hasta las bodegas de sus cooperativas para su transformaci^ó, embalaje y comercializaci^ó. Por otra parte, mencion^óque actualmente opera una ruta de recolecci^ó selectiva que transporta los materiales hasta la Alquer^í.

3.7.2.2 Asimismo, aleg^óque □(□) el programa Distrital de Reciclaje est^á en su segunda fase donde se ha abarcado el 33% de la ciudad aproximadamente, [por lo mismo] hay que reconocer que el trabajo del reciclador informal se ha mantenido en el resto de la ciudad (□)□ (AZ 5, folio 197). En contraste con la actualidad, seg^{ún} el pliego de condiciones, la ruta selectiva ser^{ía} realizada directamente por los recicladores, debiendo el operador sensibilizar a los usuarios para mejorar la separaci^ó en la fuente y su correcta presentaci^ó. En este sentido, expuso que el desarrollo del proceso de aprovechamiento cuenta con directrices normativas establecidas en el Decreto Distrital 312 de 2006. Empero, am^ó de copiar art^ículos de tal disposici^ó, se abstuvo de efectuar mayores an^{ál}isis al respecto.

3.7.2.3 Por otra parte, mencion^ó que para entender el pesaje de los residuos es necesario tener en cuenta c^óo funciona hoy en d^{ía}. As^í se^ñal^óque mensualmente y de manera aleatoria, se escoge un veh^ículo de la ruta de selecci^ó y se determinan las toneladas que carga, para efectuar posteriormente un promedio. Trat^ódose de recicladores de oficio, indic^óque los bodegueros determinan el peso para saber cu^{ánto}to deber^{ían} cancelarles. Igualmente, vuelven a efectuar el pesaje cuando van a comercializar el material como intermediarios. A su vez, expres^óque dentro de la metodolog^{ía} tarifaria vigente, las toneladas presentadas al mes por cada suscriptor se constituyen en factores importantes. Asunto este desarrollado en el art^ículo 3 de la Resoluci^ó CRA 352 de 2005.

3.7.2.4 Con respecto a las rutas de reciclaje, tambi^{én} expuso c^óo funcionan en la actualidad y qu^ése espera que suceda con ellas durante el desarrollo de la concesi^ó. As^ílas cosas, se^ñal^óque se trata de una ruta adicional, que recoge ciertos materiales en horarios determinados, previamente dispuestos y separados por los usuarios, llev^{án}dolos al Centro Distrital de Reciclaje La Alquer^í; operado por la UT Recicladores, conformada por la ARB, ARAMBIETAL y ARUB. Por lo mismo, solo en ese momento existe relaci^ó con determinadas organizaciones de segundo nivel. En cambio, □la ruta de reciclaje planteada en el pliego de condiciones, hace referencia a la que realizar^{ía}el reciclador asociado, el cual tendr^{ía}una dotaci^ó suministrada por el operador de aseo, el (sic) realizar^{ía}un recorrido libre, es decir, no necesariamente en el ASE asignada a su asociaci^ó (□)□ (AZ 5, folio 204).

3.7.2.5 Frente a las utilidades que espera recibir y la relaci^ó de las organizaciones de segundo nivel con ellas, expres^óque □(□) la UAESP aclar^óen la Licitaci^ó 001 de 2011 que las acciones de industria que se les deben ofrecer a las Organizaciones no se ver^{ían} reflejadas dentro de la composici^ó accionaria de los futuros concesionarios. Es as^ícomo se encuentra en las respuestas emitidas en la audiencia de aclaraci^ó que la UAESP precis^ó entre otros aspectos, que “son acciones de industria que se reflejan en utilidades que se liquidan anualmente, tienen derecho al reconocimiento del mayor valor de la empresa, pero su valor intr^{ín}seco no se capitaliza”□ (AZ 5, folio 205). A continuaci^ó, enfatiz^ó que tiene dudas en torno al aporte industrial de los recicladores, dado que se generaron cuestiones nebulosas en el pliego de

condiciones de la licitaci?n. En efecto, conforme establece el Anexo 21, la recolecci?n para el aprovechamiento seguir?a cargo de los recicladores que tradicionalmente est?n trabajando en el ASE respectivo. Por lo tanto, tal actividad □(□) no estar? a cargo de su socio industrial (asociaci?n de segundo nivel), sino de los recicladores de oficio ubicados en dicha ASE. Esto genera una confusi?n de car?cter l?gico y jur?dico con respecto a la identidad y el real aporte de nuestros posibles socios industriales, de los cuales se debe esperar una contraprestaci?n en su calidad de socios, como lo establece el art?culo 380 del C?digo de Comercio (□)□ (AZ 5, folio 207).

De esta forma, se impone a los concesionarios elaborar un plan de trabajo para implementar actividades de aprovechamiento, que deber?n desarrollar los recicladores que tradicionalmente act?n en el ASE. Por ende, quedan dudas sobre el aporte o contraprestaci?n que deber?n adelantar las organizaciones beneficiadas con la participaci?n accionaria. Sumado a lo cual, enfatiz?n que existe otra inconsistencia, atinente a que □(□) el objeto del futuro contrato no contempla la recolecci?n del material aprovechable por parte de los concesionarios, por lo tanto, los socios industriales no estar?n habilitados para ejercer contraprestaci?n alguna en materia de aprovechamiento por tratarse de una actividad ajena a la de la sociedad (□)□ (AZ 5, folio 208).

3.7.2.6 Por otra parte, se?l? que el Fondo de Reciclaje, conforme al Anexo 6 del pliego de condiciones, est? destinado a incentivar econ?micamente la separaci?n que realizan los usuarios en la fuente. Depende del valor de las toneladas de material potencialmente aprovechable que recojan en las rutas de reciclaje los recicladores de oficio. As? el 50% de este valor ser?para el fondo y el 50% se destinar?para beneficiar a la poblaci?n en comento. Sin embargo, enfatiz?n que la UAESP no ha explicado la naturaleza jur?dica del mismo. Por ello, a su parecer, es la entidad quien debe absolver este interrogante. Sin embargo, mencion?n que ante una solicitud de aclaraci?n, la UAESP respondi?□ el veinticinco (25) de mayo de dos mil once (2011) □ que los recursos para el fondo provendr?n de la venta del material reciclado (Z 5, folio 209).

3.7.2.7 Frente al aumento de organizaciones de segundo nivel, apunt?n que a su parecer esto se debi?a la ausencia de criterios de antig?edad que delimitaran los beneficiarios dentro de la licitaci?n. Con todo, record?n que en un principio tal criterio s?hab? sido utilizado, dado que se encontraba en los prepliegos, que establec?n como condici?n de participaci?n para estas asociaciones la constituci?n con anterioridad a un (1) a?o a la publicaci?n del proyecto de pliegos. Empero, □(□) en los pliegos definitivos publicados el d?a 25 de mayo de 2011[,] la Unidad (□) elimina el requisito del a?o de antig?edad en la constituci?n de la organizaci?n de recicladores (□)□ (AZ 5, folio 211). Posteriormente, mediante la Adenda 7 se impuso el requisito de participaci?n m?nima del 5% para la poblaci?n recicladora.

3.7.2.8 Finalmente y tras apuntar que por la l?gica de la licitaci?n no ha adelantado ninguna negociaci?n con las organizaciones de recicladores, expuso que entiende por acceso cierto y seguro a los residuos s?on los elementos contemplados en la □(□) ley 632 de 2011 (sic)□ (AZ 5, folio 215). As? las cosas, a su parecer, □(□) el acceso cierto, en el caso espec?fico del material aprovechable, se garantiza cuando existe una exclusividad en la prestaci?n del servicio, puesto que es la ?nica forma de asegurar un acceso real, ya que de lo contrario el actor se encontrar? vulnerable frente a las fuerzas del libre mercado y los intereses que genera la industria monopol?stica□ (AZ 5, folio 216).

3.8 Promesa de Sociedad Futura Bogot?Ambiental S.A. E.S.P (AZ 2, folio 306 a 315).

-

3.8.1 Este proponente, al igual que los anteriores, menciona que no ha adelantado negociaciones alguna con las organizaciones de recicladores de segundo nivel existentes en Bogotá. Igualmente, expuso que el (la) a su parecer el (la) la licitación pública en comento no cumple con la obligación de incluir acciones afirmativas a favor de la mencionada población.

-

3.8.1.1 En este sentido, manifiesta que en razón al sorteo utilizado por la UAESP solo una minoría de la población recicladora vulnerable será beneficiada por las acciones planteadas. Por ello, el (la) carecen de contenido comprensivo y por lo tanto no se pueden tomar como efectivas por no garantizar los derechos y mitigar las condiciones de vulnerabilidad de toda la población en su conjunto el (la) (AZ 2, folio 307). Así las cosas, la entidad permite que a los recicladores se les usará para obtener puntajes, pretermitiendo la finalidad de la acción afirmativa, que es superar la situación de vulnerabilidad en que se encuentran.

-

3.8.1.2 De otro lado, argumenta que tras la Adenda 8 se eliminó el tope de 10% accionario a entregar a las referidas organizaciones. Por eso, se generaron situaciones discriminatorias al permitir que los empresarios ofertaran porcentajes abismales según la rentabilidad de cada ASE. Concatenado a esto, apunta que a su juicio el (la) se constituiría una acción afirmativa el (la) establecer la obligatoriedad para los proponentes de ceder un porcentaje X, igual para todas las ASE, a las organizaciones de recicladores, que por demás, deben incluir a toda la población que se busca proteger. Así mismo, consideramos de suma importancia restablecer criterios razonables para el ofrecimiento de porcentajes a los recicladores de segundo nivel en la participación de la sociedad concesionaria, a fin de evitar que se realicen ofrecimientos de porcentajes que pongan en peligro la prestación del servicio público de aseo el (la) el (la) (AZ 2, folio 310).

Asegura que al permitir el ofrecimiento de porcentajes accionarios irrazonables, se hicieron inviables económicamente las sociedades concesionarias. Esto, a su vez cuestiona la viabilidad futura de las pretendidas acciones afirmativas, pues el (la) contraviene el principio de la continuidad en la prestación del servicio público y por tanto, afecta los derechos ofrecidos a los recicladores el (la) (AZ 2, folio 310).

-

Sobre lo anterior, enfatiza que tal Adenda fue introducida a escasos cuatro (4) días hábiles del cierre de la licitación, lo cual el (la) muestra que la UAESP no analizó los efectos materiales negativos que, frente a la acción afirmativa de dar porcentajes a los recicladores de segundo nivel en la participación de la sociedad concesionaria, podrá tener el hecho de no poner un límite razonable a tales ofrecimientos el (la) (AZ 2, folio 311). En este sentido, expuso que no resulta lógico que quienes deben responsabilizarse por el 100% de la operación, se desprendan de sumas como el 71%, el 49%, el 46% o el 45% de las acciones. Aunado a esto, enfatiza que el (la) la UAESP deberá tener en consideración que los aportes en industria ofrecidos a los recicladores convenidos por un valor no determinado (Código de Comercio, Art. 138) tal y como se contempla en la Licitación, no se redimen en aportes de la sociedad, sino que para esta (sic) constituyen un gasto, de tal manera que en la sociedad sus utilidades se verán disminuidas en la participación obligatoria del socio industrial, lo que hará más grave el riesgo de que no pueda cumplir la continuidad del servicio el (la) (AZ 2, folio 311). De contera, la inviabilidad financiera de la concesión, afectará principios de la Ley 142 de 1994, como la continua e interrumpida prestación del servicio.

-

3.8.1.3 De otro lado, señala que de poderse cumplir las prometidas utilidades, será necesario cuestionar la fórmula tarifaria existente. Esto, en razón a que según lo previsto por la Ley 142 de 1994, la tarifa permite amortizar los costos de inversión, los gastos de operación, así como la obtención de utilidades. Sin embargo, deben ser razonables y no desproporcionadas. Asunto que cuestiona con el otorgamiento de porcentajes

de utilidades que rondan entre el 45% y el 71%. Así las cosas, □(□) el ofrecimiento de tales porcentajes de las utilidades a las asociaciones de recicladores pone en “jaque” la estabilidad del sistema tarifario de las basuras en Bogotá pues pondrá en evidencia que la tarifa actual está incorrectamente calculada, [ya que] con su recaudo no solo le permite a los socios inversionistas recuperar su inversión y hacer una utilidad razonable, sino que además da para que un tercero, no inversionista, no operador, no expuesto al riesgo contractual, se lleve porcentajes significativos del beneficio económico de la concesión □ (AZ 2, folio 314). Adicionalmente, si las tarifas son injustas, se estarán vulnerando derechos colectivos y cabrán las acciones populares correspondientes.

-

3.8.1.4 A su parecer, serán acciones afirmativas aquellas que delimitaran el porcentaje accionario para las organizaciones de segundo nivel, tal y como estaba previsto antes de la Adenda 8.

-

3.8.1.5 Finalmente, apuntó que las ofertas de algunos proponentes plantean cantidades desmedidas de puestos de trabajo que no guardan estricta relación con la información presentada en la propuesta técnica. De hecho, plantearon que se les contratará como personas con ciertos niveles profesionales o técnicos, que por obvias razones no alcanzan los recicladores. Por ello, se trata de ofertas artificiales que no podrán cumplirse. Igualmente, enfatizó que la UAESP no estableció la obligación de mantener □(□) el ofrecimiento de puestos de trabajo a los recicladores. Es decir que un proponente podrá ofrecer muchos puestos de trabajo para obtener el puntaje, pero luego, retractarse una vez sea adjudicatario, sin sanción alguna por ello □ (AZ 2, folio 315).

-

3.8.2 Con posterioridad al Auto 189 de 2011, este proponente radicó escrito en la Corte Constitucional dando respuesta a las preguntas formuladas en esa providencia^[67].

-

3.8.2.1 En primer lugar, señaló que, en los términos de la Licitación Pública 001 de 2011, el aprovechamiento incluye las actividades de recolección, transporte, comercialización y reciclaje de los residuos.

-

Por su parte, las actividades realizadas por los recicladores son la recolección en carros de tracción humana, la recolección selectiva en determinado sector de la ciudad en vehículos asignados por el concesionario, junto con el conductor, y la comercialización del material aprovechable recolectado.

-

Sin embargo, Bogotá Ambiental consideró que □(□) la UAESP confunde el reciclaje con el aprovechamiento en la medida en que el reciclaje es una cadena de varias actividades que comienzan desde la producción de los desechos, por parte del productor primario, hasta el aprovechamiento de aquella parte de los desechos que eran reciclables □ (AZ 5, folio 256). Desde esta perspectiva, indicó que la base principal para alcanzar un alto porcentaje de aprovechamiento radica en □(□) la conciencia del productor primario □ (AZ 5, folio 256), razón por la cual propuso que se adelanten □(□) campañas de educación, difusión y socialización por parte del concesionario □ (AZ 5, folio 256).

-

3.8.2.5 En cuanto a las etapas en las cuales está dividido el proceso de aprovechamiento, Bogotá Ambiental enumeró cinco, explicó en qué consisten y expuso qué tareas desempeñan en dichas etapas los

recicladores y los operadores: (i) la separaci? de los residuos la realiza el productor primario, quien debe estar capacitado por el operador para que la separaci? sea correcta y eficaz; (ii) la clasificaci? de los residuos la realizan los recicladores; (iii) la recolecci? y transporte del material reciclable lo realizan los recicladores; (iv) la recolecci? y transporte del material restante hacia el relleno la efect? el operador; y (v) la disposici? final es □(□) la comercializaci? y aprovechamiento del material reciclable por parte de las bodegas de reciclaje y por las industrias como incorporaci? a la cadena productiva (□ 9□ (AZ 5, folio 257). Se aclar? que los recicladores son los responsables de la venta y comercializaci? de los residuos.

3.8.2.6 Con respecto a la manera como se pesan los residuos s?idos, Bogot? Ambiental anot? que los residuos reciclables son separados seg? su origen (cart?, vidrio, etc.) y luego pesados en la etapa de comercializaci?, esto es, □(□) en el sitio de aprovechamiento o compra de los mismos (bodega)□ (AZ 5, folio 257), en tanto que los residuos no reciclables son pesados en la entrada del relleno. Agreg? que □(□) no existe una interventor? o vigilancia por parte del Estado para la comercializaci? y pesaje del material reciclable□ (AZ 5, folio 258).

3.8.2.7 En lo que hace a la relaci? entre el peso de los residuos y el c?culo de la tarifa, Bogot? Ambiental advirti? que, de acuerdo con las resoluciones 351 y 352 de la CRA, □(□) la base de c?culo de las tarifas es el peso de los residuos□ (AZ 5, folio 258), es decir que □(□) a mayor peso, mayor tarifa y mayor ingreso para el concesionario□ (AZ 5, folio 258).

3.8.2.8 Posteriormente, observ? que la ruta de reciclaje es un recorrido que hace un veh?ulo lentamente □(□) mientras los recicladores realizan la evacuaci? de los residuos puerta a puerta hasta completar la capacidad del veh?ulo o finalizar el recorrido□ (AZ 5, folio 258). Se agreg? que □(□) la ruta de reciclaje ser?atendida exclusivamente por los recicladores de cada una de las ASE mediante el uso de veh?ulos de tracci? humana y los veh?ulos que oferte el operador□ (AZ 5, folio 258).

3.8.2.9 Igualmente, afirm? que a las organizaciones de recicladores de segundo nivel se les ofrecer?un porcentaje de participaci? en las utilidades equivalente al 9% trat?dose de las ASE 1, 2, 4, 5 y 6. En la ASE 3, se les ofrece a las organizaciones de recicladores un 5% en la participaci? de las utilidades. En ambos casos, la distribuci? de utilidades se har?anualmente, acorde con lo establecido en el pliego de condiciones, salvo que la junta directiva opte por distribuir utilidades semestralmente. Con todo, adujo que ni en el pliego de condiciones ni en las dem? etapas de la licitaci? se aclar?en qu?consiste el aporte de trabajo que efectuar? los recicladores en su condici? de socios de industria.

3.8.2.10 Por lo dem?, frente al Fondo de Reciclaje, manifest? que la UAESP □(□) no nos ha informado sobre el funcionamiento del fondo de reciclaje□ (AZ 5, folio 260). A la par, asegur? desconocer el motivo del incremento a doce (12) grupos de las organizaciones de segundo nivel, por lo tanto sugiri?□ (□) que se revise si los integrantes de las nuevas asociaciones de recicladores est? vinculados por contrato de trabajo u otra modalidad a algunos de los proponentes de la Licitaci?□ (AZ 5, folio 261).

3.8.2.11 Adicionalmente, sostuvo que □[n]o hemos tenido contacto con las organizaciones de segundo nivel, por lo que no hemos negociado ning? tipo de par?etros que establezcan prerrogativas, derechos o condiciones durante el contrato de concesi? ni ninguna de sus etapas□ (AZ 5, folio 261).

3.8.2.12 En cuanto a las utilidades proyectadas para cada una de las ASE, respondi? que la UAESP □ (□) inform? que la rentabilidad m?ima esperada para cada ASE es de 17.31% □ (AZ 5, folio 261) y que □[n]o se tiene proyectada ninguna utilidad para los concesionarios por el aprovechamiento de residuos s?idos □ (AZ 5, folio 262). Finalmente, en el escrito allegado a la Corte asever? que □ el acceso cierto y seguro de los residuos s?idos es la posibilidad de acceder a la recolecci? de los residuos s?idos de las ASE asignadas, en las microrutas establecidas □ (AZ 5, folio 262) y que el hecho de mantener las ?eas de Servicio Exclusivo, como en efecto lo hace la Licitaci? N? 001 de 2011, garantiza dicho acceso cierto y seguro. □ Sin embargo, la pregunta que surge es si las organizaciones de recicladores de segundo nivel que fueron asignadas a las ASE vinculan a un porcentaje mayoritario de la poblaci? vulnerable que se quiere proteger, pues de no ser as? la □ garant? de acceso cierto y seguro □ se convierte en un privilegio de algunos pocos □ (AZ 5, folio 262).

-

3.9 FEMSO de Colombia (AZ 2, folio 316 a 328).

-

En su escrito se?l? que no existen elementos pr?ticos para verificar que los porcentajes accionarios otorgados por los oferentes sean materialmente alcanzables. M?ime si se tiene en cuenta que tales organizaciones no asumen ning? riesgo, responsabilidad frente a la UAESP, inversiones o deudas. Adicionalmente, apunt? que no es claro qu? pasar? con aquellos recicladores que no est? coaligados a una organizaci? de segundo nivel y que, por lo mismo, no resultaron beneficiados tras el sorteo. En este sentido, se?l? que se afecta el principio de igualdad y el de buena fe.

-

De otro lado, indic? que las Adendas efectuadas por la entidad no han sido analizadas por la CRA, por lo que a? no cuentan con visto bueno alguno. Igualmente, tal omisi? repercute en posibles cuestionamientos de ausencia de legalidad, pues tal revisi? se constituye en un requisito preliminar.

-

Por lo anterior, solicit? a esta Corporaci? que valorara si □ (□) la puntuaci? otorgada y los ofrecimientos obedecen a una ponderaci? detallada, precisa y concreta que comporten una medida a favor de grupos marginados o discriminados, como lo son los recicladores (□) □ (AZ 2, folio 327).

-

3.10 Consorcio Lime (AZ 4, folio 5 a 18).

-

3.10.1 La representante legal de este consorcio intervino dentro del incidente para se?lar que, a su parecer, en la licitaci? p?lica no se cumplen las obligaciones de incluir acciones afirmativas a favor de la poblaci? recicladora. Sobre lo anterior, especific? que la jurisprudencia de la Corte Constitucional se refiere a la actividad de aprovechamiento de residuos s?idos y que los criterios que deber?n incluirse fueron delimitados en el Auto 268 de 2010.

-

Sin embargo, □ no resulta clara la aplicaci? o interpretaci? que la UAESP dio a [estas medidas] si se tiene en cuenta que la licitaci? 001 de 2011 y el contrato de concesi? que se adjudique debe tener por objeto la prestaci? del servicio p?lico de aseo, en condiciones de exclusividad, pero esta concesi? aunque incorpora las actividades de 'aprovechamiento' afirma que estas actividades no se encuentran a cargo del proponente y no se someten a exclusividad. No se entiende c?o se justifica la modalidad de

concesi? de ?eas de servicio exclusivo, excluyendo la actividad de aprovechamiento de esa exclusividad y dej?dola en la libre concurrencia del mercado (□)□ (AZ 4, folio 7). A m? de lo anterior, manifest?que las condiciones actuales de la licitaci? □ sobre todo el sorteo efectuado □ han acarreado conflictos entre algunos recicladores que buscan desplazar a otros que tradicionalmente han laborado en esas ASEs.

-

Por otra parte, cuestion?la asignaci? de puestos de trabajo en cualquier actividad de la prestaci? del servicio. Esto, dado que entend? que deb?n tener relaci? con el aprovechamiento seg? la jurisprudencia de la Corte, pues es un deber valorar la actividad que han venido desarrollando, y □ en raz? a la manera como fue contemplada en la licitaci? □ conllevaba la desocupaci? y desempleo de quienes hasta este momento hab?n desempe?do tales funciones. Estas personas, sin lugar a dudas, ser? removidos de sus labores para contratar en su lugar a poblaci? recicladora no necesariamente calificada para adelantar los trabajos. Lo que puede conllevar deficiencias en la prestaci? del servicio p?blico de aseo, arriesgando la calidad del mismo.

-

Adicionalmente, como quiera que se impone la obligaci? a las organizaciones de segundo nivel de incentivar la asociaci? de recicladores no coaligados, pueden generarse tensiones graves dentro del gremio. En relaci? con lo anterior, tambi? apunt?que se vulnera la libertad de empresa, dado que se les impone asociarse con organizaciones que no conocen como accionistas de industria. Aunado a esto, aleg?que muchas de estas agrupaciones no pueden tener experiencia en el aprovechamiento, en raz? a lo reciente de su creaci?.

-

Expuso que en un principio se hab? contemplado que la sostenibilidad financiera de la ruta de reciclaje estar? a cargo de las organizaciones de segundo nivel de cada una de las ASEs, mientras que ser? responsabilidad de los proponentes entregar los suministros de equipos y veh?ulos necesarios para la operaci? inicial de la misma. No obstante, la versi? final del pliego contempl?como una obligaci? del proponente □(□) mantener el porcentaje de cobertura ofertado una vez se entregue el manejo de la RDR [Ruta de Recolecci?]/□ (AZ 4, folios 9 a 10).

-

Ahora bien, lo anterior genera problemas, pues esa ruta estar?a cargo de los recicladores, frente a los cuales no existen garant?s del cumplimiento total de esta actividad. Por lo mismo, los porcentajes ofertados por los diferentes proponentes, que incluso llegaron al 100% en el primer a?, son ilusorios y muy probablemente imposibles de materializar. Sumado a esto, enfatiz?que □(□) esta situaci? traer? como consecuencia la posible imposici? de multas contractuales al concesionario, frente al incumplimiento de actividades que no podr?cumplir o sanear, por depender de [los recicladores]□ (AZ 4, folio 10).

Con respecto al r?imen tarifario, se?l?que no se incluye el aprovechamiento, a pesar de que la CRA ha anunciado el inicio de la revisi? y ajuste del marco existente. Ahora bien, a pesar de que se abri?la posibilidad de variar el mismo, surgen problemas en raz? a que este contrato estar?sujeto a la estabilidad regulatoria prevista en el art?ulo 10 del Decreto 891 de 2002.

-

Finalmente, manifest?que por las condiciones de la licitaci? p?lica 001 de 2011 no ha adelantado ning? proceso de negociaci? con las organizaciones de recicladores. En este orden de ideas, record?que las mismas fueron asignadas a las ASEs, sin que exista libertad de escogencia y que deber? ser socios de industria, sin que ellos conozcan □(□) sus competencias y nivel de compromiso (□)□ (AZ 4, folio 12).

-

3.10.2 Al igual que otros proponentes, el Consorcio LIME remitió - el seis (6) de septiembre de dos mil once (2011) - un escrito a esta Corporación mediante el cual dio respuesta a los interrogantes formulados en Auto 189 de 2011^[68].

-

3.10.2.1 Con el fin de definir el aprovechamiento en el marco del servicio público domiciliario de aseo, se remitió a los decretos 1713 de 2002 y 1505 de 2003, cuyos textos lo definen, según la transcripción del Consorcio, como "el conjunto de actividades dirigidas a efectuar la recolección, transporte y separación de residuos sólidos que serán sometidos a procesos de reutilización, reciclaje o incineración con fines de generación de energía, compostaje, lombricultura o cualquier otra modalidad que conlleve beneficios sanitarios, ambientales, sociales y/o económicos en el marco de la Gestión Integral de los Residuos Sólidos" (AZ 5, folio 268). En el escrito radicado en la Corte se refirió a que los recicladores se encargarán de la recolección, transporte, separación y comercialización de los residuos sólidos.

-

3.10.2.2 Con respecto a las etapas en que está dividido el proceso de aprovechamiento, el Consorcio LIME estimó en su escrito que "es la UAESP y el equipo estructurador de la Licitación No. 001 de 2011 a quienes corresponde explicar las etapas en que se divide este proceso, su funcionamiento y la intervención de los recicladores en el mismo" (AZ 5, folio 269). Simultáneamente, enfatizó en que los operadores deben intervenir "en procura de garantizar la mayor cobertura de usuarios de la Ruta de Reciclaje en el ámbito territorial de su respectiva Área de Servicio Exclusivo" (AZ 5, folio 269). Igualmente, expuso que corresponde a la UAESP explicar todo el funcionamiento para pesar los residuos sólidos, pues "[l]os Concesionarios no tendrán participación en esta actividad" (AZ 5, folio 270).

-

3.10.2.3 El Consorcio expuso que "[e]l peso de los residuos determina el valor por cobrar a cada usuario, debido a que la cantidad total de residuos generados en un Área geográfica determinada se distribuye en cantidades iguales y se factura entre todos los usuarios que la conforman, según su correspondiente estrato socioeconómico" (AZ 5, folio 270).

3.10.2.4 En cuanto a la definición y funcionamiento de las rutas de reciclaje, el Consorcio realizó una transcripción de un fragmento del Anexo 1 del Reglamento Técnico Operativo que determina lo que se entiende por ruta de reciclaje para después concluir, a partir de allí que "corresponde a los recicladores y recuperadores recoger el material potencialmente aprovechable; a los generadores de los residuos o usuarios del servicio seleccionar previamente dicho material potencialmente aprovechable y a los concesionarios del servicio de aseo suministrar a los primeros los vehículos (de tracción manual o automotor), equipos, dotaciones y uniformes durante el primer año de operación" (AZ 5, folio 271).

-

3.10.2.5 Ahora bien, el Consorcio LIME señaló que, en materia de distribución de utilidades, las empresas de servicios públicos se rigen por las normas del Código de Comercio referentes a las sociedades anónimas. Con todo, "en relación con los accionistas de industria, las utilidades generadas durante el período de concesión (8 años), se dividirán o repartirán de acuerdo con lo previsto en el Pliego de Condiciones", a cuyo tenor, de las utilidades generadas cada año se repartirán inicialmente "antes de reservas", la parte que corresponda a los accionistas de industria, en el porcentaje asignado en cada Área de Servicio Exclusivo, ASE a las organizaciones de recicladores de segundo nivel, y, posteriormente, el remanente susceptible de distribución se repartirá a los accionistas capitalistas" (AZ 5, folio 272). ...

-

As? mismo, el Consorcio revel? que el aporte de industria □ (...) consiste en una prestaci? de hacer, referida a la labor que en materia de reciclaje realizar? dichas organizaciones por conducto de sus miembros □ (AZ 5, folio 272). De todos modos, dicho aporte se realizar? sin estimaci? de su valor, □ (□) de manera que no redime acciones de capital sino de industria, que otorgan derecho a participar en las utilidades y en cualquier super?it, en la forma que se estipule □ (AZ 5, 272). La raz? de esto es que la UAESP □ (□) elimin? mediante Adenda No. 9 un aparte del Anexo 4 del Pliego de Condiciones que dispon? que las acciones de industria tendr?n los mismos derechos que las ordinarias □ (AZ 5, folio 272).

-

3.10.2.6 En lo atinente al Fondo de Reciclaje, el Consorcio cit? el numeral 10.1.14 del pliego de condiciones que dispone que □ [c]omo incentivo econ?ico para que los usuarios realicen separaci? en la fuente, la UAESP devolver? anualmente el valor de las toneladas de Material Potencialmente Reciclable que recojan las Rutas de Reciclaje. Del monto anual por este concepto se destinar? 50% a un fondo reciclaje, que ser? destinado para beneficiar a la poblaci? de recicladores o a la actividad del reciclaje y el 50% restante ser? devuelto a los usuarios del Distrito, v? factura, como incentivo del reciclaje total de los Bogotanos □ (subrayas y negrillas del original) (AZ 5, folio 273).

-

3.10.2.7 El Consorcio LIME no brind? razones para justificar el incremento a doce (12) organizaciones de segundo nivel, dado que desconoce el procedimiento que adelant? la UAESP para seleccionarlas. Aunado a esto, afirm? que no ha realizado negociaci? alguna con las organizaciones de recicladores de segundo nivel y que □ [l]os t?minos de vinculaci? de estas organizaciones y los derechos que les corresponder? fueron fijados por la UAESP en la condiciones de la Licitaci? □ (AZ 5, folio 273).

-

3.10.2.8 M? adelante en el escrito presentado, el Consorcio LIME se abstuvo de revelar la proyecci? de utilidades, como sea que ello hace parte de la propuesta econ?ica que se encuentra en el sobre que s?o se abrir? en la audiencia de adjudicaci?. No obstante, reconoci? que □ (□) no proyect? utilidades por concepto del aprovechamiento de residuos s?idos, precisamente porque esta actividad ha sido reservada a los recicladores, de manera que los concesionarios no recibir? ingresos de la misma □ (AZ 5, folio 274).

-

3.10.2.9 Por ?timo, encontr? que □ (□) la recolecci? de residuos s?idos est? limitada a aquellos que los usuarios depositen en la v? p?lica □ (AZ 5, folio 274), no obstante que □ [e]n repetidas oportunidades se puso de presente a la UAESP que se trata de una excepci? no contemplada por el art?ulo 40 de la Ley 142 de 1994 □ (AZ 5, folio 274).

-

3.11 Promesa de Sociedad Futura □ Promoambiental Distrito S.A.S. ESP (AZ 4, folio 39 a 43).

-

3.11.1 El representante de este proponente intervino dentro del incidente para se?lar que, a su parecer, en la licitaci? en comento se cumplen las obligaciones de incluir acciones afirmativas a favor de la poblaci? de recicladores del Distrito Capital. Esto se observa en □ (□) las condiciones, exigencias y requerimientos m?imos impuestos a los ofrecimientos de los proponente (□) □ (AZ a, folio 39).

-

En este orden de ideas, recordo los ofrecimientos elaborados por Proambiental, que redundan en participaci? accionaria entre el 18.36% y el 20% como socios de industria. Esto implica el derecho de los recicladores de participar en utilidades, as? como el beneficio de recibir esos porcentajes cuando la sociedad sea liquidada. Por lo dem?, asistir? con derecho a voz a las reuniones de la asamblea de accionistas. □ Como contra partida, la(s) sociedad(es) que se constituyan (□) pretenden que los socios titulares de las acciones de industria se obliguen a compensar las mismas con su trabajo, asistencia, gesti? social y servicios (□) □ (AZ 4, folio 40).

Por lo dem?, menciono que han ofrecido puestos de trabajo para la poblaci? recicladora y que ser? capacitada, calificada y vinculada para el desarrollo de las obligaciones contractuales. Adicionalmente, acompa?r? a las organizaciones de segundo nivel en la puesta en marcha de la labor de recolecci? selectiva del material potencialmente aprovechable. Dado que, □ (□) como es evidente, la inclusi? social y econ?mica de esta poblaci? (□) imprime un alto grado de complejidad al proyecto para lograr un esquema viable y auto sostenible en el tiempo □ (AZ 4, folio 42). En este sentido, expuso que apoyar? esquemas empresariales constituidos por estas organizaciones y proveer? los recursos t?nicos y equipos que □ seg? el pliego de condiciones □ se requieran. Con todo, enfatiz? que es necesario un proceso de sensibilizaci?, que □ por sus propias condiciones □ es lento y complejo, dado que el aprovechamiento involucra a diferentes actores como □ (□) recicladores, generadores, bodegueros e intermediarios (□) □ (AZ 4, folio 42).

Por ?timo, expuso que con anterioridad a la licitaci? p?blica tuvo acercamientos con algunas organizaciones de segundo nivel para presentar una propuesta conjunta, siguiendo la experiencia anterior que devino de la adjudicaci? del Relleno Sanitario Do? Juana. Con todo, no se?l? a qu? organizaciones se refer?.

3.11.2 Con posterioridad, el referido proponente alleg? un nuevo escrito a esta Corporaci? con el que busc? absolver los interrogantes expuestos en el Auto 189 de 2011^[69], as?

3.11.2.1 En cuanto a las actividades que componen el aprovechamiento, apunt? que la separaci? deber? ser adelantada principalmente por los usuarios y subsidiariamente por los recicladores. Con respecto a la recolecci? y transporte, aleg? que mediante su propuesta busca □ (□) acompa?r? a los recicladores y sus organizaciones de segundo nivel en la implementaci? y puesta en marcha de las rutas de recolecci? selectiva del material potencialmente reciclable, buscando el alcance de las metas propuestas (□) □ (AZ 5, folio 155). Por lo mismo, los recicladores realizan directamente, la recolecci?, el transporte, la separaci? y clasificaci?, y la comercializaci?.

3.11.2.2 A continuaci?, expuso que el aprovechamiento est? dividido en varias etapas, que comprenden la reutilizaci?, el reciclaje, la incineraci? con fines de generaci? de energ? y el compostaje. □ As? las cosas, los recicladores son parte fundamental del proceso de aprovechamiento, pues son ellos quienes efectivamente realizan dicha labor □ (AZ 5, folio 157).

3.11.2.3 Con respecto al momento en el cual son pesados los residuos producidos por los usuarios, apunt? que existe un procedimiento denominado aforo, que se realiza mediante los equipos de pesaje incorporados en los veh?ulos. Esto es importante, por cuanto se utiliza para aplicar los descuentos

tarifarios por aprovechamiento. A su vez, existen ☐ (☐) b?culas instaladas por el operador del relleno para tal efecto ☐ (AZ 5, folio 158). Igualmente, se?l? que pueden pesarse los residuos recogidos en la ruta de reciclaje al momento de llegada a la bodega de clasificaci?n, as? como cuando vayan a ser comercializados o reutilizados.

Sumado a lo cual, enfatiz? que el pesaje de los residuos es fundamental para el c?culo de la tarifa, dado que as? lo dispone la Resoluci?n CRA 351 de 2005, donde solamente el componente de barrido y limpieza es el ?nico que no depende de las toneladas recogidas.

3.11.2.4 Sobre la Ruta de Reciclaje, mencion? que se trata de recorridos que efect?n los recicladores, recogiendo el material potencialmente aprovechable. Para ello, contar? con equipos e implementos suministrados por los concesionarios. Existe, igualmente, una relaci?n directa entre los usuarios y esta ruta, dado que el ?xito de las mismas depende de la separaci?n en la fuente. Concluy? enfatizando que ☐ (☐) la ruta de recolecci?n selectiva es una actividad directa a cargo de la poblaci?n recicladora de oficio ☐ (AZ 5, folio 159).

3.11.2.5 Por otra parte, adujo que durante los ocho (8) a?s de prestaci?n del servicio de aseo las utilidades se repartir? conforme a la proporci?n de participaci?n de todos los accionistas. Como quiera que ellos ofrecieron entre el 18.36% y el 20% de acciones, ese ser? el monto que corresponda a las organizaciones de segundo nivel, sin afectarlos con reservas y sin lugar a capitalizaci?n. A m? de lo anterior, expuso que el aporte industrial de los recicladores consiste en ☐ (☐) colocar su experiencia y conocimiento al servicio del componente de aprovechamiento, que es parte integral de la prestaci?n del servicio p?blico de aseo (☐ ☐ (AZ 5, folio 160). Esto implica hacer seguimiento a los recicladores de oficio que tradicionalmente trabajan en el respectivo ASE, promover la asociaci?n de los mismos e incentivar el uso de los equipos otorgados.

3.11.2.6 Frente al Fondo de Reciclaje, aleg? que est? regulado en el anexo 16, que versa sobre el reglamento comercial y financiero que deber? regir la concesi?n. As? el valor de las toneladas que se recojan en la Ruta de Reciclaje, en un 50%, estar? destinado a este fondo y tendr? por objeto el beneficio de la poblaci?n en comento o el incentivo a la actividad de reciclaje.

3.11.2.7 En referencia al aumento de las organizaciones de segundo nivel, manifest? que se trata de un desarrollo l?gico de las libertades de asociaci?n y de empresa, en raz? al reconocimiento de los beneficios que acarrear? esta licitaci?n. Aunado a esto, enfatiz? que seg?n la UAESP, de los m? de 11.000 recicladores, s?o el 10% se encontraba coaligado. Por ello, las altas expectativas y posibilidades de crear empresa resultaron un incentivo para que se formaran nuevas organizaciones. Sin embargo, enfatiz? que siguiendo los par?metros de la licitaci?n, no es procedente efectuar ninguna negociaci?n con ellas. Con todo, expres? que los beneficios que recibir?, entre ellos los puestos de trabajo, deber? ser mantenidos durante toda la concesi?n, salvo que ☐ en casos extraordinarios ☐ la UAESP decida lo contrario. Ahora bien, cabe destacar que ☐ (☐) el operador adquiere el compromiso contractual de apoyar a los recicladores y colaborar con ellos en la formulaci?n del plan de negocios que permita la auto-sostenibilidad y ?xito de la empresa de aprovechamiento ☐ (AZ 5, folio 162). Por lo mismo, el concesionario no recibir? remuneraci?n alguna por esta actividad, que ser? desarrollada por los recicladores, incluida la comercializaci?n.

3.11.2.8 Por lo dem?s, apunt? que no existir? restricciones de acceso a los residuos domiciliarios para los

recicladores. Por lo tanto, se garantiza acceso cierto y seguro a los mismos. En este sentido, apunta que la licitación no contempla exclusividad alguna en las actividades de recolección y transporte que sean presentados de forma separada por los generadores.

3.12 Promesa de Sociedad Futura RBL Bogotá DC (AZ 4, folio 106 a 146)

3.12.1 El representante legal de este proponente intervino dentro del incidente para apuntar que, desde su perspectiva, en la licitación pública 001 de 2011 se cumple con la obligación de incluir acciones afirmativas a favor de la población recicladora.

Para sustentar lo anterior, recorda que el () desde la etapa de pre pliegos () (AZ 4, folio 107) se sabe que deberán participar y constituir junto a recicladores la empresa de servicios públicos concesionaria. Para regular lo anterior, se determina que a las ASES corresponderá cada una de las organizaciones de segundo nivel. Esto conlleva que su vinculación no sea una mera expectativa y que se materialice con la cesión de acciones o con la constitución de la sociedad futura. Ambas con el carácter de irrevocables.

Por lo demás, apunta que al momento de analizar las acciones afirmativas, debe constatarse si con las mismas se garantiza la forma de subsistencia de la población vulnerable dedicada a esta actividad () (AZ 4, folio 108). Pues bien, a su parecer el mínimo de 5% de participación accionaria les permite ingresar en esquemas empresariales reales. Lo mismo es predicable de la vinculación de mano de obra, que se asegura con los puntos dentro de la calificación otorgados por ella. Por ello, recorda que según las ASES, ofertaron entre 526 y 795 puestos de trabajo para la poda de árboles, corte de césped, barrido, entre otras. A más de lo anterior, los beneficios que se derivarán de su calidad de socios de industria están claramente delimitados en el Código de Comercio.

Concluye este punto exponiendo que el () son acciones afirmativas aquellas que incorporan directamente en la estructura societaria de la futura ESP, a las organizaciones de recicladores como aportantes de industria, así como lo es la apertura de posibilidades de empleo a partir de actividades conexas al servicio de aseo como componente de mano de obra - (AZ 4, folio 110). Sin embargo, enfatiza que una desproporcionada y desequilibrada participación, acarreará probables afectaciones a la prestación del servicio público.

Por otra parte, recorda que el anexo 5 al reglamento técnico operativo desarrolla la recolección del material potencialmente aprovechable y establece que el () la recolección selectiva consiste en recoger separadamente diferentes fracciones de los residuos sólidos con el fin de reciclarlos. La recolección selectiva y el reciclaje permiten ahorrar recursos escasos y parte de la energía necesaria para la fabricación de los productos a partir de materias primas vírgenes (AZ 4, folio 114). La separación se debe dar por los usuarios en el origen de la cadena de los residuos, que deben presentarlos. A continuación, enfatiza que el único destinatario en este momento de esas rutas de recolección es el centro La Alquería (AZ 4, folio 16), que es manejado por la ARB, ARUB y ARAMBIENTAL, tras su constitución en Unión Temporal. Empero, para potencializar esta posibilidad de aprovechamiento, espera que en el futuro pronto entren en operación los Parques de Reciclaje en Bogotá. Por ello, enfatiza que el () el desarrollo coordinado de las campañas de separación en la fuente, la ruta de recolección selectiva y el centro de

reciclaje la Alquer?, es fundamental para implementar un sistema de reciclaje organizado en la ciudad y asegurar la viabilidad financiera del reciclaje, a fin de contribuir a elevar el nivel, la calidad de vida y la productividad de la ciudad, beneficios entre los cuales est?la ampliaci? de la vida ?il del Relleno Sanitario Do? Juana (□)□ (AZ 4, folio 117).

A m? de lo anterior, expuso que de las 73 micro-rutas de selecci? □(□) 24 corresponden al Concesionario LIME, 24 al Concesionario Aseo Capital, 14 al Concesionario Ciudad Limpia y 11 al Concesionario ATESA (□)□ (AZ 4, folio 117). En cuanto al comportamiento general de la producci? de material potencialmente reciclable, afirm?que en marzo del dos mil once (2011) se present?un incremento, siendo las ASEs con mejores resultados la 1 y la 4 (AZ 4, folio 124). Empero, expuso que existen localidades donde actualmente no existen rutas de selecci?, por lo que de ser adjudicataria del contrato se compromete a ampliar la cobertura.

3.12.2 Al igual que los dem? proponentes, Promesa de Sociedad Futura RBL Bogot?D.C. present?- el seis (6) de septiembre de dos mil once (2011) - en cumplimiento del Auto 189 de 2011, escrito a trav? del cual absolvi?el cuestionario formulado:

3.12.2.1 Expres?que el aprovechamiento consiste en □(□) la recuperaci? de residuos s?idos potencialmente reciclables [cart?, papel. pl?tico, vidrio, entre otros] mediante un proceso que inicia con los usuarios, quienes se encargan de hacer la separaci? en la fuente de dichos residuos y presentarlos adecuadamente para su recolecci?; luego se recolecta el material por medio de una ruta de recolecci? selectiva que realiza el operador del servicio de aseo en cada ASE conjuntamente con los recicladores; el material puede ser almacenado en bodegas o se lleva directamente al centro de acopio autorizado, en donde se realiza la separaci? y clasificaci? del material para la posterior comercializaci? □ (AZ 5, folios 276 a 277).

En este mismo sentido, RBL Bogot? exhibi?las actividades que contempl?en su propuesta en materia de aprovechamiento. De esta manera, (i) har?un diagn?tico, a trav? de encuestas a los recicladores, para establecer el status actual del ASE adjudicado, que apoye el dise? de estrategias que permitan identificar los potenciales generadores de material aprovechable. Igualmente, (ii) propuso capacitar a los recicladores en torno a procesos de separaci? en la fuente y a dotarlos de uniformes. (iii) La etapa de recolecci? selectiva estar?a cargo de los recicladores del ASE, para lo cual RBL Bogot?dispondr?de unidades tipo furg? que har? la recolecci? selectiva con el sistema puerta a puerta. (iv) □Una vez recolectados los residuos inorg?icos, estos pueden ser almacenados por los recicladores en las bodegas que dispondr?Promesa de Sociedad Futura RBL Bogot?D.C para tal fin o inmediatamente pueden ser transportados al centro de acopio y reciclaje autorizado, que ser?manejado por la poblaci? recicladora asignada para la ASE□ (negritas tomadas del texto original) (AZ 5, folio 278). Por ?timo, □[e]n el centro de acopio y reciclaje autorizado, los recicladores realizan la separaci? y clasificaci? del material potencialmente reciclable (□), para su posterior comercializaci? en el mercado□ (AZ 5, folio 278).

3.12.2.2 A la pregunta sobre las etapas en las que se encuentra dividido el proceso de aprovechamiento, RBL Bogot?enunci?cinco. En primer lugar, la separaci? en la fuente es realizada por los usuarios. En segundo lugar, la recolecci? del material potencialmente aprovechable se realiza en unidades tipo furg? y en carros de tracci? manual que se les entregar? a los recicladores. Ahora, □[l]os materiales que sean recolectados tanto por Promesa de Sociedad Futura RBL Bogot?D.C, como por los recicladores, ser? trasladados directamente a las bodegas de almacenamiento donde las organizaciones de recicladores

tendr? el control y derecho sobre dichos residuos□ (negritas tomadas del texto original) (AZ 5, folio 280). En tercera instancia, el almacenamiento se realiza en centros de acopio manejados y controlados por las organizaciones de recicladores. En cuarto lugar, las organizaciones de recicladores clasifican los residuos potencialmente aprovechables. La etapa final del proceso es la comercializaci?, la cual □(□) ser?llevada a cabo y estar?bajo el total control de las organizaciones de recicladores, quienes ser? los que negocien los precios en el mercado, concreten la venta y reciban los beneficios econ?micos directamente□ (AZ 5, folio 281).

3.12.2.3 Asimismo, RBL Bogot? record?que □(□) en su propuesta ha considerado la contrataci? directa de mano de obra proveniente de las asociaciones de recicladores para desarrollar actividades de barrido, limpieza, corte de maleza, poda, lavado, etc.□ (AZ 5, folio 281). Aunado a ello, explic?que □[e]l pesaje de los residuos aprovechables ser?realizado al momento de su recolecci? a trav? de un sistema de pesaje en chasis y/o brazos CLASE III (precisi?), que permitir?un registro asociado al computador abordo y al software del Sistema de Informaci? Integral del Servicio de Aseo (SIISA)□ (may?culas tomadas del texto original) (AZ 5, folio 282). De igual manera, hizo hincapi?en que □(□) dentro de su propuesta tiene considerado realizar la recolecci? de residuos por separado seg? su fuente, es decir, separando, los residuos de producci? domiciliaria, los residuos de grandes generadores, los residuos de barrido, el material aprovechable y los residuos de operativos especiales□ (AZ 5, folio 282).

3.12.2.4 Frente a la incidencia del peso de los residuos en la metodolog? de c?culo de la tarifa, RBL Bogot? declar?que a medida que aumenta el peso de los residuos, tambi? aumenta la tarifa que se cobra a los usuarios. □De igual forma, uno de los componentes de la f?rmula para determinar las tarifas que se cobrar? a los usuarios es el costo de tratamiento y disposici? final (CDT); dicho componente est?en funci? al tonelaje de residuos que se disponen en el relleno sanitario, por lo que en la medida en que los usuarios reciclen, el tonelaje de residuos que llegan al relleno sanitario es menor y por lo tanto se ven beneficiados en la disminuci? de las tarifas□ (AZ 5, folio 283).

3.12.2.5 La ruta de reciclaje se refiere, seg? RBL Bogot? a □(□) aquel sector a atender con unidades especializadas tipo furg? y con horarios y frecuencias preestablecidas en los cuales se llevar?a cabo la recolecci? de los materiales potencialmente aprovechables□ (AZ 5, folio 283). Agreg?RBL Bogot?que las rutas de reciclaje ser? reforzadas por los recicladores que □ser? dotados con carros de tracci? manual para recorrer la zona□ (AZ 5, folio 283).

3.12.2.6 Paralelo a lo anterior, RBL Bogot?dispuso que □(□) bajo los requerimientos de la concesi?, as? como de los estatutos y la ley, adoptar? las determinaciones atinentes al reparto y distribuci? de utilidades, tanto en funci? de la participaci? en su capital de los socios o accionistas, as?como de los titulares de aportes de industria□ (AZ 5, folio 284). Siguiendo esta l?ea, afirm?que □(□) el aporte que como socios de industria efectuar? las organizaciones de recicladores de segundo nivel en la empresa de servicios p?blicos (□), est? representado por el servicio de recolecci? del material potencialmente aprovechable (actividad de reciclaje) y por el trabajo que ejecuten como personal a cargo de las labores de recolecci?, barrido mec?nico, barrido manual, limpieza, lavado, corte de c?ped y poda de ?boles, para las cuales ser? vinculados (sic) como mano de obra□. (AZ 5, folio 284).

3.12.2.7 En relaci? con el Fondo de Reciclaje, adujo que □(□) la UAESP devolver?anualmente, como incentivo econ?mico, el valor de las toneladas del □Material Potencialmente Reciclable□ recogido por los recicladores de oficio□ (AZ 5, folio 285) y el 50% de este valor devuelto se destinar?al Fondo de

Reciclaje que beneficiar? a la poblaci? de recicladores o a la actividad del reciclaje.

-

3.12.2.8 No explic? el incremento en el n?ero de organizaciones de segundo nivel, mas relat? la manera c?o la UAESP convoc? y seleccion? a estas organizaciones. Finalmente, concluy? que □ (□) es evidente que la convocatoria de la UAESP con el prop?ito de implementar acciones afirmativas a favor de los recicladores de Bogot? tuvo gran acogida por dicha poblaci?, con lo cual se foment? la agrupaci? de recicladores en nuevas asociaciones de segundo nivel con el prop?ito de ser part?ipes de la prestaci? del servicio p?blico de aseo □ (AZ 5, folio, 286). Por otro lado, reconoci? que no negoci? con ninguna asociaci? de recicladores, ya que □ [e]l porcentaje de participaci? de tales organizaciones como socios de industria es un factor de ponderaci? que cada proponente ofrece de acuerdo con su modelo financiero, y respecto del cual no es procedente efectuar negociaci? alguna con las organizaciones sorteadas para cada ASE □ (AZ 5, folio 287).

-

3.12.2.9 Con respecto a las utilidades esperadas, RBL Bogot?s?o mostr? los resultados principales que sirvieron de base para la presentaci? de la oferta, pues □ [t]anto la modelaci? como [las] utilidades proyectadas son informaci? reservada del proponente □ (AZ 5, folio 288).

-

Finalmente, expuso que la noci? de acceso cierto y seguro a los residuos s?idos es □ la certeza que tendr? las organizaciones de recicladores de acceder a los residuos s?idos generados en el ASE para el proceso de aprovechamiento □ (AZ5, folio 289). Sumado a lo anterior, RBL Bogot?sugiere que en la actual licitaci? s?se garantiza dicho acceso cierto y seguro, debido a que □ las organizaciones tendr? acceso a la informaci? sobre las cantidades generadas por los usuarios en cada zona, as? como tambi? tendr? participaci? directa en las diferentes etapas del proceso □ (AZ 5, folio 289).

-

3.13 Aseo Capital, Uni? Temporal (AZ 4, folio 147 □ 155).

-

3.13.1 El representante de este proponente intervino dentro del incidente para manifestar que □ a su parecer □ la licitaci? p?lica en comento incluye a la poblaci? recicladora del Distrito. Para sustentar su punto, se limit? a copiar los elementos del pliego de condiciones que se relacionan con este asunto. Entre ellos, los criterios de habilitaci? y clasificaci?. Aunado a ello, expuso que el dise? del pliego de condiciones y de la manera como est? contemplada la participaci? de los recicladores, no permite que se realice ning? acercamiento con las organizaciones de recicladores antes de la adjudicaci?.

-

3.13.2 Con posterioridad al Auto 189 de 2011, este proponente remiti? a la Corte Constitucional un nuevo documento para solventar las cuestiones formuladas en esa providencia^[70], as?

-

3.13.2.1 Al igual que los dem?, mencion? disposiciones que regulan la actividad de aprovechamiento y enfatiz? que seg? la licitaci?, estas operaciones ser? adelantadas por la poblaci? recicladora. A este respecto, los concesionarios solo deber? entregar dotaciones y equipos de trabajo, as? como brindar □ (□) la cobertura de usuarios beneficiarios de la Ruta de Recolecci? Selectiva ofertada como criterio ponderable dentro de la licitaci? (□) □ (AZ 5, folio 242).

-

Sumado a esto, recordo que es el Distrito el que ha formulado el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS). De la misma manera, las actividades de aprovechamiento en el marco del mismo no hacen parte de la plurimencionada licitación. Por lo tanto, el señor () desconoce las actividades o etapas que tenga previstas la Administración para efectos de llevar a cabo el proceso de Aprovechamiento en el marco del PGIRS como también las condiciones de intervención de los recicladores () (AZ 5, folio 243). Sin embargo, refirió que como concesionario deberá formular un proyecto piloto de aprovechamiento para ser puesto en consideración de la entidad.

3.13.2.2 En lo referente al pesaje, menciono que por lo general se efectúa mediante sistemas ubicados en la entrada del sitio de aprovechamiento o disposición final. Igualmente, expuso que por la metodología tarifaria la determinación de las toneladas resulta esencial para calcular el costo del servicio.

-

3.13.2.3 Frente a la ruta de reciclaje, al igual que otros proponentes, trajo a colación que se encuentra definida en el numeral 6.17 del Reglamento Técnico y Operativo de la Licitación 001 de 2011. En este orden, consiste en la recolección separada desde el origen de residuos con el fin de reciclarlos. Está a cargo de los recicladores de oficio en cada ASE, quienes continúan ejerciendo su actividad en las zonas que han venido trabajando. Para esta actividad, los concesionarios deberán entregar dotaciones, equipos y vehículos. El señor () En cualquier caso, la dotación y herramientas que el operador proporcione a los recicladores de oficio, deberán cumplir con las especificaciones técnicas mínimas de producto establecidas en [el reglamento técnico operativo] (AZ 5, folio 245).

-

3.13.2.4 En cuanto a las utilidades, hizo mención a que dependerá de la aprobación de los estados financieros que efectúa la Asamblea de Accionistas y que, conforme con la licitación, deberán seguirse determinadas reglas para el pago de las mismas. Ahora bien, con respecto al aporte de industria, trajo a colación una respuesta de la UAESP que absolvió dudas en lo tocante a este tema. Así según el proponente, la entidad señaló que Las acciones industriales representan el trabajo de la organización de segundo nivel que se encargará de hacer seguimiento, control, vigilancia, coordinación, educación e interlocución con los recicladores que de manera individual y autónoma se dedique (sic) a las labores de reciclaje dentro de la ASE correspondiente (AZ 5, folio 247). Por lo tanto, estas asociaciones no tendrán por actividad el reciclaje, a pesar de relacionarse con personas que lo ejerzan. Adicionalmente, expuso que el valor intrínseco de las acciones no se capitalizará no hará parte del capital social y el señor () la referencia al 5% del capital sirve para saber el valor de la empresa en el momento de la constitución y el momento de su liquidación (AZ 5, folio 249).

-

Por lo demás, si llegasen a haber peticiones, conforme con el artículo 380 del Código de Comercio, las organizaciones no participarán en las mismas, dado que su aporte es de industria. Así las cosas, concluyó este punto señalando que el señor () el aporte industrial () fundamenta en su conocimiento y experiencia para efectos de la coordinación, inspección, interlocución y educación en relación con las actividades de reciclaje dentro del ASE, pero no respecto de la realización en sí de dicha actividad, que las reglas de participación le permiten continuar realizando en toda la ciudad (AZ 5, folio 250).

-

3.13.2.5 Por otra parte, este proponente, a pesar de referirse al Fondo de Reciclaje contemplado en el numeral 10.1.14 del Reglamento Comercial y Financiero - y al aumento a doce (12) organizaciones de segundo nivel, no aportó nuevos elementos de juicio que deban ser mencionados. Así trajo a colación que el fondo tendrá por objeto beneficiar a la población en comento y se financiará con el 50% del valor de las toneladas que por las rutas de reciclaje no sean dispuestas en el relleno sanitario. Igualmente, alegó que

como proponente no tuvo ninguna incidencia en el sorteo o los parámetros de habilitación de las organizaciones; frente a las cuales no ha adelantado negociaciones alguna por el modelo impuesto en el pliego de condiciones.

-

3.13.2.6 Finalmente, tras alegar que las proyecciones de utilidades son secretas ☐ dado que hacen parte de la oferta económica ☐ terminando su intervención señalando que la expresión acceso cierto y seguro a los residuos sólidos no es normativa ni se encuentra en el pliego de condiciones. Por ello, le resulta imposible dar una definición de las mismas.

-

3.14 Promesa de Sociedad Futura Desarrollo Limpio S.A. ESP (AZ 5, folio 223 a 235).

-

Su apoderado intervino dentro del incidente para dar respuesta a los interrogantes planteados en el Auto 189 de 2011, así:

-

3.14.1 Al igual que las anteriores proponentes, recordando que el aprovechamiento se encuentra definido en el Decreto 1713 de 2002. Aunado a ello, especificando que básicamente se distingue en dos grandes áreas: recuperación y reincorporación al sistema productivo. Los recicladores participan principalmente en la primera. Sin embargo, en las condiciones previas a la licitación pública 001 de 2011, los operadores de las rutas selectivas son los recicladores, por lo que actúan en ambas áreas.

-

En este orden de ideas, afirma que existe un amplio margen normativo que regula la gestión integral de residuos sólidos, que incluye - entre otras ☐ las Leyes 99 de 1993 y 142 de 1994, así como los Decretos 1713 de 2002, 1140 de 2003, 1505 de 2003, y 838 de 2005. Adicionalmente, existe una política del Ministerio de ambiente que data de 1997 y que busca la reducción en el origen, el aprovechamiento, el tratamiento, la transformación y la disposición final controlada. Tras describir cada uno de estos elementos, concluye señalando que ☐ (input type="checkbox") en toda la línea del aprovechamiento actúan los recicladores, en la línea de disposición final (que va desde la recolección y el transporte de los residuos) actúan los operadores de aseo, de modo que se puede decir que los operadores del servicio de aseo no intervienen en el proceso de aprovechamiento, pues es esta una actividad económica diferente, aunque relacionada, a la que desarrollan ☐ (AZ 5, folio 227).

-

3.14.2 Por otra parte, expuso que de acuerdo con la normatividad vigente ☐ Resoluciones CRA 351 y 352 de 2005 ☐ los residuos sólidos se pesan en el sitio de disposición final o de aprovechamiento -sean las bodegas o los centros de acopio-. Para el caso de grandes generadores, apuntando que existen aforos permanentes u ordinarios, que tienen validez de un año, y que implican un pesaje independiente. Ahora bien, la separación puede darse por actuación directa de los usuarios o por el quehacer de los recicladores, pero los materiales que no sean seleccionados serán dispuestos en el relleno sanitario.

-

El peso resulta relevante para la tarifa, que está compuesta de dos componentes: uno fijo y uno variable. ☐ (input type="checkbox") El primero refleja los costos de barrido y comercialización, el segundo los de recolección, transporte y disposición final de los residuos sólidos. El segundo componente está fijado en pesos por tonelada (\$/ton) y esto se multiplica por la producción promedio de cada usuario, de modo que cada usuario paga lo que

en promedio produce su ?ea de prestaci? del servicio. Como no es posible t?nica y econ?icamente efectuar una medici? individual de los residuos s?idos[,] lo que se hace es pesar todos los residuos del ?ea, descontar los de barrido (□), los de grandes productores (□) y todos aquellos que se cobren directamente a los usuarios, y luego efectuar una distribuci? entre los usuarios del ?ea de servicio □ (AZ 5, folio 228). En suma, para la remuneraci? del operador del servicio de aseo □ Los residuos de aprovechamiento no entran en este c?culo porque los recicladores los llevan directamente a los centros de acopio y distribuci?, en ese caso los operadores del servicio no se benefician de aquella actividad □ (AZ 5, folio 229).

3.14.3 En relaci? con las rutas de reciclaje, mencion? □ al igual que los otros proponentes □ que implica la recolecci? de residuos previamente seleccionados y que en la actualidad esta actividad en Bogot? la desarrollan los operadores del servicio, pero gracias a la licitaci? p?lica 001 de 2011 estar?a cargo de los recicladores. Sobre este punto, es importante resaltar que mencion? la obligaci? de los usuarios de separar en la fuente y el hecho de que si los recicladores recogen los materiales por su propia cuenta no se contabilizar? dentro de la tarifa de aseo.

3.14.4 Por lo dem?, expres? □ frente al aporte de industria de los recicladores □ que □(□) no tendr? que llevar a cabo ninguna actividad adicional a la suscripci? de las acciones para hacerse propietarios de las mismas □ (AZ 5, folio 231). Sumado a esto, se?l? que desconoce las regulaciones del Fondo de Reciclaje, por lo que deber? ser la entidad la que absuelva los interrogantes relacionados con este tema. Lo mismo debe operar para responder el por qu? del aumento a doce (12) de las organizaciones de segundo nivel. Con respecto a las negociaciones frente a estas asociaciones, enfatiz? que la UAESP fue quien las adelant? directamente, por lo que no concertaron prerrogativas con ellas. A pesar de ello, los recicladores participar? como socios de industria, solo con derecho a voz en desarrollo de la Asamblea de Accionistas, salvo que se trate de decisiones que afecten su calidad de socios. Adicionalmente, recibir? implementos que reducir? los riesgos en desarrollo de su trabajo, as? como veh?ulos de transporte.

3.14.5 A continuaci?, hizo referencia a las utilidades que espera recibir, pero la Corte omitir? mencionarlas dada la reserva a la que est?sometida esta informaci? y a la solicitud elevada por el proponente en este sentido. A pesar de ello, vale la pena destacar que no espera utilidad alguna de la actividad de aprovechamiento.

3.14.6 Finalmente, mencion? que entiende por acceso cierto y seguro □(□) la posibilidad que tienen los recicladores de acceder a los residuos objeto de aprovechamiento □ (AZ 5, folio 234), que se garantiza con los par?etros de la licitaci?, gracias al apoyo log?stico, a la entrega de dotaci? y veh?ulos, a la libertad del mercado y a la dignificaci? de la actividad a trav? de la informaci?.

4. Intervenciones de organizaciones relacionadas con el reciclaje.

4.1 Asociaci? de Organizaciones de Reciclaje y Recuperaci? Ambiental (ARAMBIENTAL) (AZ 2, folio 329 a 336).

4.1.1 Esta organizaci? de segundo nivel de recicladores, comenz? cuestionando la inclusi? de la totalidad de la poblaci? a trav? del censo realizado. A su parecer, se dejaron por fuera varios recicladores. As? mismo, critic? el hecho de que se redujera el margen de negociaci? entre el proponente y las asociaciones, pues se estableci? en el Anexo 21 que de no presentarse un acuerdo, los empresarios podr?n constituir la sociedad por acciones con cualquier otra organizaci? recicladora.

-

Por lo dem?, censur? que las dotaciones y equipos se entregaran sin tener en cuenta la vinculaci? de los beneficiarios a las organizaciones de segundo nivel. Igualmente, mencion? que resulta problem?ico que la CRA () no [haya] determinado la cantidad de Residuos y el c?culo del valor para subsanar la diferencia de lo entregado en el relleno, lo recogido por los recicladores y beneficiado (sic), lo cual hace parte de la masa total de Residuos, por la cual se debe pagar (AZ 2, folio 332). Entonces, y a pesar de que en el escrito no lo dijo expresamente, la Sala infiere que a juicio de este interviniente, en la licitaci? p?lica no se dio efectivo cumplimiento a las ?denes conferidas por esta Corporaci? en las mencionadas providencias.

-

Lo anterior, dado que en la conclusi? del escrito figura que le solicita a () la honorable Corte Constitucional () darle tr?ite al proceso licitatorio, pero que se fijen las condiciones econ?icas o reconocimiento a los recicladores por la porci? de residuos que se recogen () (AZ 2, folio 335).

-

A continuaci?, relat? que se conform?- en el dos mil seis (2006) - por organizaciones disidentes de la Asociaci? de Recicladores de Bogot?(ARB). Por ello, su objeto social versa sobre el desarrollo de actividades encaminadas al progreso de las organizaciones de base. As? en cinco a?s espera estar liderando la gesti? integral de residuos s?idos a nivel nacional e internacional, para la conservaci?, mejoramiento y recuperaci? del ambiente.

-

Como las organizaciones de base que la conforman mencion? un total de 15, entre ellas las siguientes: ASOVIDA, ASOREMA, ANRT, ACB, COOARUPAF, COORSUBA, COPMILENIUM, CRECIFRONT, CREL 10 MUISCA, REMEC, CREAM, ASOREMEC, ASOMILENIUM300, y ARCRECIFRONT.

-

Adicionalmente, expuso que la estructura de Arambiental est? soportada en ?ganos como una Asamblea General, un Consejo Directivo, y un Director Ejecutivo. Finalmente, manifest? que las relaciones con otras organizaciones de segundo nivel es buena, dado que est? actualmente en () uni? temporal con ARUB y ARB () (AZ 2, folio 335).

-

4.1.2 De otra parte, en atenci? al Auto 189 de 2011, esta organizaci? de recicladores de segundo nivel se?l? que:

-

4.1.2.1 La ruta de reciclaje se inici? en el a? 2006 en el mes de septiembre por iniciativa de la UAESP con llegada al CENTRO PILOTO DE RECICLAJE LA ALQUER? (AZ 5, folio 416). A dicho centro, donde se desarrollan principalmente actividades de selecci?, clasificaci?, beneficio, alistamiento y comercializaci? (AZ 5, folio 416), solo llegan veh?ulos procedentes de la ruta de reciclaje que recolectan y transportan los residuos reciclables. Los residuos de org?icos y sanitarios - residuos de

rechazo - son evacuados en máximo 24 horas. Frente a la relación de los recicladores con la ruta de reciclaje, manifestó que el centro "La Alquería" es operado por la ARB, ARAMBIENTAL y la ARUB, organizaciones que constituyeron una Unión Temporal liderada por la Señora Nohra Padilla quien también lidera la ARB. Esta organización, según ARAMBIENTAL, ha sido la más beneficiada a través de sus líderes, la Señora Padilla y el Señor Silvio Ruiz Grisales.

Adicionalmente y siempre frente a la ruta de reciclaje, anotó que "()" la ruta recicladora en las ASES debe ser de los recicladores organizados y beneficiar a todas las personas vinculadas y no vinculadas, ya que los líderes de las organizaciones han aprendido que con el fortalecimiento empresarial y organizativo adquirido en estos procesos se encuentran preparados para dignificar el trabajo del reciclador" (AZ 5, folio 417).

4.1.2.2 En cuanto al funcionamiento del Servicio Público de Aseo, ARAMBIENTAL citó la normatividad que en su opinión es pertinente -"Ley 142 de 1994 y demás normas reglamentarias" (AZ 5, folio 417)- y mencionó también los cuatro consorcios que operan actualmente en la ciudad de Bogotá: "ASEO CAPITAL, ATESA, CIUDAD LIMPIA y LIME" (AZ 5, folio 417)-. Frente a la intervención de los recicladores en el Servicio Público de Aseo, manifestó que "Desafortunadamente[,] con la ejecución de los contratos actuales[,] no existe relación directa entre los recicladores y los consorcios que realizan el Servicio de Aseo" (AZ 5, folio 417). Agregó que "de manera informal los recicladores intervienen antes de que lleguen las rutas a los sitios donde la ciudadanía dispone de sus residuos, pero desafortunadamente con la norma del comparendo ambiental las personas que reciclan en la calle se han visto afectadas, también las organizaciones han realizado convenios con entidades del Distrito y con conjuntos, realizando la recolección del material reciclable antes de que lleguen los operadores de la recolección de basura" (AZ 5, folio 418).

4.1.2.3 Cuestionada sobre los parámetros negociados con cada uno de los proponentes para la ASE que le fue asignada, esta organización manifestó que el veinte (20) de junio de dos mil once (2011) se sortearon las ASEs entre las organizaciones de recicladores de segundo nivel. Así las cosas, ARAMBIENTAL solo aceptó los resultados del sorteo de manera que no se ha reunido con ningún consorcio ni existen convenios o intenciones de negociación. Por esta razón, frente a la pregunta que versa sobre los derechos que tendrán como organización de recicladores de segundo nivel derivadas de tal negociación, señaló que, al no haber entablado ningún tipo de negociación, "no hay prerrogativas en el caso particular" (AZ 5, folio 418).

4.1.2.4 Frente a lo que esta organización entiende por acceso cierto y seguro a los residuos, apuntó que, aunque a la fecha los recicladores tienen acceso a los residuos sólidos, existe un sentimiento de frustración entre ellos al ver que otros empresarios han buscado a través de sus contactos que los residuos les sean entregados excluyéndolos. A eso se sumará la expedición de varias normas que, según ARAMBIENTAL, "()" apuntan, coincidental o deliberadamente, a sacarlos del negocio de reciclaje precisamente cuando el mundo comienza a descubrir el potencial económico de las basuras y la misma Comisión Reguladora de Agua Potable (CRA) establece un incentivo económico al que haga aprovechamiento de las basuras" (AZ 5, folio 419). Además, puso de presente que carece del poder político y económico para tecnificar el proceso de reciclaje: "nuestras herramientas son nuestras manos que por décadas han contribuido al mejoramiento del medio ambiente" (AZ 5, folio 419).

4.1.2.5 Finalmente, en relación con lo anterior y frente a la pregunta sobre si la actual licitación garantiza a los recicladores el acceso cierto a los residuos, señaló que "Si bien es cierto [que] los pliegos de la actual licitación dan la oportunidad a los recicladores organizados de Bogotá también lo es que al ver lo señalado en la Sentencia T-724 y el Auto 268 no se da la cobertura real a los recicladores en lo pertinente

a las Acciones Afirmativas (AZ 5, folio 419). Por último, ARAMBIENTAL manifestó su deseo de contribuir a sensibilizar a la población en cuanto a la importancia de su contribución para hacer más digna la vida de los recicladores y al cuidado del ambiente mediante la reutilización de los materiales reciclables.

4.2 Federación sindical de Recicladores de Bogotá FEDARSIN (AZ 2, folio 370 a 383).

Alexander Fonseca Rusinique, obrando como presidente de esta organización, señaló que su personería jurídica fue () otorgada por el Ministerio de la Protección Social () [el] 8 de junio de 2011 () (AZ 2, folio 370) y que, al incluir población recicladora en condiciones de vulnerabilidad, fue aceptada dentro de la licitación en comento, expresamente.

4.2.1 A su juicio () el Distrito[,] representado por la UAESP ha generado espacios, políticas y medidas incluyentes para que () como grupo social vulnerable[, tengan] acceso a espacios y procesos en los cuales tradicionalmente [han sido excluidos] (AZ 2, folio 370). Adicionalmente, manifestó que no observó obstáculos que les imposibilitara participar en la licitación adelantada por la referida entidad. Por ello, existen doce (12) organizaciones de segundo nivel que fueron habilitadas.

Se constituye hace () aproximadamente tres (3) décadas () como Corporación Nacional de Recicladores (CORPORECICLAJE) (). [Sin embargo, su] proceso de constitución formal inicia con el acta de asamblea 01 del 04 de junio de 2011 en el cual participan diez (10) grupos sindicales con el fin de conformar la Federación Sindical de Recicladores () (AZ 2, folio 371). Por ello, su objeto social es la integración de los referidos sindicatos, que defienden el ambiente y los recursos naturales, () y trabajan en la cadena del reciclaje descontaminando los recursos sólidos para que no vayan a los rellenos sanitarios, recuperando típicamente productos industriales (AZ 2, folio 371).

Por último, refirió que se encuentra conformada por diez (10) organizaciones de base, todas () salvo una que fue fundada el treinta y uno (31) de agosto de dos mil diez (2010) - con fecha de constitución entre marzo y mayo de dos mil once (2011) (AZ 2, folio 374) y que su relación con otras asociaciones de segundo nivel es buena, ya que pretende constituir una confederación.

4.2.2 Con posterioridad al Auto 189 de 2011, FEDARSIN, apuntó

4.2.2.1 En cuanto al funcionamiento de la ruta de reciclaje y a la participación de los recicladores en ella, () Si hablamos de la que existe actualmente, sabemos que ésta es manejada por los consorcios de basuras, donde recogen 3 veces por semana en las mismas rutas que tienen para las basuras, y su disposición final es el parque de La Alquería y sabemos que no hay participación del reciclador en esta ruta (AZ 5, folio 510). Además, que la administración de este centro de acopio está a cargo de una de las organizaciones participantes en la licitación 001 de 2011 que no habría permitido la inclusión de otras organizaciones de recicladores que igualmente participan en la licitación.

Aunado a lo anterior, FEDARSIN agreg? □ Ahora, si mencionamos la ruta de reciclaje que est? dentro de la licitaci? 001 de 2011, es de nuestro conocimiento por lo que hemos le?o que s? se da participaci? a los recicladores pero no es algo que est? claro debido a las ?timas modificaciones de esta licitaci? y a que no hay exclusividad para los recicladores ni las organizaciones que est? participando □ (AZ 5, folio 510).

4.2.2.2 Frente al funcionamiento del Servicio P?blico de Aseo y la intervenci? de los recicladores en ?, FEDARSIN se?l? que ?te servicio est? bajo el manejo de cuatro consorcios distribuidos en seis ASEs, que recogen la basura tres o cuatro veces por semana seg? la log?tica dise?da para cada una de ellas. Respecto a la intervenci? de los recicladores, anot? que ?ta se da antes de que los camiones pasen recogiendo las basuras por las diferentes localidades de Bogot? Adicionalmente, se?l? que sabe de recicladores que deben pagar una cuota mensual para poder reciclar en diferentes fuentes de basuras, pr?tica con la que est? en total desacuerdo la Federaci?, ya que □ son los recicladores quienes aportan para la disminuci? de basuras y conservaci? del medio ambiente por esto son ellos quienes deber?n recibir remuneraci? □ (AZ 5, folio 510).

4.2.2.3 En cuanto a los par?etros que fueron negociados con cada uno de los proponentes para el ASE asignado tras el sorteo organizado por la UAESP, comunic? que □ la ?ica negociaci? que se ha tenido es la estipulada en la licitaci? □ (AZ 5, folio 511), negociaci? que desde su punto de vista no fue clara en cuanto al tipo de sociedad que pretende conformar y el porcentaje de participaci? accionaria. Adicionalmente, asegur? no haber recibido nunca, por parte de la UAESP y los proponentes, una explicaci? entendible o detallada acerca de la participaci? de las organizaciones de recicladores de segundo nivel.

4.2.2.4 Finalmente, por acceso cierto y seguro a los residuos, FEDARSIN dijo entender que se trata de la oportunidad de trabajar para aquellos que quieren hacerlo y conocen del funcionamiento del negocio del reciclaje. Adicionalmente, anot? que el crecimiento de la poblaci? recicladora pone en peligro el acceso seguro a los residuos, pues personas ajenas al reciclaje quieren acceder a ellos y en su opini? ni la UAESP ni el pliego de condiciones - tal y como est? redactado - aseguran a los recicladores el acceso a los residuos.

4.3 Confederaci? Ambiental Hagamos de Colombia un Pa? Grande □ Confederaci? Ambiental FUNCOLGRAN □ (AZ 2, folio 398 a 425)

4.3.1 Esta organizaci?, en su intervenci?, representada por el se?r William Bernardo Palacio V?ez, comenz? por enumerar medidas que considera se constituyen en acciones afirmativas. As? mencion? la participaci? accionaria, el ofrecimiento de puestos de trabajo directos, □(□) [el] porcentaje de utilidad en bonos redimibles dentro del proceso □ (AZ 2, folio 398) y el suministro de dotaciones, entre otros. De otro lado, se?l? que para poder convertir a los recicladores en empresarios de las basuras, es necesaria la constituci? de un centro de acopio. Para ello, propuso que se requiere un □(□) ?ea m?ima de 5.000 mts², ubicado en un sitio apropiado que cumpla las condiciones del POT (□) [y ser? utilizado para almacenar el material potencialmente aprovechable, beneficio y pretransformaci? en materias primas □ (AZ 2, folio 424). Igualmente, requerir? □(□) 4 camiones de 6 toneladas (□)[,] 4 camiones de 4.5 toneladas (□)[,] 3 camiones de estacas[,] [y] 1 (sic) camioneta doble cabina. [En este proceso, donde ser?n socios capitalistas junto a los concesionarios], compraremos a los recicladores de base su material potencialmente aprovechable, lo procesamos y comercializamos a nivel Nacional o

Internacional (AZ 2, folio 424). Cabe destacar que condicion?los beneficios a favor de las organizaciones de base a que se posean () m?imo 250 asociados en cada organizaci? de primer nivel (AZ 2, folio 421).

A continuaci?, indic?que se constituy? () el 2 de octubre de 2007, siendo inscrita en C?ara de Comercio el 2 de Febrero de 2009[.] Este proceso se llevo (sic) a cabo por solicitud de organizaciones de primer nivel con el ?imo de que las represent?amos y les apoy?amos en algunos proyectos productivos, acompa?miento administrativo, jur?ico y financiero (), a la fecha contamos con 19 organizaciones [coaligadas] (AZ 2, folio 399). Cabe indicar que en el folio 420 del mismo AZ s?o figura una lista con 11 asociadas.

Sumado a lo anterior, y tras exponer que su objeto social est?relacionado con temas ambientales, expuso varios elementos de sus estatutos, que incluyen ?ganos de la confederaci?, visi?, objetivos, y actividades a desarrollar en el corto y largo plazo.

Por otra parte, expuso que las acciones afirmativas no s?o deben ser exigidas a la UAESP, sino a las organizaciones de segundo nivel. Por ello, ha formulado un () Plan Piloto de Fortalecimiento Social Organizativo y Productivo para la poblaci? recicladora de la ASE NO. 1 () (AZ 2, folio 417) a implementar en el ?ea de servicio exclusivo que le correspondi?por sorteo. Con tal fin, adelantar? un censo de la poblaci? recicladora y buscar?la coaligaci? de al menos 30 organizaciones de base. En este sentido, se?l?que de las 19 organizaciones que la conforman actualmente, () seis (6) de ellas hac?n parte del grupo de organizaciones de la ARB, que nos eligieron para representarlos dentro de los procesos gubernamentales, motivadas por la falta de apoyo y beneficios por parte de esta [?tima] (AZ 2, folio 417).

Aunado a esto, expuso su inconformidad frente al () Pacto gremial de fecha 13 de Julio de 2011[.] que supuestamente fue suscrito por las organizaciones de segundo nivel () toda vez que es un documento ama?do y diseccionado y solo fue firmado por cuatro (4) organizaciones, dos de las cuales fueron excluidas del proceso de selecci? de la UAESP, ellas son ANIR y ACOREIN () (AZ 2, folio 416).

Expuso, adicionalmente, que desde un principio se hab? establecido en el () numeral 2.7 que las organizaciones de segundo nivel deber?n elaborar y presentar su propia propuesta de sostenibilidad financiera de la ruta de Reciclaje (sic) y la forma en que se invertir? los recursos, garantizando la sostenibilidad de la ruta por el plazo de la concesi? () (AZ 2, folio 417). Sin embargo, lo anterior fue excluido del proceso por solicitud de Nohra Padilla. A pesar de esto, apunt?que su relaci? con otras organizaciones de segundo nivel es cordial y se encuentra encaminado a la ayuda mutua.

4.3.2 Al igual que los proponentes que le precedieron, en escrito allegado a esta Corporaci? el seis (6) de septiembre de dos mil once (2011), frente a los interrogantes planteados en el Auto 189 de 2011, indic?

4.3.2.1 En lo relativo al funcionamiento de la ruta de reciclaje y la participaci? de los recicladores en ella, esta organizaci? coment?que existe un centro de reciclaje localizado en el barrio La Alquer?, en donde los recicladores de oficio realizan la separaci? y clasificaci? del material aprovechable. Dicho centro es administrado por la Uni? Temporal conformada por tres organizaciones de recicladores de segundo nivel -ARB, ARAMBIENTAL y ARUB. Adicionalmente, inform? que trat?dose de la Licitaci? 001 de 2011 la ruta de reciclaje debe ser dise?da por las organizaciones de segundo nivel en acuerdo con los consorcios.

4.3.2.2 En cuanto al funcionamiento del Servicio P?blico de Aseo y la intervenci? de los recicladores en ?, FUNCOLGRAN manifest?que el servicio est?integrado por cinco componentes (recolecci?, barrido, limpieza, corte de c?ped y poda de ?boles) y que □(□) la intervenci? de los recicladores es realizada previamente a la recolecci? de la basura□ (AZ 5, folio 401). Agreg? que a los recicladores no se les reconoce ning? pago por su labor, que consiste en recolecci?, transporte y limpieza del material aprovechable, mientras que □(□) a los consorcios si se les cancela por su labor de limpieza, recolecci? y barrido□ (AZ 5, folio 401). Por esta raz?, FUNCOLGRAN solicit?en su escrito que esta Corte □determine y obligue al pago de cada una de las toneladas que los recicladores recolectan diariamente, en la misma forma como se le reconoce a los consorcios□ (AZ 5, folio 401). De igual manera, que se determine y se obligue a quien corresponda el pago por el trabajo de recolecci? realizado por los recicladores de base □(□) y que no se tenga el criterio propuesto por la UAESP, como es el que vaya al fondo del reciclaje□ (AZ 5, folio 401).

4.3.2.3 En cuanto a los par?etros tenidos en cuenta para negociar con cada proponente del ASE que le fue asignado por sorteo a la organizaci?, FUNCOLGRAN manifest?que, pese a que no hubo ninguna negociaci? con los concesionarios, el d? de las aclaraciones de los pliegos cada uno de los concesionarios reci? por parte de FUNCOLGRAN, una solicitud tendiente a □(□) incluir dentro de sus costos la parte administrativa de las organizaciones de Segundo Nivel□ (AZ 5, folio 402). Al no estar contemplada esta posibilidad en el pliego de condiciones de la licitaci? 001 de 2011, se permiti? sugerirla a la UAESP que □La vinculaci? de las organizaciones de segundo nivel se hace ?icamente con el fin de ser accionistas del concesionario que resulte ganador en cada una de las seis zonas de la ciudad□ (AZ 5, folio 406). Esto hace coartar sus posibilidades de negociaci? y las condiciona a una participaci? de car?ter exclusivamente accionario.

4.3.2.4 Por otra parte, entiende que contar con acceso cierto y seguro a los residuos s?idos es □(□) tener la certeza que el reciclador tendr?el acceso directo a las posibles fuentes generadoras de desechos s?idos aprovechables□ (AZ 5, folio 402). En su opini?, dicho acceso no est?garantizado puesto que no es objeto de consagraci? expl?ita en el pliego de condiciones de la licitaci?. Agreg? que, pese a que los concesionarios se comprometen en sus respectivas propuestas a ampliar al 100% los usuarios de la ruta de reciclaje, no se especifica c?o cumplir? esta meta.

4.3.2.5 Frente a las razones que guiaron la escogencia del ASE, FUNCOLGRAN manifest?que escogi?la n?ero 1 porque ?ta representa una mejor rentabilidad en beneficio de la comunidad recicladora, □(□) ya que cuenta con m? de 4000 conjuntos residenciales, almacenes grandes superficies como lo son ?ITO, CARREFOUR, POMONA, CARULLA ETC, centros comerciales y empresariales□ (AZ 5, folio 404). Adem?, aclar? que en ning? momento ha intentado desplazar a las organizaciones de primer nivel existentes en las localidades de Suba y Usaqu?, sino que pretende agremiar a los recicladores de oficio que no se encuentran afiliados a ninguna organizaci? para que ellos tambi? se hagan beneficiarios de las Acciones Afirmativas ordenadas por esta Corte en la Sentencia T-724 de 2003 y en el Auto 268 de 2010.

-

4.3.2.6 Finalmente, solicitó a esta Corporación que revise y se pronuncie sobre ciertas debilidades que a su juicio presenta el proceso licitatorio, especialmente frente a la participación de organizaciones sin ánimo de lucro creadas a partir de marzo de 2011. Según FUNCOLGRAN, dicha participación no será posible a la luz del artículo 355 de la Constitución y del Decreto reglamentario 777 de 1992 en su artículo 12, puesto que, siguiendo esta normatividad, las organizaciones sin ánimo de lucro deben haberse constituido con no menos de seis meses de antelación a la celebración del contrato.

-

4.4 Federación de Recicladores Independientes de Colombia (FEDERINCOL) (AZ 3, folio 146 a 154)

-

4.4.1 El presidente y representante legal de FEDERINCO, Carlos Eduardo Garay Caicedo, intervino para apuntar que varias de las reglas establecidas en el pliego de condiciones favorecen a la población recicladora; entre ellas, la participación accionaria de industria; la ausencia de restricciones de la labor de los recicladores a Bogotá la libertad de recolección de materiales sin importar la ASE en que se efectúe, dada la libertad de mercado; la obligación al proponente de () () diseñar y ejecutar un Plan de Gestión de inclusión social para educar en buenas prácticas ambientales a nuestros afiliados () () (AZ 3, folio 150); y la promoción de la afiliación.

-

En su caso, al corresponderle por sorteo la ASE número 3, podrá recibir hasta el 45% de las utilidades de la concesión. Esto, () () transformar nuestra federación y la vida de nuestros asociados () () (AZ 3, folio 149), pues este capital permitirá la creación de empresas productivas.

-

De otra parte, relación que se constituyó el cinco (5) de octubre de dos mil cinco (2005) con seis organizaciones de primer nivel. Hoy en día, coaligan a dieciocho (18) de estas entidades. De hecho, apunta que () () es socio del Consorcio CGR Doña Juana S.A. E.S.P () () (AZ 3, folio 151). Sin embargo, enfatiza que algunas organizaciones de segundo nivel que compitieron en el sorteo, fueron creadas a escasos días del cierre de la licitación, por lo cual su inclusión implica el ejercicio de una actividad en la que no tienen experiencia y trayectoria.

-

Finalmente, menciona que su relación con las demás organizaciones no ha estado ajena a conflictos dado que diferentes asociaciones () () no siempre () han resuelto de manera pacífica [las disputas] ya que algunas () han actuado con extrema beligerancia y hasta violencia y un excesivo celo. [Por ello] las relaciones entre (sic) asociaciones no son nada buenas ni nada fáciles () () (AZ 3, folio 154).

-

4.4.2 En respuesta al Auto 189, esta asociación de recicladores de segundo nivel manifestó lo siguiente:

-

4.4.2.1 La ruta de reciclaje es uno de los cuatro componentes del Programa Distrital de Reciclaje (PDR), programa que es coordinado por la UAESP y que consta de () () dos componentes técnicos (ruta y parque de reciclaje) y dos sociales (separación en la fuente e inclusión de la población recicladora) () (AZ 5, folio 431). Así que () La ruta de reciclaje se implementó desde el año 2008 como un sistema a través del cual los operadores recogen el material reciclable previa separación en la fuente realizada por los

ciudadanos en sus hogares (AZ 5, folio 431). Por lo demás, el diseño y operación de la ruta corre a cargo de los concesionarios, quienes establecen las frecuencias y horarios.

En directa relación con lo anterior, esta organización señala que (Al igual que la ruta normal de recolección de residuos sólidos que pasa tres veces por semana recogiendo la basura ordinaria, la ruta de recolección selectiva es un servicio adicional que se presta por los operadores del servicio una vez por semana, únicamente para los residuos reciclables (AZ 5, folio 432).

Volviendo a la ruta de reciclaje, FEDERINCOL agregó que esta no ha sido implementada por la UAESP en todas las localidades sino que abarca solo el treinta y tres por ciento (33%) de la ciudad; además no genera costos adicionales para el usuario puesto que este servicio está incluido en la tarifa que paga por la prestación del Servicio Público de Aseo. También explicó que Los residuos recolectados en la ruta de reciclaje son llevados al centro de reciclaje La Alquería en donde se almacenan y se clasifican de acuerdo a su tipo (plástico, cartón, metal y vidrio principalmente) para posteriormente ser comercializados (AZ 5, folio 432).

4.4.2.2 En cuanto a la planta de reciclaje La Alquería, FEDERINCOL señala que desde que esta entró en funcionamiento, hace ya cuatro años, solo se han visto beneficiadas las tres (3) organizaciones de recicladores de segundo nivel a las cuales se ha confiado su manejo la Asociación Cooperativa de Recicladores de Bogotá (ARB), la Asociación de Cooperativas de Reciclaje y Recuperación Ambiental (ARAMBIENTAL) y Asociación de Recicladores Unidos por Bogotá (ARUB)- lo cual ha originado (una) gran cantidad de quejas de los afiliados sobre la no presentación de una rendición de cuentas del manejo y ganancias allí obtenidas (AZ 5, folio 433). Finalmente, aclaró que (una) en la actualidad los recicladores no intervienen directamente en la recolección y transporte de los residuos reciclables sino en el aprovechamiento de los mismos en el Centro de Reciclaje La Alquería (AZ 5, folio 434).

4.4.2.3 Frente al funcionamiento del Servicio Público de Aseo y a la intervención de los recicladores en Bogotá, FEDERINCOL citó la Resolución 351 de 2005-. Según esta norma, las actividades que integran el aprovechamiento en el marco del Servicio Público de Aseo son (una) el conjunto de actividades (una) dirigidas a efectuar la recolección, transporte y separación, cuando a ello haya lugar, de residuos sólidos que serán sometidos a procesos de reutilización, reciclaje o incineración con fines de generación de energía, compostaje, lombricultura o cualquier otra modalidad que conlleve beneficios sanitarios, ambientales, sociales y/o económicos (una) (AZ 5, folios 434 a 435).

Al respecto, señala que los recicladores están involucrados en el Sistema de Servicio Público de Aseo por mandato legal de acuerdo con lo establecido en la Ley 99 de 1993, según la cual, una de las funciones del Ministerio de Medio Ambiente es la promoción de actividades de descontaminación, reciclaje y reutilización de residuos.

Adicionalmente, puso de presente que en el año dos mil siete (2007) el Distrito decidió poner en marcha el Plan Distrital de Reciclaje (PDR) en la ciudad de Bogotá cuyo principal objetivo es formalizar la actividad del reciclaje en la ciudad, en aras de preservar el medio ambiente con la idea de que todos los ciudadanos tomen conciencia de la importancia del reciclaje (AZ 5, folio 436). Dijo además que dicho plan descansa sobre cuatro pilares Campañas de Separación en la Fuente, Ruta de Recolección Selectiva,

Parques de Reciclaje e Inclusi? Social- que contempla la participaci? de los recicladores en el Servicio P?blico de Aseo.

-

Por lo dem?, agreg?que □(□) por la fuerza de la costumbre, los recicladores se han autorregulado y organizado ellos mismos en sus rutas de recolecci?, reciclaje y venta de los materiales recogidos, present?dose aqu?un desequilibrio que FEDERNICOL quiere que el Estado subsane, ya que en la cadena de reciclaje el eslab? menos favorecido es el recuperador, quien recicla en la fuente, toda vez que el producto obtenido lo compran los intermediarios definiendo ellos mismos y de forma arbitraria los precios□ (AZ 5, folios 437 a 438).

-

4.4.2.4 Respecto a los par?etros que fueron negociados con cada uno de los proponentes para la respectiva ASE asignada mediante sorteo, se?l?que solo con la adjudicaci? de la licitaci? 001 de 2011 se conocer?qu?operador estar?a cargo de cada una de las ASEs en las cuales fue dividida la ciudad de manera que no se ha adelantado negociaci? previa alguna con ninguno de los trece proponentes. As? mismo, solicit?a la Corte reanudar el proceso licitatorio puesto que □(□) los recicladores no son tenidos en cuenta por los actuales operadores del servicio de aseo de Bogot?(□) y con la licitaci? en curso las organizaciones de recicladores tendr? derecho a recibir las utilidades liquidadas anualmente por el concesionario de manera proporcional al n?ero de afiliados de las organizaciones de segundo nivel correspondiente a cada ASE□ (AZ 5, folio 439).

-

4.4.2.5 Por acceso cierto a los residuos s?idos, FEDERICOL adujo entender □(□) una real cobertura del servicio de recolecci? selectiva de material reciclable en la ciudad, en donde los recicladores cuentan con autonom? en la localidad asignada para tal fin□ (AZ 5, folio 440). El acceso seguro es comprendido como □(□) las condiciones de trabajo que cumplen a cabalidad con las normas sanitarias, requisitos ambientales, protocolo de manejo de residuos peligrosos y de seguridad industrial□ (AZ 5, folio 441); lo cual requiere entregar dotaciones a los trabajadores, aplicar protocolos de calidad a su favor, implementar controles t?nicos y promover capacitaciones relativas al control de riesgos. Sobre el acceso cierto a los residuos continu?explicando: □para poder tener un acceso cierto y seguro a lo residuos s?idos, es indispensable que los recicladores cuenten con un espacio f?ico, un sistema de pesaje, control de material y un sistema de transporte de los residuos s?idos adecuado e id?eo para realizar tal actividad de recolecci? y aprovechamiento de los mismos□ (AZ 5, folio 441). Inform?adem? que, en la actualidad, la separaci? de residuos en la fuente es realizada por los ciudadanos quienes se limitan a separar los residuos org?icos de los inorg?icos de modo que el proceso de selecci? de los residuos reciclables a? debe ser realizado por los recicladores.

-

4.4.2.6 Las anteriores aclaraciones sirven de base a FEDERNICOL para sugerir dos opciones de trabajo: la clasificaci? en la fuente - consistente en la adecuaci? de un espacio al interior de los conjuntos residenciales, oficinas, centros de comercio, etc., para realizar la labor de clasificaci? en lugar de hacerla en la calle- y la clasificaci? en □Bodega de reciclaje□ □ consistente en la adecuaci? de un espacio f?ico para la labor de clasificaci?, selecci?, almacenamiento, pesaje y comercializaci? de los residuos reciclables que se recolectan en la ruta selectiva.

-

4.4.2.7 Adicionalmente, anot?que en los t?minos de la Licitaci? 001 de 2011 los recicladores son socios de industria en diferentes porcentajes seg? la oferta presentada por cada uno de los proponentes, participaci? que califica de □(□) muy conveniente para nuestras organizaciones□ (AZ 5, folio 443). Adem?, se?l?que su conocimiento del negocio del Servicio P?blico de Aseo le permite afirmar que □(□)

un contrato de esta magnitud no genera ganancias sino a partir del tercer o cuarto año de operación (AZ 5, folio 443). De esta manera, a su juicio, debería mantenerse la calificación otorgada a los posibles concesionarios en función de la participación ofertada tanto en términos de empleo como de acciones, componente que () define el compromiso social que tiene el futuro operador con los recicladores y recuperadores ambientales (AZ 5, folio 443) y además considero que deberían establecerse unos ingresos mínimos anuales que garanticen la subsistencia, manutención y el mínimo vital de cada organización de recicladores. Por las razones mencionadas, FEDERINCOL insistió en que esta Corte reanude lo antes posible el proceso licitatorio 001 de 2011, puesto que la prórroga de las actuales concesiones significa para los recicladores continuar excluidos de toda participación.

4.4.2.8 Finalmente, frente a las razones por las cuales FEDERINCOL escogió el ASE No. 3, esta organización informó que fue cobijada por el privilegio de escoger su propia ASE según el criterio de antigüedad establecido por la UAESP. Los parámetros que tuvo en cuenta fueron: el tamaño del ASE, dado que agrupa seis localidades (Chapinero, Santa Fe, Barrios Unidos, Teusaquillo, Muzo y Candelaria; su ubicación geográfica, que permite a los recicladores un fácil acceso por estar en el sector central de Bogotá y el hecho de que, gracias a la presencia de universidades, industrias y locales comerciales, a estas localidades se desplazan cerca de dos millones de personas diariamente, lo cual incrementa el consumo y por ende los residuos aprovechables.

4.5 FUNREDAMBIENTE (AZ 3, folio 255 a 261)

4.5.1 José Pablo Pabón, director ejecutivo de este interviniente, mencionó que en la jurisprudencia de la Corte Constitucional - Auto 268 de 2010 y sentencia T-291 de 2009 (), se estableció que debería incentivarse la participación efectiva en la actividad del aprovechamiento, que no podía redundar en una simple contratación laboral, sino contemplar la posibilidad de convertirse en empresarios de las basuras. Para ello, debía garantizarse el favorecimiento de formas asociativas que aseguraran tales condiciones.

A continuación, expuso que en el pliego de condiciones se encuentra una participación accionaria y el requisito de habilitación consistente en presentarse asociado con dos (2) organizaciones de segundo nivel. Adicionalmente, mencionó los criterios de calificación contemplados en el Pliego de condiciones y que el día del cierre de la licitación resultó una sorpresa que proponentes ofertaran hasta el 71% de acciones.

Desde su punto de vista, lo anterior es () una excelente oportunidad para que las organizaciones de recicladores logren organizarse como empresarios de la basura, ya que inician el ejercicio como socios de una ESP (). Además, de tener la posibilidad de afianzar sus procesos administrativos, los cuales, muy seguramente, les permitirán participar de otras oportunidades que se presenten () (AZ 3, folio 257).

Por otra parte, apuntó que se generó la oportunidad de incentivar el () empleo digno para aquellas personas que así lo deseen () (AZ 3, folio 257), dado que se califica la oferta de puestos de trabajo en cualquier actividad de la prestación del servicio. Concatenado a esto, resaltó como acción afirmativa la entrega de uniformes y dotaciones, dado que () significan un alivio a los males que le aquejan al reciclador, en el ejercicio diario del reciclaje () (AZ 3, folio 258).

-

Otro punto que resaltó fue el puntaje otorgado para el aprovechamiento, ya que varios consorcios ofertaron una cobertura del 100% en el primer año gracias al modelo adoptado por la UAESP. En este sentido, también enfatizó en la existencia de una bolsa de reciclaje, que destinará recursos para proyectos en esta materia. Aunado a esto, los recicladores serán quienes operen las rutas de reciclaje y, en un futuro, podrán modificarse las tarifas para incluir esta actividad.

-

Por otro lado, afirmó que la asociación que representa se constituyó en el dos mil nueve (2009). Debido a esto, no pudo participar en la licitación del relleno sanitario de Doña Juana, ya que ahí se exigía una antigüedad mínima de dos (2) años. En la actualidad, cuenta con seis (6) organizaciones de primer nivel coaligadas a ella, las cuales se asocian a 384 recicladores de oficio (AZ 3, folio 260). Finalmente, expuso que sus relaciones con otras organizaciones de segundo nivel son buenas, a pesar de algunas tensiones.

-

4.5.2 Al igual que las asociaciones que la precedieron, esta organización de recicladores de segundo nivel, según el artículo 189 de 2011, lo siguiente:

-

4.5.2.1 Frente a la pregunta que versa sobre el funcionamiento de la ruta de reciclaje elevada en el Auto 189 de 2011 -explicó que se está siendo manejada por los consorcios que prestan el servicio de aseo hoy por hoy, la realizan mediante campañas informativas a la comunidad y luego con un ruteo de vehículos motorizados que recogen el material reciclado y seleccionado por los usuarios de servicio público de aseo en sus casas, dicho material es entregado en el parque de reciclaje LA ALQUERIA, allí la Unidad Temporal conformada por ARB, ARAMBIENTAL y ARUB lo clasifica y comercializa (AZ 5, folio 568).

-

4.5.2.2 En cuanto a la relación que tienen los recicladores con la ruta de reciclaje, señaló que el material seleccionado por los usuarios en sus casas, recolectado por los consorcios y entregado a LA ALQUERIA lo recibe la Unidad Temporal (ARB, ARAMBIENTAL y ARUB), es en estos momentos cuando algunos asociados de las tres organizaciones mencionadas realizan la clasificación del material, recibiendo por su trabajo un jornal establecido por la unidad temporal y que fluctúa dependiendo de las políticas internas que ellos manejan (AZ 5, folio 568).

-

4.5.2.3 Sobre el funcionamiento del Servicio Público de Aseo, esta organización afirmó que el Servicio Público de Aseo obedece a una serie de normas que no son de nuestro alcance pues no tenemos el conocimiento suficiente para su discernimiento (AZ 5, folio 568). Continuó explicando que la intervención de los recicladores en dicho servicio consiste en buscar y seleccionar el material potencialmente aprovechable directamente en la fuente (canecas y chuts), labor de recolección que no es remunerada.

-

4.5.2.4 Acerca de los parámetros que fueron negociados con cada uno de los proponentes para el respectivo ASE, aclaró que en el marco de la presente licitación no fue posible realizar negociaciones alguna con los proponentes (AZ 5, folio 569). Además, adujo que en su opinión una negociación de tales proporciones podría tornarse problemática: si se pretende que 13 proponentes negocien con 12 organizaciones, desde cualquier perspectiva esto hace improcedente cualquier proceso y nunca se

lograr? una conciliaci? real impidiendo la buena marcha de la licitaci? □ (AZ 5, folio 569).

4.5.2.5 Finalmente, esta organizaci? defini?el acceso cierto y seguro como: □(□) la certeza de que el reciclador pueda acceder a los residuos s?idos desde la misma fuente□ (AZ 5, folio 569). Adem?, consider?que en la Licitaci? en comento tal acceso s?est?garantizado, □puesto que se establece en los pliegos de condiciones que la ruta de reciclaje ser?realizada puerta a puerta por los recicladores de oficio, el material es de su propiedad, lo podr? comercializar donde bien les parezca y el dinero adquirido ser?de su propiedad□ (AZ 5, folio 569).

4.6 Asociaci? Colombina de Recicladores Independientes (ACOREIN) (AZ 3, folio 269 a 271)

Su representante legal afirm?que es una de las organizaciones integrantes del Pacto Colectivo del Gremio Reciclador y que, a su parecer, es importante resaltar las problem?icas que surgen del cierre de las bodegas de reciclaje, ya que se cerraron cerca del 90% de las mismas. A su sentir, una medida que podr? redundar en beneficios para esta poblaci?, ser? la vinculaci? de estos establecimientos a la licitaci?. Esto, dado que implicar?n un ahorro en cuanto a infraestructura se refiere y permitir?n que muchos de los recicladores □ que han arrendado esas bodegas □ continuaran desarrollando su actividad.

As?las cosas, expuso que no pueden desconocerse las afectaciones que medidas normativas □ como el Decreto 456 de 2010 □ han tra?o para la cadena productiva del reciclaje.

4.7 Asociaci? de Recicladores Unidos por Bogot?(ARUB) (AZ 3, folio 309 a 311 y 388 a 391).

4.7.1 En un primer escrito, esta organizaci? record?que no existi?un criterio de antig?dad que excluyera la posibilidad de que asociaciones ficticias participaran en el proceso licitatorio. Por ello, apunt?que lo que se est?intentando es □(□) sacar poco a poco a los recicladores de [esta] actividad (□)□ (AZ 3, folio 309), burlando □ de contera □ las ?denes proferidas por la Corte Constitucional en su jurisprudencia. Posteriormente, en un segundo escrito, expuso que se encuentra conformada por catorce (14) organizaciones de primer nivel, que re?en a seiscientas (600) personas. Por ello, uno de sus objetivos es fortalecer este tipo de asociaciones, protegiendo □ mediante su accionar □ el ambiente.

Adujo que a pesar de la jurisprudencia de la Corte Constitucional, no ha habido una real inclusi? de la poblaci? recicladora de Bogot? Sumado a esto, cuestion?los resultados materiales de la adjudicaci? del Relleno Sanitario Do? Juana. Con todo, record?que en la actual licitaci? pudo escoger □ dada su antig?dad □ una de las 6 ASEs existentes, seleccionando la n?ero 3, que corresponde a las zonas de Chapinero, Barrios Unidos, Teusaquillo, M?tires, Santa fe y Candelaria.

Sin embargo, □(□) la UAESP no [les] ha planteado el plan de trabajo a desarrollar para iniciar las labores correspondientes a la recolecci? y recuperaci? en cuanto a las zonas ganadas seg? las ASEs que

[les] correspondieron, teniendo en cuenta que [sus] recursos son únicamente de mano de obra, pues no [tienen] hasta ahora apoyo (□) en cuanto a un medio que [les] pueda suplir y mejorar la recolección (AZ 3, folio 389). Por ello, requieren medios de transporte adecuados para los residuos recuperados, así como un centro de acopio.

-

Posteriormente, indicó que se constituyó el primero (1º) de septiembre de dos mil siete (2007) y que con algunas asociaciones de segundo nivel, que son (□) ASOCIACION COOPERATIVA DE RECICLADORES DE BOGOTÁ, ARB- Y ASOCIACIÓN DE ORGANIZACIONES DE RECICLAJE Y RECUPERACIÓN AMBIENTAL, ARAMBIENTAL (□) [creó] una Unión Temporal, la cual se denomina UT RECICLADORES (AZ 3, folio 391). En este momento cuentan con el contrato para manejar el centro de reciclaje La Alquería. Asimismo, expuso que con otras dos organizaciones (□) ANIR y ACOREIN (□) formaron el Pacto Gremial Reciclador.

-

4.7.2 Con posterioridad al Auto 189 de 2011, esta organización de recicladores de segundo nivel informa que:

-

4.7.2.1 Las razones que guiaron la escogencia de su ASE fueron (i) (□) poder mantener la permanencia en el oficio como recicladores; (ii) (□) tener un mejor reconocimiento como recicladores organizados de segundo nivel; (iii) (□) mejorar nuestra calidad de vida obteniendo mejores ingresos y una labor más estable (AZ 5, folio 469). Otras razones citadas son el deseo de promover y hacer visible el nombre de la ARUB, la confianza en que el ASE obtenido permitirá el mejoramiento de sus condiciones de vida y la posibilidad de proyectarse en el manejo exclusivo de residuos aprovechables.

-

4.7.2.2 En cuanto al funcionamiento de la ruta de reciclaje, señaló que (□) Funciona de dos maneras. La primera es la ruta que la UAESP llama informal que es realizada por los recicladores de oficio. Y la segunda la ruta selectiva realizada por los consorcios de aseo en diferentes puntos de la ciudad (AZ 5, folio 470). En la primera ruta los recicladores recuperan los residuos por las calles usando costales, triciclos y carretas de tracción animal entre otros. En cuanto a la ruta selectiva realizada por los consorcios de aseo, éstos (□) tienen programado un día específico para cada zona de la ciudad donde una parte de estos residuos llegan al CENTRO DE RECICLAJE LA ALQUERIA y en donde los recicladores le dan el aprovechamiento de selección (AZ 5, folio 470) de manera que el 70% es aprovechable y el 30% restante es material de rechazo.

-

4.7.2.3 Frente al funcionamiento del Servicio Público de Aseo, la ARUB informa que existen horarios y días establecidos según el tipo de residuos a recolectar; (□) por lo tanto [.] los recicladores intervienen en el sistema de aseo principalmente cuando se sabe los días y el horario de ruta de basuras en general, pero el reciclador pasa una hora antes para que pueda reciclar en la calle (AZ 5, folio 470). Respecto a los parámetros negociados con los proponentes, la ARUB señaló (□) ninguno porque no los conocimos ni antes ni después de la participación de las ASES mencionadas (AZ 5, folio 470).

-

4.7.2.4 Por lo demás, anotó que, pese a que la UAESP no ha creado conciencia entre los ciudadanos respecto a la necesidad de separar los residuos en la fuente, los recicladores logran recuperar el 30% de los residuos (□) de allí y contra el reloj en la ruta que hacen los operadores de recolección de residuos para disposición final (AZ 5, folio 470). A esto se suma la indiferencia y el trato discriminatorio que,

en opini? de la ARUB, ha caracterizado las actuaciones de algunas entidades del Distrito.

4.8 ANIR (AZ 3, folio 320 a 337).

4.8.1 El representante legal de esta organizaci? manifest?que, a su parecer, la UAESP no ha dado cumplimiento a las obligaciones atinentes a la inclusi? de acciones afirmativas a favor de la poblaci? de recicladores de Bogot? En este sentido, record?que el Auto 268 de 2010 estableci?como una obligaci? la verificaci? de la naturaleza de las organizaciones que se presentaran en la licitaci? del Relleno Sanitario Do? Juana. Asunto que fue reiterado en el Auto 298 de 2010. Empero, esta actuaci? no se llev?a cabo en el presente proceso, pues se habilit?la participaci? de organizaciones creadas d?s antes de la resoluci? de apertura de la licitaci?; aunado a lo cual se observa la doble militancia de personas dentro de ellas.

Sumado a ello, mencion?que la Adenda 2, publicada el catorce (14) de junio de dos mil once (2011), modific? los requisitos que deb?n cumplir las organizaciones de segundo nivel para participar en el proceso. A su juicio, las nuevas condiciones ten?n por objeto excluir a ANIR, pues se impuso □ un d? antes del cierre del periodo establecido para allegar la documentaci? solicitada □, que desde un principio las asociaciones deb?n haberse constituido como organizaciones de recicladores.

4.8.2 Record?que la Alcald? Mayor de Bogot?conform?una mesa de negociaci? con el □Pacto Colectivo Gremial□, conformado por ANIR, ARB, ARUB, ARAMBIENTAL y ACOREIN, para tratar temas como la inclusi? de la poblaci? recicladora en la presente licitaci?, la regulaci? urban?tica de las bodegas asociadas al acopio y alternativas para los recicladores que utilizaban veh?ulos de tracci? animal. En el marco de estas negociaciones, presentaron un estudio que □(□) demostraba la viabilidad de pagar por la recolecci? y transporte de residuos aprovechables [con] un valor igual o similar al que la ciudad de Bogot?paga hoy por la recolecci? de residuos que se llevan a disposici? final (□)□ (AZ 3, folio 322). Sin embargo, en los estudios t?nicos requeridos por la UAESP, en los que solicit?a la CRA aprobar un esquema t?nico y financiero para la prestaci? del servicio, no incorpor?lo atinente al reciclaje.

4.8.3 Aleg?que el modelo implementado por la referida entidad fracciona la cadena productiva del reciclaje y excluye a los recicladores de la labor que han adelantado, ya que el objeto de la recolecci? se circunscribe a □(□) todos los residuos s?idos, potencialmente aprovechables[,] inorg?nicos, secos, no peligrosos, separados por los usuarios u presentados de manera separada□ (AZ 3, folio 326). En otras palabras, los recicladores no podr? ejercer libremente su oficio, pues deber? actuar de com? acuerdo con los concesionarios.

As?las cosas, la exclusi? se materializa en el hecho de desconocer la complementariedad de la actividad de reciclaje, pretermitir □(□) el valor de la actividad, (□) el trabajo de los recicladores y [empeorar] las condiciones de vulnerabilidad y pobreza [en que sobreviven, y] (□) permitir que interese no afectos a las Organizaciones de Recicladores aprovechen la oportunidad que ofrece la UAESP (□), [am? de articular] una regulaci? de las bodegas afectas a la actividad de acopio que excluye m? del 95% del total de bodegas identificadas (□)□ (AZ 3, folio 328).

4.8.4 Por otra parte, expuso que en el sorteo efectuado por la UAESP, el veinte (20) de junio de esta anualidad, no se permiti?□(□) a los interesados, y representantes jur?icos de las organizaciones no habilitadas participar con sus observaciones sobre la evaluaci? de habilitaci? y sobre el procedimiento mismo (□)□ (AZ 3, folio 327).

-

4.8.5 En cuanto a la constituci? de ANIR, mencion?que seg? el Decreto 1713 de 2003 las personas naturales o jur?icas que se dediquen a acopiar material potencialmente reciclable son considerados recicladores. A continuaci?, relat?que en junio de dos mil dos (2002), ocho bodegueros comercializadores de estos materiales decidieron organizarse para mejorar su situaci?. Por ello, en un principio, se conform? por ocho (8) de estas empresas. Sin embargo, en agosto de dos mil siete (2007) modific?sus estatutos permitiendo la asociaci? de recicladores de base. Por lo mismo, en la actualidad su objeto social radica en □(□) realizar acciones enmarcadas en la cadena de reciclaje y (□) contribuir a mejorar las condiciones para los diferentes actores de la misma como organizaci? de segundo nivel (□)□ (AZ 3, folio 332).

-

4.9 Red de Organizaciones de Recicladores Ambientales □ Dame tu Mano - (AZ 3, folio 338 a 341).

-

4.9.1 Esta organizaci?, que hace parte del Pacto Gremial, aleg?que la estructura de la licitaci? permite la instrumentalizaci? de la poblaci? de recicladores, pero no brinda las herramientas para que puedan empoderarse y crecer en la cadena productiva de las basuras. Por ello, pidi?que se les vinculara al servicio ordinario de aseo, □(□) pero de acuerdo a [sus] fortalezas como recuperadores urbanos, sin hacer reguero, participar en la recolecci? selectiva, en los procesos de reutilizaci? y en la total cadena de reciclaje□ (AZ 3, folio 339).

-

A m? de lo anterior, sostuvo que en el sorteo le correspondi?escoger en sexto lugar, por ello, a pesar de que la mayor? de afiliados se encuentran en la ASE 1 (Suba-Usaqu?), considera que se desintegrar? En este sentido, enfatiz?que se vio obligada a elegir la ASE 4, dado que □(□) no ten?mos m? opciones o se aceptada o no particip?amos en esta licitaci?. [Por ello,] nos parece que esto viola la libre asociatividad (sic)□ (AZ 3, folio 339).

-

Adicionalmente, al igual que otras organizaciones, plante?cr?icas con las organizaciones recientemente conformadas que participaron en el sorteo, de cuyos dirigentes □ sin especificar cuales □ □(□) tienen contratos con la UAESP desde hace tiempo (□)□ (AZ 3, folio 339). Por su parte, adujo que, adem? de coaligar a 10 organizaciones de base, cuenta con bodegas que le permiten un mejor desempe? dentro de la cadena de reciclaje.

-

4.9.2 Con posterioridad al Auto 189 de 2011, inform?que □ En cuanto a las diez preguntas que debemos absolver, no tenemos claridad al respecto ya que nos cambiaron las adendas de la siete a la ocho y todo se complic?y quedamos en el limbo para entender todo el proceso licitatorio 001 de 2011, por tanto jam? conocimos un oferente que nos propusiera un negocio o por lo menos una ruta de reciclaje. Luego los par?etros para el acceso cierto y seguro a los residuos s?idos no es claro para las organizaciones de recicladores de Bogot?/i> (AZ 5, folio 322).

-

4.10 Federaci? Sindical de Recicladores y Carreteros de Bogot?(FESIRBO)

-

Esta organizaci? de recicladores de segundo nivel manifest?mediante su representante legal, el se?r Misael Castro Castro, que desconoce el funcionamiento de la ruta de reciclaje puesto que nunca han sido incluidos en ese proyecto. Frente al Servicio P?blico de Aseo, se?l?que □(□) funciona por medio de rutas y por zonas con diferentes operadores□ (AZ 5, folio 503) y hasta el momento no han intervenido en ? puesto que los recicladores que conforman esta organizaci? trabajan en las calles de manera independiente.

-

Inform? adem?, que □(□) hasta el momento no se ha entrado a negociar con los proponentes puesto que todav? no se sabe que operador le pertenece a la ASE 6□ (AZ 5, folio 504). En cuanto a los derechos como organizaci? de recicladores de segundo nivel, indic?que □(□) el derecho que se gan?en el sorteo es que los recicladores vulnerables entraran a participar como socios accionarios de las utilidades que genere el operador que entre a licitar con la ASE 6□ (AZ 5, folio 504).

-

Finalmente, FESIRBO consider?que los par?etros de la actual licitaci? s?garantizan el acceso cierto y seguro a los residuos □(□) porque el reciclaje no tiene exclusividad y puede uno seguir reciclando como hasta la fecha se viene haciendo□ (AZ 5, folio 504). La ?ica diferencia ser?, en su opini?, que □(□) va a ser m? organizado porque se va a trabajar en conjunto con el operador como lo dice el pliego de condiciones de la Licitaci? P?lica 001 de 2011□ (AZ 5, folio 504).

-

4.11 Federaci? Sindical de Organizaciones Protectoras del Medio Ambiente (FESNOPMA)

-

Por medio de su representante legal, el Se?r Lu? Alberto Morales Moreno, esta organizaci? de recicladores de segundo nivel manifest?desconocer el funcionamiento de la ruta de reciclaje. As?mismo, aleg?que sus afiliados no tienen ninguna relaci? con ella y que nunca han tenido la oportunidad de participar, raz? por la cual □(□) deambulan por la v? p?lica abriendo las bolsas de basura que frente a las viviendas dejan los residentes, mas no se comerciantes ni empresas ya que este reciclaje lo selecciona, transporta y comercia un peque? grupo de l?eres que se auto titulan los ?icos abanderados y representantes de los recicladores□ (AZ 5, folio 517). Adem?, se?l?que los carros de la Ruta Selectiva del Reciclaje llegan al Centro de Reciclaje La Alquer?, enviados por los consorcios de aseo que operan actualmente en la ciudad y □(□) han sido la ARB, la ARUB y ARAMBIENTAL las organizaciones que han obtenido los beneficios□ (AZ 5, folio 518-519).

-

Interrogada sobre el funcionamiento del Servicio P?blico de Aseo, la Federaci? declar?que su conocimiento al respecto es □(□) similar al que tiene todo ciudadano com? que ve los carros que aforan la basura□ (AZ 5, folio 518). Pese a esto, puso de presente la existencia de □(□) incontables botaderos de basura al aire libre□ (AZ 5, folio 518) por los cuales la ciudadan? tiene en mal concepto la prestaci? del Servicio P?blico de Aseo. Adem?, frente a la pregunta que versa sobre la intervenci? de los recicladores en dicho servicio, anot?que □Algunos de nuestros afiliados van delante de los veh?ulos que aforan la basura, revisan qu?material les sirve, lo extraen, recogen, transportan y venden en las bodegas del sector□ (AZ 5, folio 519).

-

En cuanto a los parámetros negociados con cada uno de los proponentes para el ASE que les fue asignado en el sorteo efectuado por la UAESP, aclaro que hasta la fecha no conoce ninguno de ellos ni ha tenido contacto alguno con personas pertenecientes a los consorcios licitantes. De ahí que los posibles beneficios como organización de recicladores de segundo nivel de los cuales tuvo noticia sean los consagrados en el pliego de condiciones de la Licitación en comento. Por lo demás, anoto que por sorteo debe compartir el ASE 2, Fontibón y Engativá con la ARB donde posiblemente los afiliados de FESNOPMA van a tener derecho a seleccionar el material reciclable en una fuente y ya no en la calle como siempre lo han hecho.

Adicionalmente, FESNOPMA definió la basura como todo aquello que el ser humano, en su vida cotidiana o industrial, ya no le sirve de acuerdo a su modalidad de vida o ejercicio laboral y por ello desecha (AZ 5, folio 520) Así en su opinión, el acceso cierto y seguro a los residuos es el derecho que le asiste a sus asociados de seleccionar de la basura los materiales que tienen un valor económico y contar con las herramientas de trabajo adecuadas para hacer frente a enfermedades derivadas de la labor del reciclaje. Adicionalmente, haré parte del acceso cierto y seguro a los residuos un mercado con valores sostenibles y equivalentes a la labor desarrollada, precios que sirvan para llevar una vida digna y cumplir con los deberes de la familia en la formación de los hijos (AZ 5, folio 520).

Frente a la pregunta de si el acceso cierto y seguro a los residuos está garantizado en la actual licitación, FESNOPMA respondió enfáticamente: NUNCA se nos ha dado espacio para opinar: nuestras ideas, propuestas y reclamos no pasaban de ser lamentos en el desierto (AZ 5, folio 521). La organización expresó que, pese a haber sido incluidos en el sorteo y haberse adjudicado un ASE para tener acceso cierto a los residuos, no existe ningún tipo de garantía que asegure que los resultados del sorteo serán respetados. Además, puso de presente que no conocemos cómo la UAESP nos va a garantizar la entrega de las fuentes [de residuos] cuando, ya lo dijimos, personas que se autotitulan posibles líderes del reciclaje en la ciudad, tienen las fuentes donde se genera residuos en cantidades considerables y los tienen asignados a sus familiares y amigos (AZ 5, folio 521). Finalizó este apartado diciendo que no en la Licitación 01 del 2011 no se estipula como hace el gobierno para que los generadores de residuos síidos entreguen al Reciclador el material aprovechable, o a cambio de qué (AZ 5, folio 522).

Por último, FESNOPMA aprovechó para poner en conocimiento de esta Corporación la existencia de organizaciones de recicladores de segundo nivel que carecen de trayectoria y que nunca se hicieron presentes en procesos de concertación como la Mesa Distrital del Reciclaje. Además, enfatizó que a su parecer resulta injusto que organizaciones de segundo nivel que cuentan con un reducido grupo de afiliados, se vean beneficiadas con la misma participación de aquellas conformadas por un considerable número de recicladores.

4.12 Federación Sindical Cultura de los Recicladores (FESINCURE)

Las respuestas al cuestionario planteado por esta Corporación en el Auto 189 de 2011, allegadas por la Federación Sindical Cultura de los Recicladores (FESINCURE), pertenecen al mismo formato de respuesta de la Federación Sindical de Organizaciones Protectoras del Medio Ambiente (FESNOPMA).

4.13 Federación Sindical de Recicladores y Carreteros de Colombia (FESINRECOL)

-

Cuestionada sobre el funcionamiento de la ruta de reciclaje, **FESINRECOL** respondi? por medio de su representante legal la Se?ra Graciela Buitrago Parra, que actualmente la ruta est?a cargo de consorcios. Estos consorcios disponen de veh?ulos que recorren los barrios recogiendo los desechos para trasladarlos al centro de acopio La Alquer? □(□) donde la uni? temporal conformada por ARB, ARAMBIENTAL y ARUD los procesan en la clasificaci? y comercializaci? □ (AZ 5, folio 558). En cuanto a la participaci? de los recicladores en la ruta de reciclaje, sostuvo que, en su opini?, los ?icos recicladores que participan en ella son aquellos que pertenecen a las tres organizaciones de la Uni? Temporal, puesto que son ellos quienes realizan la labor de clasificaci? de los residuos. Anot? adem?, que □Las dem? organizaciones de segundo nivel no tienen ninguna relaci? con la ruta de reciclaje porque ellos reciclan en las calles o en las fuentes por su propio esfuerzo□ (AZ 5, folio 559).

-

Frente al funcionamiento del Servicio P?blico de Aseo, **FESINRECOL** asegur?no conocer mucho al respecto, salvo que existen normas precisas sobre el tema. Sin embargo, sobre las labores que desempe?n los recicladores de base, se?l? □Nosotros los recicladores intervenimos cuando empieza nuestra rutina diaria, trabajando las canecas, las bolsas, los chuts de los conjuntos residenciales, empresas, f?ricas en general□ (AZ 5, folio 559) y continu?diciendo: □el reciclador de oficio recicla y transporta hasta el centro de acopio, de esta manera obtiene su sustento, desafortunadamente el reciclador no tiene ninguna remuneraci? por su labor□ (AZ 5, folio 559).

-

Sobre los par?etros negociados con cada uno de los proponentes para el respectivo ASE que le fue asignado tras el sorteo organizado por la UAESP, advirti?que □Nosotros, como organizaci? de segundo nivel de recicladores de oficio, no hemos tenido en el marco de la Licitaci? la oportunidad de negociar con ning? proponente porque la Licitaci? 001 de 2011 a? no ha sido adjudicada□ (AZ 5, folio 560), raz? por la cual, solici?a esta Corporaci? permitir la reanudaci? del proceso licitatorio.

-

En cuanto a la pregunta ¿qu?entiende por acceso cierto y seguro a los residuos s?idos? Esta organizaci? respondi? que □Es cuando el reciclador tiene acceso a las fuentes donde se generan los residuos s?idos□ (AZ 5, folio 560). Adicionalmente, anot?que su acceso estar? garantizado □(□) siempre y cuando la licitaci? sea a favor del reciclador de oficio□ (AZ 5, folio 561) y record?que, seg? el pliego de la licitaci? en comento, □(□) la ruta de reciclaje ser?ejecutada por los recicladores de oficio puerta a puerta, el material ser?de los recicladores por esto lo podr? comercializar en la bodega que quieran□ (AZ 5, folio 561).

-

4.14 M?kbys (AZ 3, folio 375 a 376); Cooperativa de Trabajo Asociado de Recicladores el Triunfo (AZ 3, folio 377 a 378); Asociaci? de recicladores Puerta de Oro de Bogot?(AZ 3, folio 379 a 380); Asociaci? de Recicladores Rafael Uribe Uribe (AZ 3, folio 381 a 382); Asociaci? de Recicladores el Triunfo □ASORETRIUNFO □ (AZ 3, folio 383 a 384); Asociaci? de Recicladores □Luz Verde□ de Usaqu? (AZ 3, folio 386 a 387).

-

Estas organizaciones alegaron que los recicladores sobreviven con dos (2) d?ares diarios aproximadamente, que est? estructurados en esquemas organizativos, que solicitan el reconocimiento de la actividad que realizan y de un porcentaje econ?mico por la parte del servicio p?blico que prestan. As? mismo, indicaron que no observan reales acciones afirmativas a favor de esta poblaci?, dado que se est? permitiendo que personas ajenas al gremio se vean favorecidas.

-
Por lo demás, manifestaron que buscan que las rutas de reciclaje sean operadas por ellos, conforme a las organizaciones de economía solidaria que han conformado. Asunto que, además, mejorar los sistemas de aprovechamiento en beneficio de la ciudad. Sin embargo, aclararon que al acabarse con las bodegas de reciclaje, se afecta la cadena económica y ambiental en que participan de manera grave. Por lo demás, enfatizaron que no están interesadas en participar como socias industriales de los operadores de servicio de aseo.

-
Finalmente, alegaron que esta es una oportunidad en la que se puede generar una política pública de inclusión del gremio de recicladores, que materialice los derechos que fueron amparados desde el 2003 por la Corte Constitucional.

-
5. Otras intervenciones.

-
Amicus Curiae Universidad Nacional de Colombia y Adriana Ruiz Restrepo (AZ 5, folios 137 a 146).

-
El Grupo de Investigación en Derechos Colectivos y Ambientales GIDCA de la Universidad Nacional de Colombia, intervino dentro del incidente para resaltar que si bien la licitación en cuestión permite la participación accionaria de organizaciones y brinda implementos de recolección para los miembros de las asociaciones de segundo nivel, el(los) este apoyo no implicar exclusividad de ninguna organización de recicladores en determinada zona de servicio (los) (AZ 5, folio 138). Aunado a ello, la dinámica del mercado excluye a los recicladores, pues las empresas prestadoras tendrán incentivos para el aprovechamiento, según la estructura tarifaria vigente. Igualmente, los intermediarios habituales de las basuras saldrán de la cadena productiva en razón a la regulación de las bodegas de reciclaje.

-
Con todo, enfatizó que la mayor limitación a las acciones afirmativas se encuentra en los criterios de vinculación de las organizaciones de segundo nivel. Esto, por cuanto no se emplearon elementos que permitieran determinar destinatarios específicos de manera inequívoca. Por ello, las medidas adoptadas en la licitación en comento perdieron su especificidad y razón de ser. Así las cosas, enfatizó que existen el(los) muchas nuevas organizaciones y grupos de recicladores con unas pocas semanas de creación, de los cuales no se conoce su real trabajo en el reciclaje, ni mucho menos sobre su condición de vulnerabilidad y marginación de la sociedad en razón a la actividad de reciclaje que vayan desarrollando a través del tiempo, condición inequívoca para ser destinatario de la acción afirmativa (AZ 5, folio 140).

-
Por lo demás, recalcó que la estructura tarifaria actual es obsoleta, dado que el(los) no incorporan los costos económicos derivados de la inclusión de la población recicladora (los) (AZ 5, folio 140). Por ello, no se reconoce directamente a este grupo poblacional y su labor que reduce costos de recolección y disposición final. A más de lo anterior, apuntó que el cálculo de la tarifa se basa en el peso de la producción de residuos, pero el mismo está sobre estimado, ya que se sitúa en 74 Kilos por usuario al mes, a pesar de que existen el(los) varios estudios que sitúan la producción de desechos en menos de 1.5 kilos diarios por usuario (AZ 5, folio 141). Sin embargo, no especificó a qué estudios se refiere o dónde pueden ser consultados.

-

Por su parte, Adriana Ruiz Restrepo anunció que varias personas habían instaurado acciones de tutela en contra de la Licitación Pública de la referencia, ya que en ella se desconocen las reglas establecidas en la sentencia T-291 de 2009. En efecto, no se está garantizando el acceso cierto y seguro a los residuos sólidos, dado que los mismos quedarían dispuestos en las aceras de Bogotá a libre disposición de las fuerzas del mercado. Corolario de esto, el modelo de Ruta de Reciclaje no suple esta deficiencia, comprometiendo de paso el saneamiento básico de la capital colombiana.

-

Sumado a lo anterior, alegó que los uniformes e indumentarias que entregarían los concesionarios no conllevan (□) una remuneración estable o cierta y exigible, ni exclusividad en el acceso al material del que depende su mínimo vital[,] pues (□) no hay ruta selectiva de reciclables con exclusividad ni para ellos, ni para el operador de quien son socios sino en libre mercado (AZ 5, folio 144).

-

Por lo demás, también hizo referencia a la desnaturalización de las acciones afirmativas al permitir la vinculación de organizaciones de dudosa procedencia. Aunado a ello, la participación accionaria y la repartición de dividendos es anual, por lo que no puede asegurar de manera alguna el mínimo vital de esta población. Sobre esto, echó de menos la existencia de estudios técnicos que demostraran que era la mejor opción.

ANEXO 2

1. Elementos probatorios.

Los siguientes documentos fueron allegados como pruebas al presente incidente: ...

a. Acta de Cierre de la Licitaci? P?lica No. 001 de 2011, en la que constan las siguientes propuestas, que fueron recibidas el veintinueve (29) de julio de dos mil once (2011): 1. Promesa de Sociedad Futura ATESA Siglo XXI; 2. Promesa de Sociedad Futura Bogot?Ambiental; 3. Consorcio Conambientales; 4. Uni? Temporal Aseo Triple A; 5. Promesa de Sociedad Futura Promoambiental Distrito S.A.E.S.P; 6. Aseo Capital Uni? Temporal; 7. Promesa de Sociedad Futura Desarrollo Limpio S.A. E.S.P; 8. Promesa de Sociedad Futura Aseo Bogot?S.A. E.S.P; 9. Uni? temporal Cavo Vig?; 10. Promesa de Sociedad Futura RBL Bogot?D.C.; 11. Proponente Plural Conformado por Ciudad Limpia Bogot?S.A. ESP, Felipe Holgu? Pe?, Fernando Reyes Mahecha, Juvenal Saavedra G?ez y Juan Francisco Copello Vergara, Bajo la promesa de Sociedad Futura; 12. Consorcio Lime; 13. Promesa de Sociedad Futura IPSUM S.A.S. E.S.P.; [y] 14. Organizaci? empresarial de servicio de aseo oesa (AZ 2, folio 217). Igualmente, en dicho acta se observan los aspectos generales de cada oferta. En lo atinente a la poblaci? de recicladores^[71], el proponente # 1 - Promesa de Sociedad Futura ATESA Siglo XXI -, ofert?un porcentaje de participaci? entre el 16.80% y el 18.64%; propuso alcanzar el 100% de aprovechamiento en el primer a? y contratar entre 100 y 220 recicladores (AZ 2, folio 218, respaldo). Por su parte, el proponente # 2 - Promesa de Sociedad Futura Bogot?Ambiental ofert?una participaci? accionaria entre el 5% y el 9%, un aprovechamiento para el primer a? entre el 32% y el 50% y la contrataci? de 0 a 768 recicladores (AZ 2, folio 219). El proponente # 3 - Consorcio Conambientales propuso ceder entre el 5% y el 46 % accionario, alcanzar el 100% de aprovechamiento en el primer a? y contratar entre 527 y 730 recicladores (AZ 2, folio 219 respaldo a 220). El proponente # 4 - Uni? Temporal Aseo Triple A propuso un porcentaje accionario a favor de la poblaci? de recicladores entre el 5% y el 21 %, un aprovechamiento en el primer a? entre el 32 y el 67%, y un n?ero de puestos de trabajo entre 3 y 174 (AZ 2, folio 220 y respaldo). El proponente # 5 - Promoambiental Distrito S.A.E.S.P ofert?ceder entre el 18.36% y el 20 % de acciones, promover el aprovechamiento hasta el 100% y contratar entre 548 y 850 recicladores (AZ 2, folio 221). Por su parte, el proponente # 6 - Aseo Capital Uni? Temporal ofert?una participaci? de poblaci? recicladora entre el 27% y el 71%, un aprovechamiento del 100% en el primer a? y la contrataci? de un n?ero de recicladores entre 546 y 802 (AZ 2, folio 221, respaldo). El proponente # 7 - Promesa de Sociedad Futura Desarrollo Limpio S.A. E.S.P - propuso ceder entre el 20% y el 49 % de acciones, alcanzar el 100% de aprovechamiento en el primer a? y la contrataci? entre 480 y 700 recicladores (AZ 2, folio 222 y respaldo). El proponente # 8 - Promesa de Sociedad Futura Aseo Bogot?S.A. E.S.P ofert?entre el 16% y el 20% de participaci? accionaria a favor de las organizaciones de segundo nivel, alanzar el 100% de aprovechamiento en el primer a? y la contrataci? entre 546 y 817 de recicladores (AZ 2, folio 222 respaldo y 223). A su turno, el proponente # 9 - Uni? temporal Cavo Vig? - ofert?ceder entre el 5% y el 45% de acciones, alcanzar entre el 32% y el 100% de aprovechamiento en el primer a? y contratar entre 10 y 389 recicladores (AZ 2, folio 223, respaldo). El proponente # 10 - Promesa de Sociedad Futura RBL Bogot?D.C propuso ceder entre el 5% y el 15 %, lograr el 100% de aprovechamiento en cualquiera de las ASE asignadas y contratar entre 526 y 813 recicladores (AZ, folio 224). El proponente # 11 - Proponente Plural Conformado por Ciudad Limpia Bogot?S.A. ESP, Felipe Holgu? Pe?, Fernando Reyes Mahecha, Juvenal Saavedra G?ez y Juan Francisco Copello Vergara, bajo la promesa de Sociedad Futura ofert?ceder entre el 5% y el 25% de acciones a favor de las organizaciones de segundo nivel, alcanzar entre el 33 y el 100% del aprovechamiento y entre 10 y 550 recicladores (AZ 2, folio 224, respaldo). El proponente # 12 - Consorcio Lime ofert?entre el 5% y el

25 % de participaci? accionaria, alcanzar entre el 32 y el 100% de aprovechamiento en el primer a? y entre 151 y 1027 puestos de trabajo (AZ 2, folio 225). Por su parte, el proponente # 13 - Promesa de Sociedad Futura IPSUM S.A.S. E.S.P □ ofert?ceder entre el 5% y el 20% de acciones, alcanzar entre el 32% y el 100% de aprovechamiento en el primer a? y contratar entre 0 y 1100 recicladores (AZ 2, folio 225 □ respaldo □ y 226). En cuanto al proponente 14 - Organizaci? empresarial de servicio de aseo □ Oesa - no consta lo que haya ofertado (AZ 2, folio 217 □ 226).

b. Copia de solicitud de proceso contractual y estudios previos para la Licitaci? P?lica 001 de 2011. En ella se observa que □(□) con el objeto de realizar las proyecciones correspondientes, la UAESP estim?la cantidad de residuos a ser utilizados en el c?culo del modelo econ?mico, financiero y de tarifas. De acuerdo con el Decreto 1713 de 2002 y su definici? de servicio est?dar, servicio especial y de tarifas m?imas, la cantidad de residuos a utilizar en las metodolog?s de c?culo de tarifas se componen por los residuos de producci? domiciliaria, de grandes generadores, barrido, material aprovechable y residuos de operativos especiales (□)□ (Subrayas fuera del original) (AZ 2, folio 31).

c. Carta enviada, el veintiocho (28) de julio de dos mil once (2011), por la entonces Directora de la UAESP □ Miriam Margota Mart?ez □ a la ARB, aclarando que □(□) la vinculaci? de las organizaciones de segundo nivel se hace ?icamente con el fin de ser accionistas del concesionario que resulte ganador en cada una de las seis zonas de la ciudad (□). [La asignaci? en cada ASE] se hace ?icamente para ser socio de la empresa que resulte concesionaria del proceso (□). Las acciones de reciclaje que hoy desarrolla la poblaci? recicladora en las localidades de Bogot?no tiene exclusividad para ninguna de las 12 organizaciones asignadas a cada una de las ASE, y sigue habiendo libertad de recolecci? del material potencialmente aprovechable para los recicladores de oficio en la ciudad (□). [Por ello], ninguna de las 12 organizaciones vinculadas al proceso mediante el sorteo pueden ni deben presionar a las organizaciones de primer nivel, ni a los recicladores de base para que se afilien a su agrupaci? y mucho menos segregarlos de los territorios donde naturalmente cada uno de ellos opera □ (AZ 2, folio 49 a 50).

d. Copia de Informe de Organizaciones de Segundo Nivel, elaborado por la UAESP, en el que se observan catorce (14) organizaciones que se presentaron tras la convocatoria elaborada por la entidad. Entre estas ?timas, existen cuatro □ Federaci? de recicladores la cultura de los recicladores, Federaci? sindical de los recicladores y carreteros de Bogot?(FESIRBO), Federaci? sindical de recicladores y carreteros de Colombia (FESINRECOL) y Federaci? sindical ambiental del reciclador colombiano (FEDERSIN) □ con las siguientes fechas de constituci?: quince (15) de marzo de dos mil once (2011), treinta (30) de mayo de dos mil once (2011), siete (7) de junio de dos mil once (2011) y ocho (8) de junio de dos mil once (2011). Igualmente, se indica que dos (2) de las organizaciones que se presentaron fueron excluidas del sorteo, dado que no cumpl?n con los requisitos m?imos. As? la □(□) Asociaci? Nacional de Industriales del Reciclaje ANIR, no cumple con las condiciones m?imas solicitadas, por cuanto no se trata de una organizaci? de recicladores de segundo nivel que desde su creaci? haya sido organizaci? de recicladores en condiciones de vulnerabilidad (□). [Igualmente] la organizaci? denominada Asociaci? de Recicladoras Colombia Mujer del Progreso □ Red de Mujeres, no cumple con las condiciones (□) por cuanto al verificar su objeto social en el documento aportado, se constat?que esta organizaci? no agrupa organizaciones de recicladores de primer nivel (□)□. El objetivo de estas limitaciones era, en t?minos de la UAESP □(□) evitar que organizaciones que incluyan a personas distintas a los recicladores de oficio, en condiciones de vulnerabilidad, resulten favorecidas con las medidas de discriminaci? positiva que se pretenden □ (AZ 2, folio 101) (AZ 2, folio 98 a 102).

e. Copia de Estatutos de la Asociaci? de Cooperativas de Reciclaje Recuperaci?

Ambiental (ARAMBIENTAL), en el que se le define como una empresa de economí? solidaria. A continuaci?n, por naturaleza jurí?ica y raz? social se indica que se trata de □(□) un organismo de Segundo Grado, de car?ter Asociativo Nacional, personer? jurí?ica de derecho privado, de responsabilidad limitada, sin ?imo de lucro, regida por la constituci?n y la ley (□)□ (AZ 2, folio 342). Por objeto se contempl? la promoci?n de espacios de desarrollo y reconocimiento de las organizaciones de base. Con respecto al ejercicio econ?mico, el pliego establece que □(□) ARAMBIENTAL tendr? ejercicios econ?micos que se cerrar? al treinta y uno (31) de Diciembre de cada a?o calendario. Al t?mino de cada ejercicio se cortar? las cuentas y se elaborar? el balance General, el inventario y el estado de resultados (□). Los excedentes del ejercicio los aplicar? la Asamblea de acuerdo a: 1. Compensar p?didas del ejercicio anterior[;] 2. Un veinte (20) por ciento como m?imo, para crear y mantener una reserva de protecci?n de los aportes sociales[;] 3. Un veinte (20) por ciento como m?imo, para crear y mantener un fondo de educaci?n[;] 4. Un diez (10) por ciento para un fondo de solidaridad[; y] 5. El remanente se aplicar? para incrementara (sic) los anteriores o para nuevas reservas y fondos destinados a la (sic)cumplimiento de sus objetivos o para lo que destine la Asamblea General□ (AZ 2, folio 351 a 352). Cabe mencionar que constituyen esta asamblea los representantes de las entidades asociadas h?iles, conforme al art?culo 30 del Estatuto (AZ 2, folio 337 a 369).

f. ----- Estatutos de la Federaci?n Sindical Ambiental del Reciclador Colombiano (FEDERSIN). Como objeto de la organizaci?n □ definida como de segundo nivel □ figura □(□) la integraci?n de los Sindicatos cuyos trabajadores en su ejercicio laboral, defienden el medio ambiente, los recursos naturales y con su actuar, se disminuye la contaminaci?n, (sic) en las fuentes h?ricas, la poluci?n del aire y trabajan en la **cadena del reciclaje** descontaminando los residuos s?idos para que no vayan a los rellenos sanitarios, recuperando t?nicamente productos industriales□ (?fasis original) (AZ 2, folio 384). En el capitulo III figuran las condiciones para admitir afiliados. Una de ellas es la siguiente: □(□) Ser sindicato con Naturaleza Ambientalista que sus trabajadores sean activistas defensores del Medio Ambiente y de los recursos naturales, acompa?do de la actividad laboral en la Cadena del Reciclaje□ (AZ 2, folio 386). Como ?ganos figura, en el art?culo 9, el Comit?ejecutivo, compuesto por delegados de los Sindicatos; que tiene entre sus funciones elegir la directiva sindical, para un periodo de dos (2) a?s. Como beneficios de cada afiliado aparecen, en el art?culo 8: participar en los debates de las Asambleas, elegir y ser elegidos como directivos, presentar proposiciones, hacer parte de las comisiones y gozar de los beneficios que otorga la Federaci?n. Un elemento que hay que destacar figura en el art?culo 39, que fija que en caso de liquidaci?n y disoluci?n de la Federaci?n □(□) en ning? caso, ni por ning? motivo[,] un afiliado puede recibir m? del monto de las cuotas ordinarias que haya aportado (□)□ (AZ 2, folio 395) (AZ 2, folio 384 a 397)

g. ----- Copia de Estatutos de la Confederaci?n Ambiental Hagamos de Colombia un pa? grande □ Confederaci?n Ambiental FUNCOLGRAN□, en donde se define como □(□) una entidad sin ?imo de lucro (□) cuya funci?n principal es la de agrupar a las organizaciones, cooperativas y asociaciones de Recicladores (□) sus bienes ser? repartidos entre cada una de las organizaciones teniendo en cuenta que el 60% de estos (□) pasar? a Organizaciones ambientales que manejen ni?s y ancianos (□) y [el] 40% [a] Organizaciones sociales ambientales legalmente constituidas y con reconocimiento de la autoridad ambiental (□)□ (AZ 2, folio 426). En cuanto a la distribuci?n de beneficios, los estatutos plantean que ser?□(□) equitativa [y] a trav? de la distribuci?n de los excedentes a sus organizaciones afiliadas que prestan servicios de car?ter ambiental y social de manera proporcional al uso de los servicios o a la participaci?n en el trabajo de (□) FUNCOLGRAN (□)□ (AZ 2, folio 454). En cuanto a los ?ganos de administraci?n, el art?culo 13 establece que el presidente ser? vitalicio, y escogido de los miembros fundadores. Igualmente contempla la existencia de un consejo de administraci?n. Para pertenecer a este ?timo, se requiere □(□) ser profesional con experiencia de 5 a?s en cargos administrativos en organizaciones sin ?imo de lucro o tener 20 a?s de experiencia como directivos de organizaciones sin ?imo de lucro□ (AZ 2, folio 457). Tambi? se menciona una Asamblea General, que tiene entre sus funciones elegir al fiscalizador, y aprobar negocios jurí?icos por cuantí?s superiores a un salario m?imo, entre otros (AZ 2, folio 426 a 466).

h. ----- Copia del Pacto Gremial Reciclador, firmado - el trece (13) julio de dos mil once (2011) - por los representantes de la ARB, ANIR, ACOREIN y ARUB. En el documento se afirma que en ? se □(□) deja constancia (□) de las siguientes situaciones de vulnerabilidad de los derechos del gremio (□): promover la constituci? obligada de grupos y organizaciones de segundo grado (□)[;] La existencia de un n?ero importante de personas censadas no recicladoras (□)[;] [La omisi? de] definir los par?etros de articulaci? de la cadena de residuos (□) [y el traslado de] la obligaci? del Plan de acci? a los empresarios de aseo que queden asignados en la operaci? (□)[;] [la imposici? de] la obligaci? a las organizaciones de segundo grado [de] la recolecci? de las rutas de reciclaje (□)[;] [las exigencias tecnol?icas] no les permiten estar realmente en el negocio (□) [y] les ponen obligaciones que no pueden cumplir (□)□ (Subrayas del original). Con fundamento en lo anterior plantearon los siguientes interrogantes: □[¿] Cu? es la respuesta (□) para miles de recicladores que no tendr? carretas □VTA-, ni bodegas cercanas en donde vender (□) [pues] s?o pueden recorrer hasta 10 kil?etros (□)?[¿] Cu? finalmente es el factor que se debe tener en cuenta en las rutas de reciclaje: 1) el porcentaje de usuarios cubiertos (ahora est?en 33%) y se cubre con 6 carros, 18 personas y 70 rutas semanales o 2) el 4% en cantidad que se espera con los mismos recursos (□)□ (AZ 2, 467 a 468).

i. ----- Escrito de coadyuvancia de la ARB a una acci? de tutela instaurada por Andrea Ruiz y otros contra la UAESP, en el que se indica que con las sumas de los contratos □(□) para el desarrollo de acciones afirmativas a favor de los recicladores (□) se habr? podido construir y dotar unos 8 centros de reciclaje (□) como lo muestra el ejemplo (□) de la ciudad de Buenos Aires (□)□ (AZ 3, folio 4). En este sentido, se se?la que una acci? afirmativa implicar? mejoras sustanciales para su trabajo, pues ellas deben ser □(□) procesos estructurales que [permitan] al gremio superar [la] pobreza progresivamente apropiando capacidades propias en el oficio que desempe?n y no en otros (□)□ (AZ 3, folio 4) y se enfatiza que no se pidieron puestos de trabajo otorgados por los empresarios o que se les repartan utilidades por actividades que no incluyen el reciclaje, dado que s?solicitaron la posibilidad de apropiarse de los recursos necesarios para la operaci?. A m? de lo anterior, se manifiesta que la licitaci? instrumentaliza a los recicladores, pues ellos □(□) no manejan de manera directa nada, ni siquiera la convocatoria a sus propios compa?ros (□). Si los empresarios tienen la potestad del manejo de los recursos y de los balances, pues van a tratar de llevar al m?imo las utilidades [que supuestamente ser? repartidas por el porcentaje accionario]□ (AZ 3, folio 5). En cuanto a los puestos de trajo ofrecidos, se se?la que resulta perjudicial, pues cuando termine la licitaci? □ a aquellos que superen los 50 a?s de edad □ se les dejar? sin posibilidades laborales. De otro lado, se afirma que el cierre de 1340 bodegas, as?como la exclusi? de circulaci? de 4000 carretas, afecta gravemente la cadena de valor del reciclaje, excluyendo al gremio de la actividad. De otra parte, se expone que los ahorros que genera al sistema el aprovechamiento □ conforme a la Ley 142 □ no llegar? a los recicladores, pues el 50% ser? rebajas a las tarifas y la mitad restante corresponder?a programas de reciclaje (AZ 3, folio 2 a 15). Igualmente, expuso que en los componentes que la licitaci? reconoce remuneraci? posible se encuentra la recolecci?, que □(□) no especifica [sobre] qu?tipo de recursos [se desarrollar?□, desconociendo el pago sobre la labor que desarrollan los recicladores (AZ 3, folio 7 a 10).

j. ----- Trato Colectivo Gremio Reciclador Colombiano, elaborado el doce (12) de octubre de dos mil diez (2010), por representantes de ARB, ARUB, RED de SUBA, ANIR, ACOREIN, ARAMBIENTAL, Y ALFUTURO. En ? se plantea la necesidad de defender el oficio de reciclador, el crecimiento en la cadena de valor de los residuos y la promoci? del trabajo digno, entre otros. Por ello, se efect? una lista de denuncias a divulgar, que incluyen □Desenmascarar las actuaciones de intereses particulares de las organizaciones, que al no representar un n?ero grande de recicladores y al tener integrantes de otras categor?s-actividades NO persiguen [el] inter? del gremio y venden a la UAESP su apoyo incondicional (□). No permitir la realizaci? del Censo a Recicladores que pretende desarrollar la UAESP sin que antes no se haya negociado la aplicabilidad del mismo a necesidades del gremio y a sus aspiraciones coherentes con una pol?ica p?lica definida conjuntamente y validada socialmente por el

gremio a trav? de sus organizaciones representativas (□) □ (AZ 3, folio 11 a 12). De otro lado, se se?la que incluso tras la celebraci? del Congreso Mundial de Recicladores, desarrollado en Bogot?en el dos mil ocho (2008), □(□) La din?ica resultante de la organizaci? del gremio, es la presi? para resolver el conflicto de la integraci? y articulaci? del oficio de reciclaje en el sistema p?lico de aseo al cual el Pa? ha llegado con la participaci? sin reconocimiento del Gremio □ (AZ 3, folio 13) (AZ 3, folio 11 a 15).

k. Solicitud efectuada por el □Pacto Gremial Reciclador□ a varias entidades p?licas, en busca de apoyo para la defensa de la actividad econ?ica desarrollada. Dentro de las alegaciones del escrito, que justifican la existencia del □Pacto del Gremio Reciclador□ se encuentra □(□) alinear esfuerzos para promover la defensa del leg?imo derecho del sector a mantenerse en el oficio (□) y de crecer en la cadena [de] valor de los residuos en condiciones de dignidad humana y organizativa, debidamente articulado con el servicio de aseo p?lico de responsabilidad del estado (□)□(AZ 3, folio 24). Igualmente, en ? se reitera la importancia ambiental de la recolecci? para el aprovechamiento. A continuaci? se relata que □(□) el **mercado** de reciclaje ha proporcionado los recursos de ingreso [a] los diferentes actores de esta cadena de valor, desde luego los m? bajos son para la base de la cadena, que su oficio se ha mantenido en el nivel de supervivencia (□)□ (AZ 3, folio 25). En este sentido, se expone que con la vinculaci? digna de los recicladores se puede mejorar ambientalmente el manejo de basuras de Bogot? siempre y cuando exista una coordinaci? con el Gobierno. En el escrito, tambi? se refiere al origen del □Pacto Gremial Reciclador□, que se sit? en junio de dos mil diez (2010) □dado que el escrito tiene fecha del siete (7) de julio de dos mil once (2011) □ y se contempla como la uni? de varias organizaciones: □(□) 7 de las organizaciones m? representatias del Sector (□) [Que incluyen recicladores y] organizaciones de los otros eslabones de la cadena como los comercializadores y peque?s y medianos empresarios de procesamiento [de los residuos] a materia prima, como la asociaci? Nacional de Industriales del reciclaje □ ANIR □ y la Asociaci? Colombiana de recicladores Independientes □Acorein; as?como los compa?ros carreteros de veh?ulos de tracci? animal (□)□ (AZ 3, folio 25). Como propuesta de acci? afirmativa plantearon la □(□) configuraci? de un proceso de regulaci? para el aseo que precise los mecanismos y criterios de pago del servicio que presta el gremio reciclador Colombiano. [Que le otorgue] la preferencia en el reconocimiento de su oficio para que mantenga las rutas de recolecci? del reciclaje y el aprovechamiento, pero no solo a modo de supervivencia sino que se haga justicia en el valor a trasladar en las tarifas □ (AZ 3, folio 27) (AZ 3, folio 24 a 27).

l. La ARB, la ASN y la Red Latinoam?icana de Recicladores adjuntaron una presentaci? titulada: □Organizaci? de los Recicladores, una alternativa social, t?nica, econ?ica y ambiental en Colombia, dentro de un sistema organizado para el manejo de los residuos s?idos□, en la que se mencionan, como t?nicas alternativas de estrategia de incidencia: □(□) Centros de Acopio, Proyectos [de] aprovechamiento, Prestaci? [de] Servicios [de] Aseo, Rutas [de] Recolecci? [y] Recolecci? Reciclaje□, de materiales como □(□) Papel, vidrio, pl?tico [y] cartuchos (□)□ (AZ 3, folio 37). Como objetivos econ?icos se establecen □Promover comercializaci?, mercadeo y distribuci? del material recuperado. Establecer convenios con [el] estado (sic) y [el] sector privado (□)□ y, como objetivos pol?icos y ambientales se contemplan: □(□) constituir una fuerza gremial real, buscando el reconocimiento social y la dignificaci? de la labor del reciclador [y] contribuir a la conservaci? de los recursos naturales[. Por ejemplo] Ton. Papel recuperado (□) evita la tala de 20 ?boles□ (AZ 3, folio 38). Como lineamientos generales de la propuesta se describen: □Conformaci? de esquemas empresariales solidarios constituidos por las organizaciones de recicladores para la prestaci? del servicio[;] establecimiento de sectores diferenciados de recolecci? (SDR) sin exclusividad[;] Realizaci? de micro rutas coordinadas de recolecci? del material reciclable, separado en la fuente, de parte de cuadrillas de los Recicladores del Sistema[;] Establecimiento de centros de transferencia M?il (CTM) dependiendo de vol?enes de material y distancias a recorrer en cada SDR[;] Realizaci? de macro rutas de transporte de parte de los consorcios de aseo[;] Acopio, selecci?, pretransformaci? y comercializaci? de los materiales en centros de reciclaje administrativos y operados por las organizaciones de recicladores□ (AZ 3, folio 42). En la presentaci?, tambi? se exponen fortalezas y debilidades del gremio detectadas en los ?timos

15 a?s. En las primeras figuran: □(□) [la] existencia de microrutas, (□) centros de acopio [y] mano de obra experimentada para la operaci? (□)□; mientras que en las segundas aparece: □(□) demasiado tiempo invertido en la recolecci? (□) vol?enes insuficientes y centros de acopio mal distribuidos (□)□ (AZ 3, folio 43). (AZ 3, folio 28 a 48).

-

m. ----- Certificado de existencia y Representaci? de la ARB expedido por la C?ara de Comercio de Bogot?y donde figura, como fecha de constituci?, el quince (15) de noviembre de mi novecientos noventa (1990). Como objeto general de la asociaci? aparece □(□) la defensa de los intereses comunes de los recicladores en la Regional y a nivel Nacional cuando las circunstancias lo ameriten [y como objetivos espec?icos se observan, entre otros,] buscar el reconocimiento y legalidad de la labor del reciclador y sus organizaciones (□); servir como representante de los recicladores para la consecuci? y comercializaci? de los materiales reciclables o de los art?ulos necesarios para la actividad de los recicladores[;] promover la creaci? de canales de comercializaci? id?eos y adecuados para la promoci?, mercadeo y distribuci? de los materiales reciclables, sea en el Mercado interno o en el exterior (□)[;] promover la educaci? tecnol?ica, administrativo, acad?ica, profesional, cultural y ambiental de sus asociados (□)□(AZ 3, folio 51 y 51). Como ?ganos de la ARB se establece, en el art?ulo 15, la Asamblea General, la Junta Directiva, y el Director Ejecutivo. No se observan mayores requisitos para formar parte de ellos, salvo □ en el par?rafo 2 del art?ulo 27 □ la prohibici? de que hayan dos miembros de un mismo grupo afiliado en la Junta directiva. (AZ 3, folio 49 a 66).

-

n. ----- Listado de documentos presentados por la ARB a la UAESP dentro del proceso de la Licitaci? P?lica 001 de 2011, en el que mencionan veintid? (22) organizaciones afiliadas. A pesar de ello, vale la pena indicar que se observan en total veintitr? (23) (AZ 3, folio 67).

-

o. ----- Extractos de estatutos de la Federaci? de Recicladores Independientes de Colombia y certificado de existencia y representaci?, donde figura como misi? □Agrupar (□) a todos los recuperadores ambientales en todos los ?denes y a las asociaciones o sociedades dedicadas al servicio del reciclaje (□)□ (AZ 3, folio 163). A partir del art?ulo 10 se contemplan los ?ganos de gobierno y administraci?. As? se indica □ en el art?ulo 11 □ que las decisiones de la asamblea general ser? adoptadas por el principio mayoritario o de democracia interna. En cuanto a la junta directiva, se se?la que para pertenecer a ella se requiere □(□) ser mayor de edad, estar en pleno uso de los derechos civiles, ser representante legal o delegado de una organizaci? federada y no estar incurso en los motivos de incompatibilidad establecidos en la legislaci? vigente□ (AZ 3, folio 231). Para ser presidente, no se necesitan mayores cualidades, salvo ser miembro fundador de FEDERINCOL o tener una antig?dad de cinco (5) a?s. En cuanto al r?imen econ?ico, resulta relevante resaltar que □(□) todos los bienes y derechos que integran su patrimonio [ser? de la Federaci? (□)□ (AZ 3, folio 245), seg? el art?ulo 43. (AZ 3, folio 160 a 168; 216 a 249).

-

p. ----- Estatutos de la Fundaci? de Servicios Ambientales -FUNREDAMBIENTE □, en el que se expone que □Por ser una Entidad Sin ?imo de Lucro, los rendimientos que se obtienen en el desarrollo de su ejercicio no son objeto de distribuci? entre los asociados (□)□ (AZ 3, folio 262). Como objeto social figura la agremiaci? de organizaciones dedicadas a la defensa del ambiente y la formulaci? de proyectos relacionados con este tema. A partir del cap?ulo III se regulan los ?ganos de administraci?, dentro de los que figuran una Asamblea General de Asociados, una Junta Directiva y un Director Ejecutivo. No se observan mayores requisitos para pertenecer a alguno de ellos (AZ 3, folio 262 a 268).

-

g.----- Copia de Carta enviada por Juber Mart?ez Hernandez, Director de Estrategia de la Secretar? De H?itat, a William Fernando Camargo Triana, Director de V?s, Transporte y Servicios P?licos de la Secretar? Distrital de Planeaci?, en la que se □(□) manifiesta [la] preocupaci? [de la UAESP] en relaci? al alto impacto social y ambiental negativo que genera la implementaci? de este Decreto [456 de 2010] para la Gesti? Integral de los Residuos S?idos en el Distrito Capital, ya que en los t?minos del Sistema Organizado [de] Reciclaje, este tipo de establecimientos son un eslab? fundamental en la cadena de reciclaje. Que actualmente recicla en el distrito 1200 toneladas diarias aproximadamente de material potencialmente aprovechable, que son recolectados, transportados y llevados a las bodegas privadas de reciclaje, con una tendencia en el marco de la licitaci? de RBL [Recolecci?, Barrido y Limpieza] al aumento de esta cifra (□)□ (AZ 3, folio 279 a 280).

r.----- Copia de un Informe de la Contralor? de Bogot? elaborado para la vigencia de dos mil cinco (2005), titulado: □An?isis y Evaluaci? al manejo, estabilidad y vida ?il del Relleno Sanitario Do? Juana, proyecto de Biogas y Parques de Reciclaje□, en el que se se?la que el Plan Nacional de Desarrollo □ en ese momento □ incorpor?la necesidad de formular Planes de Gesti? Integral de Residuos S?idos (PGIRS), que fueron definidos en el Decreto Nacional 1713 de 2002 y en la Resoluci? 1045 de 2003, expedida por el Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial. Por su parte, a nivel Distrital, se menciona que tal Plan se adopt?mediante la Resoluci? 132 de 2004 y que obedeci?a un Plan Maestro Integral de Residuos S?idos (PMIRS). En este ?timo se estableci? entre otras cosas, que se deb? □(□) capacitar a la poblaci? recicladora de oficio en actividades productivas, empresariales y de comercializaci? dentro y fuera de las cadenas de reciclaje y aprovechamiento (□)□ (AZ 3, folio 285). Posteriormente, se menciona que la UAESP formul?el proyecto de inversi? 245, □Programa Distrital de Reciclaje□ que comprendi? entre otras, □(□) la implementaci? gradual de la ruta selectiva, [que] estar?a cargo de los operadores de aseo. [Por lo dem?] el aprovechamiento de los residuos s?idos, que involucran las acciones de selecci?, clasificaci?, acopio y pretransformaci?, ser?desarrollado en los parque de reciclaje, para lo cual se proyecta la construcci? y operaci? de seis (6) [con] la vinculaci? de organizaciones de recicladores a la cadena de reciclaje de la ciudad (□)□ (AZ 3, folio 288). Sin embargo, al analizar las metas establecidas por la UAESP dentro de esta pol?ica p?lica, que inclu?n vincular organizaciones, promover cuatro (4) parques de reciclaje, generar ochocientos (800) empleos formales en los mismos, erradicar el 80% de trabajo infantil en esta actividad, promover 20 proyectos de transformaci? de materiales, entre otros (AZ 3, folio 289 a 290), la Contralor? enfatiz?que se evidenciaba el □(□) incumplimiento de cinco (5) de las seis (6) metas planteadas en el Proyecto de Inversi? 245 □ Programa Distrital de Reciclaje (□) particularmente (□) la construcci? y puesta en marcha de un parque de reciclaje (□)□. En este sentido, es importante se?lar que el ente de control critic?que □(□) la UAESP emplea verbos [en los] que no son susceptibles de ser medidos sus resultados, como promover y generar (□)□ (AZ 3, folio 292). Adicionalmente, en cuanto a otros proyectos de inversi? □ n?eros 7381 y 7387 □ relacionados con campa?s de prevenci? y separaci? en la fuente de residuos s?idos, y un sistema de reciclaje mejorado para Bogot? la Contralor? tambi? se?l?que desde el a? dos mil uno (2001) □(□) han apuntado al manejo de residuos s?idos aprovechables en la ciudad de Bogot? D.C., tiempo en el cual se han llevado a cabo innumerables estudios, actividades y acciones en atenci? a los objetivos y metas planteados, demandado importantes recursos[,] sin que a 31 de diciembre de 2005, el Distrito pueda beneficiarse social y econ?icamente de la operaci? efectiva del proceso de reciclaje (□)□ (subrayas fuera del original) (AZ 3, Folio 294). Posteriormente, en el informe se reitera que una de las medidas propuestas inicialmente radic?en □(□) la construcci? de seis (6) parques de reciclaje cuyas zonas de influencia corresponden a las ?eas de Servicio Exclusivo □ ASE □ para la prestaci? del servicio de aseo□ (AZ 3, folio 298). En este sentido, se se?la que □En el mes de diciembre de 2006, la UAESP tiene previsto la entrada de operaci? de los dos parques de reciclaje o aprovechamiento, uno en el Tintal y el otro en los terrenos de la Planta de Tratamiento El Salitre□ (AZ 3, folio 299) (AZ 3, folio 275 a 277 y 283 a 307).

s.----- Certificado de Existencia y Representaci? legal de la Red de Organizaciones de Recicladores Ambientales □ Dame tu Mano -, donde figura que se constituy?el primero (1?) de

septiembre de dos mil ocho (2008) y se inscribió en la Cámara de Comercio el dos (2) de abril de dos mil nueve (2009). Igualmente, se observa que antes del veinticuatro (24) de enero de este año su nombre era diferente: Organización de Recicladores de Suba, a pesar de que la sigla que la distingue □ Dame tu Mano □ permaneció inalterada. Como objeto social, figura □ entre otras □ la agremiación de organizaciones (AZ 3, folio 342 a 343).

t. Carta Dirigida por Dame Tu Mano a la Alcaldía Mayor de Bogotá sin fecha de presentación, en la que se solicita la inclusión dentro del Plan de Desarrollo Local de Suba la □(□) consecución de un Centro de Acopio y transformación, (□) que les permita tener una manera de comercializar formalmente los [residuos] a precio justo. Este centro de acopio facilitar el manejo ordenado de materiales y la transformación de los mismos para lograr un mayor valor agregado. [También plantean la necesidad de] emprender una gran campaña de capacitación y sensibilización de los generadores de residuos, (□) que permita dar a conocer las ventajas de hacer separación, ejemplo mejoramiento de las tarifas multiusuario, alivio económico para los residentes, pero también la difusión de las medidas punitivas que acarrea el no hacer dicha separación, sensibilizar sobre el papel de los recicladores (□) □ (AZ 3, folio 360 a 362).

u. Copia de estatutos de la Asociación de Recicladores Unidos por Bogotá □ ARUB □, en los cuales se define como objeto social el fortalecimiento y representación de organizaciones de recicladores, así como el desarrollo de acciones encaminadas a la protección y conservación del ambiente. Como gananciales de administración figuran □ en el artículo 23 □ una Asamblea General, un Consejo Directivo, un Comité de Control y Vigilancia y un Representante Legal. Forman parte de la primera dos (2) socios de cada una de las organizaciones de base coaligadas. Mientras que, para poder hacer parte de Consejo, se requiere tener antigüedad de un año y estar a paz y salvo con la asociación de base de la que hace parte. Le corresponde a este Consejo, entre otras cosas, □(□) Estudiar, aprobar o no el presupuesto anual de ingresos, inversiones y gastos de la Asociación y autorizar los gastos no contemplados en el presupuesto, con definición de la manera como deben ser cubiertos □ (AZ 3, folio 404). (AZ 3, folio 392 a 410).

v. Extracto de observaciones y solicitudes de aclaración al pliego de condiciones de la licitación pública 001 de 2011, presentado por LIME ante la UAESP, en el que se indica que las peticiones dadas por la Corte Constitucional se relacionaban con el aprovechamiento. Por ello, y ante la posibilidad de desvincular trabajadores que no sean recicladores para ofertar las plazas laborales, se plantea la opción de □(□) vinculación de personal operativo (no recicladores) especializados en la actividad de corte de césped y poda de árboles, [que tengan] la obligación de entregar los residuos provenientes de esas actividades a la población recicladora[,] para que sean ellos quienes se encarguen de su aprovechamiento, de tal forma que se evite colocar en riesgo operativo a la población recicladora respecto a aquellas actividades y se evite crear una nueva población en situación de vulnerabilidad o configurar desigualdades □ (AZ 4, folio 22). Por otra parte, se solicita que se aclare el hecho de que se plantee la □(□) prestación del servicio público de aseo en condiciones de exclusividad, pero esta concesión aunque incorpora las actividades de 'aprovechamiento' afirma que estas actividades no se someten a exclusividad □ (AZ 4, folio 22). Adicionalmente, se indica que para el dieciséis (16) de marzo de dos mil once (2011), se contemplaba en el proyecto de pliego de condiciones, □(□) numeral 4.1.4, sobre 'Cobertura de la Ruta de Reciclaje RDR' [que] □(□) cada uno de los concesionarios garantizar que se procesen 5 toneladas diarias de Material Efectivamente Aprovechable en el Centro de Reciclaje la Alquería □ (AZ 4, folio 24). Por otra parte, se enfatiza que □(□) el vocablo 'cesión' en materia de sociedades comerciales hace referencia a la transferencia de un bien o derecho que ya existe, motivo por el cual en el ámbito de la promesa de sociedad futura no es dable utilizar dicho vocablo toda vez que ni siquiera existe la sociedad emisora de las acciones y mucho menos se han emitido los títulos correspondientes □ (AZ 4, folio 26). Igualmente, se vislumbra una observación atinente a las personas que

ven?n desempe?ndo las labores de corte de c?ped y poda de ?boles, ya que se les deja a la suerte del mercado, ignorando el lugar que han ocupado, pues □(□) al no ser recicladores[,] no podr? ser contratados □(□) □ (AZ 4, folio 30). Por otra parte, se expone que □(□) con la exigencia de vincular mano de obra recicladora para que adelanten actividades operativas de corte de c?ped y poda de ?boles □(□) se [les] estar? apartando □(□) de las actividades que han venido desarrollando, en contrav? de uno de los elementos tenidos en cuenta por la Corte □(□) □ (AZ 4, folio 30). Y se concluye con el siguiente interrogante: □¿Por qu?se estima que lo ordenado por la H. Corte Constitucional, se cumple restringiendo el acceso a otra poblaci? que tambi? est?en condiciones de vulnerabilidad?□ (AZ 4, folio 31). A m? de lo anterior, se se?la que en la Adenda 7 se estableci?la asignaci? de 50 puntos a la propuesta que ofrezca mayor n?ero de puestos de trabajo para ser ocupados por recicladores en cualquier actividad de la prestaci? del servicio. Empero, se enfatiza que □(□) la misma Adenda 7 sigue se?lando en otros apartes que la poblaci? recicladora solamente puede contratarse para adelantar labores de corte de c?ped y poda de ?boles □(□) □ (AZ 4, folio 37). Por lo dem?, el veintiuno (21) de junio de esta anualidad, LIME pregunt?a la UAESP, en relaci? con el aprovechamiento, si □(□) esta exigencia es un porcentaje de cobertura de usuarios de la Ruta de Reciclaje dentro de su respectiva ASE o un % de aprovechamiento total de toneladas por ASE □(□). [Igualmente se cuestion?que] en el "Plan de Trabajo" □(□) se menciona que □(□) debe incluir la utilizaci? de las bodegas del sector □(□) □ (AZ 4, folio 33). ____ (AZ a, folio 19 a 38)

-

w. _____ Respuesta de la CRA a petici? presentada por la ciudadana Claudia Patricia Barrantes Venegas, relacionada con la Promesa de Sociedad Futura conformada por Ciudad Limpia y otros. En ese documento, se indica que el an?isis tarifario efectuado por la CRA se plantea sobre la viabilidad financiera del contrato. Por lo mismo, esta entidad hace un modelo financiero con base en la informaci? remitida por la entidad distrital (AZ 4, folio 48 y 49). Por lo dem?, se enfatiza que no es competencia de la Comisi? aprobar o autorizar las tarifas sino ser consultiva del modelo existente. Tambi? se menciona que el aprovechamiento y reciclaje pueden estar sometidos a la libre competencia, conforme establece el art?ulo 9 de la Ley 632 de 2000. Por lo tanto, sobre estas actividades no se extiende la exclusividad que rige sobre las ASEs (AZ 4, folio 52). Finalmente, y aunado a lo anterior, se expone que los costos de estas actividades no se encuentran en el modelo financiero remitido por la entidad distrital (AZ 4, folio 45 a 53).

-

x. _____ Oficio de la Contralor? General de la Rep?lica, n?ero 2011EE91156? radicado en la Corte Constitucional el treinta (30) de noviembre de dos mil once (2011), mediante el cual se da respuesta a los interrogantes elevados en el Auto 240 de 2011 de esta Corporaci?, por el cual se solicit? establecer si con cargo a los remanentes de la bolsa general del esquema de aseo se han impulsado medidas de discriminaci? positiva para la protecci? de los derechos que le asisten a los recicladores y o para incidir en el aprovechamiento y tratamiento de residuos s?idos. Asimismo, se solicit?la verificaci? y la elaboraci? de un concepto con fundamento en los documentos del proceso de selecci? materia de este estudio, que estableciera si las ofertas presentadas eran o no viables financieramente, dado que en algunos casos las utilidades proyectadas a ceder a las asociaciones de segundo nivel, superan el 50% de las ganancias (AZ 2, folio 469 a 481).

[1] A pesar de que la solicitante envi?tres escritos diferentes a esta Corporaci? para sustentar las razones de hecho y de derecho que, a su juicio, muestran el incumplimiento de las mentadas obligaciones por parte de la UAESP, a continuaci? se exponen en conjunto tales alegaciones, sin diferenciarlas de modo alguno, salvo por las referencias expresas a AZs o a Cuadernos.

[2] Esto tiene relaci?, pero no exclusivamente, con el aforo que reviste a ciertos generadores de residuos

s?idos.

[3] Al respecto, ver, por ejemplo, la intervenci? de la ARB y de LIME en el Anexo 1 de esta providencia.

[4] Cabe recordar, que en este momento los operadores actuales de las concesiones surgidas de la licitaci? de 2002 manejan rutas especiales de recolecci? y que tales materiales potencialmente aprovechables son transportados por ellos al Centro de Acopio la Alquer?. De manera paralela a tal actividad, trabajan los recicladores de oficio, en rutas informales y que operan bajo las din?icas que emanan de la libre competencia, recogiendo los residuos s?idos en las calles bogotanas.

[5] Como se explicar?a continuaci?, dicho fondo □ conforme a los medios probatorios obrantes en el tr? ite □ se financiar? con dineros del Distrito, a partir del c?culo de los residuos s?idos que dejen de llegar al Relleno Sanitario Do? Juana, en raz? a la recolecci? para el aprovechamiento de los mismos. _

[6] En autos como el A-114 del 2005, la Corte Constitucional ha se?lado que el solicitar pruebas para verificar el cumplimiento es m? que una potestad, es un deber espec?ico del juez.

[7] Ver al respecto el auto A-141B del 2004.

[8] Ver al respecto las sentencias de la Corte Constitucional SU-1185 del 2001 y SU-1158 del 2003.

[9] Auto A-141B del 2004.

[10] Como en el caso de la verificaci? de cumplimiento de la Sentencia T-025 del 2004.

[11] A-178-08.

[12] SU-1158-03.

[13] Elementos estos se?lados en el Auto 180 de 2011, mediante el cual se decidi? avocar el conocimiento de esta causa.

[14] Auto 147 de 2011 y Auto 167 de 2011.

[15] Autos 214 de 2003 y 010 de 2004.

[16] Sentencia SU-713 de 2006, por la cual se ventila una acci? de tutela propuesta por la firma Inverapuestas S.A. contra la Loter? de Bol?ar respecto del proceso de licitaci? p?lica para la adjudicaci? de la concesi? de explotaci? del juego de apuestas permanentes □ chance □.

[17] Ver auto A-166/05 en el cual se analiz? el incumplimiento de la sentencia T-677/04.

[18] El mentado art?ulo dispone: □ La constituci? es norma de normas. En todo caso de incompatibilidad entre la Constituci? y la ley u otra norma jur?ica, se aplicar? las disposiciones constitucionales □.

[19] Al respecto ver la sentencia SU-1158 de 2003.

[20] Sentencias T-395/01, T-510/02 y T-421/03

[21] El art?ulo 93 Superior contempla que: □ Los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos humanos y que proh?en su limitaci? en los estados de excepci?, prevalecen en el orden interno. Los derechos y deberes consagrados en esta Carta, se interpretar? de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia □.

[22] Corte Constitucional. Sentencia C-350/94.

[23] Ferrajoli, L. *Los fundamentos de los derechos fundamentales*, Madrid: Editorial Trotta, 2007, p. 363.

[24] Consejo de Estado, Secci? Tercera. A.P.13405 de 7 de julio de 2001.

[25] En efecto, la orden dada en la sentencia T-724 de 2003 fue la siguiente: □(□) **Tercero.-PREVENIR** en los t?minos del art?ulo 24 del Decreto 2591 de 1991, a la Unidad Ejecutiva de Servicios P?licos del Distrito Capital de Bogot?o a la entidad del Distrito que haga sus veces, para que en futuras ocasiones incluya acciones afirmativas a favor de los recicladores de Bogot? cuando se trate de la contrataci? de servicios p?licos de aseo, debido a que la actividad que ellos desarrollan est? ligada con dicho servicio, a fin de lograr condiciones reales de igualdad y de dar cumplimiento a los deberes sociales del Estado, y que por ning? motivo vuelva a reincidir en las omisiones en que incurri?en la Licitaci? No. 01 de 2002, respecto de los recicladores de Bogot? Por su parte, en el Auto 268 de 2010, en el que se analiz?el cumplimiento de tales ?denes en el caso de la licitaci? 001 de 2010 que ten? por objeto contratar un operador para el Relleno Sanitario Do? Juana, se dispuso □ entre otras cosas - lo siguiente: □(□) **CUARTO-. PREVENIR** a la UAESP que deber?incluir los criterios se?lados en el presente Auto en futuros contratos que desarrollen las ?denes conferidas en la sentencia T-724 de 2003□.

[26] En esta providencia, la Corte revis?un caso en el cual un vendedor ambulante demandaba a la Polic? Metropolitana de Bogot?□ Grupo de Espacio P?lico □ por las medidas adoptadas con el fin de recuperar el espacio p?lico. Entre los temas abordados, la Sala de Revisi? se pronunci?sobre el principio de igualdad y las pol?icas p?licas. Igualmente, abord?la relaci? existente entre la f?rmula del Estado Social de Derecho y el contenido m?ximo de tales pol?icas, as?como el deber estatal de preservar el espacio p?lico, pero bajo la obligaci? de garantizar los derechos fundamentales de las personas. _

[27] Art?ulo 2? C.P.

[28] El inciso primero del mencionado art?ulo establece: □Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibir? la misma protecci? y trato de las autoridades y gozar? de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminaci? por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religi?, opini? pol?ica o filos?ica□.

[29] Al respecto Fiss, Owen, □Grupos y Cl?sula de Igual Protecci?□, en Gargarella R. (Comp.), *Derecho y grupos desventajados*, Barcelona: Editorial Gedisa, Yale Law School y la Universidad de Palermo, 1999, pp 137-159.

[30] Como se indic?anteriormente, el inciso primero de tal art?ulo justifica la intervenci? del Estado en la econom? para racionalizarla, con □(□) el fin de conseguir el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes, la distribuci? equitativa de las oportunidades y los beneficios del desarrollo y la preservaci? de un ambiente sano□. As?mismo, el inciso tercero establece que □(□) El Estado, de manera especial, intervendr?para dar pleno empleo a los recursos humanos y asegurar que todas las personas, en particular los de menos ingresos, tengan acceso efectivo a los bienes y servicios b?icos□.

[31] El inciso primero de este art?ulo contempla que □El bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de la poblaci? son finalidades sociales del Estado. Ser?objetivo fundamental de su actividad la soluci? de las necesidades insatisfechas de salud, de educaci?, de saneamiento ambiental y de agua potable (□)□.

[32] En esta providencia se estudi?un caso en el cual un grupo de recicladores demandaban a varias entidades p?licas de Cali por el cierre del Botadero Navarro, as?como por el incumplimiento de acuerdos adoptados con el fin de evitar graves perjuicios al desplazarlos de la actividad econ?mica concreta que adelantaban para sobrevivir.

[33] En esta sentencia, esencial para el asunto bajo estudio, la Corte se pronunci?sobre la acci? de tutela instaurada por varios recicladores de Bogot?contra la entidad encargada de contratar operadores para el servicio p?lico de aseo en el Distrito Capital. En ese caso, los demandantes alegaban la violaci? de su derecho a la igualdad en raz? a la ausencia de adopci? de medidas afirmativas a su favor, dado que se trataba de sujetos de especial protecci? constitucional, y a la exclusi? que el modelo de la licitaci? adelantada implicaba para ellos frente a la actividad econ?mica que por a?s hab?n llevado a cabo. Se debe precisar que la Corte declar? en primer lugar, la carencia actual de objeto, dado que al momento de pronunciarse de fondo sobre el asunto, la licitaci? ya hab? sido adjudicada. Sin embargo, en segundo lugar, y con miras a evitar situaciones similares en el futuro, dispuso que la entidad responsable de adelantar tales contrataciones, que para esta coyuntura se trata de la UAESP, deb? adoptar en todo contrato que versara sobre el servicio p?lico de aseo acciones afirmativas a favor de la poblaci? de recicladores del distrito.

[34] Ver, en este sentido, la sentencia C-671 de 2002 (M.P. Eduardo Montealegre Lynett).

[35] As? por ejemplo, en la sentencia C-225 de 1998. MP. Eduardo Cifuentes Mu?z, se expres? □En efecto, en estos eventos, como en los que se refieren a la protecci? del m?ximo vital de la poblaci? m? pobre y marginada, le corresponde a las autoridades p?licas demostrar los hechos que conduzcan a la exoneraci? de su responsabilidad constitucional□.

[36] Ver entre otras, las sentencias C-275 de 1999, MP: Alfredo Beltr? Sierra; C-371 de 2000, MP. Carlos Gaviria D?z; T-500

de 2002, MP: Eduardo Montealegre Lynett; C-401 y C-964 de 2003, MP: ?varo Tafur Galvis, C-667 de 2006, MP: Jaime Araujo Renter?; C-075 de 2007, MP: Rodrigo Escobar Gil.

[37] *En relaci? con lo anterior, es importante reiterar que la presunci? de discriminaci? y el juicio estricto de igualdad, se predica no s?o de diferenciaciones basadas expl?itamente en un criterio sospechoso o potencialmente prohibido, sino que tambi? se deriva de normas o actuaciones que pueden generar un impacto adverso y desproporcionado frente a un grupo marginado y discriminado. La precisi? es importante, pues este impacto es el resultado de la aplicaci? de normas en principio neutras, que podr?n llevar al juez a pensar que la intensidad que corresponde al juicio de igualdad debe ser leve. Por eso debe resaltar la Corte, que cuando se presenta un cargo de igualdad que se funda en los efectos adversos y desproporcionados que se generan para un grupo marginado o discriminado, por la aplicaci? de un norma aparentemente neutra, es a la autoridad acusada, a quien le corresponde entrar a demostrar, o bien que no existe el alegado impacto adverso y desproporcionado, o que a pesar de que se presenta, de todas formas la medida cumple con una finalidad imperiosa que no puede ser alcanzada por medios menos onerosos en t?minos de la afectaci? de determinado grupo poblacional.*

[38] *Sobre la inclusi? de otros par?etros, adem? de los jur?icos para analizar las cuestiones ambientales debido a su complejidad, ver la sentencia C-339 de 2002.*

[39] *Al respecto, en especial en relaci? con el ahorro de energ? que se presenta gracias al aprovechamiento, puede consultarse a: Lovelock, J., La venganza de la tierra: por qu? la tierra est? rebel?dose y c?o podemos todav? salvar a la humanidad?, Barcelona: Editorial Planeta, 2007.*

[40] *Es importante se?alar que la Constituci? - en el art?ulo 80 - utiliza el t?mino ambiente y no medio ambiente, lo que concuerda con una posici? ?ica consagrada a partir de la Carta de 1991, donde se asume que el ser humano es dependiente de lo que lo rodea, a la vez que hace parte de la naturaleza. En otras palabras, se trata de un cuestionamiento respecto a la tradicional dicotom? entre hombre y naturaleza que lo contempla como superior o dominador. Al respecto, puede consultarse la sentencia C-339 de 2002, al igual que los siguientes textos: Mesa Cuadros Gregorio, □Deuda ambiental y clim?ica: amigos o depredadores-contaminadores del ambiente□ en Revista Pensamiento Jur?ico, No. 25, Bogot? Universidad Nacional de Colombia, Facultad de Derecho, Ciencia Pol?icas y Sociales, Instituto Unidad de Investigaciones Jur?ico-Sociales Gerardo Molina (UNIJUS), 2009, pp. 77-90; y Henao P?ez, Juan Carlos, □Perspectiva Constitucional del derecho al ambiente sano en el ordenamiento jur?ico colombiano□, en Revista de la Corte Constitucional, No. 1, Bogot? Corte Constitucional, 2010. Con todo, como quiera que la jurisprudencia, al igual que las normas que a continuaci? se enuncian no hacen tal distinc?, en esta providencia se utilizar?indistintamente los t?minos medio ambiente y ambiente.*

[41] *Art?ulo 67*

[42] *Al respecto, puede consultarse a Rodr?uez, C., □En busca de alternativas econ?icas en tiempos de globalizaci?: el caso de las cooperativas de recicladores de basuras en Colombia□, en De Sousa Santos, B., Producir para Vivir, Los caminos de la producci? no capitalista, M?ico: Fondo de Cultura Econ?ico, 2011, pp. 255-285.*

[43] *Gim?ez Gl?k, D., Juicio de Igualdad u Tribunal Constitucional, Editorial Bosh, Barcelona, 2004, pp. 316 y 317.*

[44] *Young, Iris. 1996. Vida pol?ica y diferencia de grupo: una cr?ica del ideal de ciudadan? universal. En: Castells Carmen (compiladora) Perspectivas feministas en teor? pol?ica. Paidos, Buenos Aires.*

[45] *Como se observa, el t?mino de acciones afirmativas, a la luz de la jurisprudencia constitucional comprende diferentes medidas, como las de concientizaci?, incentivo o discriminaciones positivas.*

[46] *Al respecto puede consultarse a Durango ?varez, G. A., Incorporaci?, Inclusi? y Desarrollo de las acciones Positivas en la Jurisprudencia de la Corte Constitucional Colombiana, Medell?: Biblioteca Jur?ica Dike y Universidad Nacional de Colombia, Facultad de Ciencias Humanas y Econ?icas, 2011, pp. 25-26.*

[47] *Al respecto: Medina Mart?, □Reciclaje de desechos s?idos en Am?ica Latina□, en Frontera Norte, Vol 11, n?, 21, 1999, visible en http://aplicaciones.colef.mx:8080/fronteranorte/articulos/FN21/1-f21_Reciclaje_desechos_solidos_en_America_Latina.pdf (12 de Julio de 2010); y Medina Mart?, □Cooperativas de Recicladores Informales en Am?ica Latina□, visible en <http://www.bvsde.paho.org/bvsaidis/mexico2005/medina2.pdf> (12 de julio de 2010).*

[48] Al respecto, pueden consultarse las sentencias T-291 de 2009 y T-411 de 2009. En ambas providencias, la Corte se pronunció sobre la situación de marginalidad y discriminación que padecen los recicladores de Cali, en especial aquellos que trabajaban en el botadero de Navarro.

[49] Según el artículo 11 del Decreto 1713 de 2002, son (□) componentes del servicio público de aseo, los siguientes: 1. Recolección, 2. Transporte, 3. Barrido y limpieza de vías y áreas públicas, corte de césped y poda de árboles ubicados en las vías y áreas públicas, lavado de estas áreas, 4. Transferencia, 5. Tratamiento, 6. Aprovechamiento [y] 7. Disposición final□.

[50] Al respecto ver: LÓPEZ CUÉLLAR, N. y OLARTE OLARTE, M. C., □Incumplimiento de las sentencias de la Corte Constitucional colombiana: Aparentes Garantías, silenciosos Incumplimientos□ en Universitas. Bogotá(Colombia) N° 113: 71-112, enero-junio de 2007.

[51] Artículo 6° de la Ley 454 de 1998.

[52] Al respecto, puede consultarse a: Tafur Galvis, A. Las personas jurídicas privadas sin ánimo de lucro y el Estado, Bogotá Editorial Temis, 1990, p. 8.

[53] Cifra que se obtiene si se divide el número de habitantes de Bogotá que según el DANE es de 7.363.782 personas a 2005, en el número de centros de acopio regulados por el referido decreto. Al respecto ver: DANE, □Boletín Censo General 2005□.

[54] Tom L. Beauchamp_(1998). In Defense of Affirmative Action. Journal of Ethics 2 (2):143-158.

[55] En el caso Grutter v. Bollinger la Corte estudió el asunto de Barbara Grutter quien aplicó en 1996 para estudiar en la Facultad de Derecho de la Universidad de Michigan. Aunque Grutter cumplió con los requisitos que exigía la Universidad para su admisión, fue rechazada en virtud de que su puesto fue ocupado por otro estudiante que fue objeto de una acción afirmativa. En este caso, la Corte fue clara en señalar que las medidas de discriminación positiva funcionan apropiadamente cuando se encuentran estrechamente confeccionadas□ y se pueden aplicar con independencia de otros criterios que puedan obstruir la satisfacción del objetivo de equidad que yace en la política. La Corte Suprema decidió que no había discriminación pues, en la medida en que la política estaba cuidadosamente trazada, el resultado de la misma era el cumplimiento de los fines planteados. En el mismo sentido se pronunció en el caso de Wygant v. Jackson Board of Education, al rechazar una acción afirmativa por no responder al criterio de estar □estrechamente confeccionada□.

[56] Lo anterior fue mencionado, por ejemplo, por FUNCOLGRAN (numeral 4.3, anexo 1), FESNOPMA (numeral 4.11, anexo 1) y en el escrito de amicus curiae de Adriana Ruiz Restrepo (numeral 5, anexo 1).

[57] AZ 5, folios 59 a 60.

[58] Tal escrito se encuentra en el AZ 5, folios 27 a 55.

[59] AZ 5, folios 308 a 319.

[60] A pesar de que este interviniente mencionó al Consejo de Estado, lo cierto es que las providencias a las que aludió fueron todas proferidas por la Corte Constitucional.

[61] AZ 5, folios 290 a 299.

[62] Lo anterior es explicado por el referido ciudadano de la siguiente manera: (□) En relación con el oficio a través del cual fuimos notificados el pasado 12 de Agosto (□) es de mencionar que el mismo iba dirigido a la Unión Temporal Gestión Ambiental, y no al proponente plural conformado por mis representadas (□). Al parecer la Corporación tuvo en cuenta que la Unión Temporal Gestión Ambiental participó en la Licitación Pública 001 de 2010 para contratar la operación del Relleno Sanitario Doña Juana. No obstante, dado que mis representadas conforman un proponente plural (□) proceder a indicar las

razones por las cuales considero que en [esta] licitaci? se cumplen las obligaciones de incluir acciones afirmativas (□)□ (AZ 2, folio 255).

[63] AZ 5, folio 165 a 183.

[64] AZ 5, folio 184 a 192.

[65] AZ 5, folio 236 a 240.

[66] AZ 5, folio 193 a 216.

[67] AZ 5, folios 255 a 266.

[68] AZ 5, folios 267 a 275

[69] AZ 5, folio 155 a 164.

[70] AZ 5, folio 241 a 254.

[71] A continuaci? se efect? una descripci? general de los elementos concernientes a los recicladores y al aprovechamiento que constan en el acta referida. Vale la pena mencionar que se se?lan □ indistintamente al ASE correspondiente □ los m?imos y los m?imos ofertados.